

DIRITTO AMMINISTRATIVO E LE ALTRE BRANCHE DEL DIRITTO	7
Diritto costituzionale	7
Diritto europeo.....	7
Diritto privato	7
I CARATTERI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO	8
La natura giurisprudenziale del Diritto Amministrativo	8
Diritto amministrativo generale e diritto amministrativo speciale	8
LA FUNZIONE DI REGOLAZIONE E LE FONTI DEL DIRITTO	9
La costituzione.....	10
Fonti dell'Unione Europea	10
Fonti primarie	10
Fonti derivate	11
Recepimento del diritto dell'Unione	11
Fonti normative statali, riserva di legge e principio di legalità	11
Le fonti normative statali	11
Le riserve di legge	12
Il principio di legalità	12
Le leggi-provvedimento	13
I regolamenti governativi	13
I testi unici e i codici	15
Cenni alle fonti normative regionali, degli enti locali e di altri enti pubblici	15
Gli atti di regolazione aventi natura non normativa	16
Gli atti amministrativi generali	16
Regime giuridico	17
Le ordinanze contingibili e urgenti	18
Le direttive e gli atti di indirizzo	18
Direttive a valenza regolatoria	19
Le norme interne e le circolari	19
La prassi amministrativa	20
Le circolari	20
La soft law, le raccomandazioni e le linee guida	20
La better regulation e altri modelli di regolazione	21

IL RAPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO	21
Le funzioni e l'attività amministrativa	21
Il potere, il provvedimento, il procedimento	22
Il potere amministrativo	23
L'atto e il provvedimento amministrativo	23
Il procedimento amministrativo	23
Il rapporto giuridico amministrativo	24
Il modello privatistico: diritto soggettivo e obbligo	24
Situazioni affini: potestà e diritto potestativo	24
Il potere amministrativo come diritto potestativo pubblico	25
Specificità del potere amministrativo	25
Struttura del rapporto giuridico amministrativo	25
La norma attributiva del potere	25
Il potere discrezionale.....	27
Ambiti della discrezionalità	27
Vincolatezza in astratto e in concreto	27
Autovincolo	27
Il merito amministrativo	28
Valutazioni tecniche.....	28
Meri accertamenti tecnici	28
L'interesse legittimo	28
La svolta della risarcibilità	29
Definizione e struttura	29
Evoluzione Dottrinale	29
La Concezione Moderna: Sostanzialità e Partecipazione	30
Gli interessi legittimi oppositivi e pretensivi.....	31
Natura e Dinamica Procedimentale	31
La Tutela Giurisdizionale: Conservazione vs. Acquisizione	31
I criteri di distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi	32
Natura della Norma Attributiva: Relazione vs Azione	32
Distinzione tra Potere Vincolato e Discrezionale	32
Natura del Vizio: Cattivo Esercizio vs Carenza di Potere	33

Focus: I Diritti "Indegradabili"	33
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi	33
Il problema della qualificazione giuridica	34
Interessi di fatto, diffusi e collettivi.....	35
Interessi Diffusi e Interessi Collettivi.....	35
Interessi Individuali Omogenei (Class Action)	35
Nuovi rimedi: L'efficienza della P.A.	36
Il Ricorso per l'Efficienza della P.A. (D.Lgs. 198/2009)	36
I principi generali	37
IL PROVVEDIMENTO	38
L'esecutorietà e l'efficacia.....	39
Il Principio di Legalità e la Diffida	40
Imperatività.....	40
Inoppugnabilità.....	41
L'Acquiescenza: L'inoppugnabilità per comportamento del privato	41
L'asimmetria del rapporto: Il potere di autotutela	41
Gli Elementi Strutturali del Provvedimento Amministrativo	42
L'Obbligo di Motivazione (Art. 3 l. 241/1990)	42
Provvedimenti limitativi	43
Sanzioni Punitive vs Ripristinatorie	44
Responsabilità degli Enti (D.Lgs. 231/2001)	44
La Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA)	44
Le autorizzazioni e le concessioni.....	45
Rilevanza Processuale: L'Azione di Adempimento	46
Gli atti amministrativi dichiarativi	46
La struttura soggettiva: atti complessi e collegiali	48
La classificazione per destinatari: atti generali, collettivi e plurimi	48
Il confine tra politica e amministrazione: atti politici e di alta amministrazione	48
L'INVALIDITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	48
Il regime dell'invalidità: Nullità vs Annullabilità	49
Estensione e propagazione del vizio	49
Il fattore tempo: Invalidità originaria e sopravvenuta	49

La tripartizione dei vizi di legittimità	49
L'annullabilità.....	49
Vizi formali vs Vizi sostanziali.....	50
La dequotazione dei vizi formali (Art. 21-octies, comma 2)	50
Il profilo processuale	50
I Vizi di Legittimità: Incompetenza e Violazione di Legge	51
La Dequotazione dei Vizi Formali (Art. 21-octies, comma 2)	51
L'eccesso di potere	52
La violazione di norme interne, circolari e prassi	54
L'ingiustizia grave e manifesta	54
Nullità	54
Il regime processuale: tra stabilità e accertamento	55
L'Annullamento d'Ufficio (Art. 21-nonies)	55
La Conservazione dell'Atto: Convalida, Ratifica e Sanatoria	56
Conferma e Conversione	56
La Revoca (Art. 21-quinquies)	56
Il Recesso (Art. 21-sexies)	56
IL PROCEDIMENTO DELL' ATTO AMMINISTRATIVO	58
Le leggi generali sul procedimento e la l. n. 241/1990	58
Anatomia della fase decisionale: termini, responsabilità e regimi del silenzio significativo	60
La complessità e i subprocedimenti	61
La conferenza di servizi e altre forme di coordinamento	63
Tipo di procedimento.....	65
L'espropriazione per pubblica utilità	65
Le sanzioni pecuniarie e disciplinari	67
Le autorizzazioni. Il permesso a costruire e la valutazione di impatto ambientale	68
I procedimenti concorsuali	69
L'accesso ai documenti amministrativi	70
I CONTROLLI	71
I controlli sugli atti e sull'attività	72
I controlli gestionali.....	73

LA RESPONSABILITÀ	74
L'art. 28 della Costituzione e gli sviluppi successivi	74
La responsabilità civile da comportamento illecito	75
La risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi	76
La responsabilità amministrativa	77
PROFILI ORGANIZZATIVI	78
Persone giuridiche, organi uffici	79
Le amministrazioni pubbliche	81
Lo Stato	82
Gli enti territoriali: i comuni, le province, le regioni	83
Gli enti pubblici	85
Le autorità indipendenti	86
Le società a partecipazione pubblica	88
Le relazioni interorganiche e intersoggettive	91
Il disegno organizzativo degli enti pubblici e lo spazio regolatorio	92
SERVIZI PUBBLICI	93
I servizi di interesse generale nel diritto europeo	94
La regolazione e le forme di gestione dei servizi pubblici	95
Le autorità di regolazione	96
I servizi pubblici locali	98
Il servizio sanitario nazionale, il servizio scolastico, i servizi sociali	98
IL PERSONALE	100
Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro	101
La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro	103
La dirigenza pubblica	104
I BENI	106
I beni di interesse privato e i beni di interesse pubblico	107
I beni patrimoniali indisponibili e i beni demaniali	109
I beni comuni e le prospettive di riforma	110
CONTRATTI	110
L'influenza del diritto europeo	111

I capitolati	111
Le fonti esterne al Codice dei contratti pubblici.....	111
L'ANAC e l'organizzazione del sistema	112
I principi generali e il campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici ...	112
L'ambito soggettivo	113
L'ambito oggettivo	113
Gli ulteriori criteri di differenziazione della disciplina	113
L'oggetto del contratto	114
Appalto e concessione	114
La finanza di progetto e il partenariato pubblico-privato	114
Il contraente generale	114
Le procedure di affidamento.....	115
L'esecuzione del contratto	117
I mezzi di tutela	118
LA FINANZA	119
I principi costituzionali.....	120
Il Documento di economia e finanza, la legge di bilancio	121
La gestione delle risorse e il procedimento di spesa	123

DIRITTO AMMINISTRATIVO E LE ALTRE BRANCHE DEL DIRITTO

Diritto costituzionale

Il diritto costituzionale e il diritto amministrativo riguardano rami diversi:

- **DIRITTO COSTITUZIONALE:** riguarda i rami “alti” dell’ordinamento
 - Diritto privati
 - Le fonti del diritto
- **DIRITTO AMMINISTRATIVO:** riguarda i rami “bassi” dell’ordinamento, ovvero il complesso di apparati pubblici.

Vi sono due legami da analizzare riguardanti i rapporti tra queste branche del diritto: in primo luogo, il diritto amministrativo è il diritto costituzionale, reso concreto e in secondo luogo il diritto costituzionale passa, il diritto amministrativo resta. Diritto amministrativo, infatti, non è altro che il diritto costituzionale reso concreto, ovvero preso nella sua effettiva realizzazione nella legislazione nella vita dell’ordinamento. Ma è anche riassunto dell’affermazione secondo la quale il diritto istituzionale passa e il diritto amministrativo resta, in cui si vuole sottolineare la diversa velocità dei mutamenti costituzionali rispetto alle riforme amministrative. Questo avviene in quanto i diritti costituzionali incidono sui rami alti dell’ordinamento, al contrario le riforme amministrative mirano a modificare l’organizzazione e il modo di operare di apparati burocratici.

Diritto europeo

A livello europeo, il diritto amministrativo italiano acquisisce una dimensione europea sotto cinque profili principali:

1. L’articolo 117, comma uno della costituzione stabilisce che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni attraverso la legislazione amministrativa deve essere esercitata **nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario**.
2. L’articolo uno, comma uno, della legge numero 241 del 1990 include tra i principi generali dell’attività amministrativa, anche i **principi generali dell’ordinamento comunitario**.
3. **Il diritto europeo condiziona l’assetto organizzativo e funzionale degli apparati pubblici.** Infatti molte agenzie autorità indipendenti sono state istituite in Italia con leggi di attuazione di direttive europee, esempio sistema europeo delle banche centrali, nel quale fanno parte anche le banche centrali nazionali.
4. **Il diritto europeo impone agli Stati membri vincoli sempre più pressanti alla finanza pubblica che condizionano l’operatività delle pubbliche amministrazioni** e l’attuazione dei loro programmi di intervento.
5. Il diritto europeo esercita un’influenza anche sul **diritto processuale e amministrativo**, il codice del processo amministrativo, adottato col decreto legislativo 104 del 2010, stabilisce che la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva se i principi della costituzione del diritto europeo.

Diritto privato

Il diritto amministrativo è una disciplina autonoma rispetto al diritto privato. Un esempio di questo rapporto si trova **nella legge n. 241 del 1990**, che prevede la **possibilità per la pubblica amministrazione di stipulare accordi con i privati per definire il contenuto di un provvedimento amministrativo**. Questi accordi restano di natura pubblicistica, ma per alcuni aspetti si applicano anche le regole del codice civile sui contratti e sulle obbligazioni, purché siano compatibili. Per questo motivo, diritto amministrativo e diritto privato non stanno in un rapporto di regola ed eccezione: non è

che uno vale sempre e l'altro solo in casi particolari. Sono due sistemi giuridici autonomi, ognuno con le proprie regole. La pubblica amministrazione, al pari delle persone giuridiche private, godono di una capacità giuridica generale ovvero l'attitudine ad assumere la titolarità di diritti e obblighi in conformità alle norme del codice civile e delle leggi speciali. **L'articolo 1 della legge 241 del 1990** enuncia il principio secondo il quale la pubblica amministrazione agisce secondo le norme del diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente, nell'adozione di atti di natura non autoritaria. Le pubbliche amministrazioni sono titolari di una capacità giuridica generale di diritto privato. Tuttavia, tale capacità incontra un limite nel fatto che deve essere esercitata per il **perseguimento delle finalità di interesse pubblico** affidate alla loro cura. Alla capacità di diritto privato si affianca una **capacità speciale di diritto pubblico**, che deriva dall'attribuzione legislativa di poteri amministrativi necessari alla tutela degli interessi pubblici. In diversi settori si assiste quindi alla **compresenza di regole pubblicistiche e privatistiche**. Un esempio è rappresentato dai contratti della pubblica amministrazione per la fornitura di beni, servizi e lavori, **disciplinati dal Codice dei contratti pubblici**. Analoga situazione si riscontra nel pubblico impiego privatizzato: a seguito del **d.lgs. 165/2001**, il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è regolato prevalentemente dal diritto comune, pur restando inserito nell'organizzazione pubblica. In più il diritto amministrativo ha una capacità espansiva in cui, a certe condizioni, si applica anche **nei confronti di soggetti privati**: es. per i soggetti privati che in base ai criteri posti dalla normativa EU e nazionale sono qualificati come **organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche**, i quali sono tenuti ad avviare procedimenti competitivi a evidenza pubblica per la scelta dell'impresa fornitrice e i loro dati sono **impugnabili innanzi al giudice amministrativo**.

I CARATTERI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

La natura giurisprudenziale del Diritto Amministrativo

La nascita del diritto amministrativo in Francia e in Italia è legata **all'istituzione di un giudice speciale per le controversie tra cittadino e pubblica amministrazione**, infatti il diritto amministrativo viene considerato un diritto di **provenienza giurisprudenziale** poiché nato dalle sentenze dei primi giudici speciali operanti nel settore, assomigliando, così, al sistema di *common law*. In Italia la **legge 2248/1865 allegato E** abolì il **contenzioso amministrativo**, ritenuto **non compatibile con la visione di stato liberale**, e attribuì al giudice ordinario tutte le controversie tra privati e pubblica amministrazione relative alla tutela di diritti soggettivi. **Nel 1889 venne operata una correzione di tale sistema**, istituendo un **giudice amministrativo** il cui nucleo originario fu costituito dalla **IV Sezione del Consiglio di Stato**, che stilò i principi generali dell'atto amministrativo nonché la prima forma di riparto delle competenze tra i giudici ordinari e quelli amministrativi a seguito di un "concordato giurisprudenziale" con la Corte di Cassazione. Per risolvere contrasti interpretativi nella giurisprudenza amministrativa interviene l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**. Si tratta di un **collegio allargato**, composto da giudici provenienti da tutte le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (II, III, IV, V e VI). L'Adunanza Plenaria svolge una **funzione nomofilattica**, cioè garantisce l'interpretazione uniforme del diritto. Se una sezione del Consiglio di Stato ritiene di dover adottare un'interpretazione diversa da quella già espressa dall'Adunanza Plenaria, **non può decidere autonomamente** la controversia, ma deve **rimettere la questione all'Adunanza Plenaria**. Una volta che quest'ultima si pronuncia, la sezione deve conformarsi al suo orientamento. Il tutto è previsto dall'art. 99 del Codice del processo amministrativo.

Diritto amministrativo generale e diritto amministrativo speciale

Il diritto amministrativo si caratterizza per la **vastità e frammentarietà delle fonti normative**, poiché disciplina numerosi ambiti dell'attività della pubblica amministrazione. Per questo motivo la dottrina distingue tra **diritto amministrativo generale** e **diritto amministrativo speciale**. Il **diritto amministrativo speciale** comprende l'insieme delle norme che regolano **specifici settori di intervento della pubblica amministrazione**. Si tratta di discipline settoriali, contenute in leggi statali,

regionali o dell'Unione europea, che riguardano ambiti come la **sanità, la tutela dell'ambiente, i beni culturali, l'ordine pubblico, la difesa, lo sport**, e altri settori dell'azione amministrativa. Queste norme regolano nel dettaglio l'organizzazione e l'attività amministrativa in ciascun ambito. Il **diritto amministrativo generale**, invece, raccoglie **principi e istituti comuni** che si applicano trasversalmente a tutta l'attività della pubblica amministrazione, indipendentemente dal settore considerato. Esso costituisce il **nucleo fondamentale della materia**, poiché definisce le regole generali dell'azione amministrativa, come i principi di **legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza**, nonché gli istituti fondamentali dell'attività amministrativa. Una parte significativa di questi principi è stata **codificata nella legge n. 241 del 1990**, che disciplina il **procedimento amministrativo** e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. La distinzione tra diritto amministrativo generale e speciale consente quindi di **ordinare una materia estremamente ampia**, individuando da un lato le **regole comuni dell'azione amministrativa**, e dall'altro le **discipline settoriali** che regolano i singoli ambiti di intervento della pubblica amministrazione.

LA FUNZIONE DI REGOLAZIONE E LE FONTI DEL DIRITTO

Negli ultimi decenni la **funzione regolatrice della pubblica amministrazione** (p.a.) è diventata sempre più **importante**. Questo fenomeno è **collegato alla crisi della legge** come strumento principale di regolazione dei rapporti giuridici. Il Parlamento, infatti, fatica sempre più a produrre leggi complete e aggiornate e ad adattare rapidamente ai cambiamenti economici e sociali. Per questo motivo la legge spesso si limita, oggi, a **stabilire i principi fondamentali di una disciplina**, lasciando alla pubblica amministrazione il **compito di definire le regole di dettaglio**. Queste regole vengono adottate attraverso diversi strumenti sub-legislativi, tra cui:

- Regolamenti,
- Atti di pianificazione e programmazione,
- Atti amministrativi generali,
- Direttive,
- Circolari,
- Linee guida.

In questo modo la pubblica amministrazione **svolge una vera e propria funzione regolatrice**, cioè utilizza strumenti formali e informali per orientare o condizionare il comportamento dei privati. Questo fenomeno **comporta anche un parziale attenuarsi del principio classico di separazione dei poteri**, poiché l'amministrazione non si limita ad applicare la legge, ma contribuisce anche a specificarne e completarne la disciplina. Le pubbliche amministrazioni assumono quindi una duplice posizione: da un lato **sono soggetti regolati**, perché devono rispettare le norme che disciplinano la loro organizzazione e attività; dall'altro sono **soggetti regolatori**, perché producono atti che incidono sui comportamenti dei privati. Da questa situazione emerge una distinzione fondamentale:

1. **Fonti sull'amministrazione:** Sono le norme che disciplinano l'**organizzazione**, le **funzioni** e i **poteri** delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni sono quindi destinatarie di queste norme e risultano soggetti etero-regolati, cioè regolati da fonti esterne. Queste fonti costituiscono anche il parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti amministrativi. In base al **principio della riserva di legge relativa** (art. 97 Cost.), tali fonti sono costituite innanzitutto da fonti normative primarie e secondarie, come ad esempio i regolamenti governativi.
2. **Fonti dell'amministrazione:** Sono invece gli atti attraverso cui la pubblica amministrazione esercita la propria funzione regolatrice. Attraverso queste fonti la p.a. può:
 - disciplinare il comportamento dei privati, nei limiti stabiliti dalla legge;
 - organizzare il funzionamento dei propri apparati, quando la legge le riconosce autonomia organizzativa.

La costituzione

Essa costituisce la fonte giuridica di livello più elevato, infatti è il parametro in base al quale la Corte costituzionale esercita il proprio sindacato sulle leggi e sugli atti avanti forza di legge. La Costituzione **non disciplina in modo approfondito l'assetto organizzativo della pubblica amministrazione**, ma si limita ad **enunciare i principi fondamentali** che ne devono informare l'attività e la struttura. In primo luogo, **l'art. 97 Cost.** stabilisce i principi di **imparzialità** e **buon andamento**, quali criteri direttivi dell'organizzazione e dell'azione amministrativa. A tali principi si è affiancato, a seguito della **legge costituzionale n. 1 del 2012**, il principio dell'**equilibrio di bilancio**, che vincola l'attività amministrativa sotto il profilo finanziario. Con riguardo ai rapporti tra politica e amministrazione, **l'art. 95 Cost.** afferma il principio della **strumentalità dell'amministrazione rispetto all'indirizzo politico del Governo**, nonché il principio della **responsabilità politica dei ministri** per gli atti compiuti nell'ambito del proprio dicastero. Ne deriva che l'attività amministrativa si inserisce nell'ambito dell'indirizzo politico governativo, pur nel rispetto dei limiti e delle garanzie previste dall'ordinamento. In materia di **giustizia amministrativa**:

1. Gli **artt. 103, 113 e 125 Cost.** delineano l'assetto essenziale del sistema di tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.
2. **L'art. 103** attribuisce al **giudice amministrativo** la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi e, nei casi stabiliti dalla legge, dei diritti soggettivi;
3. **L'art. 113** garantisce la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione;
4. **L'art. 125** prevede l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado. Il principio di legalità, pur non essendo enunciato in una disposizione costituzionale espressa e generale, è presupposto dall'intero impianto costituzionale e implica che l'amministrazione possa esercitare i propri poteri solo nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge. Sotto il profilo organizzativo-territoriale,
5. **L'art. 5 Cost.** afferma il principio autonomistico, riconoscendo e promuovendo le autonomie locali nel quadro dell'unità e indivisibilità della Repubblica.
6. **L'art. 118 Cost.** introduce il principio di sussidiarietà quale criterio generale di riparto delle funzioni amministrative, attribuendole in via primaria ai livelli di governo più prossimi ai cittadini, salvo esigenze di esercizio unitario.
7. Infine, **l'art. 81 Cost.**, come modificato dalla legge costituzionale **n. 1 del 2012**, sancisce il principio del pareggio di bilancio, imponendo l'equilibrio tra entrate e spese dello Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Fonti dell'Unione Europea

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost., la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto, tra l'altro, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Ne consegue, sul piano della gerarchia delle fonti, la primazia del diritto dell'Unione rispetto alle fonti primarie interne. Il principio di primazia comporta che la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione debba essere disapplicata. Tale obbligo incombe non solo sul giudice nazionale, cui spetta individuare la disciplina applicabile al caso concreto, ma anche sulla pubblica amministrazione nell'esercizio del potere amministrativo, in sede di adozione del provvedimento. Le fonti del diritto dell'Unione si articolano in fonti primarie e fonti derivate.

Fonti primarie

Le fonti primarie sono costituite dai **Trattati istitutivi e dalle successive modifiche e integrazioni**, da ultimo operate con il Trattato di Amsterdam (1997), il Trattato di Nizza (2001) e il Trattato di Lisbona (2007), entrato in vigore nel 2009. Quest'ultimo si compone di due testi: il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I principi generali

contenuti nei Trattati, quali il principio di non discriminazione, di legalità e di proporzionalità, unitamente ai principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea quali principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, sono dotati di efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, ove ricorrano i presupposti di chiarezza, precisione e incondizionatezza. Rientrano nel sistema delle fonti rilevanti anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui il Trattato di Lisbona ha riconosciuto valore giuridicamente vincolante, nonché la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), che, pur non essendo formalmente fonte dell'Unione, rileva nell'ordinamento interno quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117 Cost.

Fonti derivate

Tra le fonti derivate, **l'art. 288 TFUE** annovera regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

- I **regolamenti** hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri. Non necessitano di recepimento e non possono essere derogati dal legislatore nazionale. Essi costituiscono parametro diretto di legittimità degli atti amministrativi e devono essere motivati.

- Le **direttive** sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, restando riservata agli organi nazionali la scelta della forma e dei mezzi (art. 288, comma 3, TFUE). Esse non sono, in linea generale, immediatamente applicabili, salvo il caso in cui presentino i requisiti per l'efficacia diretta e lo Stato sia inadempiente all'obbligo di recepimento. Anche le direttive devono essere motivate.

- Le **decisioni** sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da esse designati. Esse applicano disposizioni generali a situazioni specifiche e vincolano i soggetti individuati, potendo, in determinate ipotesi, essere dotate di efficacia diretta.

Recepimento del diritto dell'Unione

Il recepimento della normativa europea è disciplinato, nell'ordinamento italiano, dalla legge n. 11 del 2005 e, attualmente, dalla legge n. 234 del 2012. Lo strumento principale è costituito da due leggi annuali di iniziativa governativa:

- la **legge europea**, volta a modificare o abrogare disposizioni interne incompatibili con il diritto dell'Unione ovvero a chiudere procedure di infrazione;
- la **legge di delegazione europea**, con la quale il Parlamento conferisce al Governo delega legislativa per l'attuazione delle direttive e per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi europei.

Il sistema così delineato assicura l'integrazione del diritto dell'Unione nell'ordinamento interno, nel rispetto del principio di primazia e dell'obbligo di leale cooperazione tra Stato e Unione europea

Fonti normative statali, riserva di legge e principio di legalità

Le fonti normative statali

La Costituzione disciplina in modo organico le fonti statali di livello primario e subprimario. Tra le fonti primarie rientrano:

- la **legge ordinaria**, approvata da entrambe le Camere e promulgata dal Presidente della Repubblica (artt. 71–74 Cost.);

- il **decreto-legge**, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, con efficacia immediata ma soggetto a conversione in legge entro sessanta giorni (art. 77 Cost.);
- il **decreto legislativo**, emanato dal Governo sulla base di una legge di delegazione che ne definisce oggetto, principi e criteri direttivi, nonché il termine di esercizio della delega (art. 76 Cost.).

A seguito della riforma **del Titolo V del 2001**, la **potestà legislativa statale non ha più carattere generale**. Ai sensi dell'**art. 117 Cost.**, essa si esercita esclusivamente nelle materie indicate ai commi 2 e 3, rispettivamente in via esclusiva e concorrente, mentre la competenza residuale spetta alle Regioni. Le fonti *subprimarie* sono costituite, in particolare, dai regolamenti governativi e ministeriali, che si collocano in posizione subordinata rispetto alla legge e non possono derogarla.

Le riserve di legge

Le riserve di legge concorrono a delineare il rapporto tra Parlamento e potere esecutivo, limitando l'intervento delle fonti secondarie in determinate materie. La Costituzione, in numerose disposizioni, prevede che talune materie siano disciplinate "con legge", riservando al Parlamento la competenza normativa e circoscrivendo l'ambito di intervento del potere regolamentare. Si distinguono tre tipologie di riserva di legge:

1. **Riserva di legge assoluta:** Impone che la disciplina della materia sia integralmente contenuta nella legge, con esclusione dell'intervento di fonti sublegislative. Sono ammessi soltanto regolamenti di stretta esecuzione, privi di contenuti innovativi o discrezionali. È tipica, ad esempio, in materia penale.
2. **Riserva di legge rinforzata:** Oltre a richiedere l'intervento della legge, la Costituzione predetermina direttamente principi o limiti sostanziali o procedurali cui il legislatore ordinario deve attenersi. Essa opera soprattutto in materia di diritti di libertà, come nel caso dell'art. 18 Cost.
3. **Riserva di legge relativa:** Esige che la legge stabilisca i principi fondamentali della disciplina, consentendo alle fonti secondarie di integrare la normativa con disposizioni di dettaglio. È esemplificativa la materia tributaria.

Le riserve di legge, pertanto, operano quale tecnica di distribuzione delle competenze normative, rafforzando la centralità parlamentare in settori ritenuti costituzionalmente sensibili.

Il principio di legalità

Il principio di legalità costituisce un principio fondamentale dell'attività amministrativa. Esso trova un espresso richiamo **nell'art. 1 della legge n. 241 del 1990**, secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, ed è ricavabile, in via sistematica, da diverse disposizioni costituzionali, tra cui l'**art. 113 Cost.**, che presuppone l'esistenza di un parametro legislativo rispetto al quale sindacare la legittimità degli atti amministrativi. Il principio di legalità assolve una duplice funzione:

- **legalità-garanzia**, quale presidio delle situazioni giuridiche soggettive dei privati incise dall'esercizio del potere amministrativo;
- **legalità-indirizzo**, in quanto la legge, espressione della sovranità popolare, orienta e legittima l'azione amministrativa nel quadro del circuito politico-rappresentativo.

Il principio può essere inteso in due accezioni:

1. **Legalità come preferenza della legge:** Gli atti amministrativi non possono porsi in contrasto con la legge, che opera quale limite negativo all'esercizio del potere. La violazione determina il vizio di illegittimità per violazione di legge.
2. **Legalità come necessaria base legale del potere:** L'amministrazione può esercitare un potere solo se una norma di legge gliene attribuisce espressamente la titolarità, definendone presupposti, modalità e contenuti essenziali. In assenza di norma attributiva, l'atto è affetto da nullità per carenza di potere. In tale accezione, oggi prevalente, il principio presenta una duplice dimensione:
 - **legalità formale (o in senso debole),** soddisfatta dalla mera individuazione legislativa dell'autorità competente;
 - **legalità sostanziale (o in senso forte),** che richiede una disciplina normativa puntuale dei presupposti, delle modalità procedurali e dei limiti del potere amministrativo.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, il rispetto del principio di legalità implica anche la conformità dell'atto amministrativo alle fonti secondarie legittimamente emanate. Inoltre, il parametro di legalità è integrato dai principi generali del diritto amministrativo, desumibili dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea e dall'elaborazione giurisprudenziale, molti dei quali sono richiamati dall'**art. 1 della legge n. 241 del 1990**.

Le leggi-provvedimento

Le c.d. *leggi-provvedimento* costituiscono una **figura peculiare nel sistema delle fonti** e sono spesso considerate **sintomo di una tensione nei rapporti tra Parlamento e potere esecutivo**. Si tratta di leggi, statali o regionali, che difettano dei caratteri tipici della generalità e dell'astrattezza, in quanto disciplinano situazioni concrete e determinate, talvolta riferite a un'unica fattispecie o a soggetti specificamente individuati. Rientrano in tale categoria, ad esempio, **le leggi che revocano o prorogano concessioni amministrative relative a determinate imprese**, che dispongono finanziamenti a favore di singoli operatori economici, ovvero che istituiscono società per azioni di **interesse nazionale introducendo deroghe al diritto comune**, come avvenuto in passato per la RAI. La Costituzione non contempla un principio di "riserva di amministrazione" che precluda al legislatore l'intervento in ambiti tipicamente propri dell'azione amministrativa. Ne consegue che rientra nella **discrezionalità del Parlamento la scelta se regolare una determinata fattispecie mediante legge**, anziché attribuire **all'amministrazione il potere di provvedere in via generale e astratta**. Tuttavia, la prassi del "amministrare per legge" è stata oggetto di rilievi critici, in quanto ritenuta idonea a incidere sull'equilibrio tra i poteri e a comprimere le garanzie proprie del procedimento amministrativo. In particolare, la legge-provvedimento elide gli strumenti di tutela tipici dell'atto amministrativo: il diritto di partecipazione procedimentale, l'obbligo di motivazione, nonché la possibilità di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo per ottenerne l'annullamento per vizi di legittimità. Diversamente dal provvedimento amministrativo, la legge-provvedimento è sindacabile esclusivamente sotto il profilo della legittimità costituzionale, mediante il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, nei limiti e secondo le forme proprie del controllo di costituzionalità. Non è pertanto ammesso un sindacato diretto di legittimità ordinaria. La questione delle leggi-provvedimento si colloca, dunque, al crocevia tra principio di separazione dei poteri, garanzie procedimentali e tutela giurisdizionale, sollecitando un bilanciamento tra la discrezionalità legislativa e le esigenze di protezione delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte.

I regolamenti governativi

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha introdotto il principio di parallelismo tra competenza legislativa e competenza regolamentare dello Stato. Ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost., la potestà regolamentare spetta allo Stato esclusivamente nelle materie attribuite alla sua competenza legislativa

esclusiva. Nelle restanti materie la potestà regolamentare compete alle Regioni. Lo Stato può tuttavia intervenire, con regolamenti, anche in ambiti riconducibili alla potestà legislativa concorrente o residuale regionale, nelle more dell'adozione della disciplina regionale e in caso di inerzia. Tali regolamenti hanno carattere cedevole, poiché perdono efficacia con l'entrata in vigore della normativa regionale (art. 11, comma 8, l. n. 11/2005). Il potere regolamentare del Governo trova fondamento anche **nell'art. 87 Cost.**, che attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di emanare i regolamenti. La disciplina generale è contenuta nella **legge n. 400 del 1988**, il cui **art. 17 individua diverse tipologie di regolamenti governativi**:

1. **Regolamenti esecutivi:** Contengono disposizioni di dettaglio necessarie per l'attuazione concreta della legge (specificazioni tecniche, modalità procedurali, termini). Non è richiesta una specifica autorizzazione legislativa per ciascun regolamento, essendo sufficiente il fondamento generale previsto dalla **legge n. 400/1988** ai fini del rispetto del principio di legalità. Nelle materie coperte da riserva di legge assoluta sono ammessi soltanto regolamenti di stretta esecuzione.
2. **Regolamenti di attuazione e integrazione:** Possono essere adottati nelle materie non coperte da riserva di legge assoluta, qualora la legge si limiti a stabilire i principi generali e autorizzi espressamente il Governo a dettare la disciplina di dettaglio.
3. **Regolamenti indipendenti:** Intervengono in materie non soggette a riserva di legge, in assenza di una disciplina primaria. Essi operano in ambiti non riservati al legislatore.
4. **Regolamenti di organizzazione:** Disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni dettate dalla legge. Si configurano come sottospecie dei regolamenti esecutivi o di attuazione. **L'art. 97 Cost.** prevede una riserva di legge relativa in materia di organizzazione degli uffici, sicché è sempre necessaria una base legislativa che delinea l'assetto generale.
5. **Regolamenti delegati o autorizzati (delegificazione):** Sono previsti nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge e attuano il fenomeno della delegificazione, sostituendo la disciplina primaria con una disciplina secondaria. La **legge n. 400/1988** richiede:
 - Una legge di autorizzazione;
 - La previsione di norme generali regolatrici della materia;
 - La disposizione dell'abrogazione delle norme vigenti, con effetto differito all'entrata in vigore del regolamento.

L'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 disciplina inoltre i **regolamenti ministeriali e interministeriali**, adottabili nelle materie di competenza di uno o più ministri, nei soli casi espressamente previsti dalla legge. Essi sono gerarchicamente subordinati ai regolamenti governativi e devono essere previamente comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini del coordinamento. La **tipologia dei regolamenti non si esaurisce nell'art. 17 della legge n. 400/1988**, poiché **numerosi leggi speciali prevedono fattispecie derogatorie**. Nella prassi si sono affermati anche atti normativi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sotto il profilo formale e procedurale, i regolamenti:

- Recano espressamente la denominazione di "regolamento";
- Sono adottati previo parere del Consiglio di Stato;
- Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti;
- Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Non è prevista la partecipazione dei privati al procedimento di formazione, né è richiesto l'obbligo di motivazione. Quanto al regime giuridico, i regolamenti sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi. Per un verso, sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo e

possono essere annullati ove contrastino con la legge. Per altro verso, in quanto fonti del diritto, sono soggetti alle regole sull'interpretazione **di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile**; si applica il **principio iura novit curia** e la loro violazione può costituire motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

I testi unici e i codici

Negli ultimi decenni la **produzione legislativa ha acquisito ormai una dimensione patologica**, tanto che può parlarsi di **"inflazione legislativa"**. Lo strumento di riordino più tradizionale è costituito dai **c.d. testi unici**, che accorpano e razionalizzano in un unico corpo normativo **le disposizioni legislative vigenti che disciplinano una determinata materia**. Si distinguono:

1. **I testi unici innovativi**, che sono emanati sulla base di un'autorizzazione legislativa che stabilisce i criteri del riordino (c.d. testi unici autorizzati o delegati). Essi sono pertanto fonti del diritto in senso proprio;
2. **I testi unici di mera compilazione**, che sono emanati su iniziativa autonoma del governo (c.d. testi unici spontanei) e hanno soltanto la funzione pratica di unificare in un unico testo le varie disposizioni vigenti, rendendone più semplice il reperimento.

Cenni alle fonti normative regionali, degli enti locali e di altri enti pubblici

1. Fonti normative regionali: La Costituzione individua tre principali fonti normative regionali.

- a) **Statuto regionale:** Per le Regioni ordinarie, l'art. 123, comma 1, Cost. attribuisce allo statuto la funzione di determinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione. Lo statuto è approvato con procedimento aggravato: doppia deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza assoluta e possibilità di referendum popolare (commi 2 e 3). Gli statuti delle Regioni a statuto speciale, invece, sono approvati con legge costituzionale ai sensi dell'art. 116 Cost.
- b) **Leggi regionali:** Sono approvate dal Consiglio regionale e promulgate dal Presidente della Giunta (art. 121 Cost.). Esse intervengono nelle materie attribuite dall'art. 117 Cost. alla competenza concorrente (comma 3) e residuale (comma 4) delle Regioni. La giurisprudenza costituzionale ha tuttavia precisato che anche nelle materie regionali possono operare limiti derivanti da competenze statali. In particolare:
 - talune materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato presentano carattere trasversale (ad esempio, la tutela della concorrenza), consentendo al legislatore statale di incidere su ambiti materiali altrimenti regionali;
 - in applicazione del principio di sussidiarietà verticale, qualora una funzione richieda un esercizio unitario a livello statale, anche la funzione legislativa può essere attratta nella competenza dello Stato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 303 del 2003, ha elaborato in proposito il principio della c.d. "chiamata in sussidiarietà".
- c) **Regolamenti regionali** Ai sensi dell'art. 121 Cost., i regolamenti regionali sono adottati dalla Giunta regionale. In conformità al principio di parallelismo tra competenza legislativa e regolamentare, essi possono essere emanati nelle materie attribuite alla competenza concorrente e residuale della Regione.

2. Fonti normative degli enti locali: Le fonti normative di Comuni, Province e Città metropolitane sono costituite da statuti e regolamenti.

- a) **Statuto dell'ente locale:** L'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) prevede che lo statuto sia approvato dal Consiglio con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non sia raggiunta, è sufficiente una doppia deliberazione a maggioranza assoluta.

Lo statuto disciplina le norme fondamentali sull'organizzazione dell'ente, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, il decentramento, nonché l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Sotto il profilo gerarchico, lo statuto si colloca a livello subprimario, essendo subordinato alle leggi statali di principio. L'art. 117, comma 2, lett. p), Cost. riserva infatti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina degli organi di governo e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

- b) **Regolamenti degli enti locali:** L'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare in ordine all'organizzazione e al funzionamento degli organi e degli uffici, nonché all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

3. Fonti normative di altri enti pubblici: A partire dagli anni Novanta, numerosi enti pubblici hanno acquisito una più ampia autonomia organizzativa e funzionale. Tra questi rientrano, ad esempio, le università e le camere di commercio. Tale autonomia comprende generalmente la potestà statutaria, esercitata nei limiti e secondo i principi stabiliti dalla legge, nonché la potestà regolamentare in materia di organizzazione e disciplina delle proprie funzioni. Analoga autonomia normativa è riconosciuta alle autorità amministrative indipendenti, le quali adottano regolamenti interni e atti normativi secondari nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge istitutiva.

Gli atti di regolazione aventi natura non normativa

La funzione di regolazione delle pubbliche amministrazioni non si esaurisce nell'adozione di fonti normative in senso proprio, ma si esplica anche attraverso atti aventi natura non normativa. La distinzione tra atti normativi e atti non normativi è tradizionalmente fondata su criteri formali e sostanziali, la cui applicazione non risulta tuttavia univoca. Sotto il profilo sostanziale, agli atti normativi sono generalmente attribuiti i caratteri della **generalità**, dell'**astrattezza** e della **novità**. Quest'ultima è intesa quale attitudine dell'atto a innovare l'ordinamento giuridico, mediante sostituzione, modifica o integrazione di norme preesistenti. Gli atti non normativi, pur potendo avere contenuto generale, difetterebbero della capacità innovativa tipica della fonte del diritto. Secondo altre impostazioni, la distinzione si fonda su criteri diversi. In particolare:

- La connotazione **politica dell'atto normativo**, in contrapposizione al carattere esecutivo o attuativo dell'atto non normativo;
- La finalizzazione dell'atto normativo alla regolazione in astratto di rapporti giuridici, mentre l'atto non normativo sarebbe orientato alla cura di interessi pubblici concreti;
- Il diverso grado di discrezionalità e di autonomia rispetto a scelte legislative pregresse.

Tali criteri, tuttavia, non consentono di tracciare una linea di demarcazione netta in tutti i casi, specie con riferimento agli atti amministrativi generali, che presentano contenuti rivolti a una pluralità indeterminata di destinatari ma non integrano necessariamente una fonte normativa. Nel diritto amministrativo, la distinzione tra atti normativi e atti non normativi assume rilievo limitato, poiché il regime giuridico applicabile agli atti amministrativi generali è, per larga parte, coincidente con quello degli altri atti amministrativi: essi sono soggetti ai principi generali dell'azione amministrativa, al sindacato giurisdizionale e ai limiti derivanti dal principio di legalità. La qualificazione dell'atto come normativo o non normativo rileva principalmente ai fini della sua collocazione nel sistema delle fonti e della sua idoneità a innovare l'ordinamento, ma non incide in modo decisivo sul regime sostanziale di controllo e di validità nell'ambito dell'ordinamento amministrativo.

Gli atti amministrativi generali

Il provvedimento amministrativo, in via ordinaria, ha contenuto concreto ed è rivolto a destinatari determinati o determinabili; esso incide su uno specifico rapporto giuridico, definendone autoritativamente l'assetto in relazione a una situazione di fatto puntuale. Accanto a tale modello,

l'ordinamento conosce gli **atti amministrativi generali**, caratterizzati da un contenuto rivolto a una pluralità indifferenziata di destinatari. Essi sono spesso strumentali o propedeutici all'adozione di provvedimenti puntuali ovvero si collocano nell'ambito dell'attività di organizzazione e coordinamento dell'azione amministrativa. In taluni casi presentano anche il requisito dell'astrattezza, potendo trovare applicazione in una serie reiterata di situazioni. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, i piani, i programmi, le direttive, gli atti di indirizzo, le linee guida, le autorizzazioni generali, i bandi di concorso e di gara, nonché gli atti che determinano prezzi e tariffe in via autoritativa. A livello statale, la competenza ad adottare atti amministrativi generali spetta al Governo, cui l'art. 95 Cost. attribuisce il compito di mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo e di coordinare l'attività dei ministri, nonché ai singoli ministri nell'ambito delle rispettive attribuzioni. A livello locale, i consigli comunali e provinciali adottano piani territoriali e urbanistici, programmi e indirizzi per enti e aziende dipendenti.

Regime giuridico

Gli atti amministrativi generali sono soggetti a un regime in parte derogatorio rispetto a quello dei provvedimenti individuali disciplinati dalla legge n. 241 del 1990 e, sotto taluni profili, assimilabile a quello degli atti normativi. **In particolare:**

- non è richiesto l'obbligo di motivazione;
- non è prevista la partecipazione procedimentale dei privati;
- l'attività diretta alla loro emanazione è esclusa dal diritto di accesso.

Tali deroghe trovano giustificazione nella natura generale dell'atto e nella funzione programmatica o organizzativa che esso assolve.

1. **Bandi di concorso e avvisi di gara:** Tra gli atti amministrativi generali privi di carattere di astrattezza rientrano i bandi di concorso per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni e gli avvisi di gara per la selezione del contraente nei contratti pubblici. Essi sono rivolti a una pluralità indifferenziata di destinatari, ma esauriscono i propri effetti in relazione a una procedura specifica; la loro natura non normativa è pacifica.
2. **Atti di pianificazione e programmazione:** L'attività di pianificazione e programmazione risponde all'esigenza di garantire coerenza e razionalità nell'esercizio dei poteri amministrativi. In molte materie la legge prevede strumenti pianificatori mediante i quali sono individuati obiettivi, limiti, priorità e criteri destinati a orientare l'azione amministrativa. Il rilascio dei titoli edilizi, ad esempio, avviene nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali; analogamente, l'allocatione delle frequenze radiotelevisive si fonda su un piano nazionale di settore. La pianificazione si articola spesso secondo il modello della "pianificazione a cascata", che assicura il coordinamento tra livelli di governo, come accade in ambito sanitario con il piano sanitario nazionale e i piani sanitari regionali. Particolarmente rilevante è il piano regolatore generale (PRG), principale strumento di governo del territorio comunale. Esso realizza la c.d. zonizzazione, suddividendo il territorio in zone omogenee e stabilendo, per ciascuna, le destinazioni d'uso ammesse, in conformità ai parametri fissati a livello nazionale. Individua inoltre le aree destinate a edifici e infrastrutture pubbliche o di uso pubblico. Qualora tali previsioni incidano su proprietà private, esse comportano un vincolo di inedificabilità di durata quinquennale, che decade in mancanza di espropriazione. Il PRG si inserisce in un sistema multilivello di pianificazione ed è subordinato, tra l'altro, al piano territoriale di coordinamento provinciale e ai piani paesaggistici. Il procedimento di formazione prevede forme di partecipazione: adozione da parte del Consiglio comunale, pubblicazione per la presentazione di osservazioni, nuova deliberazione sulle osservazioni e successiva approvazione regionale. La Regione esercita un controllo non limitato alla mera legittimità, potendo introdurre modifiche a tutela di interessi ambientali e paesaggistici.

Il piano regolatore presenta una **natura mista**, normativa e amministrativa: da un lato contiene disposizioni generali e astratte sull'assetto del territorio; dall'altro reca prescrizioni puntuali relative a specifiche aree. I suoi effetti sono molteplici: orientano la pianificazione sovraordinata e subordinata, conformano il territorio e incidono sul contenuto del diritto di proprietà.

Le ordinanze contingibili e urgenti

Gli ordinamenti prevedono strumenti idonei a fronteggiare situazioni eccezionali e imprevedibili, suscettibili di porre in pericolo interessi fondamentali della collettività, quali l'incolumità pubblica, la sicurezza o la salute. Tali situazioni non sono sempre disciplinabili in via preventiva mediante fonti primarie. Nel periodo dello Statuto albertino, si riteneva che rientrasse nei poteri del sovrano l'adozione di ordinanze urgenti anche in deroga alla legislazione vigente. Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la funzione di fronteggiare situazioni straordinarie è stata in larga parte ricondotta allo strumento del decreto-legge, adottabile dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza. A livello subcostituzionale, tuttavia, numerose disposizioni legislative attribuiscono a specifiche autorità amministrative il potere di emanare **ordinanze contingibili e urgenti**, in settori quali l'ordine pubblico, la sanità o la protezione civile. Tra le principali ipotesi:

- Il **prefetto** può adottare, in caso di urgenza o grave necessità pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- Il **sindaco**, quale ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000). Analoghi poteri sono previsti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica locale, nonché per esigenze di sicurezza urbana, decoro e vivibilità (art. 50, comma 5);
- In materia di **protezione civile**, il Consiglio dei Ministri può deliberare lo stato di emergenza, fissandone durata ed estensione territoriale. Il potere di ordinanza è esercitato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile entro i limiti e secondo i criteri stabiliti nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Le ordinanze sono immediatamente efficaci.

Le leggi attributive di tali poteri individuano l'autorità competente, delineano in termini generali il presupposto legittimante (situazione contingibile e urgente) e indicano il fine pubblico da perseguire. Esse soddisfano, pertanto, il principio di legalità in senso formale, ma lasciano ampio margine di discrezionalità quanto al contenuto concreto delle misure adottabili e ai destinatari. Ne deriva un problema di compatibilità con il principio di legalità in senso sostanziale, che esige una più puntuale predeterminazione dei presupposti e dei limiti del potere. Sotto il profilo della natura giuridica, le ordinanze contingibili e urgenti sono, di regola, atti non normativi. Anche quando si rivolgono a una pluralità indifferenziata di destinatari, esse sono collegate a situazioni fattuali specifiche (ad esempio, un'epidemia o una calamità naturale) e presentano carattere concreto e temporaneo. Qualora, tuttavia, la situazione emergenziale si protragga nel tempo, l'ordinanza può assumere tratti di astrattezza e perdere il carattere della temporaneità, avvicinandosi funzionalmente ai regolamenti, specie nelle ipotesi di ordinanze sindacali in materia di sicurezza o decoro urbano. Le ordinanze contingibili e urgenti si distinguono dagli **atti necessitati**, i quali presuppongono anch'essi una situazione di urgenza, ma hanno contenuto e effetti integralmente predeterminati dalla norma attributiva del potere. In tali casi, l'amministrazione non dispone di una discrezionalità atipica, bensì esercita un potere rigidamente conformato dalla legge; ne è esempio l'occupazione d'urgenza di terreni nell'ambito del procedimento espropriativo, a seguito della dichiarazione di indifferibilità e urgenza dei lavori.

Le direttive e gli atti di indirizzo

Le direttive amministrative costituiscono strumenti espressivi della funzione di indirizzo politico-amministrativo e presentano affinità con gli atti di pianificazione e programmazione. A differenza delle

fonti normative, primarie o secondarie, esse non contengono prescrizioni puntuali e rigidamente vincolanti, ma indicano fini, obiettivi e criteri cui l'attività amministrativa deve conformarsi. La loro vincolatività è attenuata: il destinatario può discostarsene, in tutto o in parte, ove sussistano ragioni giustificative, che devono essere esplicitate in motivazione. La direttiva, pertanto, non elimina la discrezionalità dell'organo destinatario, ma la orienta. Si distinguono due principali tipologie.

1. **Direttive nell'ambito di rapporti interorganici:** Esse operano all'interno della medesima organizzazione amministrativa e rappresentano lo strumento mediante il quale l'organo sovraordinato orienta l'attività dell'organo sottordinato. Quando il rapporto ha natura gerarchica in senso proprio, la direttiva può affiancarsi o sostituire l'ordine gerarchico. Quest'ultimo ha contenuto puntuale e si riferisce a una situazione concreta; la direttiva, invece, si colloca su un piano più generale e programmatico. Un esempio è il rapporto tra il Ministro dell'interno e i prefetti. Quando, invece, l'organo sottordinato è titolare di una competenza autonoma e non interamente ricompresa in quella dell'organo sovraordinato, il rapporto non è qualificabile come gerarchico, bensì come rapporto di direzione. In tal caso la direttiva assume la sua configurazione tipica. Emblematico è il rapporto tra Ministro e dirigenti generali delineato dal d.lgs. n. 165 del 2001, fondato sul principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione. Il Ministro non può esercitare poteri di gestione diretta, ma può emanare direttive generali e svolgere un controllo successivo sull'attività dirigenziale.
2. **Direttive nei rapporti intersoggettivi:** Le direttive possono operare anche in rapporti tra soggetti distinti, quali quelli tra Ministero o Regione ed enti pubblici strumentali. In tali ipotesi, esse costituiscono strumenti di indirizzo finalizzati ad assicurare la coerenza dell'attività dell'ente con gli obiettivi istituzionali dell'amministrazione di riferimento.

Direttive a valenza regolatoria

In epoca più recente si sono affermate direttive con marcata funzione regolatoria. Le autorità amministrative indipendenti, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, possono emanare direttive nei confronti delle imprese esercenti il servizio, al fine di definire standard generali di qualità, criteri organizzativi o modalità di erogazione delle prestazioni. In tali casi, la direttiva assume un ruolo centrale nella regolazione dei mercati, pur mantenendo natura formalmente non normativa e collocandosi nell'ambito degli strumenti di indirizzo e coordinamento dell'azione amministrativa.

Le norme interne e le circolari

Le organizzazioni complesse, pubbliche e private, si dotano di regole interne volte a disciplinare il funzionamento e i rapporti tra le diverse unità operative. Nel diritto pubblico, tali regole si collocano nell'ambito dei c.d. ordinamenti sezionali, caratterizzati da alcuni elementi strutturali:

- la plurisoggettività, con individuazione dei soggetti appartenenti all'ordinamento speciale mediante atti di ammissione, iscrizione o attribuzione di status;
- un'organizzazione stabile, con distribuzione di ruoli e competenze;
- un sistema di norme interne emanate dagli organi dell'ordinamento e assistite da sanzioni interne;
- la presenza, talvolta, di organi giustiziali propri, quali ad esempio corti arbitrali sportive.

Le norme interne possono assumere forme diverse: regolamenti interni, ordini di servizio, istruzioni operative, direttive generali.

La prassi amministrativa

Una particolare espressione delle norme interne è costituita dalla prassi amministrativa, intesa come comportamento uniforme e costante adottato dagli uffici in casi analoghi. Il principio di coerenza e imparzialità dell'azione amministrativa comporta che i precedenti consolidati assumano una rilevanza vincolante, nel senso che l'amministrazione, in presenza di casi analoghi, deve tenerne conto e può discostarsene solo fornendo adeguata motivazione. La prassi non coincide con la consuetudine quale fonte del diritto, poiché non si fonda su un convincimento generalizzato della sua obbligatorietà (*opinio juris*), ma su esigenze di uniformità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Le circolari

Lo strumento ordinario di diffusione delle norme interne è la circolare, che costituisce un mezzo di orientamento e coordinamento dell'attività degli uffici. Pur non avendo natura normativa, nella prassi amministrativa le circolari possono esercitare un'influenza significativa sull'azione degli organi destinatari. Si distinguono tre principali tipologie:

1. **Circolari interpretative:** Sono volte a garantire un'applicazione uniforme di nuove disposizioni normative. All'interno di strutture gerarchiche esse possono assumere carattere vincolante per gli organi subordinati. Al di fuori di un rapporto gerarchico, esse sono generalmente considerate meri atti di indirizzo interpretativo, privi di vincolatività giuridica esterna.
2. **Circolari normative:** Non hanno ad oggetto l'interpretazione di norme, ma l'orientamento dell'esercizio del potere discrezionale. L'organo sovraordinato indica criteri, priorità e finalità cui l'organo subordinato deve attenersi nell'ambito della propria competenza. Il destinatario è tenuto a considerarle, potendo discostarsene solo mediante adeguata motivazione.
3. **Circolari informative:** Hanno funzione meramente comunicativa e sono destinate a diffondere notizie, dati o informazioni all'interno dell'organizzazione, senza contenuto prescrittivo. Le circolari, in quanto atti interni, non sono di regola direttamente impugnabili dai privati, salvo che producano effetti lesivi immediati. Esse rilevano principalmente nell'ambito dei rapporti organizzativi interni e contribuiscono a garantire uniformità, coordinamento e prevedibilità dell'azione amministrativa.

La soft law, le raccomandazioni e le linee guida

Con l'espressione *soft law* si fa riferimento **all'insieme di atti e strumenti**, spesso privi di forma tipica e di vincolatività giuridica in senso proprio, **diretti a orientare i comportamenti delle autorità amministrative e dei soggetti destinatari**. Rientrano in tale categoria comunicazioni, raccomandazioni, linee guida, inviti, segnalazioni, note interpretative, documenti di prassi e analoghi atti di indirizzo. La soft law incide sul principio di tipicità delle fonti e degli atti amministrativi a contenuto regolatorio, quale espressione del principio di legalità. **In assenza di una base normativa che conferisca espressamente poteri regolamentari**, tali atti non innovano formalmente l'ordinamento, ma producono effetti di orientamento e conformazione indiretta dei comportamenti. Un esempio significativo si rinviene nel settore della protezione dei dati personali: il Comitato europeo per la protezione dei dati può adottare linee guida, raccomandazioni e *best practices* rivolte alle autorità nazionali e ai soggetti privati, al fine di assicurare un'applicazione uniforme della disciplina. Analogamente, il Garante per la protezione dei dati personali può emanare linee guida destinate a specificare criteri applicativi della normativa di settore. A **livello nazionale**, anche **autorità di regolazione quali CONSOB e Banca d'Italia** pubblicano atti variamente denominati – avvisi,

comunicazioni, richiami di attenzione, note amministrative, documenti di domande e risposte – che, pur non avendo natura normativa, orientano in modo significativo l'attività degli operatori vigilati. Il grado di effettività della *soft law* non deriva dalla sua forza giuridica vincolante, bensì dall'autorevolezza dell'organo emanante, dalla competenza tecnica riconosciuta e dal ruolo istituzionale svolto. In tal senso, la *soft law* opera come strumento di regolazione flessibile, idoneo a integrare o specificare discipline complesse, specie in ambiti caratterizzati da elevato tecnicismo o rapida evoluzione.

La better regulation e altri modelli di regolazione

Negli ultimi anni si è affermato, a livello europeo e nazionale, il paradigma della *better regulation*, volto a migliorare la qualità della produzione normativa e a razionalizzare l'intervento regolatorio pubblico. Tale approccio persegue una pluralità di obiettivi:

- Contrastare l'iperregolazione e la proliferazione di norme;
- ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle pubbliche amministrazioni e sui destinatari privati;
- Assicurare maggiore proporzionalità e semplificazione, anche mediante discipline differenziate per le piccole e medie imprese;
- Incrementare trasparenza e prevedibilità delle scelte regolatorie.

Uno degli strumenti centrali è l'**analisi di impatto della regolazione (AIR)**, introdotta nell'ordinamento italiano negli anni Novanta. L'AIR impone alle amministrazioni, prima dell'adozione di un atto normativo o regolatorio, di:

- Individuare le possibili opzioni alternative, inclusa la c.d. *opzione zero* (mancato intervento);
- Valutare i costi e i benefici di ciascuna opzione;
- Esplicitare le valutazioni effettuate in un documento che accompagna la proposta normativa.

L'AIR rappresenta uno strumento di razionalizzazione *ex ante* della decisione pubblica, orientato a garantire proporzionalità, efficienza ed economicità dell'intervento regolatorio.

Accanto alla valutazione preventiva, il sistema prevede un meccanismo di controllo successivo, la **verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)**. Essa consiste in una valutazione *ex post* degli effetti prodotti dalla normativa, da effettuarsi dopo il primo biennio di applicazione e successivamente con cadenza biennale. La VIR è finalizzata ad accertare:

- I costi effettivamente sostenuti;
- Le difficoltà applicative riscontrate;
- I risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

All'esito della verifica può essere proposta la modifica, l'integrazione o l'abrogazione delle disposizioni vigenti. La *better regulation* si inserisce in un più ampio processo di modernizzazione dell'azione amministrativa, fondato su criteri di evidenza empirica, valutazione comparativa delle opzioni e controllo sistematico degli effetti della regolazione, in coerenza con i principi di buon andamento e proporzionalità.

IL RAPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Le funzioni e l'attività amministrativa

Esaminata la funzione di regolazione, intesa quale insieme di strumenti normativi e non normativi mediante i quali l'amministrazione disciplina i rapporti con i privati e la propria organizzazione, occorre considerare la funzione di amministrazione attiva. Essa consiste nell'esercizio, attraverso

moduli procedurali, dei poteri amministrativi attribuiti dalla legge ad apparati pubblici per la cura concreta dell'interesse pubblico nei rapporti con i soggetti privati. Quando la legge istituisce un apparato amministrativo, ne individua anzitutto le **funzioni**, correlate alle finalità di interesse pubblico che ne definiscono la missione istituzionale. Il termine "funzione" presenta una pluralità di significati; nel contesto rilevante, per funzioni amministrative si intendono i compiti che la legge attribuisce a un apparato per la cura di uno specifico interesse pubblico. In relazione alle funzioni, la legge conferisce all'apparato le **attribuzioni**, ossia l'insieme dei poteri e delle risorse necessari e ripartisce tali poteri tra gli organi che compongono l'apparato, individuandone le **competenze**.

Le funzioni sono normalmente elencate in modo espresso dalla legge istitutiva dell'ente. L'esercizio delle funzioni comporta lo svolgimento di una pluralità di attività materiali e giuridiche. L'**attività amministrativa** consiste nell'insieme dei comportamenti e delle decisioni, inclusi gli atti e i provvedimenti amministrativi, posti in essere da una pubblica amministrazione nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge. Essa è caratterizzata dalla finalizzazione alla cura di un interesse pubblico e dal carattere della doverosità, poiché il mancato esercizio dell'attività può dar luogo a responsabilità. Tale carattere distingue l'attività amministrativa dall'esercizio della capacità giuridica da parte dei privati, che nel diritto comune è normalmente libero. **L'art. 1 della legge n. 241 del 1990** stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Sotto il profilo giuridico, **la nozione di attività amministrativa va distinta da quella di atto o provvedimento amministrativo**.

- **L'attività** costituisce il **complesso unitario dell'operato dell'amministrazione** e può essere valutata **in termini di legalità, efficienza, efficacia ed economicità**, anche nell'ambito del controllo della Corte dei conti.
- **L'atto amministrativo**, invece, rappresenta una **singola manifestazione dell'attività** e si **presta a essere scrutinato sotto il profilo della legittimità** e, nei limiti consentiti, dell'opportunità o merito amministrativo.

Quanto alla distinzione **tra attività amministrativa e attività di diritto privato della pubblica amministrazione**, la giurisprudenza ha affermato che l'amministrazione svolge attività amministrativa non solo quando esercita poteri autoritativi, ma anche quando persegue finalità istituzionali mediante strumenti disciplinati, in tutto o in parte, dal diritto privato. Da ciò discende la distinzione tra:

- Attività amministrativa svolta con moduli privatistici;
- Attività d'impresa di enti pubblici.

La tendenza a qualificare come pubblicistica anche l'attività svolta mediante strumenti privatistici risponde all'esigenza di evitare che le amministrazioni eludano l'applicazione delle regole proprie del diritto amministrativo, ricorrendo a forme organizzative quali società di capitali controllate, al fine di sottrarsi a vincoli quali l'obbligo di concorso per l'assunzione del personale o l'evidenza pubblica nella stipulazione dei contratti. In tale prospettiva, il rapporto giuridico amministrativo si configura come la relazione che si instaura tra pubblica amministrazione e privato nell'esercizio di una funzione pubblica, relazione strutturalmente orientata alla cura dell'interesse pubblico e regolata da principi e garanzie proprie dell'ordinamento amministrativo.

Il potere, il provvedimento, il procedimento

L'attività amministrativa si manifesta non solo attraverso comportamenti materiali, ma soprattutto mediante l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, quali espressioni concrete dei poteri attribuiti dalla legge a un apparato pubblico. In relazione a ciascuna funzione, la legge individua specifici poteri (autorizzativi, ablatori, sanzionatori, ordinatori, ecc.), definendone presupposti, contenuto ed effetti.

Il potere amministrativo

La nozione di potere appartiene alla teoria generale del diritto e può riferirsi, oltre che al potere amministrativo, al potere legislativo (emanazione di norme generali e astratte), al potere giurisdizionale (decisione di controversie con efficacia di giudicato) e al potere negoziale (autonoma disposizione dei propri interessi). Il potere amministrativo consiste nella capacità giuridica speciale di diritto pubblico attribuita dalla legge a un apparato, consistente nella possibilità di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica altrui mediante un atto autoritativo. Esso si aggiunge alla capacità giuridica generale di diritto comune, di cui le amministrazioni sono dotate al pari dei soggetti privati. Il **potere amministrativo pone il suo titolare in posizione di supremazia rispetto al destinatario**, configurando un rapporto di sovraordinazione. È necessario distinguere tra:

- **potere in astratto**, definito dalla norma attributiva che ne individua gli elementi costitutivi. L'assenza di una norma di conferimento determina un difetto assoluto di attribuzione e comporta la nullità del provvedimento. Il potere in astratto ha carattere inesauribile, potendo essere esercitato in una pluralità indeterminata di situazioni conformi alla fattispecie legale;
- **potere in concreto**, che si realizza quando, verificatisi i presupposti di fatto, l'amministrazione esercita il potere mediante l'adozione di un atto autoritativo.

In virtù del principio di doverosità, l'amministrazione non solo è legittimata, ma è tenuta ad attivarsi, avviando il procedimento volto all'emanazione del provvedimento idoneo a disciplinare il rapporto con il privato.

L'atto e il provvedimento amministrativo

L'ordinamento non offre una definizione legislativa generale di atto o provvedimento amministrativo; la nozione è di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. L'art. 113 Cost. afferma la piena tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e richiama implicitamente due elementi essenziali del loro regime: la sottoposizione al controllo giurisdizionale e la loro annullabilità in caso di difformità dall'ordinamento.

La legge n. 241 del 1990 fornisce ulteriori elementi qualificanti:

- L'art. 1, comma 1-bis, distingue gli atti di natura non autoritativa, soggetti di regola al diritto privato, dagli atti autoritativi;
- L'art. 3 impone l'obbligo di motivazione per ogni provvedimento amministrativo;
- Gli artt. 7 e 21-bis richiamano il carattere autoritativo del provvedimento, che acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione.

Dottrina e giurisprudenza talvolta distinguono tra:

- **Atto amministrativo**, nozione ampia che ricomprende ogni dichiarazione di volontà, conoscenza o giudizio resa da un soggetto pubblico nell'esercizio di una potestà amministrativa, inclusi atti endoprocedimentali (pareri, valutazioni tecniche, proposte);
- **Provvedimento amministrativo**, quale atto conclusivo del procedimento, espressione della volontà dell'amministrazione titolare del potere, volto alla cura concreta dell'interesse pubblico e produttivo di effetti giuridici esterni in modo unilaterale.

Il provvedimento rappresenta, dunque, la forma tipica di esercizio del potere amministrativo.

Il procedimento amministrativo

L'esercizio del potere si realizza attraverso il **procedimento amministrativo**, ossia una sequenza ordinata di atti e operazioni strumentali all'adozione del provvedimento finale. La **legge n. 241 del**

1990 disciplina in via generale il procedimento, pur senza fornirne una definizione espressa. Il procedimento assolve a plurime funzioni:

- Garantire la partecipazione dei soggetti interessati, mediante la presentazione di memorie e documenti e, ove previsto, l'audizione personale;
- Consentire all'amministrazione di acquisire gli elementi istruttori necessari;
- Assicurare il coordinamento tra amministrazioni coinvolte;
- Rendere trasparente e controllabile l'esercizio del potere.

Il rapporto tra potere, procedimento e provvedimento evidenzia la dimensione dinamica dell'azione amministrativa: il potere, definito in astratto dalla legge, si concretizza attraverso il procedimento e si manifesta nel provvedimento, quale atto autoritativo idoneo a incidere nella sfera giuridica dei destinatari.

Il rapporto giuridico amministrativo

L'esercizio della funzione di amministrazione attiva determina l'instaurarsi di una relazione tra la pubblica amministrazione, titolare del potere, e il soggetto privato destinatario del provvedimento. Tale relazione è oggi qualificata, anche in sede giurisprudenziale (Corte cost., sent. n. 94/2017), come **rapporto giuridico amministrativo**, intercorrente tra l'amministrazione che esercita un potere e il privato titolare di un interesse legittimo. La configurazione di un vero e proprio rapporto giuridico segna il superamento della concezione tradizionale dello Stato in posizione di mera sovraordinazione, priva di vincoli giuridici bilaterali nei confronti degli amministrati.

Il modello privatistico: diritto soggettivo e obbligo

Nei rapporti interprivati, lo schema tipico è quello **diritto soggettivo-obbligo**, caratterizzato da una relazione paritaria. Il diritto soggettivo consiste nel potere di agire riconosciuto e garantito dall'ordinamento per la soddisfazione di un interesse proprio. Ad esso corrisponde:

- un dovere generico di astensione (nei diritti assoluti);
- un obbligo giuridico specifico di prestazione (nei diritti relativi), cui corrisponde la pretesa del titolare.

Tale modello presuppone una simmetria tra le posizioni soggettive delle parti.

Situazioni affini: potestà e diritto potestativo

Nel diritto privato esistono figure più prossime alla dinamica del rapporto amministrativo. La **potestà** è un potere attribuito per la cura di un interesse altrui. Essa si configura come potere-dovere, poiché il titolare deve esercitarla perseguendo la finalità eteroimposta dall'ordinamento. Analoga è la struttura del potere amministrativo, finalizzato alla cura dell'interesse pubblico. Il **diritto potestativo**, invece, consiste nella facoltà di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica altrui mediante una dichiarazione di volontà, ponendo il destinatario in stato di soggezione. La produzione degli effetti non richiede il consenso del soggetto inciso. La tecnica di produzione degli effetti segue lo schema: **norma – fatto – potere – effetto giuridico**, diversamente dallo schema ordinario **norma – fatto – effetto**, in cui l'effetto discende automaticamente dalla fattispecie. La dottrina distingue:

1. diritti potestativi a esercizio stragiudiziale, nei quali l'effetto si produce direttamente con la dichiarazione del titolare;
2. diritti potestativi a necessario esercizio giudiziale, nei quali l'effetto presuppone un previo accertamento giudiziale.

Il potere amministrativo come diritto potestativo pubblico

Il potere amministrativo è riconducibile allo schema del diritto potestativo a esercizio stragiudiziale: l'effetto giuridico si produce immediatamente con l'adozione del provvedimento, senza necessità di previo controllo giudiziale. L'eventuale sindacato giurisdizionale interviene solo in via successiva, su iniziativa del soggetto inciso. Tale struttura trova giustificazione nell'esigenza di assicurare l'immediata realizzazione dell'interesse pubblico. La posizione del privato trova tuttavia tutela già nella fase procedimentale, attraverso le garanzie di partecipazione, trasparenza e imparzialità previste dalla **legge n. 241/1990**.

Specificità del potere amministrativo

Nonostante l'analogia con il diritto potestativo, il potere amministrativo presenta rilevanti peculiarità:

- **Nei rapporti interpretavi**, il diritto potestativo trova normalmente un fondamento consensuale; il potere amministrativo, invece, deriva direttamente dalla legge e non presuppone un rapporto giuridico preesistente né il consenso del destinatario;
- **Nel diritto privato**, il contenuto e l'effetto del diritto potestativo sono rigidamente predeterminati; nel potere amministrativo, al contrario, sussistono frequentemente margini di discrezionalità, che consentono una modulazione del contenuto e degli effetti del provvedimento.

La discrezionalità incide anche sul sindacato giurisdizionale: il giudice può esercitare un controllo pieno sugli aspetti vincolati, mentre non può sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni discrezionali. In caso di illegittimità, il giudice si limita ad annullare il provvedimento, rimettendo all'amministrazione il riesercizio del potere.

Struttura del rapporto giuridico amministrativo

Il rapporto giuridico amministrativo si configura dunque come una relazione non paritaria, nella quale:

- La pubblica amministrazione è titolare di un potere finalizzato alla cura dell'interesse pubblico;
- Il privato è titolare di un interesse legittimo, che si concreta nella pretesa alla corretta e legittima esplicazione del potere.

La relazione è strutturalmente dinamica: dalla norma attributiva del potere si passa al procedimento e quindi al provvedimento, che incide unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario, entro i limiti tracciati dal principio di legalità e dalle garanzie giurisdizionali.

La norma attributiva del potere

La tradizionale distinzione tra **norme di azione** e **norme di relazione** muove dall'idea che le prime disciplinino l'esercizio del potere amministrativo nell'interesse dell'amministrazione, mentre le seconde regolino direttamente i rapporti tra amministrazione e privati, a tutela di questi ultimi.

- Le **norme di azione** seguono lo schema *norma-fatto-potere-effetto*: definiscono i limiti interni del potere e guidano l'attività amministrativa.
- Le **norme di relazione** seguono lo schema *norma-fatto-effetto*: incidono direttamente sull'assetto degli interessi, tracciando i limiti esterni tra sfera pubblica e sfera privata.

Da tale impostazione derivavano conseguenze sistematiche: la correlazione tra interesse legittimo e norme di azione, tra diritto soggettivo e norme di relazione; la distinzione tra annullabilità e nullità; il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario. Tale ricostruzione dicotomica appare oggi superata nella sua rigidità. È preferibile fare riferimento alla più ampia categoria della

norma attributiva del potere, quale espressione del principio di legalità. La norma attributiva individua gli elementi essenziali del potere amministrativo in astratto.

1. **Il soggetto competente:** Ogni potere deve essere attribuito in modo specifico a un determinato soggetto o organo. L'esercizio del potere da parte di un soggetto diverso integra il vizio di incompetenza.
2. **Il fine pubblico:** La norma individua l'interesse pubblico primario affidato alla cura dell'apparato. Il fine è eteroimposto dalla legge: l'amministrazione non può perseguire finalità diverse da quelle stabilite. La deviazione dal fine legale configura il vizio di **eccesso di potere per sviamento**.
3. **Presupposti e requisiti:** Sono i fatti costitutivi del potere, in presenza dei quali esso può essere esercitato legittimamente. Il grado di analiticità della previsione normativa incide sull'intensità della discrezionalità:
 - nei **poteri vincolati**, l'amministrazione deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti e ad adottare l'atto con effetti rigidamente predeterminati;
 - nei **poteri discrezionali**, la norma lascia margini di apprezzamento quanto alla valutazione dei presupposti e alla determinazione del contenuto dell'atto;
 - nei poteri "in bianco", come le ordinanze contingibili e urgenti, lo spazio valutativo è particolarmente ampio.

La latitudine della discrezionalità dipende anche dall'impiego di **concetti giuridici indeterminati**, distinguibili in:

- a) **concetti empirici o descrittivi**, che implicano valutazioni tecnico-scientifiche (area della discrezionalità tecnica);
 - b) **concetti normativi o di valore**, che implicano giudizi valutativi (area della discrezionalità amministrativa in senso stretto).
4. **Modalità di esercizio e requisiti formali:** La norma disciplina la forma degli atti (di regola scritta) e le modalità procedurali. La violazione di norme procedurali o formali non comporta automaticamente l'annullabilità: occorre verificare se la violazione abbia inciso in concreto sul contenuto dispositivo dell'atto. Se il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, l'atto non è annullabile.
 5. **Elemento temporale:** La norma può prevedere:
 - termini per l'avvio del procedimento;
 - termini per la conclusione (art. 2 l. 241/1990);
 - termini per atti endoprocedimentali (pareri, valutazioni tecniche, conferenza di servizi).

Molti termini hanno natura ordinatoria, ma il loro mancato rispetto può produrre effetti giuridici, quali l'operatività del silenzio-assenso o l'estinzione di obbligazioni.

6. **Effetti giuridici:** Il provvedimento, quale manifestazione del potere, è idoneo a produrre effetti costitutivi:
 - **costitutivi in senso stretto**, quando crea una nuova situazione giuridica (es. concessione);
 - **modificativi**, quando incide su una situazione preesistente (es. sospensione disciplinare);
 - **estintivi**, quando elimina una situazione giuridica (es. decreto di espropriazione).

La norma attributiva del potere costituisce, dunque, il fondamento legale dell'azione amministrativa: essa delimita competenza, finalità, presupposti, modalità, tempi ed effetti dell'esercizio del potere, assicurando la conformità dell'attività amministrativa al principio di legalità e rendendo possibile il controllo giurisdizionale sulla sua legittimità.

Il potere discrezionale

La discrezionalità rappresenta un elemento strutturale dell'azione amministrativa, in quanto la cura concreta dell'interesse pubblico implica la possibilità di scelta tra più soluzioni astrattamente consentite dalla legge. Un'interpretazione rigorosa del principio di legalità in senso sostanziale condurrebbe a concepire soltanto poteri vincolati. Tale impostazione, tuttavia, non è compatibile con la complessità e variabilità delle situazioni concrete, che richiedono adattabilità e capacità di valutazione. L'amministrazione, pertanto, deve disporre di un margine di scelta, pur entro limiti giuridicamente determinati. La discrezionalità amministrativa può definirsi come il margine di apprezzamento che la norma attributiva del potere rimette all'amministrazione affinché individui, tra le opzioni legittime, quella più idonea alla cura dell'interesse pubblico nel caso concreto. Essa si esercita mediante una **valutazione comparativa degli interessi** coinvolti, acquisiti nel corso dell'istruttoria:

- l'interesse pubblico primario, individuato dalla norma di conferimento del potere;
- gli interessi pubblici secondari eventualmente incisi;
- gli interessi privati coinvolti.

L'amministrazione è tenuta a massimizzare la realizzazione dell'interesse primario, arrecando il minor sacrificio possibile agli interessi secondari.

Ambiti della discrezionalità

La discrezionalità può riguardare diversi elementi del potere:

1. **An**: scelta se esercitare o meno il potere.
2. **Quid**: determinazione del contenuto del provvedimento.
3. **Quomodo**: modalità di esercizio del potere oltre le prescrizioni legali minime.
4. **Quando**: individuazione del momento opportuno per l'esercizio.

Un potere può essere vincolato o discrezionale con riferimento a uno solo o a più di tali elementi.

Vincolatezza in astratto e in concreto

La vincolatezza può essere:

- **in astratto**, quando la norma predetermina integralmente presupposti ed effetti;
- **in concreto**, quando, pur in presenza di discrezionalità astratta, all'esito dell'istruttoria residua un'unica soluzione legittima.

Il Codice del processo amministrativo (art. 31, co. 3) consente al giudice di accertare la fondatezza della pretesa del privato nei soli casi di attività vincolata o quando non residuino margini di discrezionalità.

Autovincolo

La discrezionalità può essere ulteriormente limitata dall'**autovincolo**, ossia dalla predeterminazione, da parte dell'amministrazione stessa, di criteri e parametri applicativi (ad es. criteri di valutazione nelle procedure concorsuali). Tali criteri vincolano l'azione amministrativa e garantiscono coerenza e imparzialità.

Il merito amministrativo

Il **merito** rappresenta l'area residua di scelta non coperta da vincoli giuridici. Esso attiene alla valutazione di opportunità tra più soluzioni tutte legittime. Il merito non è sindacabile dal giudice nella giurisdizione di legittimità, salvo i casi tassativi di giurisdizione estesa al merito (art. 7, co. 6, c.p.a.), nei quali il giudice può sostituirsi all'amministrazione. La distinzione tra legittimità e merito rileva:

1. nei controlli amministrativi (controllo di legittimità vs. controllo di merito);
2. nella giurisdizione amministrativa;
3. nella responsabilità amministrativa per danno erariale, ove vige il limite dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali (art. 1, l. 20/1994).

Valutazioni tecniche

Le valutazioni tecniche si riferiscono a giudizi fondati su conoscenze scientifiche o tecniche, richiesti dalla norma attributiva del potere. Esse si distinguono dalla discrezionalità amministrativa propriamente detta, poiché attengono all'accertamento del fatto e non alla ponderazione degli interessi. L'espressione "discrezionalità tecnica" è impropria: manca l'elemento volitivo tipico della discrezionalità amministrativa. Tradizionalmente, il sindacato giurisdizionale era limitato a un controllo estrinseco (illogicità, incongruenza). In tempi più recenti, il giudice ha ampliato l'intensità del controllo, verificando attendibilità e correttezza del criterio tecnico adottato. Valutazioni tecniche e discrezionalità possono coesistere nella medesima fattispecie (c.d. discrezionalità mista).

Meri accertamenti tecnici

I meri accertamenti tecnici riguardano fatti oggettivamente verificabili mediante strumenti tecnici, senza margini di opinabilità. Essi sono pienamente sindacabili dal giudice amministrativo. La discrezionalità amministrativa, dunque, costituisce lo spazio fisiologico di scelta riconosciuto all'amministrazione per la cura dell'interesse pubblico, ma trova limiti nei vincoli legali, nei principi dell'azione amministrativa e nel controllo giurisdizionale di legittimità.

L'interesse legittimo

L'interesse legittimo costituisce il termine soggettivo passivo del rapporto giuridico amministrativo ed è espressamente riconosciuto a livello costituzionale negli artt. 24, 103 e 113 Cost., quali norme in materia di tutela giurisdizionale.

La distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo conserva una rilevanza sistematica sotto un duplice profilo:

1. **criterio di riparto della giurisdizione** tra giudice ordinario (diritti soggettivi) e giudice amministrativo (interessi legittimi). La Corte costituzionale, con sent. n. 204/2004, ha riaffermato che il criterio soggettivo resta centrale, ammettendo l'attribuzione al giudice amministrativo di diritti soggettivi solo in ipotesi tassative, quando risultino connessi a un rapporto nel quale l'amministrazione agisce in veste autoritativa;
2. **ambito della responsabilità della pubblica amministrazione**, ampliato dalla sentenza Cass., Sez. Un., n. 500/1999, che ha riconosciuto la risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo.

La svolta della risarcibilità

La sentenza Cass., Sez. Un., n. 500/1999 ha segnato un mutamento decisivo, riconoscendo la risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo. La Corte costituzionale, con sent. n. 204/2004, ha chiarito che l'azione risarcitoria non tutela un autonomo diritto soggettivo, bensì costituisce una tecnica rimediale di tutela dell'interesse legittimo, che si affianca all'azione di annullamento.

Ne consegue che l'interesse legittimo non può più essere concepito come mera pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa, ma implica il collegamento con un **bene della vita** suscettibile di lesione.

Definizione e struttura

L'**interesse legittimo** costituisce il termine passivo del rapporto giuridico amministrativo. Si tratta di una situazione giuridica soggettiva dotata di pieno **rango costituzionale** (Artt. 24, 103, 113 Cost.), la cui distinzione rispetto al diritto soggettivo risponde a due esigenze fondamentali:

1. Il Riparto di Giurisdizione

La distinzione funge da criterio per incardinare la competenza giurisdizionale:

- **Giudice Ordinario (G.O.):** Competente per le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi.
- **Giudice Amministrativo (G.A.):** Competente per la tutela degli interessi legittimi.

Nota Giurisprudenziale: La **Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale** ha ribadito che il riparto non può basarsi meramente su "blocchi di materie" (criterio oggettivo), ma deve fondarsi sulla natura della situazione soggettiva lesa. Il G.A. può conoscere di diritti soggettivi solo in sede di **giurisdizione esclusiva**, e unicamente quando l'amministrazione agisce in veste di autorità.

2. La Risarcibilità del Danno: Storicamente, solo la lesione di un diritto soggettivo permetteva l'accesso al risarcimento del danno (ex art. 2043 c.c.). Tale dogma è stato scardinato dalla **Sentenza n. 500/1999 della Cassazione a Sezioni Unite**, che ha ammesso la risarcibilità degli interessi legittimi, superando l'immunità della P.A.

Evoluzione Dottrinale

Il concetto di interesse legittimo è il risultato di una lunga stratificazione interpretativa, nata per colmare il vuoto di tutela generato dalla Legge di Abolizione del Contenzioso Amministrativo (L. 2248/1865 all. E). Le principali teorie ricostruttive:

1. **Diritto fatto valere come interesse:** Si basava sul *petitum* (la richiesta di annullamento dell'atto), lasciando al privato la scelta della giurisdizione. Teoria superata dal criterio della *causa petendi* (la natura della situazione giuridica).
2. **Interesse di mero fatto:** Visione puramente processualistica; l'interesse legittimo era solo un presupposto per ricorrere in giudizio contro un atto illegittimo.
3. **Diritto alla legittimità degli atti:** Inteso come pretesa formale al rispetto delle norme. Critica: la legittimità non è un "bene della vita" autonomo.
4. **Diritto affievolito (o degradato):** Teoria secondo cui l'esercizio del potere amministrativo "degrada" il diritto soggettivo (es. proprietà) in interesse legittimo. Questa tesi riduceva drasticamente l'ambito di cognizione del G.O.
5. **Interesse occasionalmente protetto:** L'interesse del privato riceve tutela solo in via riflessa, in quanto la norma mira primariamente a proteggere l'interesse pubblico. Qui il "bene della vita" è mediato dalla discrezionalità amministrativa.

La Concezione Moderna: Sostanzialità e Partecipazione

La dottrina contemporanea, influenzata dalla **L. 241/1990** e dalla giurisprudenza costituzionale, ha spostato il baricentro dell'interesse legittimo dal potere dell'amministrazione al **bene della vita** del privato. L'interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva attiva, correlata all'esercizio del potere amministrativo, che conferisce al titolare poteri e facoltà volti a influire sul procedimento per acquisire o conservare un'utilità finale (bene della vita).

La Duplice Dimensione

- **Dimensione Passiva:** Una posizione di soggezione rispetto al potere d'imperio della P.A.
- **Dimensione Attiva:** Un complesso di facoltà partecipative (accesso agli atti, memorie, accordi

e x	a r t .	1 1	L .	2 4 1 / 9 0)	e	p r e t e s e	r i s a r c i t o r i e .
Caratteristica			Interesse Legittimo			Diritto Soggettivo	
Relazione col Potere			Correlato all'esercizio della potestà			Prescinde dall'esercizio del potere	
Protezione			Mediata dal corretto agire della P.A.			Immediata e diretta	
Giudice			Giudice Amministrativo			Giudice Ordinario	
Tutela Risarcitoria			Ammessa (dopo Sent. 500/99)			Sempre garantita	

Verso una "Diritto-soggettivazione"? Indica un processo dottrinale volto a eliminare la storica distinzione "ontologica" (di natura) tra diritto soggettivo e interesse legittimo, cercando di assorbire quest'ultimo nella categoria generale del diritto soggettivo. In parole semplici: si tenta di dimostrare che l'interesse legittimo non è una creatura aliena o "minore", ma solo una **variante particolare di diritto soggettivo**. Parte della dottrina propone di ricondurre l'interesse legittimo a un'articolazione del diritto soggettivo, paragonandolo alle **obbligazioni di mezzi** o ai **doveri di protezione**. In questa prospettiva, l'interesse legittimo sarebbe un "diritto di credito" avente ad oggetto una prestazione comportamentale (correttezza, buona fede, imparzialità) da parte della Pubblica Amministrazione.

Ecco i punti chiave per comprendere questa tesi:

1. Il superamento della distinzione "Autorità-Libertà": Tradizionalmente, il diritto soggettivo era visto come un'area di libertà assoluta del privato, mentre l'interesse legittimo era visto come una posizione di "soggezione" di fronte al potere autoritativo della P.A. La tesi della diritto-soggettivazione dice: **anche nel rapporto con il potere pubblico, il privato è titolare di una pretesa sostanziale**.
2. L'analogia con le "Obbligazioni di Mezzi": Per capire questo passaggio, pensa alla differenza tra un contratto d'appalto e una visita medica:
 - **Obbligazione di risultato:** Se chiedo a un muratore di costruirmi un muro, ho diritto al muro (risultato). Se il muro non c'è, c'è inadempimento.
 - **Obbligazione di mezzi (o di comportamento):** Se vado da un medico, non ho il "diritto alla guarigione" (che dipende da fattori imponderabili), ma ho il **diritto a che il medico agisca con perizia, diligenza e secondo scienza**.

L'interesse legittimo viene letto così: il privato non ha sempre il diritto al "bene finale" (es. vincere l'appalto), perché c'è la discrezionalità della P.A., ma ha un **diritto di credito** affinché la P.A. svolga il procedimento in modo corretto, imparziale e secondo buona fede.

3. I "Doveri di Protezione": Questa teoria attinge dal diritto civile (il cosiddetto "contatto sociale qualificato"). Si sostiene che, nel momento in cui il privato e la P.A. "entrano in contatto" in un procedimento:
 - Nasce una relazione specifica.

- In questa relazione, la P.A. ha dei **doveri di protezione** verso il privato (non deve danneggiarlo, deve informarlo, deve essere coerente).
- Se la P.A. viola questi doveri, non sta solo violando una norma pubblica, ma sta ledendo un **diritto soggettivo alla correttezza** del privato.

Perché è importante questa distinzione? Se l'interesse legittimo venisse totalmente "diritto-soggettivato":

1. **Scomparebbe il riparto di giurisdizione:** Non ci sarebbe più bisogno di due giudici diversi (G.O. e G.A.).
2. **La responsabilità sarebbe contrattuale:** La P.A. risponderebbe per inadempimento di un'obbligazione (con termini di prescrizione più lunghi, 10 anni anziché 5) e non solo per illecito extracontrattuale.

Gli interessi legittimi oppositivi e pretensivi

Questa distinzione rappresenta la **classificazione funzionale** più importante dell'interesse legittimo, poiché ne determina la dinamica nel procedimento, le tecniche di tutela processuale e le modalità di ristoro risarcitorio. Ecco la rielaborazione sistematica dei tuoi appunti, organizzata per punti di divergenza:

Natura e Dinamica Procedimentale

La differenza risiede nell'impatto del potere sulla sfera giuridica del privato e sulla direzione del flusso relazionale con la P.A.

Caratteristica	Interessi Legittimi Oppositivi	Interessi Legittimi Pretensivi
Effetto del potere	Restrittivo: incide negativamente su un bene già posseduto.	Ampliativo: mira ad acquisire un bene non ancora posseduto.
Esempio tipico	Espropriazione, Sanzione, Occupazione d'urgenza.	Autorizzazione, Concessione, Permesso di costruire.
Dinamica	Contrapposizione: il privato vuole bloccare l'azione (pretesa a un <i>non facere</i>).	Collaborazione: il privato stimola l'azione (pretesa a un <i>facere</i>).
Iniziativa	D'ufficio: l'amministrazione avvia il procedimento autonomamente.	D'istanza: il privato presenta una domanda (obbligo di provvedere ex Art. 2 L. 241/90).

La Tutela Giurisdizionale: Conservazione vs. Acquisizione

A seconda della categoria, cambia radicalmente il **bisogno di tutela** e, di conseguenza, il tipo di sentenza necessaria a soddisfarlo.

1. **Interessi Oppositivi** (Tutela Annulatoria): Il privato mira a **conservare** il bene. Se l'atto è illegittimo, l'**annullamento con efficacia retroattiva (*ex tunc*)** è di per sé soddisfacente: l'atto scompare, l'effetto restrittivo viene rimosso e il privato viene reintegrato nella situazione precedente (es. il terreno torna di proprietà del privato senza vincoli di esproprio).
2. **Interessi Pretensivi** (Tutela di Adempimento): Il privato mira ad **acquisire** il bene. L'annullamento del diniego non basta, perché il privato rimarrebbe a "mani vuote". È necessaria l'**Azione di Adempimento**: Prevista dal Codice del Processo Amministrativo (C.P.A.), permette al

giudice di condannare la P.A. a rilasciare il provvedimento richiesto, previo accertamento della spettanza del bene della vita.

3. **La Tutela Risarcitoria:** Il risarcimento interviene per coprire il pregiudizio che l'annullamento da solo non può riparare:

- **Negli interessi oppositivi:** Riguarda il **danno da occupazione/privazione**. Si risarcisce il mancato godimento del bene nel periodo in cui l'atto illegittimo è stato efficace (es. il mancato raccolto durante i mesi di esproprio illegittimo).
- **Negli interessi pretensivi:** Riguarda il **danno da ritardo o da diniego**. Si risarcisce il lucro cessante per non aver potuto avviare l'attività economica nel tempo stabilito (es. i guadagni persi per il ritardo nel rilascio di una licenza commerciale).

4. **I Provvedimenti "a Doppio Effetto" e il Rapporto Trilaterale:** Questa categoria complica lo schema binario introducendo una dinamica **trilaterale**. Si verifica quando un unico provvedimento produce simultaneamente:

- Un effetto **ampliativo** per un soggetto (Interesse Pretensivo).
- Un effetto **restrittivo** per un altro soggetto (Interesse Oppositivo).

Esempio: Il rilascio di un permesso di costruire (ampliativo per il richiedente) che toglie la veduta al vicino (restrittivo per il confinante). Conseguenze Processuali: In questi casi, il processo non è più "Privato vs. P.A.", ma vede l'ingresso di una terza figura necessaria: il **Controinteressato**.

- Il confinante (ricorrente) impugna il permesso.
- Il beneficiario del permesso (controinteressato) interviene in giudizio per difendere la legittimità dell'atto, affiancando la P.A. (resistente).

I criteri di distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi

L'individuazione del confine tra diritto soggettivo e interesse legittimo rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto amministrativo, essenziale per determinare se la controversia vada instaurata innanzi al Giudice Ordinario o al Giudice Amministrativo.

Natura della Norma Attributiva: Relazione vs Azione

Questo criterio si basa sulla struttura del precetto giuridico e sulla modalità di produzione dell'effetto.

- **Norme di Relazione:** Disciplinano i rapporti intersoggettivi tra P.A. e privato, delimitando le rispettive sfere giuridiche. Esse seguono lo schema **Norma-Fatto-Effetto**. L'effetto (il diritto) sorge automaticamente al verificarsi del fatto; l'atto della P.A. è solo ricognitivo. La violazione genera un **illecito** lesivo di un **Diritto Soggettivo**.
- **Norme di Azione:** Disciplinano le modalità di esercizio del potere pubblico per il perseguimento dell'interesse generale. Seguono lo schema **Norma-Fatto-Potere-Effetto**. L'effetto si produce solo tramite l'intermediazione del provvedimento (efficacia costitutiva). La violazione genera una **illegittimità** lesiva di un **Interesse Legittimo**.

Distinzione tra Potere Vincolato e Discrezionale

Il criterio si sposta sull'ampiezza della valutazione riservata all'Amministrazione.

- **Potere Discrezionale:** La norma non predetermina l'esito del procedimento, ma affida alla P.A. la comparazione tra gli interessi. Il privato non ha la certezza del "bene della vita", poiché la scelta è rimessa all'autorità. Qui la situazione è **sempre di interesse legittimo**.

- **Potere Vincolato:** La norma definisce rigidamente i presupposti per l'esercizio del potere. Il privato può compiere un "giudizio di spettanza" certo.
 - *Nota di cautela:* La giurisprudenza precisa che il potere vincolato non genera automaticamente un diritto soggettivo. Se il vincolo è posto nell'**interesse pubblico**, la situazione resta di **interesse legittimo**. Si ha diritto soggettivo solo se il vincolo è posto a **garanzia diretta** del privato.

Natura del Vizio: Cattivo Esercizio vs Carenza di Potere

Introdotta dalla **Cassazione (S.U. 1657/1949)**, questo criterio analizza l'esistenza stessa della potestà amministrativa.

A. Cattivo Esercizio del Potere: L'amministrazione ha il potere (fondamento legale), ma lo esercita male (viziato).

- **Vizi:** Incompetenza, Violazione di legge, Eccesso di potere.
- **Conseguenza:** Il provvedimento è annullabile. La situazione giuridica è l'**Interesse Legittimo**.

B. Carenza di Potere: L'amministrazione agisce in assenza totale di potere. L'atto è un "nudo fatto", inidoneo a incidere (degradare) il diritto soggettivo.

- **Carenza in astratto:** Manca del tutto la norma che conferisce il potere.
- **Carenza in concreto:** Esiste la norma, ma manca un presupposto essenziale (es. esproprio senza dichiarazione di pubblica utilità).
- **Conseguenza:** Il provvedimento è **nullo** (o inesistente). La situazione resta di **Diritto Soggettivo**.

Focus: I Diritti "Indegradabili"

Esiste una categoria di diritti soggettivi che la giurisprudenza definisce "**resistenti**" o **indegradabili**. Si tratta di diritti legati a valori supremi della Costituzione (salute, ambiente) che non possono essere compressi dall'autorità amministrativa. In questi casi, anche di fronte a un potere apparentemente discrezionale, la giurisdizione resta del G.O. (sebbene la tendenza recente dei "blocchi di materie" e della giurisdizione esclusiva stia parzialmente erodendo questa visione).

Criterio	Diritto Soggettivo	Interesse Legittimo
Schema Normativo	Norma-Fatto-Effetto	Norma-Fatto-Potere-Effetto
Tipologia di Potere	Assente o vincolato (a tutela del	Discrezionale o vincolato (a tutela
Vizio dell'Atto	Carenza di potere (Nullità)	Cattivo esercizio (Annullabilità)
Giurisdizione	Giudice Ordinario	Giudice Amministrativo

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi

L'Accesso "Documentale" (Legge 241/1990) è la forma classica di accesso, legata a una specifica posizione del richiedente. Tipologie funzionali

- **Accesso Procedimentale (Endoprocedimentale):** Strumento di partecipazione informata (Art. 10). Serve a "giocare ad armi pari" con la P.A. durante la formazione del provvedimento.
- **Accesso Non Procedimentale (Esoprocedimentale):** Esercitato autonomamente (Artt. 22 ss.) su documenti già detenuti dalla P.A., a prescindere da un procedimento in corso.

Il problema della qualificazione giuridica

Sebbene la rubrica della legge parli di "diritto", la dottrina e la giurisprudenza sono divise:

- **Tesi del Diritto Soggettivo:** Si basa sul tenore letterale della norma e sul fatto che, sussistendo i presupposti di legge, la P.A. *deve* esibire i documenti.
- **Tesi dell'Interesse Legittimo (Prevalente):** Si fonda sulla presenza di un **potere di valutazione** in capo alla P.A. L'amministrazione, infatti, deve bilanciare l'interesse del richiedente con la **riservatezza di terzi** (controinteressati) e con i limiti tassativi (Segreto di Stato, ordine pubblico, ecc.).
- **Rilevanza Processuale:** Se lo consideriamo interesse legittimo, il diniego va impugnato nel termine decadenziale stretto di **30 giorni** (rito speciale ex art. 116 C.P.A.), non potendo attendere i tempi lunghi dei diritti.

Le Nuove Frontiere: L'Accesso Civico (FOIA), il D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D.Lgs. 97/2016) ha introdotto il modello *Freedom of Information Act* (FOIA) in Italia, spostando il baricentro verso il **diritto soggettivo pieno**. Distinzione tra Accesso 241/90 e Accesso Civico

Caratteristica	Accesso Documentale (L. 241/90)	Accesso Civico (D.Lgs. 33/13)
Legittimazione	Soggetto con interesse "diretto, concreto, attuale"	Chiunque (Nessuna limitazione)
Motivazione	Obbligatoria (deve spiegare il nesso col documento)	Non richiesta
Finalità	Tutela di situazioni giuridiche proprie	Controllo diffuso e trasparenza democratica
Natura Giuridica	Discussa (Interesse Legittimo/Diritto)	Diritto Soggettivo

Le sottospecie di Accesso Civico:

1. **Semplice:** Riguarda documenti che la P.A. *aveva l'obbligo di pubblicare*. È una reazione all'inadempimento della P.A.
2. **Generalizzato:** Riguarda dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Anche qui operano limiti (Art. 5-bis) a tutela di interessi pubblici (sicurezza, difesa) e privati (dati personali), ma la platea dei richiedenti rimane universale.

Altre Ipotesi di "Diritto" in senso stretto: oltre all'accesso civico, esistono casi in cui la qualificazione come **diritto soggettivo** è pacifica:

- **Ambito Ambientale:** Accesso libero a chiunque per le informazioni sullo stato dell'ambiente (D.Lgs. 195/2005).

- **Ambito Enti Locali:** Il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di ottenere informazioni per il mandato (Art. 43 TUEL). In questo caso, il diritto è funzionale a una pubblica funzione e non può essere negato per ragioni di riservatezza, salvo casi estremi.

L'incertezza sulla qualificazione dell'accesso (Diritto vs Interesse) nasce dalla **discrezionalità** che la P.A. esercita nel bilanciamento tra trasparenza e segretezza. Mentre l'accesso civico tende al modello del diritto soggettivo universale, l'accesso della L. 241/90 rimane ancorato a una dimensione più "autoritativa", dove il giudice amministrativo opera in sede di **giurisdizione esclusiva** proprio per risolvere i dubbi sulla natura della situazione lesa.

Interessi di fatto, diffusi e collettivi

1. **Interesse di Fatto vs Interesse Legittimo:** Il punto di rottura tra ciò che è tutelabile e ciò che non lo è si fonda su due "filtri" fondamentali:

- **Criterio della Differenziazione:** Per agire in giudizio non puoi essere un *quisque de populo* (uno qualunque). Devi trovarti in una posizione specifica. Il criterio principe è la **vicinitas** (es. abiti vicino a dove sorgerà la discarica, quindi il tuo interesse è diverso da quello di chi abita a 100 km).
- **Criterio della Qualificazione:** Una volta differenziato, quell'interesse deve essere "preso in considerazione" da una norma che attribuisce il potere alla P.A. Se la norma mira solo all'efficienza interna dell'ufficio, il tuo è un mero **interesse di fatto**.

Interessi Diffusi e Interessi Collettivi

Entriamo nel campo dei cosiddetti **interessi superindividuali**. Interessi Diffusi (Interessi "Adespoti") Sono interessi che appartengono a tutti e a nessuno in particolare (es. aria pulita, tutela del paesaggio).

- **Caratteristiche:** Riguardano beni **non rivali** (se respiro io, respiri anche tu) e **non escludibili** (non si può impedire a qualcuno di godere del paesaggio).
- **Problema:** Essendo di tutti, chi ha il diritto di fare causa alla P.A.? Se tutti potessero ricorrere, i tribunali esploderebbero (**azione popolare**, ammessa solo in casi rarissimi).

Interessi Collettivi: È la soluzione giuridica per dare "voce" agli interessi diffusi. L'interesse viene "personalizzato" attraverso un ente esponenziale (Associazioni, Sindacati, Ordini professionali).

- **Differenza:** Mentre l'interesse diffuso è amorfo, quello collettivo fa capo a un **gruppo organizzato**.
- **Legittimazione ex lege:** In settori critici (es. Ambiente), lo Stato riconosce per legge ad alcune associazioni (es. WWF, Legambiente) il potere di ricorrere al G.A. per conto della collettività.

Interessi Individuali Omogenei (Class Action)

Qui la logica cambia: non siamo di fronte a un interesse "comune" per natura (come l'ambiente), ma a tanti **interessi individuali identici** lesi dallo stesso evento (es. un guasto alla rete elettrica che colpisce un intero quartiere). Nel sistema delle situazioni giuridiche soggettive, gli **interessi individuali omogenei** (definiti anche isomorfi) rappresentano una categoria concettuale distinta rispetto agli interessi diffusi e collettivi. Sebbene essi emergano in contesti di massa, la loro natura rimane squisitamente individuale. A differenza dell'interesse diffuso (che è *adespoto*, ovvero privo di un titolare specifico e riferibile all'intera collettività per beni non escludibili come l'ambiente), l'interesse omogeneo è la somma di tante posizioni giuridiche singole, autonome e scindibili.

Il tratto distintivo è l'**omogeneità della lesione**: una pluralità di soggetti subisce un pregiudizio identico derivante dal medesimo **fatto plurioffensivo** (un'attività illegittima della P.A. o di un gestore di pubblico servizio). Si pensi all'interruzione prolungata di un servizio a rete (energia, internet) o all'applicazione di una clausola contrattuale nulla a un'intera platea di utenti. In questi casi, ogni individuo vanta un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, ma l'esiguità del danno individuale (c.d. *danno polverizzato*) rende spesso antieconomico il ricorso giurisdizionale singolo. Per rimediare a questa inefficienza del sistema processuale, l'ordinamento ha approntato due diverse tipologie di *Class Action*:

- **La Class Action Privatistica (Art. 840-bis c.p.c.):** Disciplina l'azione volta all'accertamento della responsabilità e alla condanna al **risarcimento del danno** o alle restituzioni. È lo strumento tipico quando la lesione riguarda diritti soggettivi scaturiti da rapporti contrattuali con gestori di servizi pubblici o imprese.
- **La Class Action Pubblica (D.Lgs. 198/2009):** È lo strumento specifico per la tutela contro l'**inefficienza della P.A.** e dei concessionari di pubblici servizi. Qui la logica non è quella del ristoro patrimoniale, bensì quella **ripristinatoria**.

Il legislatore, con il D.Lgs. 198/2009, ha introdotto un rimedio volto a garantire il corretto svolgimento della funzione amministrativa e l'erogazione dei servizi secondo standard qualitativi prestabiliti.

- **L'Oggetto del Giudizio:** L'azione può essere esperita per la violazione di termini, la mancata adozione di atti amministrativi generali (non normativi) obbligatori, o la violazione di standard di qualità e continuità del servizio.
- **La Fase Pre-processuale (La Diffida):** Il ricorso è procedibilmente condizionato dalla notifica di una **diffida ad adempiere**. Il ricorrente deve intimare alla P.A. di eliminare l'inefficienza entro un termine di 90 giorni. Solo l'infruttuoso decorso di questo termine apre la via al ricorso innanzi al Giudice Amministrativo.
- **La Sentenza di Condanna:** Il giudice, accertata la lesione di un interesse omogeneo, non può condannare la P.A. al risarcimento, ma ordina l'adozione delle misure idonee a ripristinare la funzionalità del servizio o il rispetto degli standard. La sentenza agisce dunque sulla **performance** dell'apparato pubblico.

Nuovi rimedi: L'efficienza della P.A.

Il **D.Lgs. 198/2009** ha introdotto una forma speciale di ricorso collettivo contro la P.A. Non serve a ottenere un risarcimento (per quello c'è l'azione risarcitoria ordinaria), ma a **obbligare la P.A. a ripristinare il corretto funzionamento dei servizi** (es. uffici postali sempre chiusi, mancata adozione di piani obbligatori). **Punto chiave:** Mentre nell'interesse legittimo classico cerchi di "annullare" un atto, qui cerchi di "correggere" un comportamento inefficiente o un'omissione dell'amministrazione. Certamente. Questa parte dei tuoi appunti si focalizza sulla cosiddetta **Class Action Pubblica** (o ricorso per l'efficienza delle amministrazioni), uno strumento che segna il passaggio da una tutela prettamente "statica" (annullamento di atti) a una tutela "dinamica" (ripristino degli standard di servizio).

Il Ricorso per l'Efficienza della P.A. (D.Lgs. 198/2009)

A differenza della *class action* civilistica, che mira al risarcimento del danno, l'azione prevista dal decreto 198/2009 ha una finalità esclusivamente **ripristinatoria**. L'obiettivo è obbligare l'amministrazione (o il concessionario di pubblici servizi) a conformarsi agli standard di qualità e continuità dichiarati.

1. I Presupposti dell'Azione: Il ricorso può essere esperito in tre ipotesi tassative di "malfunzionamento":

- **Violazione di termini:** Inosservanza degli obblighi contenuti nelle Carte di servizio.
- **Violazione di standard qualitativi:** Mancato raggiungimento dei livelli di prestazione stabiliti per quel determinato servizio.
- **Omessa adozione di atti amministrativi generali:** Quando la P.A. non emana atti (non aventi contenuto normativo) entro i termini stabiliti, impedendo l'erogazione dei servizi.

2. Legittimazione Ad Agire: La platea dei soggetti legittimati è ampia, a conferma della natura "collettiva" dell'interesse:

- **Singoli titolari** di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei.
- **Associazioni o comitati** a tutela degli interessi dei propri associati. Il presupposto è la derivazione di un **pregiudizio diretto, concreto e attuale** dalla lesione degli standard.

3. La Procedura: La Diffida Preventiva: L'azione giudiziale è preceduta da un passaggio obbligatorio: la **diffida**.

- Il ricorrente deve notificare all'amministrazione l'invito a rimediare entro un termine (non inferiore a 90 giorni).
- Solo se la P.A. non provvede entro tale termine, è possibile proporre il ricorso al Giudice Amministrativo (entro un anno dalla scadenza).

4. La Sentenza e i suoi Limiti: Il G.A., se accoglie il ricorso, emana una **sentenza di condanna** con cui ordina alla P.A. di porre rimedio all'inefficienza entro un termine congruo.

- **Cosa non può fare il giudice:** Non può condannare al risarcimento del danno.
- **Cosa può fare il giudice:** Può ordinare misure organizzative per ripristinare il servizio, ferma restando l'autonomia della P.A. nelle scelte di dettaglio (rispetto del nucleo della discrezionalità).

I principi generali

Il diritto amministrativo contemporaneo non è più un sistema di comandi unilaterali, ma un equilibrio complesso retto da principi che trasformano l'autorità in servizio. Tutto inizia con una domanda fondamentale: **chi deve decidere?** La risposta risiede nel **principio di sussidiarietà**. Nella sua dimensione **verticale**, l'ordinamento stabilisce che il potere deve essere amministrato dal livello di governo più vicino al cittadino, ovvero il Comune. Stato e Regioni intervengono solo se l'ente locale non risulta adeguato, rispettando così i criteri di **differenziazione e adeguatezza** organizzativa. Ma la gestione del bene comune non è un monopolio pubblico: la **sussidiarietà orizzontale** invita la P.A. a fare un passo indietro per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali quando questi possono curare l'interesse generale con maggiore efficacia. Una volta stabilito chi agisce, occorre definire **come** si debba agire. Il baricentro del sistema si è spostato dalla "legalità formale" all'**amministrazione di risultato**. Non basta che un ufficio rispetti la legge, deve essere "performante". L'attività deve quindi essere guidata dall'**efficienza** (ottimizzare le risorse per il massimo rendimento) e dall'**efficacia** (raggiungere effettivamente gli obiettivi prefissati). In questo contesto, l'amministrazione non è più un luogo oscuro, ma una **"casa di vetro"**: i principi di **pubblicità e trasparenza** permettono oggi un controllo diffuso, trasformando ogni cittadino in un potenziale supervisore dell'utilizzo delle risorse pubbliche. Il cuore pulsante di questo sistema è però l'**esercizio della discrezionalità**. Quando la P.A. ha margine di scelta, deve muoversi entro binari etici e logici rigorosi. L'**imparzialità** impedisce favoritismi, mentre la **proporzionalità** funge da test di legittimità: ogni misura deve essere **idonea** allo scopo, **necessaria** (ovvero la meno restrittiva tra quelle possibili) e **adeguata** rispetto al sacrificio richiesto al privato. A protezione del cittadino intervengono poi la **ragionevolezza** (coerenza logica dell'agire) e il **legittimo affidamento**, che impedisce alla P.A. di tradire arbitrariamente la fiducia che un soggetto ha riposto in un suo comportamento precedente. E dove la scienza non offre certezze — come in campo ambientale o sanitario — il **principio di precauzione** abilita l'autorità ad agire preventivamente per scongiurare rischi potenziali. Tutti questi valori convergono infine nel **procedimento amministrativo**, che è la "grammatica" del rapporto tra Stato e individuo. Qui il **contraddittorio** garantisce a chiunque il diritto di essere ascoltato prima di subire un effetto negativo, mentre la **certezza dei tempi** trasforma il fattore

cronologico in un vero e proprio bene della vita: il cittadino non può essere lasciato nell'incertezza. Ogni decisione finale, il provvedimento, deve essere sorretto da una solida **motivazione**, che ne permetta la **sindacabilità** davanti a un giudice. Il rapporto si chiude, idealmente, con un patto di **correttezza e buona fede**: una leale collaborazione che obbliga la P.A. a comportarsi con onestà e il cittadino a agire con diligenza, trasformando il vecchio conflitto tra autorità e libertà in un moderno rapporto giuridico paritario. L'allocazione del potere: Chi decide? Il primo pilastro riguarda la distribuzione delle funzioni, dominato dal **principio di sussidiarietà**. Nella sua dimensione **verticale** (Art. 118 Cost. e Art. 5 TUE), la regola aurea è la vicinanza: il potere appartiene al Comune, il livello più prossimo al cittadino. Stato e Regioni intervengono solo se l'ente locale non è adeguato a garantire l'esercizio unitario, rispettando i criteri di **adeguatezza** (capacità organizzativa) e **differenziazione** (caratteristiche del territorio). Accanto a questa, la **sussidiarietà orizzontale** apre le porte alla società civile: la P.A. non deve occuparsi di tutto, ma deve favorire l'iniziativa autonoma dei cittadini per attività di interesse generale. L'azione e il risultato: Come agisce la P.A.? Una volta assegnato il potere, la P.A. deve agire secondo logiche di **"amministrazione di risultato"**. Non basta più la semplice obbedienza formale alla legge; l'azione deve essere **efficace** (raggiungere gli obiettivi) ed **efficiente** (ottimizzare le risorse/economicità). Questo "ciclo delle performance" (D.Lgs. 150/2009) trasforma l'amministrazione in una struttura orientata al cittadino, la cui attività deve svolgersi in una **"casa di vetro"**. La **trasparenza** e la **pubblicità** (D.Lgs. 33/2013) garantiscono infatti un controllo diffuso sull'uso delle risorse e sul perseguimento dei fini istituzionali. I limiti alla scelta: La gestione della discrezionalità; Quando la legge lascia alla P.A. un margine di scelta (discrezionalità), intervengono principi etici e logici per evitare l'arbitrio:

- **Imparzialità**: L'obbligo di evitare favoritismi, garantito dalla separazione tra indirizzo politico e gestione tecnica.
- **Proporzionalità**: La misura scelta deve essere **idonea** allo scopo, **necessaria** (la meno restrittiva possibile per il privato) e **adeguata** (il sacrificio del singolo non deve superare il beneficio pubblico).
- **Ragionevolezza e Precauzione**: L'agire pubblico deve essere logico e coerente; in caso di rischi per la salute o l'ambiente, la P.A. deve agire preventivamente anche senza certezze scientifiche assolute.
- **Legittimo Affidamento**: La P.A. non può tradire improvvisamente la fiducia che ha ingenerato nel privato con i suoi atti o comportamenti precedenti.

Il "giusto procedimento" e l'atto finale: Infine, il rapporto tra P.A. e privato si cristallizza nel procedimento. Qui regnano il **contraddittorio** (diritto di essere ascoltati) e la **certezza dei tempi** (Art. 2 L. 241/90): il tempo è un "bene della vita" e l'amministrazione non può lasciarlo scorrere inutilmente. L'atto finale, il provvedimento, deve essere sempre sorretto da una **motivazione** chiara che ne spieghi l'iter logico, rendendolo così **sindacabile** (Art. 113 Cost.) davanti a un giudice. Il tutto è avvolto dal principio di **correttezza e buona fede**: un patto di lealtà reciproca che obbliga la P.A. a non deludere le aspettative e il privato a collaborare diligentemente con l'autorità.

IL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento amministrativo rappresenta l'espressione massima del potere esecutivo: è l'atto con cui la Pubblica Amministrazione trasforma le previsioni astratte della legge in comandi concreti e unilaterali. Se la legge è la norma generale e la sentenza è la decisione su una lite, il **provvedimento** è lo strumento con cui lo Stato interviene attivamente nella realtà per curare l'interesse pubblico.

1. La Natura del Provvedimento: A differenza dei contratti tra privati, dove serve l'accordo tra le parti per modificare le reciproche sfere giuridiche, il provvedimento è un atto **unilaterale**. L'amministrazione decide e la sua volontà produce effetti direttamente nella sfera del privato, anche senza o contro il consenso di quest'ultimo. Questo potere non è però assoluto, ma è strettamente regolato dalla Legge 241/1990, che ne definisce il regime giuridico basato su due cardini fondamentali: la **tipicità** e l'**imperatività**.

2. Il Regime della Tipicità e Nominatività: Il principio di legalità impone che la P.A. non possa inventarsi nuovi poteri. Mentre un privato può stipulare contratti "atipici" (non previsti dal codice civile, purché leciti), l'amministrazione può emanare solo i provvedimenti espressamente previsti dalla legge.
- **Tipicità:** La norma stabilisce sia il **fine** da perseguire, sia lo **strumento** giuridico da utilizzare.
 - **Nominatività:** L'amministrazione può utilizzare solo gli schemi di provvedimento che hanno un "nome" e una disciplina nel sistema legislativo.
 - **Deroghe:** L'unica parziale eccezione è costituita dalle **ordinanze contingibili e urgenti** (es. per emergenze sanitarie o di sicurezza), dove la legge non predetermina tutto il contenuto dell'atto, lasciando spazio all'autorità per affrontare l'urgenza.
3. L'Imperatività (o Autoritarità): L'imperatività è la capacità del provvedimento di imporre le proprie determinazioni al destinatario, operando una modifica unilaterale della sua sfera giuridica. È qui che emerge la **dimensione verticale** del rapporto Stato-Cittadino. Punti chiave dell'imperatività:
1. **Indipendenza dalla Validità:** Anche un atto illegittimo (viziato) è imperativo e produce effetti finché non viene annullato dal Giudice o dalla stessa P.A. L'unica eccezione è l'**atto nullo** (ex art. 21-septies), che non ha forza imperativa e non produce alcun effetto.
 2. Rapporto con gli Interessi Legittimi:
 - **Negli interessi oppositivi** (es. esproprio), l'imperatività è evidente: il privato subisce una restrizione (soggezione) a prescindere dalla sua volontà.
 - **Negli interessi pretensivi** (es. richiesta di una licenza), l'unilateralità rimane. Anche se il privato "chiede" l'atto con un'istanza, l'effetto ampliativo non nasce da un accordo (come in un contratto), ma è prodotto esclusivamente dalla determinazione unilaterale della P.A.
 3. **Superamento dell'unilateralità:** Il carattere unilaterale può essere attenuato dagli **accordi (art. 11 L. 241/90)**, con i quali P.A. e privato concordano il contenuto discrezionale del provvedimento, introducendo una logica consensuale nel rapporto.

L'esecutorietà e l'efficacia

Con l'esecutorietà entriamo nella fase più "concreta" del diritto amministrativo: non si tratta più solo di produrre effetti sulla carta (imperatività), ma di tradurre quegli effetti nel mondo materiale, anche contro la volontà del privato. 1. L'Esecutorietà: Il Potere di Autotutela Esecutiva L'**art. 21-ter della L. 241/1990** definisce l'esecutorietà come la capacità della P.A. di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nati da un provvedimento, senza dover chiedere il permesso a un giudice.

- **Deroga al Diritto Civile:** Se un privato non paga un debito, il creditore deve fare causa e ottenere un titolo esecutivo dal giudice. La P.A., invece, agisce in **autotutela**: è lei stessa a creare il titolo e a portarlo a esecuzione (es. abbattere un muro abusivo con i propri mezzi se il proprietario non lo fa).
- **Differenza dall'Imperatività:** * L'**Imperatività** agisce sul piano giuridico (cambia la tua situazione di diritto, es. da proprietario a espropriato). L'**Esecutorietà** agisce sul piano materiale (ti toglie fisicamente il bene o demolisce un manufatto).

Il Principio di Legalità e la Diffida

Oggi l'esecutorietà non è più una "presunzione" astratta, ma è soggetta a limiti rigorosi:

- **Riserva di legge:** La P.A. può agire coattivamente solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. Non è un potere generico di ogni atto.
- **La Diffida:** Prima di usare la forza o intervenire d'ufficio, la P.A. deve inviare una **diffida**. È l'ultimo avviso: si intima al privato di adempiere, indicando termini e modalità, offrendogli un'ultima chance di collaborazione.

Efficacia, Esecutività ed Esecutorietà: è fondamentale non confondere questi tre termini, che rappresentano i tre "gradini" del provvedimento:

- **Efficacia (Art. 21-bis):** È l'idoneità dell'atto a produrre effetti. I provvedimenti che limitano la sfera del privato sono **atti recettizi**: producono effetti solo quando vengono comunicati al destinatario. *Eccezione:* Gli atti urgenti o cautelari sono efficaci subito, a prescindere dalla notifica.
- **Esecutività (Art. 21-quater):** Una volta efficace, il provvedimento deve essere eseguito immediatamente. L'esecutività è l'obbligo di dar corso all'atto (può essere sospesa o differita dalla P.A. per gravi motivi).
- **Esecutorietà (Art. 21-ter):** È la fase (eventuale) dell'intervento forzoso della P.A. se il privato non rispetta l'esecutività dell'atto.

Provvedimenti che non richiedono esecuzione come hai giustamente notato, l'esecutività non riguarda tutti gli atti **provvedimenti "auto-esecutivi"**: Sono quelli in cui l'effetto giuridico soddisfa già l'interesse pubblico. Ad esempio, un'autorizzazione commerciale: una volta che il privato ce l'ha, l'interesse pubblico è soddisfatto dalla regolarizzazione dell'attività. Non c'è bisogno di attività materiali della P.A. per "eseguirla".

Imperatività

L'**imperatività** (o autoritarietà) è il tratto distintivo per eccellenza del provvedimento amministrativo, quello che ne segna la distanza più netta rispetto ai negozi di diritto privato. L'imperatività consiste nell'idoneità del provvedimento amministrativo a **produrre effetti giuridici in modo unilaterale**, modificando la sfera soggettiva del destinatario a prescindere dal suo consenso. Mentre nel diritto privato l'effetto giuridico nasce dall'accordo (autonomia negoziale), nel diritto amministrativo l'effetto scaturisce dall'esercizio di una potestà pubblica (autoritarietà). L'imperatività manifesta la **sovraordinazione** della Pubblica Amministrazione rispetto al privato. Tale asimmetria è giustificata dalla necessità di far prevalere l'interesse pubblico, individuato dalla norma, sugli interessi particolari.

- **Negli interessi legittimi oppositivi** (es. espropriazione, sanzione), l'imperatività agisce contro la volontà del privato, che si trova in una posizione di **soggezione**.
- **Negli interessi legittimi pretensivi** (es. concessione, autorizzazione), l'imperatività permane: anche se l'atto è sollecitato dal privato, l'effetto ampliativo non nasce da un incontro di volontà (contratto), ma dalla determinazione unilaterale dell'autorità che "concede" il bene della vita richiesto.

Un punto cardine della teoria del provvedimento è che l'imperatività **non presuppone la validità dell'atto**.

- **L'atto illegittimo** (annullabile per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge) è comunque imperativo: esso produce i suoi effetti e incide sulla sfera del privato finché non interviene l'annullamento (da parte del giudice o in autotutela).
- **L'atto nullo** (ex art. 21-septies L. 241/90) è l'unico caso in cui l'imperatività viene meno. Poiché la nullità deriva da vizi gravissimi (mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di

attribuzione), l'atto non è in grado di degradare il diritto soggettivo del privato, che può dunque "resistere" alla pretesa amministrativa.

Il carattere autoritativo del provvedimento ha subito una parziale evoluzione con l'introduzione dell'**amministrazione consensuale**. L'Art. 11 della Legge 241/1990 permette infatti alla P.A. di concludere **accordi con gli interessati** al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. In questo caso, l'imperatività viene "mediata" dal consenso, pur rimanendo nell'alveo del diritto pubblico e del perseguimento del fine legislativo.

Inoppugnabilità

L'**inoppugnabilità** rappresenta il punto di chiusura del regime di stabilità del provvedimento amministrativo. Se l'imperatività permette all'atto di produrre effetti anche se viziato, l'inoppugnabilità impedisce che tali effetti possano essere messi in discussione dal privato dopo un certo periodo di tempo. L'inoppugnabilità (o incontestabilità) è la caratteristica del provvedimento amministrativo che ne sancisce l'attitudine a divenire definitivo e non più contestabile in sede giurisdizionale. Tale istituto non mira alla protezione dell'atto in sé, ma risponde a un'esigenza superiore di **certezza del diritto** e di stabilità degli assetti giuridici determinati dall'azione amministrativa. A differenza dei rapporti di diritto privato, dove l'azione di annullamento del contratto è soggetta a un termine prescrizione lungo (cinque anni) e l'azione di nullità è imprescrittibile, nel diritto amministrativo i termini sono estremamente brevi e di natura **decadenziale**. Il superamento di tali termini preclude al privato la possibilità di adire il Giudice Amministrativo:

- **Azione di annullamento:** Deve essere proposta entro il termine perentorio di **60 giorni** (art. 29 c.p.a.). È il termine "classico" che garantisce che la validità di un atto non resti incerta per un tempo eccessivo.
- **Azione di nullità:** Pur riguardando vizi più gravi, è soggetta a un termine di **180 giorni** (art. 31, comma 4, c.p.a.), a testimonianza del fatto che anche la nullità amministrativa non può restare azionabile all'infinito.
- **Azione risarcitoria:** Se proposta in via autonoma, il termine è di **120 giorni** (art. 30 c.p.a.).

L'Acquiescenza: L'inoppugnabilità per comportamento del privato

L'atto può divenire inoppugnabile anche prima della scadenza dei termini qualora il destinatario ponga in essere l'**acquiescenza**. Questa consiste in una manifestazione di volontà, espressa o tacita (*per facta concludentia*), con cui il privato accetta gli effetti del provvedimento. Perché si configuri acquiescenza, è necessario che il comportamento sia univoco e che il soggetto abbia piena conoscenza del contenuto dell'atto e della sua lesività. In tal caso, il privato decade dal diritto di ricorrere poiché il suo comportamento è considerato incompatibile con la volontà di contestare l'atto.

L'asimmetria del rapporto: Il potere di autotutela

L'aspetto più critico dell'inoppugnabilità risiede nell'asimmetria tra P.A. e cittadino. Mentre l'inoppugnabilità "blinda" l'atto contro le contestazioni del privato, essa non vincola allo stesso modo l'Amministrazione. La P.A., infatti, conserva il potere di **autotutela decisoria**, potendo intervenire d'ufficio sull'atto inoppugnabile attraverso:

- **Annullamento d'ufficio (Art. 21-nonies L. 241/90):** Per motivi di legittimità, entro un termine ragionevole (comunque non superiore a 12 mesi per i provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici).
- **Revoca (Art. 21-quinquies L. 241/90):** Per motivi di merito o mutamento dell'interesse pubblico, con efficacia *ex nunc*.

Si configura così una **stabilità unilaterale**: il rapporto è stabile per il privato (che non può più ricorrere), ma resta precario per la P.A., che può ancora rimuovere l'atto nell'esercizio della sua funzione di cura dell'interesse pubblico.

Gli Elementi Strutturali del Provvedimento Amministrativo

Il provvedimento amministrativo, pur essendo espressione di una potestà unilaterale, presenta una **struttura composta da elementi essenziali** la cui assenza o vizio incide direttamente sulla validità dell'atto. Ai sensi dell'**art. 21-septies l. 241/1990**, la mancanza degli elementi essenziali ne determina la **nullità**, sebbene il legislatore non ne abbia fornito un elenco tassativo, lasciando all'interprete il compito di ricostruirne il contenuto.

1. Il Profilo Soggettivo e la Volontà

- **Soggetto:** L'atto deve promanare da un organo investito della relativa competenza. Solitamente si tratta di una Pubblica Amministrazione, ma la qualità di "autorità amministrativa" può essere riconosciuta anche a soggetti privati (concessionari di pubblici servizi) quando esercitano poteri autoritativi o sono tenuti a procedure ad evidenza pubblica.
- **Volontà:** Va intesa in senso **oggettivato**, ovvero come "volontà procedimentale". Non rileva lo stato psichico del funzionario (volontà psicologica), bensì la determinazione che emerge dall'iter istruttorio. Per tale ragione, i vizi del consenso tipici del diritto civile non determinano l'annullabilità diretta, ma rilevano solo indirettamente come figure sintomatiche di **eccesso di potere**.

2. L'Oggetto e il Contenuto

- **Oggetto:** È il termine passivo su cui incidono gli effetti giuridici (una cosa, un'attività o una situazione soggettiva). Requisito essenziale è che l'oggetto sia **determinato o determinabile**.
- **Contenuto:** Rappresenta la parte dispositiva dell'atto (ciò che la P.A. ordina, permette o certifica). Può essere vincolato o discrezionale e includere elementi accidentali (condizioni, termini). A differenza del contratto, nel provvedimento la "causa" non ha rilievo autonomo poiché i fini sono già tipizzati dalla legge; assumono invece rilievo i **motivi**, intesi come le ragioni di interesse pubblico perseguite.

3. La Forma e la Digitalizzazione: Di norma è richiesta la **forma scritta ad substantiam**, sebbene siano ammesse forme orali in casi specifici (es. comandi di polizia o proclamazioni di voto). Oggi, il sistema è governato dal **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**, che equipara i documenti informatici e le firme digitali alla forma scritta tradizionale, favorendo la dematerializzazione dell'azione amministrativa.

L'Obbligo di Motivazione (Art. 3 l. 241/1990)

La motivazione costituisce il presupposto logico-giuridico fondamentale dell'atto, distinguendolo sia dall'attività legislativa che da quella negoziale. Essa deve enunciare i **presupposti di fatto** e le **ragioni giuridiche** che hanno determinato la decisione, in coerenza con le risultanze dell'istruttoria. La motivazione adempie a una triplice funzione:

1. **Trasparenza:** Consente al cittadino di conoscere il "perché" delle scelte pubbliche.
2. **Interpretazione:** Agevola la comprensione del contenuto del provvedimento.
3. **Garanzia Giurisdizionale:** Permette al Giudice Amministrativo di ricostruire l'iter logico della P.A., rendendo possibile il sindacato sull'eccesso di potere.

Tipologie e Limiti

1. **Motivazione per *relationem*:** È legittimo il rinvio ad un altro atto risultante dal procedimento, purché quest'ultimo sia indicato e reso disponibile all'interessato.

2. **Motivazione sintetica:** Ammessa in caso di domande manifestamente inammissibili o infondate.
3. **Provvedimenti vincolati vs discrezionali:** Nei primi la motivazione può limitarsi alla verifica dei presupposti di legge; nei secondi è invece essenziale per giustificare il bilanciamento tra gli interessi operato dall'amministrazione.
4. **Esclusioni:** L'obbligo è escluso per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale (art. 3, comma 2).

Secondo il **principio della stabilità degli effetti**, se un provvedimento è sorretto da una pluralità di ragioni autonome (atto plurimotivato), l'eventuale illegittimità di una sola di esse non conduce all'annullamento qualora le altre siano sufficienti a giustificare la decisione (c.d. **prova di resistenza**).

Provvedimenti limitativi

I **provvedimenti limitativi** della sfera giuridica, ovvero quegli atti con cui la Pubblica Amministrazione sacrifica un interesse privato per tutelare un interesse collettivo superiore.

1. I **Provvedimenti Ablatori Reali** sono atti che incidono su diritti reali, determinandone l'estinzione, la limitazione o il trasferimento coattivo.
 - **L'Espropriazione per Pubblica Utilità (D.P.R. 327/2001):** Rappresenta la massima espressione del potere ablatorio. La P.A. trasferisce il diritto di proprietà dal privato a sé (o a un beneficiario) prescindendo dal consenso.
 - **L'Indennizzo:** Punto di equilibrio costituzionale (Art. 42 Cost.). Non deve essere puramente simbolico né necessariamente pari al valore di mercato, ma deve costituire un "**serio ristoro**", calcolato in base alle potenzialità economiche del bene (Sent. 5/1980 Corte Cost.).
 - **Requisizioni e Servitù:** La requisizione incide sull'uso di beni (mobili o immobili) per urgenze militari o civili. Le servitù pubbliche (es. acquedotto) limitano il godimento del bene per un'utilità pubblica permanente.
2. I **Provvedimenti Ordinatori:** Questi atti impongono obblighi di fare o di non fare (divieti) e si dividono in due ambiti:
 - **Rapporti Gerarchici (Interorganici):** L'ordine è lo strumento con cui il superiore guida il subordinato (es. forze di polizia, Art. 16 D.P.R. 3/1957).
 - **Il dovere di rimostranza:** Se l'impiegato ritiene l'ordine illegittimo, deve motivare il dissenso. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, deve eseguirlo, salvo che l'atto costituisca reato (Art. 17).
 - **Rapporti Intersoggettivi (P.A.-Cittadino):**
 - **Ordini di Polizia:** Emanati per la sicurezza e l'ordine pubblico (TULPS).
 - **Ordini di Vigilanza:** Emanati da Autorità indipendenti (es. Banca d'Italia, AGCM) per regolare settori sensibili o reprimere pratiche scorrette.
 - **La Diffida:** Un ordine di cessazione di un comportamento illecito con fissazione di un termine per il ripristino della legalità (es. inquinamento acque).
3. Le Sanzioni Amministrative hanno una funzione **afflittiva e dissuasiva**, volta a reprimere la violazione di norme o provvedimenti. Sono governate dalla **L. 689/1981**, che mutua i principi del diritto penale (legalità, irretroattività, personalità della responsabilità). Tipologie di Sanzioni
 1. **Pecuniarie:** Obbligo di pagare una somma. È prevista l'**oblazione** (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni) per estinguere il procedimento senza accertamento definitivo.
 2. **Interdittive:** Incidono su facoltà o titoli (es. ritiro patente, decadenza concessione).

3. **Disciplinari:** Colpiscono soggetti legati alla P.A. da uno status speciale (dipendenti, professionisti). Sono regolate da leggi speciali e non dalla L. 689/1981.

Sanzioni Punitive vs Ripristinatorie

Occorre distinguere tra la sanzione in senso stretto (che punisce il trasgressore) e le **misure ripristinatorie** (es. l'ordine di demolizione edilizia). Queste ultime non mirano a "punire", ma a reintegrare materialmente l'interesse pubblico leso dall'abuso.

Responsabilità degli Enti (D.Lgs. 231/2001)

Una deroga al principio di personalità è la responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi nel loro interesse da dipendenti. L'ente può esentarsi solo provando di aver adottato **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire l'illecito.

La Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA)

La SCIA, introdotta nel 2010 dall'**Art. 19 della L. 241/1990**, rappresenta il principale strumento di semplificazione amministrativa. Essa trasforma il regime di controllo sulle attività private da un modello **ex ante** (autorizzazione espressa) a un modello **ex post** (controllo successivo), sostituendo ogni atto di licenza, concessione non costitutiva o nulla osta.

1. **La Natura Giuridica e il Meccanismo Operativo:** a differenza dell'autorizzazione tradizionale, la SCIA non è un provvedimento amministrativo, ma un **atto privato di autovalutazione**.

- **Avvio immediato:** Il privato comunica l'inizio dell'attività e può avviarla contestualmente alla presentazione della segnalazione (Art. 19-bis).
- **Autocertificazione:** Il segnalante dichiara, sotto responsabilità anche penale, il possesso dei requisiti di legge.
- **Inversione dello schema logico:** Si passa da un rapporto di tipo *pretensivo* (chiedo un bene della vita alla P.A.) a uno di tipo *oppositivo* (esercito un diritto e la P.A. può eventualmente opporsi).

2. **Ambito di Applicazione e Limiti:** l'istituto della SCIA non è universale, ma opera secondo criteri precisi:

- **Attività vincolate:** La SCIA sostituisce solo gli atti il cui rilascio dipenda dall'accertamento di requisiti **oggettivi e vincolati** dalla legge. Se la P.A. dispone di discrezionalità (valutazione comparativa degli interessi), la SCIA è inapplicabile.
- **Assenza di limiti quantitativi:** Non può essere usata se l'attività è soggetta a contingenti o programmazioni di settore (es. licenze taxi).
- **Esclusioni per interessi sensibili:** Sono esclusi i casi in cui entrino in gioco la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'amministrazione della giustizia e la tutela della salute e dell'ambiente.

3. **I Poteri di Verifica della P.A.:** una volta ricevuta la SCIA, l'Amministrazione dispone di un **termine perentorio di 60 giorni** (30 in materia edilizia) per verificare la sussistenza dei requisiti.

- **Inibitoria e Ripristino:** Se accerta la carenza dei requisiti, emana un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti.
- **Conformazione:** Se l'irregolarità è sanabile, la P.A. invita il privato a conformare l'attività entro un termine (non inferiore a 30 giorni).

- **Poteri residui:** Decorso il termine dei 60 giorni, la P.A. può intervenire solo tramite l'**autotutela** (Art. 21-nonies), ovvero in presenza di pericoli gravi per il patrimonio artistico, l'ambiente o la salute pubblica, ed entro il termine massimo di 18 mesi (Art. 19, comma 4).

4. **La Tutela del Terzo:** La natura privata della SCIA pone un problema di tutela per il terzo (es. il vicino di casa) che subisca un pregiudizio dall'attività segnalata.

- **Inimpugnabilità diretta:** Poiché la SCIA non è un provvedimento (nemmeno tacito), il terzo non può impugnarla davanti al G.A. (Art. 19, co. 6-ter).
- **L'Azione contro il silenzio:** Il terzo deve **sollecitare** la P.A. a esercitare i propri poteri di verifica. Se la P.A. rimane inerte, il terzo può esperire l'azione contro il silenzio (Artt. 31 e 117 c.p.a.) per obbligare l'amministrazione a provvedere.
- **Termini di decadenza:** Secondo la **Corte Costituzionale (Sent. 45/2019)**, il terzo deve sollecitare la P.A. entro i medesimi termini di 60 giorni (o 18 mesi per l'autotutela) concessi all'amministrazione per il controllo d'ufficio, per non ledere l'affidamento del segnalante.

Le autorizzazioni e le concessioni

Secondo il principio di sussidiarietà e la libertà di iniziativa economica, il regime del controllo preventivo (il "permesso" prima di agire) è oggi considerato un'eccezione. Ai sensi del **D.Lgs. 59/2010** (attuativo della Direttiva Bolkestein), i regimi autorizzatori possono essere mantenuti solo se giustificati da **motivi imperativi di interesse generale** e se l'obiettivo non può essere raggiunto con misure meno restrittive.

- **L'Autorizzazione:** L'autorizzazione è l'atto con cui la P.A. rimuove un limite legale all'esercizio di un **diritto soggettivo già esistente** in capo al privato.
 - **Funzione:** Controllo preventivo della conformità dell'attività alla legge.
 - **Situazione soggettiva:** Il privato vanta un **interesse legittimo pretensivo** che "fa coppia" con un diritto soggettivo preesistente ma "compresso".
 - **Esempio:** L'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale o il porto d'armi
- **La Concessione:** La concessione è l'atto con cui la P.A. **attribuisce ex novo** o trasferisce al privato un diritto o un potere di cui l'amministrazione è titolare.
 - **Funzione:** Spesso è uno strumento di **esternalizzazione**: la P.A. affida a privati la gestione di beni o servizi pubblici anziché provvedervi direttamente.
 - **Situazione soggettiva:** Il privato è titolare di un **interesse legittimo pretensivo "puro"**. Il diritto soggettivo sorge solo dopo l'emanazione dell'atto.
 - Tipologie:
 - **Traslative:** Trasferiscono un potere pubblico (es. gestione di uno stabilimento balneare su bene demaniale).
 - **Costitutive:** Creano un nuovo diritto (es. un'onorificenza)

Il diritto europeo ha profondamente scardinato la distinzione classica tra autorizzazioni e concessioni, preferendo una visione unitaria fondata sul concetto di "**regime autorizzatorio**" (Dir. 2006/123/CE). Per l'Europa, la discrezionalità amministrativa è spesso vista come una barriera all'entrata nel mercato. Per questo:

1. **Liberalizzazione:** Molte concessioni discrezionali sono state trasformate in autorizzazioni vincolate (es. le comunicazioni elettroniche, ora libere).
2. **Divieto di test economici:** È vietato subordinare il rilascio di un titolo alla prova di un "bisogno economico" o della domanda di mercato, poiché sono logiche anti-concorrenziali.
3. **Concorrenza "per il mercato":** Quando le risorse sono scarse (es. frequenze radio, aree demaniali), la P.A. deve procedere tramite **procedure di selezione pubblica** (gare), garantendo imparzialità e trasparenza (Art. 16 D.Lgs. 59/2010).

Superata la dicotomia rigida, la distinzione più rilevante oggi riguarda la natura del potere esercitato:

- **Atti Vincolati (Autorizzazioni Ricognitive):** L'effetto giuridico si ricollega direttamente alla legge; alla P.A. spetta solo l'accertamento dei requisiti (schema *norma-fatto-effetto*).
- **Atti Discrezionali (Autorizzazioni Costitutive):** L'atto è la fonte diretta dell'effetto, frutto di una ponderazione di interessi (schema *norma-fatto-potere-effetto*).

Rilevanza Processuale: L'Azione di Adempimento

L'azione di adempimento rappresenta una delle novità più significative introdotte dal **Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010)**, segnando il passaggio da un giudizio puramente "sull'atto" (annullamento) a un giudizio "sul rapporto" tra cittadino e potere. L'Azione di Adempimento (**Art. 34, comma 1, lett. c, c.p.a.**) è l'azione con cui il ricorrente chiede al Giudice Amministrativo di condannare la P.A. a rilasciare il provvedimento richiesto (c.d. **condanna a un fare specifico**). Essa è finalizzata a soddisfare l'**interesse legittimo pretensivo**, superando la mera eliminazione del diniego per giungere alla spettanza del "bene della vita". L'azione di adempimento non può essere proposta isolatamente: essa deve essere contestuale all'**azione di annullamento** del diniego o all'**azione contro il silenzio**. Il legislatore ha voluto evitare che il giudice si sostituisca integralmente all'amministrazione senza che vi sia stata prima una manifestazione (o un'inerzia) del potere pubblico.

- **Il Limite della Discrezionalità (Art. 31, comma 3, c.p.a.):** La vera rilevanza processuale risiede nel limite che il giudice incontra nell'accertare la spettanza del provvedimento. Il Giudice può pronunciare la condanna al rilascio dell'atto solo in due casi:
 1. **Attività Vincolata:** Quando l'amministrazione non ha margini di scelta e il giudice può verificare meccanicamente la sussistenza di tutti i requisiti di legge.
 2. **Discrezionalità Esaurita:** Quando, pur essendo il potere originariamente discrezionale, l'amministrazione ha già compiuto tutte le valutazioni di merito durante l'istruttoria, esaurendo il proprio margine di apprezzamento (c.d. *discrezionalità ridotta a zero*).
- **Il Divieto di Sostituzione (Art. 34, comma 2, c.p.a.):** Un principio cardine del processo amministrativo, derivante dalla separazione dei poteri, è che **il giudice non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati**. Se la P.A. ha negato un'autorizzazione per un motivo "X" senza ancora valutare il motivo "Y" (che richiede discrezionalità tecnica o amministrativa), il giudice non può integrare quella valutazione mancante. In questo caso, il giudice annullerà il diniego e ordinerà alla P.A. di rideterminarsi, ma non potrà ordinare il rilascio del titolo.

Questa distinzione è cruciale in sede di ricorso. Se il diniego di un'autorizzazione è illegittimo:

- In caso di **potere vincolato**, il giudice può condannare la P.A. a rilasciare il provvedimento richiesto (**azione di adempimento**).
- In caso di **potere discrezionale**, il giudice non può sostituirsi alla P.A. nella valutazione di merito, limitandosi ad annullare il diniego e ordinando un nuovo esame.

Gli atti amministrativi dichiarativi

Mentre il provvedimento è un atto di *volontà*, l'atto dichiarativo è un atto di **scienza** o di **giudizio**. La sua funzione non è quella di disporre di interessi, ma di accertare fatti, stati o qualità, rendendoli opponibili ai terzi o utilizzabili nel corso di un procedimento. Nell'ampio panorama dell'attività amministrativa, gli atti dichiarativi si distinguono dai provvedimenti per l'assenza di un momento volitivo volto a innovare l'ordinamento. Essi non costituiscono, modificano o estinguono situazioni giuridiche, ma assolvono a una funzione meramente **ricognitiva e dichiarativa**, finalizzata alla produzione di certezze giuridiche all'interno del sistema. Il cuore di questa categoria è rappresentato dalle **certificazioni**, ovvero manifestazioni di scienza con cui la Pubblica Amministrazione attesta atti,

fatti o qualità soggettive (come la residenza o lo stato civile) risultanti da pubblici registri. Tale attività di "certezza pubblica" è oggi profondamente segnata dal processo di decertificazione imposto dall'**art. 18 della L. 241/1990** e dal **d.p.r. 445/2000**, che obbligano le amministrazioni a scambiarsi d'ufficio i dati, sollevando il privato dall'onere di esibire certificati. In questo contesto, l'**autocertificazione** (nelle forme delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà) assume un ruolo centrale: il privato si sostituisce alla P.A. nell'attestare i propri requisiti sotto responsabilità penale. È importante ricordare che, in caso di dichiarazioni false, l'ordinamento non solo prevede sanzioni punitive, ma impedisce radicalmente la sanatoria della posizione del privato, disponendo la decadenza immediata dai benefici eventualmente conseguiti.

1. Le Certificazioni e la Funzione di Certezza: Le certificazioni sono dichiarazioni che attestano dati contenuti in registri, albi o elenchi pubblici. Esse assolvono alla funzione di **certezza pubblica**, eliminando le controversie sulla sussistenza di determinati presupposti. Tuttavia, il regime tradizionale delle certificazioni è stato profondamente innovato per ridurre gli oneri a carico dei privati (**Art. 18 L. 241/90 e D.P.R. 445/2000**):

- **Decertificazione:** Le P.A. sono obbligate a scambiarsi d'ufficio i dati in loro possesso. Al privato non può essere chiesto un certificato se la P.A. può acquisire l'informazione da un'altra amministrazione.
- **Autocertificazione (Dichiarazioni Sostitutive):** Il privato può sostituire il certificato con una propria dichiarazione sotto responsabilità penale.
 - **Dichiarazioni sostitutive di certificazione (Art. 46):** Per dati semplici (nascita, residenza, titoli di studio).
 - **Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Art. 47):** Per fatti o stati a conoscenza dell'interessato anche relativi ad altri.
- **Conseguenze del falso:** La falsità non solo comporta sanzioni penali, ma determina la **decadenza** dai benefici ottenuti e impedisce la sanatoria (conformazione) dell'attività (Art. 21 L. 241/90).

2. Altre tipologie: Atti Paritetici e Verbalizzazioni

- **Atti Paritetici:** Sono atti in cui la P.A. non esercita alcun potere discrezionale, ma si limita a riconoscere un diritto già definito dalla legge in tutti i suoi elementi (es. la determinazione di uno stipendio o di una pensione). Essendo atti meramente ricognitivi, il cittadino li può contestare davanti al giudice ordinario nei termini di prescrizione ordinaria, non essendo soggetti al termine di decadenza dei 60 giorni.
- **Verbalizzazioni:** Consistono nella narrazione oggettiva di fatti o operazioni avvenuti alla presenza di un pubblico ufficiale (es. verbale di un'ispezione della Banca d'Italia). Il verbale ha una particolare forza probatoria: "fa fede fino a querela di falso".

3. Atti di Giudizio: Pareri e Valutazioni Tecniche: Questi atti intervengono nella fase istruttoria del procedimento e servono a fornire all'amministrazione procedente gli elementi necessari per decidere.

- **Pareri (Art. 16 L. 241/90):** Sono manifestazioni di giudizio volte a illuminare la P.A. sugli interessi in gioco. Possono essere:
 - *Obbligatorie:* La legge impone di chiederli.
 - *Facoltative:* La P.A. decide di chiederli per maggiore completezza.
 - *Vincolanti:* L'amministrazione deve conformarsi al contenuto del parere.
- **Valutazioni Tecniche (Art. 17 L. 241/90):** Riguardano l'accertamento di fatti complessi secondo le regole di una scienza o di un'arte (es. il valore artistico di un quadro o la pericolosità di un virus). A differenza dei pareri, sono indispensabili per l'emanazione dell'atto e, se l'organo tecnico non provvede, la P.A. deve rivolgersi ad altri organi con competenze analoghe.

Oltre alle ripartizioni classiche basate sul contenuto, il diritto amministrativo opera ulteriori classificazioni che tengono conto della struttura soggettiva, della platea dei destinatari e della vicinanza dell'atto alla funzione di indirizzo politico.

La struttura soggettiva: atti complessi e collegiali

Sotto il profilo della provenienza soggettiva, l'atto amministrativo può promanare da un organo monocratico o risultare dalla convergenza di più volontà. In quest'ultimo caso si parla di **atto complesso**, dove due o più organi, posti in posizione paritaria, concorrono alla formazione di un unico provvedimento per il perseguimento di un fine comune; l'esempio tipico è il decreto interministeriale, che richiede il consenso paritario dei ministri coinvolti. Diversa è la natura degli **atti collegiali**, imputabili a un organo composto da una pluralità di persone fisiche che agiscono come un'unità (ad esempio una commissione di concorso o un consiglio comunale). La validità di tali delibere dipende dal rispetto di rigorose regole procedurali relative alla convocazione, alla costituzione del numero legale (quorum costitutivo) e alla maggioranza necessaria per l'approvazione (quorum deliberativo).

La classificazione per destinatari: atti generali, collettivi e plurimi

Il criterio dei destinatari permette di distinguere innanzitutto gli **atti amministrativi generali**, che si rivolgono a una classe indeterminata di soggetti (come un bando di gara o un piano regolatore) e che, pur avendo un contenuto concreto, non richiedono la comunicazione individuale. Da questi occorre isolare gli **atti collettivi** e gli **atti plurimi**. Negli atti collettivi la P.A. colpisce una categoria di soggetti considerata unitariamente, ma i cui componenti sono già precisamente individuati: è il caso dello scioglimento di un organo collegiale, che produce effetti simultanei e inscindibili su tutti i suoi membri. Al contrario, negli **atti plurimi**, pur essendovi una pluralità di destinatari individuati, gli effetti sono scindibili per ciascuno di essi; il decreto che approva una graduatoria di concorso è l'esempio calzante, poiché l'annullamento della posizione di un candidato non travolge necessariamente quella degli altri.

Il confine tra politica e amministrazione: atti politici e di alta amministrazione

Un'ultima fondamentale distinzione riguarda l'ampiezza della discrezionalità e il raccordo con la funzione di governo. L'**atto politico** è caratterizzato dalla massima libertà nel fine, è emanato da organi costituzionali ed è espressione diretta della funzione di guida dello Stato (si pensi alla decisione di proporre un disegno di legge). Per espressa previsione dell'**art. 7 del Codice del Processo Amministrativo**, tali atti sono insindacabili dal giudice amministrativo, in quanto sottratti al regime del provvedimento. Situati in una zona di confine sono invece gli **atti di alta amministrazione**, che pur essendo caratterizzati da una discrezionalità amplissima, mantengono natura amministrativa. Essi fungono da cerniera tra l'indirizzo politico e la gestione concreta (come le nomine dei vertici dei servizi segreti o dei direttori generali delle ASL). A differenza degli atti politici, quelli di alta amministrazione devono essere obbligatoriamente motivati e sono sempre impugnabili. Tuttavia, proprio per la loro natura "alta", il giudice amministrativo esercita su di essi un sindacato limitato, intervenendo solo di fronte a vizi macroscopici di irragionevolezza o illogicità, per non invadere indebitamente il campo riservato alle scelte strategiche dell'Esecutivo.

L'INVALIDITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

La teoria dell'invalidità del provvedimento rappresenta il momento patologico dell'azione amministrativa. Per comprenderne la portata, è necessario distinguere preliminarmente tra norme di condotta, che impongono obblighi la cui violazione genera un illecito, e norme di conferimento di potere, la cui inosservanza determina l'invalidità dell'atto, ovvero il disconoscimento degli effetti che l'ordinamento ricollega al modello legale.

Il regime dell'invalidità: Nullità vs Annullabilità

A differenza del diritto civile, dove la nullità è la sanzione generale per la violazione di norme imperative (carattere atipico), nel diritto amministrativo la **nullità è una categoria residuale e tassativa**. Ciò accade perché quasi tutte le norme amministrative sono imperative, in quanto poste a tutela dell'interesse pubblico; sanzionare ogni loro minima violazione con la nullità renderebbe l'azione amministrativa eccessivamente instabile. Pertanto, il regime ordinario del provvedimento invalido è l'**annullabilità**, che garantisce un'efficacia precaria all'atto fino all'eventuale intervento del giudice.

Estensione e propagazione del vizio

L'invalidità può colpire l'atto nella sua interezza o solo in parte. L'**invalidità parziale** è frequente negli atti plurimi (come una graduatoria di concorso), dove il vizio che colpisce un singolo destinatario non travolge l'intero provvedimento, a meno che le parti non siano strettamente dipendenti. Un concetto fondamentale è quello di **invalidità derivata**, che si verifica quando il vizio di un atto presupposto (ad esempio un bando di gara illegittimo) si propaga all'atto conseguente (l'aggiudicazione). Questa propagazione può avere due intensità:

1. **Effetto caducante:** L'annullamento del primo atto travolge automaticamente il secondo, poiché tra i due sussiste un rapporto di stretta e necessaria causalità.
2. **Effetto viziante:** Il secondo atto è invalido ma conserva i suoi effetti finché non viene impugnato autonomamente, poiché la sua adozione richiedeva nuovi e ulteriori apprezzamenti da parte della P.A.

Il fattore tempo: Invalidità originaria e sopravvenuta

La validità di un atto si valuta in base al principio *tempus regit actum*, ovvero con riferimento alle norme vigenti al momento della sua adozione. Tuttavia, si parla di **invalidità sopravvenuta** in casi eccezionali, come l'emanazione di leggi retroattive o le dichiarazioni di illegittimità costituzionale. Le sentenze della Corte Costituzionale, avendo efficacia retroattiva, rendono invalidi i provvedimenti fondati sulla norma dichiarata incostituzionale, purché non si tratti di "rapporti esauriti" (ad esempio per decorrenza dei termini di impugnazione).

La tripartizione dei vizi di legittimità

Il sistema attuale, cristallizzato dall'**art. 21-octies della L. 241/1990**, riconduce l'annullabilità a tre figure sintomatiche tradizionali:

- **L'incompetenza:** Quando l'atto è emanato da un organo diverso da quello previsto dalla legge (ma appartenente alla stessa amministrazione).
- **L'eccesso di potere:** Il vizio della funzione discrezionale, rilevabile attraverso figure sintomatiche come l'illogicità o il travisamento dei fatti.
- **La violazione di legge:** Una categoria residuale che comprende ogni altra difformità tra il provvedimento e la norma (es. vizi di forma o di procedimento).

La **nullità**, invece, è confinata dall'**art. 21-septies** a ipotesi gravissime: mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione (incompetenza assoluta), violazione o elusione del giudicato.

L'annullabilità

L'annullabilità costituisce il regime ordinario dell'invalidità del provvedimento amministrativo. Sebbene nel linguaggio corrente si utilizzino come sinonimi i termini **illegittimità** e **annullabilità**, l'evoluzione normativa impressa dalla L. 241/1990 ha introdotto una sottile ma fondamentale

distinzione: mentre l'illegittimità indica la generica difformità dell'atto dal paradigma legale, l'annullabilità ne rappresenta la conseguenza sanzionatoria, che tuttavia oggi può essere esclusa in presenza di determinati vizi puramente formali. L'annullamento del provvedimento produce una triplice efficacia, volta a eliminare la patologia e le sue conseguenze:

- **Effetto caducante (ex tunc):** L'atto viene rimosso con efficacia retroattiva, come se non fosse mai venuto ad esistenza.
- **Effetto ripristinatorio:** Nasce in capo alla P.A. l'obbligo di ricostituire lo *status quo ante*, ossia la situazione di fatto e di diritto sussistente prima dell'emanazione dell'atto (ad esempio, la restituzione di un bene illegittimamente espropriato).
- **Effetto conformativo:** Rappresenta il vincolo che la sentenza (o l'atto di autotutela) impone all'attività futura dell'amministrazione. È qui che si misura la reale portata della vittoria del privato.

Vizi formali vs Vizi sostanziali

La portata dell'effetto conformativo dipende dalla natura del vizio accertato, distinguendo tra errori nella procedura (*error in procedendo*) ed errori nel merito della decisione (*error in iudicando*):

- **Vizi formali o procedurali:** Se l'atto è annullato per incompetenza o per mancata acquisizione di un parere, la P.A. conserva il potere di emanare un nuovo atto dal contenuto identico, purché emendato dal vizio (es. chiedendo il parere mancante). Il bene della vita non è ancora garantito al privato.
- **Vizi sostanziali:** Se l'atto cade perché manca un presupposto di legge o per un travisamento dei fatti (eccesso di potere), il vincolo conformativo è molto più stringente: la P.A. non potrà reiterare un provvedimento con lo stesso contenuto dispositivo, poiché il giudice ha accertato che quel potere, in quella situazione, non poteva essere esercitato.

La dequotazione dei vizi formali (Art. 21-octies, comma 2)

Una delle novità più dirompenti è la cosiddetta "**non annullabilità**" dei provvedimenti illegittimi. La norma stabilisce che il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma non è annullabile qualora, per la natura vincolata del potere, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Allo stesso modo, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non comporta annullamento se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere differente. In questi casi, l'illegittimità rimane, ma l'ordinamento preferisce sacrificare la forma in nome del principio di **efficacia ed economia dell'azione amministrativa**, evitando annullamenti "inutili" di atti che verrebbero inevitabilmente riadottati nello stesso modo.

Il profilo processuale

Il profilo processuale dell'annullabilità è governato da una logica di rapidità e certezza, volta a stabilizzare l'assetto degli interessi pubblici nel più breve tempo possibile. Il fulcro del sistema risiede nell'**azione di annullamento**, che ai sensi dell'**art. 29 del Codice del processo amministrativo (c.p.a.)** deve essere proposta entro il termine di decadenza perentorio di **60 giorni**. Tale termine decorre, a seconda dei casi, dalla notificazione, dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto da parte del soggetto leso. La brevità di questo termine risponde all'esigenza di evitare che il provvedimento, e con esso l'azione della Pubblica Amministrazione, resti esposto a contestazioni per un tempo indefinito. Una volta spirato il termine di 60 giorni senza che sia stato proposto ricorso, l'atto diventa **inoppugnabile**: ciò significa che la sua validità non può più essere messa in discussione dal privato davanti al giudice, anche se l'atto dovesse risultare palesemente illegittimo. In questo senso, l'annullabilità dà vita a un'**efficacia precaria**: il provvedimento produce i suoi effetti sin dal momento dell'emanazione, **ma tali effetti sono "instabili" e possono essere rimossi retroattivamente dal**

giudice se il ricorso viene presentato tempestivamente e accolto. Sul piano dell'onere della prova, il processo amministrativo segue un modello di stampo inquisitorio attenuato. Il ricorrente ha l'onere di fornire un **principio di prova** circa i vizi dedotti (incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge), ma è il giudice a disporre dei poteri istruttori necessari per acquisire dall'amministrazione i documenti e i chiarimenti necessari. È fondamentale sottolineare che l'accertamento del giudice deve limitarsi ai vizi di legittimità, senza poter mai sconfinare nel "merito" amministrativo, ovvero nelle scelte di opportunità riservate alla P.A., salvo i rari casi di giurisdizione di merito previsti dall'art. 134 c.p.a. Infine, l'azione di annullamento può essere accompagnata da una **domanda cautelare** (art. 55 c.p.a.). Poiché il ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto, il privato che rischi di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione (il c.d. *periculum in mora*) può chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione del provvedimento fino alla sentenza di merito, a condizione che sussista anche il *fumus boni iuris*, ovvero una ragionevole probabilità che il ricorso venga accolto.

I Vizi di Legittimità: Incompetenza e Violazione di Legge

L'annullabilità del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'**art. 21-octies l. 241/1990**, discende dalla tripartizione dei vizi di legittimità. Sebbene l'incompetenza e la violazione di legge possano sembrare categorie contigue, esse rispondono a logiche diverse: l'una riguarda il "chi" emana l'atto, l'altra il "come" e il "perché" lo si emana rispetto al paradigma normativo.

- **L'Incompetenza** (Vizio Soggettivo): L'incompetenza si verifica quando il potere viene esercitato da un organo diverso da quello individuato dalla norma attributiva. È considerata una specie del genere "violazione di legge", poiché la ripartizione dei compiti tra uffici è definita da fonti normative. È cruciale distinguere l'intensità del vizio:
 - **Incompetenza Relativa:** L'atto è emanato da un organo che appartiene allo stesso plesso amministrativo del titolare del potere (es. un dirigente dello stesso Ministero ma di un ufficio diverso). Determina l'**annullabilità**.
 - **Incompetenza Assoluta:** Si ha quando l'organo è totalmente estraneo (soggettivamente e funzionalmente) al plesso titolare del potere. In questo caso non si ha annullabilità, ma **nullità** per "difetto assoluto di attribuzione".

Le quattro articolazioni dell'incompetenza

1. **Per materia:** Attiene all'oggetto dell'intervento (es. urbanistica vs commercio).
2. **Per grado:** Riguarda la gerarchia interna (tipica delle organizzazioni militari).
3. **Per territorio:** Coinvolge ambiti geografici diversi (es. la Prefettura di Firenze che agisce su quella di Prato).
4. **Per valore:** Relativa a soglie di spesa diverse attribuite a vari organi dello stesso ente.

Nota Processuale: Il vizio di incompetenza ha una priorità logica: il giudice deve esaminarlo per primo e, se accertato, annulla l'atto rimettendo l'affare all'autorità corretta senza analizzare gli altri motivi di ricorso.

- **La Violazione di Legge** (Categoria Residuale): La violazione di legge è una categoria di chiusura che accoglie tutte le difformità dal modello legale che non rientrano nell'incompetenza o nell'eccesso di potere. Comprende la violazione di norme di forma, di procedimento o di sostanza.

La Dequotazione dei Vizi Formali (Art. 21-octies, comma 2)

In nome del principio di **efficacia ed efficienza** (amministrazione di risultato), il legislatore ha previsto che non ogni illegittimità formale porti all'annullamento. Si distingue tra:

- Atti Vincolati e Vizi di Forma/Procedimento: Il provvedimento **non è annullabile** se:
 - Ha natura vincolata.

- È palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, anche se la forma fosse stata rispettata. In questo caso, l'annullamento è considerato una reazione sproporzionata per un atto che è "sostanzialmente" corretto.
- **L'Omessa Comunicazione di Avvio** (Regime speciale): Qui la legge è più elastica ma rigorosa sulla prova:
 - Si applica anche agli atti **discrezionali** (se vincolati "in concreto").
 - L'amministrazione ha l'**onere della prova**: deve dimostrare in giudizio che l'apporto del privato (non chiamato a partecipare) non avrebbe comunque cambiato l'esito della decisione.
 - Il privato, dal canto suo, deve allegare quali elementi avrebbe portato se fosse stato avvisato.
- **Irregolarità vs Illegittimità non annullabile**: È fondamentale non confondere l'**irregolarità** (errori materiali minimi come una data errata, che non ledono alcun interesse) con l'**illegittimità non annullabile** *ex art. 21-octies*. Mentre l'atto irregolare è valido, l'atto che viola norme di forma ma non è annullabile resta **illegittimo**. Tuttavia, l'ordinamento gli nega la tutela dell'annullamento perché il risultato finale è conforme all'interesse pubblico sostanziale.
 - **Risarcimento?** Improbabile, perché manca il danno da provvedimento (l'atto sarebbe stato comunque lo stesso).
 - **Responsabilità?** Resta possibile una sanzione disciplinare per il funzionario che ha ignorato le regole formali.

L'eccesso di potere

L'eccesso di potere rappresenta il vizio più peculiare del diritto amministrativo, poiché si concentra non sulla forma o sulla competenza, ma sulla **funzione** stessa dell'agire pubblico. Se l'incompetenza risponde alla domanda su "chi" ha agito e la violazione di legge al "cosa" è stato fatto, l'eccesso di potere indaga il "**perché**" e il "**come**" l'amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità. Si tratta di un vizio sostanzialmente ignoto al diritto privato, dove i motivi interni di un contratto sono solitamente irrilevanti; nel diritto amministrativo, invece, l'amministrazione è obbligata a perseguire il fine pubblico assegnatole dalla legge, e ogni deviazione da questo percorso configura una patologia dell'atto. La figura originaria e più grave di questo vizio è lo **sviamento di potere**, che si verifica quando l'amministrazione utilizza correttamente un potere ma per un fine diverso da quello previsto dalla norma. Un esempio classico è il trasferimento di un dipendente motivato da esigenze organizzative, che nasconde in realtà una finalità punitiva. Poiché provare l'intenzione soggettiva del funzionario è estremamente difficile, la giurisprudenza ha elaborato le cosiddette **figure sintomatiche**: dei "campanelli d'allarme" o indizi oggettivi che permettono al giudice di risalire al cattivo esercizio del potere. Queste figure costituiscono un catalogo aperto e includono, ad esempio, il travisamento dei fatti, che avviene quando la P.A. decide basandosi su presupposti inesistenti, o il difetto di istruttoria, che emerge quando l'amministrazione non ha compiuto tutti gli accertamenti necessari prima di deliberare. Un ruolo fondamentale è giocato dalla **motivazione**, che deve rendere trasparente l'iter logico seguito dall'ente. Se la motivazione è insufficiente, illogica, contraddittoria o perplessa, il giudice può annullare l'atto ravvisandovi un sintomo di eccesso di potere. Allo stesso modo, il principio di eguaglianza impone che a casi uguali corrisponda un trattamento uguale: se l'amministrazione decide in modo difforme per situazioni identiche senza una giustificazione razionale, incorre nel vizio di **disparità di trattamento**. Anche l'ingiustizia grave e manifesta o la violazione delle circolari e della prassi amministrativa rientrano in questo ambito, segnalando che l'amministrazione ha agito in modo incoerente rispetto ai propri precedenti o a canoni di ragionevolezza minimi. Le **figure sintomatiche** rappresentano lo strumento più raffinato creato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per rendere effettivo il sindacato sul potere discrezionale. Poiché lo sviamento di potere — ovvero l'uso di un potere per un fine diverso da quello di legge — è quasi **impossibile da dimostrare direttamente** (l'atto appare quasi sempre inattaccabile nella sua veste

formale), **il giudice analizza l'attività amministrativa alla ricerca di indizi**, i "*sintomi*" appunto, che rivelino un'anomalia nel processo di formazione della volontà pubblica. Queste figure fungono da prova indiretta: se l'atto presenta una di queste patologie logiche, si presume che il potere non sia stato esercitato nell'interesse pubblico. Tra le figure legate alla base conoscitiva del provvedimento, spiccano **l'errore o travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria**. Nel primo caso, l'amministrazione fonda la propria scelta su una **realtà oggettivamente inesistente o percepita in modo errato**, come quando si impone un vincolo di bonifica su un'area che le analisi tecniche dimostrano essere priva di inquinanti. Il travisamento si verifica quando l'amministrazione fonda il proprio provvedimento su una rappresentazione della realtà oggettivamente errata o alterata. Questo accade quando la P.A. dà per esistente un fatto che non esiste (falso supposto in fatto) o, al contrario, ignora l'esistenza di una circostanza che è invece palesemente presente. L'aspetto cruciale è che non si discute qui della "scelta" (la discrezionalità), ma della "conoscenza" del punto di partenza. Per il diritto amministrativo, se la base conoscitiva è falsa, l'intero processo logico che porta al provvedimento è irrimediabilmente viziato, rendendo l'atto illegittimo per eccesso di potere. Un esempio pratico chiarificatore è quello di un comune che neghi un'autorizzazione edilizia sostenendo che l'area sia sottoposta a un vincolo idrogeologico che, mappe alla mano, non riguarda affatto quella particella di terreno. In questo caso, l'amministrazione non ha esercitato male un potere discrezionale decidendo se il vincolo fosse importante o meno: ha semplicemente "travisato" la realtà, vedendo un vincolo dove non c'era. È importante sottolineare che il travisamento dei fatti deve essere **immediatamente rilevabile** dagli atti del procedimento: il giudice non deve compiere indagini complesse sostituendosi alla P.A., ma deve poter riscontrare che l'amministrazione ha agito sulla base di un abbaglio sensoriale o documentale. Il *difetto di istruttoria*, invece, **colpisce il metodo**: la P.A. non ha compiuto tutti gli accertamenti necessari o non ha acquisito gli interessi rilevanti prima di decidere. A differenza del travisamento, qui la scelta finale potrebbe anche essere teoricamente corretta, ma il giudice annulla l'atto perché il procedimento è stato lacunoso o affrettato, impedendo una valutazione ponderata. Un'altra colonna portante è costituita dai **difetti della motivazione**, che è considerata lo specchio dell'iter logico seguito dall'ente. La motivazione può essere insufficiente, quando non illustra le ragioni del sacrificio imposto al privato, oppure illogica e contraddittoria, quando contiene passaggi incompatibili tra loro o premesse che portano a conclusioni opposte nel dispositivo. In questa categoria rientra anche la **perplexità**, che si verifica quando dal testo dell'atto non si riesce nemmeno a comprendere quale potere l'amministrazione abbia inteso esercitare, lasciando il destinatario in una situazione di incertezza inaccettabile. Sul piano della coerenza dell'agire amministrativo, le figure sintomatiche analizzano la razionalità esterna e interna dell'atto attraverso l'**irragionevolezza manifesta** e la **disparità di trattamento**. L'irragionevolezza emerge quando l'atto viola le regole elementari della logica o dell'esperienza, come nel caso di una diffida che assegni un termine materialmente impossibile da rispettare. La disparità di trattamento, invece, censura la violazione del principio di imparzialità: se l'amministrazione, in presenza di situazioni identiche, adotta provvedimenti diversi senza fornire una motivazione ragionevole per tale distinzione, l'atto è viziato. È tuttavia fondamentale sottolineare che il privato non può invocare l'uguaglianza nell'illegittimità: non si può cioè pretendere un favore contrario alla legge solo perché la P.A. lo ha precedentemente concesso a un altro soggetto. Infine, l'eccesso di potere si manifesta anche attraverso la **violazione di circolari, norme interne o prassi consolidate**. Pur non essendo leggi in senso stretto, questi atti creano un'aspettativa di coerenza nell'azione amministrativa; se un organo si discosta improvvisamente e senza spiegazioni dai criteri che egli stesso o l'ente superiore ha prefissato per orientare la discrezionalità, il suo comportamento viene considerato sintomatico di un arbitrio. In rari casi, la giurisprudenza si spinge fino a rilevare l'**ingiustizia grave e manifesta**, una figura di confine che permette l'annullamento di atti che, pur formalmente corretti, producono risultati talmente iniqui e sproporzionati da urtare la sensibilità comune, come l'esonero dal servizio per scarso rendimento di un dipendente che ha perso la capacità lavorativa a causa di un incidente subito proprio in occasione del servizio.

La violazione di norme interne, circolari e prassi

L'eccesso di potere per violazione di norme interne o di circolari è una figura di particolare interesse perché agisce su un piano diverso dalla violazione di legge. Mentre la legge è una fonte primaria che vincola l'amministrazione dall'esterno, le **circolari, le direttive e gli atti di pianificazione** sono strumenti con cui l'amministrazione auto-vincola la propria discrezionalità per garantire uniformità e prevedibilità. Sebbene tali atti non abbiano efficacia esterna diretta (non possono cioè essere impugnati di per sé dai cittadini come se fossero leggi), essi creano un obbligo di coerenza. Quando un organo amministrativo si discosta da una circolare o da una prassi consolidata senza fornire una motivazione analitica e convincente sulle ragioni del caso concreto, scatta il "sintomo" dell'eccesso di potere. Il vizio non risiede nella violazione della circolare in sé, ma nella **violazione del principio di affidamento e di imparzialità**: l'amministrazione non può trattare in modo diverso situazioni analoghe solo perché decide, in quel momento, di ignorare i criteri che essa stessa ha stabilito per orientare i propri uffici. Il privato ha infatti il diritto di attendersi che la P.A. agisca secondo schemi predefiniti; un mutamento repentino e non motivato della linea d'azione viene interpretato dal giudice come un indizio di arbitrio o, peggio, di favoritismo.

L'ingiustizia grave e manifesta

Ancor più peculiare è la figura dell'**ingiustizia grave e manifesta**, che rappresenta una sorta di clausola di salvaguardia contro esiti paradossali o iniqui dell'attività amministrativa. In questo caso, il provvedimento può apparire perfetto sotto ogni profilo: è emanato dall'organo competente, segue la procedura corretta e non viola alcuna norma specifica. Tuttavia, il suo contenuto dispositivo produce un effetto così stridente con il senso comune di giustizia e con i principi di umanità e ragionevolezza da risultare intollerabile. Il limite di questa figura è molto sottile, poiché il giudice non deve mai scivolare nel "merito", ovvero non deve dire "io avrei deciso diversamente perché è più opportuno". Per evitare questo sconfinamento, l'ingiustizia deve essere **manifesta**, ossia rilevabile *ictu oculi* (a colpo d'occhio) da chiunque, senza necessità di complesse indagini. Il caso storico del dipendente delle ferrovie esonerato per scarso rendimento dopo un infortunio sul lavoro è emblematico: l'amministrazione aveva il potere di licenziarlo, ma esercitarlo in quel modo e in quel momento, dopo che il dipendente era stato menomato proprio servendo l'amministrazione, è stato considerato un esercizio del potere talmente sproporzionato e privo di sensibilità da configurare un eccesso di potere. Questa figura richiama il principio di **proporzionalità**, inteso come l'obbligo per la P.A. di non imporre sacrifici ai privati che siano eccedenti rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento del fine pubblico.

Nullità

Entriamo ora nell'analisi della **nullità**, la forma più grave e radicale di invalidità che può colpire un provvedimento. Se l'annullabilità è la reazione dell'ordinamento a un atto "malato" (viziato), la nullità è la risposta a un atto "nato morto", ovvero un provvedimento talmente distante dal modello legale da non essere nemmeno in grado di produrre effetti giuridici. Ai sensi dell'**art. 21-septies della L. 241/1990**, la nullità è una categoria tassativa e residuale, limitata a quattro ipotesi specifiche che segnano il confine invalicabile dell'agire amministrativo. Le quattro ipotesi di nullità sono:

- Il primo caso riguarda la **mancaanza degli elementi essenziali**. Sebbene il legislatore non li abbia elencati, l'interprete li ricava per analogia dal diritto civile (soggetto, oggetto, forma e volontà). Un esempio classico è l'espropriazione di un edificio già distrutto o di un bene demaniale: in questi casi l'atto è nullo perché l'oggetto è impossibile o inesistente.
- Segue poi il **difetto assoluto di attribuzione**, che si verifica quando l'amministrazione esercita un potere che non le appartiene affatto, né per materia né per plesso organizzativo (la

cosiddetta incompetenza assoluta). Qui non siamo di fronte a un errore nel modo di agire, ma a uno "straripamento di potere" dove l'ente invade una sfera di competenza totalmente aliena.

- La terza ipotesi, di grande rilevanza pratica, è la **violazione o elusione del giudicato**. Si ha quando la P.A., dopo che una sentenza definitiva (passata in giudicato) ha annullato un suo atto, emana un nuovo provvedimento che riproduce lo stesso vizio o tenta di aggirare l'ordine del giudice. È una forma di ribellione dell'amministrazione all'autorità giudiziaria che l'ordinamento sanziona con la nullità per garantire l'effettività della tutela del cittadino. Infine, vi sono i casi di **nullità testuale**, in cui è una specifica norma di legge a prevedere tale sanzione, come accade per gli atti adottati da organi collegiali oltre il periodo di 45 giorni di *prorogatio*.

Il regime processuale: tra stabilità e accertamento

Sotto il profilo processuale, la nullità segue regole che cercano di bilanciare la gravità del vizio con l'esigenza di stabilità dei rapporti pubblici. A differenza del diritto civile, dove l'azione di nullità è imprescrittibile, nel diritto amministrativo l'azione di accertamento della nullità deve essere proposta entro il termine di decadenza di **180 giorni** (art. 31, comma 4, c.p.a.). È un termine molto più lungo di quello previsto per l'annullamento (60 giorni), ma comunque limitato per evitare che situazioni giuridiche pubbliche rimangano incerte per anni. Va però sottolineato che la nullità può sempre essere rilevata d'ufficio dal giudice o opposta come eccezione dalla P.A. resistente. Un regime speciale è previsto per la **violazione o elusione del giudicato**. In questo caso, il vizio va fatto valere davanti al giudice amministrativo attraverso il **giudizio di ottemperanza**. Qui i termini sono molto più ampi: il ricorso può essere proposto fino a **10 anni** dal passaggio in giudicato della sentenza. In questa sede, il giudice gode di poteri molto estesi, potendosi sostituire all'amministrazione inadempiente (tramite la nomina di un commissario *ad acta*) per assicurare che il comando contenuto nella sentenza venga finalmente eseguito e che l'atto nullo venga rimosso.

L'Annullamento d'Ufficio (Art. 21-nonies)

Dopo aver analizzato la "patologia" dell'atto amministrativo, è fondamentale esaminare i rimedi che l'amministrazione può adottare autonomamente per correggere, rimuovere o stabilizzare i propri provvedimenti. Questa attività rientra nel potere di **autotutela**, che permette alla P.A. di farsi giustizia da sé senza l'intervento del giudice. A differenza dell'annullamento pronunciato da un giudice, che è un atto vincolato all'accertamento del vizio, l'**annullamento d'ufficio** è un provvedimento di secondo grado **discrezionale**. L'amministrazione non è obbligata ad annullare un atto solo perché è illegittimo; deve invece valutare se la sua rimozione risponda a un effettivo interesse pubblico. I presupposti necessari per esercitare questo potere sono quattro e devono coesistere:

- 1. Sussistenza di un vizio:** L'atto deve essere illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge).
- 2. Interesse pubblico attuale:** Non basta il semplice ripristino della legalità (interesse astratto). La P.A. deve dimostrare che l'annullamento giovi a un interesse pubblico concreto (es. la tutela dell'erario o della concorrenza).
- 3. Ponderazione degli interessi:** L'amministrazione deve bilanciare l'interesse pubblico con quello del destinatario (affidamento) e degli eventuali controinteressati.
- 4. Termine ragionevole:** Il potere va esercitato entro un tempo che non leda eccessivamente la certezza del diritto. Per i provvedimenti di autorizzazione o vantaggio economico, la legge fissa oggi un limite invalicabile di **18 mesi**.

La Conservazione dell'Atto: Convalida, Ratifica e Sanatoria

L'ordinamento tende, ove possibile, a conservare i valori giuridici anziché distruggerli. Esistono quindi strumenti per "guarire" l'atto viziato:

- **Convalida:** È l'atto con cui la P.A. elimina un vizio di un provvedimento precedente (es. integrando una motivazione carente). Come l'annullamento, richiede un interesse pubblico e un termine ragionevole.
- **Ratifica:** È un tipo particolare di convalida che interviene quando il vizio è l'**incompetenza relativa**. L'organo competente fa proprio l'atto emanato da un organo incompetente, sanando il vizio soggettivo.
- **Sanatoria:** Si verifica quando un atto o un presupposto mancante nella sequenza procedimentale interviene dopo l'emanazione del provvedimento conclusivo, "regolarizzando" ex post la fattispecie.

Conferma e Conversione

Spesso il privato sollecita la P.A. a riesaminare un atto. L'amministrazione può giungere alla conclusione che l'atto originale fosse corretto. Qui bisogna distinguere:

- **Conferma:** È un nuovo provvedimento che sostituisce il precedente dopo una nuova istruttoria. Essendo un atto nuovo, riapre i termini per l'impugnazione.
- **Atto meramente confermativo:** La P.A. comunica solo che non ci sono motivi per riaprire il caso. Non è un nuovo provvedimento e non può essere impugnato.
- **Conversione:** Simile al modello civilistico, permette a un atto nullo o annullabile di produrre gli effetti di un atto diverso di cui contenga i requisiti di sostanza e di forma.

La Revoca (Art. 21-quinquies)

Mentre l'annullamento colpisce la **legittimità** (vizi di legge), la **revoca** colpisce il **merito** (l'opportunità) di un atto perfettamente valido ed efficace. È l'espressione massima della precarietà del rapporto amministrativo: la P.A. può cambiare idea se l'interesse pubblico lo richiede.

La revoca può avvenire per tre motivi:

1. **Sopravvenuti motivi di pubblico interesse:** La situazione di fatto cambia e l'atto non è più utile alla collettività.
2. **Mutamento della situazione di fatto:** Non previsto al momento dell'emanazione.
3. **Nuova valutazione dell'interesse pubblico originale:** (C.d. revoca per pentimento), ammessa solo se non riguarda provvedimenti di autorizzazione o vantaggi economici.

A differenza dell'annullamento (che agisce *ex tunc*, da allora), la revoca agisce **ex nunc** (da ora): gli effetti prodotti fino a quel momento restano salvi, ma l'atto cessa di esistere per il futuro. Proprio perché colpisce un atto valido su cui il privato ha fatto affidamento, la revoca comporta l'obbligo per la P.A. di corrispondere un **indennizzo** al destinatario per il pregiudizio subito.

Il Recesso (Art. 21-sexies)

Il recesso si distingue dalla revoca perché riguarda i **contratti** della Pubblica Amministrazione. La legge stabilisce che la P.A. può recedere dai contratti solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto stesso, riportando l'azione amministrativa nell'alveo della parità tipica del diritto privato.

La disciplina della **revoca** rappresenta uno dei punti di maggior attrito tra l'esigenza di dinamismo dell'azione amministrativa e la tutela dell'affidamento del privato. Se l'annullamento d'ufficio rimedia a un'illegittimità, la revoca interviene su un atto nato legittimo ma divenuto, nel tempo, non più rispondente all'interesse pubblico. L'**art. 21-quinquies della l. 241/1990** delinea un sistema in cui la discrezionalità della P.A. deve confrontarsi con pesanti conseguenze economiche e limiti procedurali.

Il legislatore distingue nettamente le ragioni che possono spingere un'amministrazione a tornare sui propri passi:

- **La revoca per sopravvenienza:** È l'ipotesi più lineare e giustificabile. Si verifica quando mutano i presupposti di fatto (es. nuove tecnologie che rendono obsoleta una concessione) o quando emergono nuovi interessi pubblici (es. un'area balneare che deve diventare riserva naturale). In questi casi, il provvedimento originale non è più coerente con la realtà attuale.
- **La revoca per "jus poenitendi" (pentimento):** Si ha quando la P.A. non riscontra cambiamenti esterni, ma opera una semplice rivalutazione dei medesimi interessi originali, ammettendo in sostanza di aver sbagliato la valutazione iniziale. Per garantire stabilità economica, dal 2014 questa forma di revoca è **vietata** per i provvedimenti di autorizzazione o che attribuiscono vantaggi economici: se l'amministrazione ha concesso un beneficio, non può toglierlo solo perché ha "cambiato idea", a meno che non intervengano fatti nuovi.

A differenza dell'annullamento, che cancella l'atto dal passato (*ex tunc*), la revoca opera solo per il futuro (*ex nunc*). L'atto smette di produrre effetti dal momento della revoca, ma ciò che è accaduto prima resta valido. Proprio per questo, la revoca riguarda tipicamente atti a **efficacia durevole** (come le concessioni); non avrebbe senso revocare un atto i cui effetti si sono già esauriti o che è stato interamente eseguito. Il vero contrappeso al potere di revoca è l'**indennizzo obbligatorio**. Poiché il privato subisce il ritiro di un atto legittimo, la P.A. deve "pagare" per il suo pentimento. Tuttavia, l'indennizzo non è un risarcimento pieno:

- È limitato al solo **danno emergente** (le spese sostenute), escludendo il lucro cessante (il mancato guadagno).
- È soggetto a riduzioni se il privato ha concorso all'errore di valutazione della P.A. o se l'interesse pubblico contrario all'atto era facilmente conoscibile.

Le controversie su tali somme spettano alla **giurisdizione esclusiva** del Giudice Amministrativo. È essenziale non confondere la revoca discrezionale con altre figure apparentemente simili:

- **Revoca sanzionatoria (o decadenza):** Non deriva da una scelta della P.A., ma dall'inadempimento del privato. Se non rispetti le condizioni di un'autorizzazione, la P.A. la toglie. In questo caso non spetta alcun indennizzo.
- **Mero ritiro:** Riguarda atti non ancora efficaci. È una sorta di "ripensamento a costo zero" che non richiede particolari motivazioni né tutele per il privato, poiché il provvedimento non aveva ancora iniziato a incidere sulla realtà giuridica.

Chiude il quadro il **recesso**, [L'**articolo 21-sexies** della Legge 241/1990] che sposta l'azione amministrativa sul piano del diritto privato. Se la P.A. agisce come un contraente privato, può recedere da un contratto solo se la legge o il contratto stesso lo prevedono. Qui scompare il potere autoritativo e subentra il regime della parità negoziale: la P.A. non può usare la "supremazia" per sciogliersi da un vincolo contrattuale senza basi legali o pattizie certe. L'**articolo 21-sexies** della Legge 241/1990 è una norma brevissima ma di estrema importanza strategica, poiché segna il confine tra il potere autoritativo della Pubblica Amministrazione e la sua attività di diritto comune. Il testo recita:

«Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.»

Per spiegare correttamente questa disposizione, dobbiamo analizzarla sotto tre profili principali: la natura del rapporto, il principio di parità e la differenza con la revoca. Quando la Pubblica Amministrazione stipula un contratto (si pensi a un appalto di lavori o a una fornitura di servizi), essa non agisce più come "autorità" che impone la propria volontà dall'alto, ma come un **soggetto privato**. In questa fase negoziale, il rapporto tra l'ente pubblico e il cittadino (o l'impresa) è paritetico. L'art. 21-sexies serve a ribadire che, una volta firmato un contratto, la P.A. non può più esercitare i suoi tipici

"poteri di supremazia" per sciogliersi dal vincolo a proprio piacimento. Se volesse uscirne, deve sottostare alle stesse regole che valgono per qualsiasi contraente privato nel Codice Civile: il recesso è possibile solo se le parti lo hanno previsto espressamente nel contratto o se esiste una norma di legge specifica che lo autorizzi (come avviene, ad esempio, nel Codice degli Appalti per motivi di sicurezza o infiltrazioni mafiose). Se l'amministrazione recedesse da un contratto al di fuori dei casi previsti, il privato potrebbe rivolgersi al giudice (solitamente il Giudice Ordinario, trattandosi di diritti derivanti da contratto) per chiedere l'adempimento o il risarcimento dei danni, proprio come farebbe contro un qualsiasi altro partner commerciale che non rispetta i patti.

IL PROCEDIMENTO DELL' ATTO AMMINISTRATIVO

Il **procedimento amministrativo** non è una mera successione cronologica di fatti, ma una **struttura logico-giuridica** coordinata, finalizzata a legittimare l'esercizio del potere autoritativo. Per comprenderne l'essenza in termini strettamente giuridici, occorre analizzarlo come lo strumento di mediazione tra la norma astratta e l'assetto concreto degli interessi. In termini di teoria generale, il procedimento rappresenta il passaggio dalla **potestà** (il potere potenziale previsto dalla legge) all'**atto** (l'esercizio concreto di tale potere). Se nel diritto privato l'effetto giuridico discende spesso da un unico atto di volontà, nel diritto pubblico l'effetto è il risultato di una **fattispecie a formazione progressiva**. Ogni atto della sequenza (atti endoprocedimentali come pareri, nulla osta o valutazioni tecniche) non ha una propria autonomia esterna, ma è funzionalmente collegato agli altri: l'invalidità di un singolo atto della catena si riflette, per **invalidità derivata**, sul provvedimento finale.

Sotto il profilo dei principi, il procedimento trasforma il potere in **funzione**. Esso assicura il rispetto del principio del **giusto procedimento** (*due process of law*), che impone all'amministrazione di agire in modo trasparente e partecipato. Questa dimensione giustiziale serve a garantire che il destinatario dell'atto non sia un mero oggetto della potestà pubblica, ma un soggetto titolare di **interessi legittimi**, il quale può interloquire con la P.A. prima che la decisione sia assunta. In questo senso, il procedimento assolve a una funzione di **oggettivazione della scelta**: la decisione finale non è un atto di arbitrio, ma l'esito di un'analisi documentata e razionale di tutti i fatti e gli interessi emersi durante l'iter. Giuridicamente, la partecipazione del privato (artt. 7 e 10 L. 241/90) non è solo una cortesia burocratica, ma un vero e proprio **diritto all'interlocuzione**. Il contraddittorio procedimentale permette l'introduzione di interessi "secondari" (privati o pubblici) che la P.A. ha l'obbligo giuridico di ponderare rispetto all'interesse pubblico "primario". Tale confronto può essere:

- **Verticale**: volto a mitigare l'unilateralità del potere nei rapporti di supremazia (es. procedimenti sanzionatori).
- **Orizzontale**: volto a garantire l'imparzialità nei casi di conflittualità tra privati (es. procedure concorsuali o di gara), dove l'amministrazione funge da regolatore della parità di trattamento.

Infine, il procedimento funge da modulo di **coordinamento amministrativo**. Poiché un singolo intervento può incidere su molteplici ambiti (ambiente, paesaggio, sanità), il procedimento permette la **fusione o il raccordo di diverse competenze**. Attraverso istituti come la *conferenza di servizi*, la sequenza procedimentale diventa il luogo in cui diverse amministrazioni esprimono la propria volontà, garantendo che il provvedimento finale sia espressione di una sintesi unitaria e non frammentata dell'interesse pubblico.

Le leggi generali sul procedimento e la l. n. 241/1990

La **Legge 241/1990** non è un codice minuzioso, ma una **legge-quadro** che definisce l'ossatura logica dell'azione amministrativa. La sua introduzione ha segnato il passaggio da un'amministrazione intesa come apparato autoritario e impenetrabile a una concezione di **amministrazione aperta**, intesa come "casa di vetro". L'applicabilità della legge è definita da un perimetro che si estende oltre la Pubblica Amministrazione in senso stretto:

- **Profilo Soggettivo:** La legge vincola le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le **società a capitale pubblico** (limitatamente alle attività di pubblico interesse). Un dato fondamentale riguarda il riparto di competenze: sebbene Regioni ed Enti locali abbiano autonomia, gli istituti cardine della 241 (termini, responsabile, partecipazione) sono considerati **livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** ai sensi dell'art. 117 Cost. Questo significa che lo Stato impone uno standard minimo di garanzie che le amministrazioni locali possono solo migliorare, mai diminuire.
- **Profilo Oggettivo:** La legge trova piena applicazione nei procedimenti individuali. Tuttavia, subisce delle deroghe per gli **atti normativi** e gli **atti amministrativi generali** (come i piani regolatori), ai quali non si applicano gli obblighi di partecipazione e motivazione analitica, data la loro natura programmatica e non puntuale.

La Legge 241/1990 ha operato una vera e propria "rivoluzione copernicana" attraverso quattro pilastri fondamentali:

- **Dal Provvedimento al Consenso:** Il privato non subisce più solo la decisione finale, ma vi "entra" come **co-amministratore**. La legge privilegia l'uso di **accordi integrativi o sostitutivi** (Art. 11), trasformando l'unilateralità del potere in una convergenza consensuale tra interesse pubblico e privato.
- **Superamento del Segreto d'Ufficio:** Il principio cardine diventa la **Trasparenza**. Il segreto d'ufficio, un tempo regola assoluta, diventa residuale e soccombe di fronte al **diritto di accesso** (Art. 22). La pubblicità non è più una concessione, ma un dovere della P.A. per garantire il controllo democratico.
- **L'Umanizzazione del Potere: Il Responsabile del Procedimento:** Viene abbattuto il muro dell'anonimato burocratico. L'individuazione di un **Responsabile** (Artt. 5 ss.) fornisce al cittadino un interlocutore fisico, garantendo certezza nella gestione della pratica e una chiara imputazione delle responsabilità.
- **Cooperazione tra Amministrazioni:** La legge elimina la "frammentazione" dei poteri. Strumenti come la **conferenza di servizi** (Artt. 14 ss.) e gli **accordi tra P.A.** (Art. 15) obbligano le diverse autorità a parlarsi e coordinarsi, evitando che il cittadino diventi l'unico onerato del peso di raccogliere documenti e pareri (principio di soccorso istruttorio e autocertificazione).

Giuridicamente, la **241/1990** supera la visione atomistica (cittadino-v-Stato) aprendosi alla società civile. Non solo chi subisce un pregiudizio diretto può partecipare, ma anche i portatori di **interessi diffusi** organizzati in associazioni (Art. 9). Questo trasforma il procedimento in un'arena di confronto plurale, legittimando la scelta amministrativa come sintesi sociale e non solo tecnica.

Il procedimento amministrativo si articola in una sequenza dinamica che trasforma il potere astratto in un effetto giuridico concreto. Come hai correttamente esposto, questa sequenza si divide in tre fasi fondamentali: l'**iniziativa**, l'**istruttoria** e la **conclusione**.

1. La Fase dell'Iniziativa: L'Apertura del Procedimento: L'iniziativa segna il passaggio dalla doverosità dell'agire amministrativo al dovere di provvedere.

- **Iniziativa di parte:** Nasce da un'istanza (domanda) del privato che mira a un provvedimento favorevole (interesse legittimo pretensivo). L'obbligo di procedere scatta solo se l'istanza è prevista da una norma di settore.
- **Iniziativa d'ufficio:** L'amministrazione stessa avvia l'iter, spesso dopo attività **preistruttorie** (ispezioni, accertamenti, denunce). Qui il confine è segnato dal momento in cui la P.A. acquisisce la notizia di un fatto che rende necessario l'esercizio del potere.
- **La Comunicazione di avvio (Art. 7):** È l'atto fondamentale per garantire il **contraddittorio**. Deve essere inviata ai destinatari diretti, ai soggetti che per legge devono intervenire e ai controinteressati individuabili. Senza questa comunicazione, il provvedimento è annullabile (salvo i casi di sanatoria dell'art. 21-octies).

2. La Fase Istruttoria: Il Cuore della Decisione: È la fase in cui si accertano i fatti e si acquisiscono gli interessi. È governata dal **principio inquisitorio**, per cui il Responsabile del Procedimento ha ampi poteri di indagine d'ufficio.

- **Il Responsabile del Procedimento (Artt. 5-6):** È l'innovazione della L. 241/90 che "umanizza" la P.A. Funge da guida dell'istruttoria: accerta i fatti, chiede rettifiche, indice conferenze di servizi e redige la relazione finale. Deve astenersi in caso di **conflitto di interessi**.
- La Funzione Consultiva (Pareri e Valutazioni):
 - **Pareri (Art. 16):** Possono essere obbligatori (l'omissione vizia l'atto) o facoltativi. Se vincolanti, la P.A. non può discostarsene.
 - **Valutazioni tecniche (Art. 17):** Sono accertamenti complessi (es. medico-legali) che non possono essere sostituiti da una valutazione discrezionale.
- **Partecipazione e Preavviso di rigetto (Art. 10-bis):** I privati possono presentare memorie e documenti che la P.A. ha l'obbligo di valutare. Nei procedimenti a istanza di parte, se la P.A. intende negare il provvedimento, deve inviare una "comunicazione dei motivi ostativi", concedendo al privato 10 giorni per tentare di convincerla del contrario (il cosiddetto "contraddittorio supplementare").

3. La Fase Conclusiva: La Determinazione Finale: Questa fase porta all'adozione del provvedimento o all'arresto del procedimento.

- **Il Termine (Art. 2):** L'amministrazione ha l'obbligo giuridico di concludere il procedimento entro un termine certo (solitamente 30 giorni, se non diversamente stabilito). Il superamento del termine può configurare il **silenzio-inadempimento**.
- **Decisioni Pluristrutturate:** Non sempre l'atto è emanato da un solo organo.
 - **Concetto:** Una autorità decide, l'altra deve dare il consenso (co-decisione).
 - **Intesa:** Strumento tipico dei rapporti Stato-Regioni. Se l'intesa è "forte", il mancato accordo blocca il provvedimento.
- **Silenzio-Assenso tra P.A. (Art. 17-bis):** Introdotto per accelerare i tempi, stabilisce che se un'amministrazione non risponde a una richiesta di assenso o nulla osta di un'altra P.A. entro 30 (o 90) giorni, l'atto si intende acquisito favorevolmente.

Anatomia della fase decisionale: termini, responsabilità e regimi del silenzio significativo

Il momento in cui il procedimento giunge al termine è dominato da una tensione costante tra due esigenze opposte: da un lato il bisogno della Pubblica Amministrazione di ponderare bene gli interessi in gioco, dall'altro il diritto del cittadino alla certezza dei tempi. L'**articolo 2 della legge 241/1990** cerca di sciogliere questo nodo stabilendo che il tempo non è una variabile indipendente: ogni procedimento deve avere un termine certo. Se l'amministrazione non si dà una regola specifica, scatta il termine residuale di 30 giorni, ma la tendenza generale è quella di non superare mai i 90. Questo non è solo un principio di efficienza, ma di lealtà, perché permette a chiunque di programmare la propria vita o la propria attività economica sapendo quando arriverà una risposta. Tuttavia, bisogna fare attenzione alla natura di questi termini. Nella maggior parte dei casi sono definiti "ordinatori", il che significa che se la P.A. risponde in ritardo, l'atto è comunque valido. Ma questo non significa che il ritardo sia senza conseguenze. Il legislatore ha infatti introdotto una serie di "anticorpi" per punire l'inerzia, che vanno dalla responsabilità disciplinare del funzionario fino al cosiddetto **danno da ritardo**. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché permette al privato di chiedere un risarcimento se l'attesa gli ha causato un danno economico, a prescindere dal fatto che alla fine il provvedimento sia stato di accoglimento o di rigetto. Per i casi più critici, esiste poi il **potere sostitutivo**: se l'ufficio competente dorme, il privato può rivolgersi a un dirigente superiore che deve chiudere la pratica in tempi record, a volte nominando un commissario apposito. Il vero cambio di passo avviene però quando il termine scade nel silenzio assoluto. Qui il diritto amministrativo ha

dovuto inventare delle soluzioni per evitare che il cittadino restasse prigioniero dell'inerzia burocratica. Il regime più moderno e diffuso è quello del **silenzio-assenso** (art. 20). In pratica, se scade il tempo e la P.A. non ha detto "no", la legge interpreta quel silenzio come un "sì". È un provvedimento tacito a tutti gli effetti, che il privato può utilizzare come se avesse l'autorizzazione in mano. È un meccanismo potente che ribalta l'onere dell'inefficienza sulle spalle dello Stato: se non vuoi che il privato faccia qualcosa, devi dirmelo chiaramente e nei tempi previsti. Naturalmente, questa "scorciatoia" non può valere per tutto. Esistono dei confini invalicabili legati alla tutela di **interessi sensibili**: quando si parla di ambiente, salute, beni culturali o sicurezza pubblica, il silenzio non può mai significare assenso. In questi ambiti la cautela prevale sulla celerità, e l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi con un atto espresso. In questi casi, se la P.A. tace, ci troviamo di fronte a un **silenzio-inadempimento**, che non dà alcun diritto al privato se non quello di correre dal giudice per far dichiarare che l'amministrazione ha l'obbligo di rispondere. In definitiva, la fase decisionale è un equilibrio delicatissimo dove il silenzio diventa uno strumento di semplificazione, ma solo finché non entra in gioco la protezione di valori superiori della collettività. Il **silenzio-assenso**, pur essendo nato come una "terapia d'urto" contro la burocrazia pigra, porta con sé dei difetti genetici non trascurabili. Come giustamente osservavi, quando l'amministrazione tace su un provvedimento discrezionale, sta di fatto rinunciando alla sua funzione primaria: quella di "pesare" gli interessi in gioco. Questo silenzio è un'abdicazione che lascia il privato in una sorta di limbo dorato: ha ottenuto ciò che voleva, ma non sa se l'ha ottenuto perché ne aveva diritto o semplicemente perché una pratica è scivolata sotto una pila di fogli. Questa incertezza rende il titolo del privato estremamente fragile, esponendolo a un rischio di **autotutela** (annullamento d'ufficio) molto più alto rispetto a un atto scritto, dove la motivazione funge da scudo e da garanzia. Proprio per superare questa fredda "scorciatoia" del silenzio, l'ordinamento punta sempre di più sugli **accordi integrativi e sostitutivi** (Art. 11). Qui non siamo di fronte a un'amministrazione che tace, ma a un'amministrazione che dialoga. L'accordo trasforma il procedimento in una tavola rotonda dove il contenuto del provvedimento non è più calato dall'alto (unilateralità), ma è il frutto di una negoziazione tra le esigenze del pubblico e le aspettative del privato. È una soluzione che si sposa perfettamente con i poteri discrezionali, dove esiste un margine di manovra per trovare un punto di equilibrio che soddisfi tutti. Nella pratica, questi accordi possono vivere in due forme. Gli **accordi integrativi** sono quasi dei "pre-contratti": le parti si mettono d'accordo sul contenuto, ma poi serve comunque un provvedimento finale che ufficializzi il tutto. Gli **accordi sostitutivi**, invece, sono più radicali: l'accordo stesso prende il posto del provvedimento e produce immediatamente gli effetti voluti. È interessante notare come, per evitare che la P.A. "svenda" l'interesse pubblico in queste trattative, la legge imponga comunque una **determinazione preliminare** dell'organo competente, che fissa i paletti della negoziazione. Anche in questo clima di collaborazione, però, l'amministrazione non spogliarsi mai del tutto della sua veste di autorità. Esiste infatti un potere di **recesso legale** (da non confondere con quello contrattuale che abbiamo visto prima) che permette alla P.A. di sciogliersi dall'accordo se sopravvengono gravi motivi di interesse pubblico. È una sorta di "clausola di salvaguardia" che riconduce l'accordo nell'alveo della revoca: l'amministrazione può cambiare idea, ma deve indennizzare il privato per il pregiudizio subito. In definitiva, se il silenzio-assenso è una risposta sbrigativa a un problema di efficienza, l'accordo è la risposta matura a un bisogno di democrazia e partecipazione, dove il consenso sostituisce l'imposizione senza però sacrificare la cura dell'interesse collettivo.

La complessità e i subprocedimenti

I procedimenti amministrativi possono presentare una struttura semplice oppure complessa, e la differenza dipende dall'oggetto del procedimento, dal numero e dalla natura degli interessi pubblici e privati coinvolti e, di conseguenza, dalla necessità o meno di far intervenire una pluralità di amministrazioni. Mentre nel **procedimento semplice** il rapporto è lineare (domanda → verifica → risposta), nel **procedimento complesso** la struttura si frammenta. Qui entrano in gioco i **subprocedimenti**, che sono vere e proprie "cellule" autonome all'interno del corpo principale. L'aspetto giuridicamente più interessante è che, sebbene la regola generale preveda che solo l'atto finale sia impugnabile, alcuni atti dei subprocedimenti hanno una tale forza da poter essere contestati subito. È il caso delle **esclusioni**: se in una gara d'appalto vieni escluso nella fase di prequalifica, non

devi aspettare che vinca qualcun altro per fare ricorso. Quell'atto, pur essendo interno alla sequenza, ha già prodotto un effetto negativo definitivo nella tua sfera giuridica, diventando un atto "autonomo". Quando l'obiettivo è ambizioso, come la costruzione di una grande infrastruttura, non basta un solo procedimento. Si parla allora di **procedimenti collegati**:

- **In sequenza:** Come i vagoni di un treno (es. l'espropriazione, dove ogni fase deve finire perché inizi la successiva).
- **In parallelo:** Come diversi uffici che lavorano contemporaneamente per darti i vari permessi (urbanistici, sanitari, ambientali) necessari a un unico scopo industriale.

Infine, è utile osservare "verso dove" guarda l'amministrazione quando agisce:

- **Primo grado vs Secondo grado:** I procedimenti di primo grado guardano all'esterno (darti una licenza); quelli di secondo grado (come l'annullamento d'ufficio o la revoca che abbiamo visto prima) guardano "indietro", per correggere o ripensare atti già esistenti.
- **Finali vs Strumentali:** I primi servono a noi cittadini; i secondi servono alla macchina stessa per funzionare (assunzioni, bilanci, gestione uffici).

Si può immaginare una scala che va da un estremo all'altro. Da un lato si collocano i **procedimenti autorizzatori semplici**, nei quali la sequenza procedimentale è essenziale: **vi è una domanda o un'istanza dell'interessato, segue un'istruttoria limitata a poche verifiche documentali e la decisione è rimessa a un'unica autorità amministrativa**. In questi casi l'interesse pubblico è circoscritto e non richiede valutazioni particolarmente articolate. All'estremo opposto si trovano i **procedimenti complessi**, che implicano accertamenti fattuali approfonditi, momenti partecipativi, acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, e spesso il coinvolgimento, anche nella fase decisoria, di una molteplicità di amministrazioni statali, regionali e locali. **Qui l'interesse pubblico è plurimo o intrecciato con altri interessi pubblici**, e ciò impone un **coordinamento tra diversi centri decisionali**. Nei procedimenti complessi è frequente la **presenza di subprocedimenti sequenziali**, ciascuno dei quali presenta una **propria autonomia funzionale**. Questo significa che ogni subprocedimento **svolge una funzione specifica all'interno della sequenza complessiva**. Talvolta tali subprocedimenti si concludono con atti che incidono immediatamente **su situazioni giuridiche soggettive**, producendo effetti esterni autonomi rispetto all'effetto finale del provvedimento conclusivo. In altre parole, non sono meri passaggi interni irrilevanti, ma atti capaci di incidere direttamente sulla sfera giuridica dei destinatari. Un esempio significativo si rinviene nel **procedimento per la conclusione di un contratto pubblico**, in particolare nelle procedure ristrette. In questo caso è prevista una fase di prequalifica finalizzata a individuare, sulla base dei requisiti minimi di capacità tecnica e finanziaria stabiliti dal bando di gara, le imprese ammesse alle successive fasi di presentazione e valutazione comparativa delle offerte, che culminano con l'aggiudicazione. L'atto di non ammissione alla fase successiva, adottato al termine della prequalifica, ha una natura duplice: è un atto endoprocedimentale, perché si inserisce nella sequenza unitaria che va dal bando fino all'aggiudicazione; ma è anche un atto autonomo, in quanto produce effetti giuridici negativi immediati nella sfera del destinatario, escludendolo dalla gara, ed è quindi suscettibile di impugnazione immediata. Non è un semplice passaggio interno privo di rilievo esterno, ma un atto che può essere contestato subito. In termini generali si parla di procedimenti collegati, o connessi, quando una pluralità di procedimenti, avviati in sequenza oppure in parallelo, è funzionale al raggiungimento di un risultato unitario. Nei procedimenti collegati in sequenza, ciascun procedimento costituisce il presupposto logico e giuridico di quello successivo: è il caso dell'espropriazione per pubblica utilità, che si articola in più procedimenti tra loro teleologicamente connessi, tutti orientati al medesimo fine. Diversa è l'ipotesi dei procedimenti collegati in parallelo, come accade nella realizzazione di un impianto industriale, che richiede il rilascio di una pluralità di atti autorizzativi distinti, ciascuno volto a garantire la conformità a specifiche normative, urbanistiche, di sicurezza, sanitarie e così via. I procedimenti sono autonomi sotto il profilo formale, ma convergono verso un unico risultato

sostanziale. Un'ulteriore distinzione riguarda i procedimenti di primo grado e quelli di secondo grado. I procedimenti di primo grado sono diretti all'emanazione di provvedimenti amministrativi con effetti esterni e mirano alla cura diretta di un interesse pubblico, come accade nel rilascio di una licenza o di un'autorizzazione. I procedimenti di secondo grado, invece, hanno ad oggetto provvedimenti amministrativi già emanati e sono finalizzati alla verifica della loro legittimità e della loro perdurante compatibilità con l'interesse pubblico. Rientrano in questa categoria i procedimenti di autotutela e i ricorsi amministrativi, nei quali l'amministrazione riesamina un proprio atto per confermarlo, modificarlo o annullarlo. Si distingue inoltre tra procedimenti finali e procedimenti strumentali. I procedimenti finali sono quelli che incidono nei rapporti esterni tra amministrazione e privati, realizzando direttamente la cura dell'interesse pubblico. I procedimenti strumentali, invece, hanno prevalentemente una funzione organizzativa interna e riguardano, ad esempio, la gestione del personale o delle risorse finanziarie; non sono immediatamente rivolti all'esterno, ma servono a rendere possibile e ordinata l'azione amministrativa. Infine, occorre differenziare tra procedimento in senso proprio e procedura interna all'amministrazione. Il procedimento in senso proprio è costituito da una sequenza di atti disciplinata dalla legge o da fonti normative in senso formale, come i regolamenti, e culmina in un provvedimento amministrativo. La procedura interna, invece, concerne atti e adempimenti che trovano fondamento in regole organizzative interne e che non sono direttamente disciplinati da fonti normative primarie o secondarie. In sostanza, nel primo caso siamo davanti a una sequenza tipizzata dall'ordinamento; nel secondo, a modalità organizzative interne che regolano il funzionamento dell'amministrazione stessa. Il tutto, come sempre nel diritto amministrativo, sembra semplice finché non provi a spiegarlo a voce alta senza respirare a metà frase. Però, sotto la stratificazione terminologica, la logica è lineare: più interessi e più amministrazioni entrano in gioco, più il procedimento si articola e si moltiplica in snodi che, a volte, diventano essi stessi rilevanti sul piano giuridico.

La conferenza di servizi e altre forme di coordinamento

La conferenza di servizi nasce perché, sorprendentemente, quando metti più amministrazioni intorno allo stesso interesse pubblico, ognuna con i propri tempi, pareri e formalismi, il rischio è che il procedimento si trasformi in una staffetta infinita. Nei procedimenti complessi o collegati, infatti, il problema centrale è il coordinamento degli adempimenti e delle tempistiche relative all'adozione di atti imputabili a una pluralità di uffici o amministrazioni competenti. **La legge n. 241 del 1990 individua come strumento principale di coordinamento la conferenza di servizi**, disciplinata nel Capo IV, anche se alcune sue specifiche configurazioni trovano disciplina in leggi speciali. Sul piano descrittivo, la conferenza di servizi consiste in **una o più riunioni dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte**, chiamati a confrontarsi, esprimere il proprio punto di vista e, nel caso della conferenza decisoria, anche a deliberare. Con questo meccanismo viene meno la tradizionale sequenza lineare degli atti endoprocedimentali adottati separatamente da ciascuna amministrazione: il confronto avviene in modo contestuale, e non più frammentato nel tempo. **La legge distingue tre tipi di conferenza.**

1. **La conferenza di servizi istruttoria** è sempre facoltativa e ha la funzione di promuovere un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un unico procedimento o in più procedimenti collegati che riguardino la stessa attività o lo stesso risultato. Quando il procedimento è attribuito alla competenza di una sola amministrazione, la conferenza istruttoria serve a raccogliere, in un unico contesto e con il confronto tra tutti gli uffici interni interessati, gli elementi istruttori che costituiranno la base della decisione finale.
2. Se invece si tratta di una **conferenza interprocedimentale**, cioè relativa a più procedimenti connessi, la convocazione spetta all'amministrazione che cura l'interesse pubblico prevalente. In sostanza, la fase istruttoria viene "compattata" in un momento unitario, così da evitare che ogni ufficio lavori in isolamento.

3. Ben diversa è la **conferenza di servizi decisoria**, che sostituisce i singoli atti di assenso, intese, concerti, nullaosta o autorizzazioni che l'amministrazione procedente dovrebbe altrimenti acquisire separatamente. Essa è convocata dall'amministrazione procedente, anche su richiesta del privato interessato, soprattutto quando sono in gioco atti autorizzativi che condizionano l'avvio di un'attività. La conferenza si conclude con un verbale che riporta le posizioni espresse da ciascuna amministrazione partecipante; sulla base di esso, l'amministrazione procedente adotta una determinazione motivata di conclusione del procedimento, la quale sostituisce a tutti gli effetti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte.

È importante comprendere che la conferenza di servizi non è un organo collegiale in senso proprio: non produce una volontà unitaria imputabile a un nuovo soggetto. Ogni atto di assenso mantiene la propria imputazione all'amministrazione di riferimento. **La conferenza è piuttosto una sede procedimentale di coordinamento**, regolata in modo dettagliato quanto a convocazione, modalità di svolgimento, tempistiche e formazione della decisione. Di regola, oggi la conferenza si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo quanto previsto dal **d.lgs. 127 del 2016**, con l'obiettivo di **accelerare i tempi**. L'amministrazione procedente acquisisce **entro termini prestabiliti le determinazioni motivate delle altre amministrazioni**; decorso inutilmente il termine, opera il silenzio-assenso tra amministrazioni. La conferenza si conclude comunque con una determinazione motivata. Se i dissensi non possono essere superati, nei procedimenti a istanza di parte la conseguenza è il rigetto della domanda. Nei casi di particolare complessità, invece, la conferenza si svolge in forma simultanea e sincrona, cioè con una riunione alla quale sono invitate tutte le amministrazioni interessate. Due sono gli aspetti più rilevanti della disciplina della conferenza decisoria. Il primo riguarda la partecipazione obbligatoria: le amministrazioni invitate devono partecipare con rappresentanti muniti dei poteri necessari per assumere determinazioni vincolanti. L'assenza alla conferenza regolarmente convocata produce un effetto di silenzio-assenso rispetto all'atto di competenza dell'amministrazione non presente. Il secondo aspetto concerne il dissenso. **Con la riforma del 2005 è stato superato il principio dell'unanimità**: la determinazione finale è adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti. La prevalenza non va intesa in senso meramente quantitativo, come voto a maggioranza aritmetica, ma in senso qualitativo, cioè tenendo conto del peso degli interessi pubblici coinvolti. Se invece vi è approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. L'efficacia può però essere sospesa quando il dissenso provenga da amministrazioni preposte alla tutela di interessi pubblici di rango prioritario, come quelli ambientali, paesaggistici, storico-artistici, della salute o dell'incolumità. In tal caso è possibile proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, che convoca una riunione per tentare una soluzione condivisa; se il contrasto permane, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri. Qui si vede chiaramente come il coordinamento amministrativo possa trasformarsi in un problema politico-istituzionale di livello superiore. La conferenza di servizi è dunque soprattutto uno strumento di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, ma in alcuni casi anche i soggetti privati possono partecipare, pur senza diritto di voto, in una logica di maggiore collaborazione. Accanto alla conferenza decisoria e istruttoria, la legge prevede la conferenza di servizi preliminare, che può essere convocata su richiesta motivata di soggetti privati interessati alla realizzazione di progetti particolarmente complessi o di insediamenti produttivi. Il privato presenta uno studio di fattibilità prima ancora di formalizzare le istanze autorizzative, così da acquisire un orientamento preventivo delle amministrazioni competenti. È una sorta di verifica anticipata della "praticabilità amministrativa" del progetto, per evitare di investire tempo e risorse in iniziative destinate a scontrarsi con dinieghi successivi. Oltre alla conferenza di servizi, l'ordinamento conosce ulteriori strumenti di coordinamento. Il Testo unico degli enti locali, **d.lgs. 267 del 2000**, disciplina l'accordo di programma, promosso dal presidente della regione, della provincia o dal sindaco, finalizzato alla definizione e attuazione di opere o interventi che coinvolgono più amministrazioni. A differenza della conferenza decisoria, l'accordo di programma resta fondato sul principio del consenso unanime dei partecipanti.

La stessa **legge n. 241 del 1990** prevede poi gli accordi tra pubbliche amministrazioni, volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L'oggetto è volutamente ampio e generico, così da coprire una vasta gamma di situazioni in cui le amministrazioni devono interagire stabilmente. Un altro strumento è la cosiddetta autorizzazione unica, come quella prevista per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In questo caso la competenza è attribuita alla regione, che convoca una conferenza di servizi entro un termine prestabilito. L'obiettivo è concentrare in un unico titolo abilitativo una pluralità di atti autorizzativi altrimenti distinti. Infine, sotto il profilo organizzativo, assume rilievo lo sportello unico, concepito per semplificare i rapporti tra privati e amministrazioni. Si tratta di un ufficio che funge da tramite tra il cittadino e le amministrazioni competenti a rilasciare atti di assenso, pareri e valutazioni. Lo sportello unico per l'edilizia, ad esempio, si interfaccia con tutti gli uffici comunali e con le altre amministrazioni coinvolte nell'intervento edilizio per il quale il privato richiede il permesso di costruire o presenta una segnalazione certificata di inizio attività. Proprio presso lo sportello unico, di regola telematico, va presentata la **SCIA**. Se guardi l'insieme, il filo conduttore è evidente: l'ordinamento cerca di evitare che la pluralità di competenze si traduca in paralisi. La conferenza di servizi e gli altri strumenti di coordinamento sono tentativi, più o meno riusciti, di far dialogare pezzi diversi dell'apparato amministrativo senza lasciare il privato in mezzo a un labirinto di pareri che non si parlano tra loro. Una forma di razionalità imposta a un sistema che, lasciato a sé stesso, avrebbe la tendenza naturale a complicarsi.

Tipo di procedimento

L'espropriazione per pubblica utilità

L'espropriazione per pubblica utilità è uno di quei procedimenti in cui l'amministrazione tocca un diritto che non è esattamente secondario: la proprietà. E siccome togliere coattivamente un bene a qualcuno non è una passeggiata giuridica, l'ordinamento circonda l'esercizio di questo potere di una serie di garanzie a tutela del privato. Il riferimento normativo è **il d.p.r. 327 del 2001, Testo unico in materia di espropriazioni**, che enuncia anzitutto il principio di legalità: l'espropriazione può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. Nessuna fantasia creativa dell'amministrazione, quindi. Il potere espropriativo è attribuito a tutte le amministrazioni competenti a realizzare un'opera pubblica, dunque Stato, regioni e comuni. Si parla di potere "diffuso", perché non concentrato in un unico soggetto, e di potere accessorio, perché strumentale alla realizzazione dell'opera pubblica. Non si espropria per sport, ma perché serve a costruire qualcosa che l'ordinamento considera di interesse pubblico. **Il Testo unico ha unificato la disciplina prevedendo quattro fasi fondamentali.** La prima è l'**apposizione del vincolo preordinato all'esproprio**. Qui il procedimento espropriativo si collega all'attività di pianificazione urbanistica: il vincolo può derivare da un piano urbanistico, da una variante o dall'approvazione di un progetto preliminare o definitivo di un'opera pubblica. Con il vincolo il bene viene "segnato" come destinato all'espropriazione. Proprio perché già incide sulla sfera giuridica del proprietario, sono previste **garanzie partecipative**: deve essere inviato un avviso di avvio del procedimento, così che il proprietario possa presentare osservazioni entro trenta giorni. Se i destinatari **sono più di cinquanta, si procede con avviso pubblico**. Il vincolo dura **cinque anni**, entro i quali deve intervenire la dichiarazione di pubblica utilità; decorso il termine, il vincolo perde efficacia. Inoltre, trattandosi di un atto già lesivo, è impugnabile davanti al giudice amministrativo. La seconda fase è la **dichiarazione di pubblica utilità**, che accerta la conformità dell'opera all'interesse pubblico e legittima il futuro trasferimento coattivo della proprietà. Negli ultimi anni questa fase è stata in parte "assorbita" da altri atti: in molti casi la dichiarazione è implicita nell'approvazione del progetto definitivo o di un piano di lottizzazione. Si ritiene, infatti, che l'interesse pubblico sia già accertato in re ipsa attraverso tali atti. Anche la dichiarazione di pubblica utilità ha una durata limitata, di regola cinque anni, prorogabile o

diversamente determinata nell'atto stesso. Entro tale termine deve essere emanato il decreto di esproprio; la scadenza è perentoria e comporta l'inefficacia della dichiarazione. **La terza fase è l'emanazione del decreto di esproprio**, che produce l'effetto traslativo del diritto di proprietà dal soggetto espropriato al soggetto beneficiario. Non solo: determina anche l'estinzione automatica dei diritti reali e personali gravanti sul bene, salvo quelli compatibili con le finalità dell'espropriazione. Tuttavia l'efficacia non è immediata, perché è subordinata a due condizioni: la notifica del decreto e la sua esecuzione mediante immissione in possesso entro il termine perentorio di due anni. Solo con l'immissione in possesso si perfeziona l'effetto traslativo. **La quarta fase riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio**. Il decreto deve indicare un importo determinato in via provvisoria, all'esito di un contraddittorio con il proprietario. Dopo che la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta efficace, il promotore della procedura formula un'offerta; il proprietario può presentare osservazioni e indicare il valore che ritiene corretto, eventualmente avvalendosi di propri tecnici. L'autorità determina quindi l'indennità provvisoria. Se il proprietario, **entro trenta giorni**, dichiara irrevocabilmente di accettare, si può procedere alla cessione volontaria del bene, con pagamento immediato dell'importo concordato. Se invece non vi è accettazione, **l'autorità emana il decreto di esproprio e deposita l'indennità presso la Cassa depositi e prestiti**. Da quel momento la determinazione definitiva dell'indennità segue un procedimento autonomo, con ulteriore contraddittorio e l'intervento di una commissione provinciale. Contro la stima definitiva è possibile proporre opposizione davanti alla Corte d'appello entro trenta giorni, per ottenere una determinazione giudiziale dell'indennità. **L'espropriazione resta espressione di un potere unilaterale**, ma **l'ordinamento favorisce soluzioni consensuali tramite la cessione volontaria**, che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo dell'espropriando fino all'esecuzione del decreto. Il vantaggio è economico: l'indennità può essere maggiorata rispetto alla misura ordinaria. L'accordo di cessione produce gli stessi effetti del decreto di esproprio, ma con una dinamica meno conflittuale. La vicenda espropriativa può intrecciarsi con procedimenti collegati in parallelo. Dopo la dichiarazione di pubblica utilità, l'amministrazione può avviare un procedimento di occupazione d'urgenza per acquisire immediatamente la disponibilità materiale del bene e iniziare i lavori. Ciò è possibile quando vi sia un'urgenza tale da non consentire di attendere la conclusione ordinaria del procedimento, nel caso delle grandi opere previste dalla legge obiettivo o quando siano coinvolti più di cinquanta proprietari. Anche qui è previsto il contraddittorio nella fase di immissione in possesso. Un capitolo a parte è la retrocessione, che si fonda sul principio di proporzionalità: la proprietà può essere sacrificata solo nella misura strettamente necessaria al perseguimento dell'interesse pubblico. Se l'opera non viene realizzata entro dieci anni dall'esecuzione del decreto, oppure risulta impossibile realizzarla, il proprietario può chiedere la retrocessione totale del bene e il pagamento di un'indennità. Se invece solo una parte del bene non viene utilizzata, può chiedere la retrocessione parziale. Tuttavia il comune gode di un diritto di prelazione sull'area inutilizzata, potendo acquisirla al proprio patrimonio indisponibile. Infine, va ricordato l'istituto dell'acquisizione sanante, **previsto dall'art. 42-bis**. Esso consente all'amministrazione che abbia occupato sine titolo un bene per finalità di pubblica utilità, e i cui atti siano stati annullati o rimossi, di disporre l'acquisizione non retroattiva al proprio patrimonio indisponibile. Si tratta di una sorta di rimedio ex post a una situazione patologica. Il provvedimento deve prevedere un indennizzo pari al valore venale del bene e un risarcimento del danno, e richiede una motivazione particolarmente rigorosa, con riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, valutate comparativamente con gli interessi privati e con l'esplicita dimostrazione dell'assenza di alternative ragionevoli. Se lo si guarda nel suo complesso, il procedimento espropriativo è il tentativo dell'ordinamento di conciliare un potere incisivo e autoritativo con un sistema di garanzie procedurali e patrimoniali. È la dimostrazione che l'interesse pubblico può prevalere, ma non senza condizioni, non senza termini, e soprattutto non senza pagare il prezzo giuridico ed economico di quella scelta.

Le sanzioni pecuniarie e disciplinari

Tra i provvedimenti che incidono in senso restrittivo sulla sfera giuridica dei destinatari rientrano anche i provvedimenti sanzionatori. Qui l'amministrazione non si limita a organizzare o autorizzare, ma reagisce a una violazione, comprimendo una posizione giuridica del privato. Proprio per questo, il procedimento è costruito in modo da garantire il rispetto del principio del contraddittorio, cioè il diritto dell'interessato a conoscere l'accusa e a difendersi prima che venga adottata la decisione finale. Le principali tipologie di sanzioni amministrative sono quelle pecuniarie e quelle disciplinari. Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, la disciplina generale è contenuta nella legge 689 del 1981, che ha costruito un sistema organico, autosufficiente e speciale rispetto alla legge 241 del 1990. Il procedimento si articola in più fasi. **Si parte dalla fase di accertamento**, che consiste in un'attività di raccolta e prima valutazione degli elementi di fatto idonei a integrare una fattispecie di illecito amministrativo. In questa fase si svolge un'attività che potremmo definire "preprocedimentale": assunzione di informazioni, rilievi descrittivi o fotografici, ispezioni di cose e luoghi. Tali attività sono poste in essere dagli agenti accertatori individuati dalle normative di settore, come gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria o gli organi amministrativi addetti alla vigilanza. Tutto confluisce in un processo verbale che fa piena prova, fino a querela di falso, per quanto riguarda i fatti oggettivamente constatati. In pratica, ciò che l'agente ha visto e documentato si presume vero, salvo prova contraria particolarmente rigorosa. Se dall'accertamento emerge una violazione, si apre la fase della contestazione dell'illecito. Quando possibile, la contestazione deve essere immediata; in ogni caso deve essere notificata entro novanta giorni dall'accertamento. Il termine è perentorio: se scade inutilmente, si estingue l'obbligazione di pagamento. Qui il contraddittorio prende forma concreta, perché entro trenta giorni dalla contestazione l'interessato può presentare scritti difensivi, documenti e chiedere di essere sentito personalmente dall'autorità amministrativa. Inoltre, entro sessanta giorni dalla notificazione, è possibile procedere all'oblazione, cioè al pagamento di una somma ridotta che estingue l'obbligazione senza che si arrivi a un accertamento definitivo dell'illecito. È una sorta di chiusura anticipata del procedimento, conveniente per chi preferisce evitare un contenzioso. Se l'autorità, valutati gli elementi istruttori e l'eventuale audizione, ritiene provata la violazione, adotta l'ordinanza-ingiunzione, un provvedimento motivato con cui determina l'importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento entro trenta giorni, insieme alle spese. In caso contrario dispone l'archiviazione con ordinanza motivata. L'ordinanza-ingiunzione può anche prevedere sanzioni accessorie, come la confisca di beni o la sospensione di una licenza. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo, quindi se non si paga, l'amministrazione può procedere alla riscossione coattiva. Contro l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione davanti al giudice ordinario entro trenta giorni dalla notificazione. **La legge 689 del 1981 rappresenta una disciplina generale delle sanzioni amministrative**, ma spesso le normative di settore introducono deroghe, modificando termini o modalità del contraddittorio. Non è raro che il legislatore, nel nome dell'efficienza, ritocchi le garanzie procedurali. Un'abitudine che il diritto conosce fin troppo bene.

Accanto alle sanzioni pecuniarie vi sono le sanzioni disciplinari, che riguardano in primo luogo i dipendenti pubblici, ma anche altri soggetti sottoposti a poteri di vigilanza, come promotori finanziari o professionisti iscritti ad albi. Anche qui il contraddittorio è centrale. **Il d.lgs. 165 del 2001** prevede che, quando il dirigente o l'ufficio competente venga a conoscenza di un comportamento illecito di un dipendente pubblico, debba contestare per iscritto l'addebito senza indugio e comunque non oltre venti giorni. Il dipendente è convocato con un preavviso di dieci giorni per esercitare il proprio diritto di difesa, potendo farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale. Può anche scegliere di non presentarsi e limitarsi a inviare una memoria scritta. L'amministrazione può svolgere ulteriori attività istruttorie, ad esempio acquisendo informazioni da altre amministrazioni. Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito con l'archiviazione oppure con l'irrogazione della sanzione, che può consistere in un rimprovero scritto, nella sospensione dal servizio o nel licenziamento. I termini sono perentori: il loro superamento comporta la decadenza dall'azione

disciplinare e, simmetricamente, dal diritto di difesa del dipendente. Il tempo, nel diritto disciplinare, non è un dettaglio organizzativo ma una garanzia. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti al giudice ordinario, previo tentativo obbligatorio di conciliazione presso un collegio istituito presso la Direzione provinciale del lavoro o secondo le procedure previste dai contratti collettivi. Per i dipendenti non privatizzati, la giurisdizione resta invece del giudice amministrativo. Nel complesso, il procedimento sanzionatorio mostra bene la tensione tra potestà autoritativa e garanzie difensive. L'amministrazione esercita un potere unilaterale, ma deve farlo rispettando termini, forme e soprattutto il diritto dell'interessato a essere ascoltato. Perché punire è semplice; farlo nel rispetto delle regole è ciò che distingue un potere legittimo da un abuso. E l'ordinamento, almeno sulla carta, questo lo sa.

Le autorizzazioni. Il permesso a costruire e la valutazione di impatto ambientale

Passiamo ora ai procedimenti che si concludono con provvedimenti ad effetti ampliativi della sfera giuridica del destinatario. Qui l'amministrazione non limita o sanziona, ma attribuisce un vantaggio, rimuove un limite legale, consente l'esercizio di un'attività. La disciplina di riferimento si rinviene, oltre che **nella legge 241 del 1990**, anche nella **direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno**, che ha inciso profondamente sulla logica autorizzatoria, spingendo verso semplificazione, proporzionalità e riduzione degli oneri amministrativi. Un esempio paradigmatico è il procedimento per il rilascio del permesso a costruire, disciplinato dal **d.p.r. 380 del 2001**. Il procedimento si avvia con la presentazione della domanda allo sportello unico per l'edilizia del comune, di regola da parte del proprietario dell'immobile. La domanda deve essere corredata dal titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali e dalla documentazione tecnica richiesta. **Entro dieci giorni lo sportello unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento**, figura centrale che cura l'istruttoria. Il responsabile acquisisce i pareri interni degli uffici comunali e quelli eventualmente necessari da parte di altre amministrazioni, come l'Azienda sanitaria locale o i Vigili del fuoco. Se sono richiesti atti di assenso di amministrazioni diverse, può essere convocata una conferenza di servizi, così da concentrare il momento valutativo. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile, verificata la conformità del progetto alla normativa vigente, in particolare agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio, formula una proposta al dirigente competente. Quest'ultimo, nei successivi quindici giorni, rilascia il permesso a costruire. La determinazione è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio. Se i termini decorrono inutilmente, si forma il silenzio-rifiuto. Non è silenzio-assenso, ma l'esatto contrario: l'inerzia equivale a diniego tacito. L'interessato può allora proporre ricorso giurisdizionale oppure presentare un'istanza formale di diffida affinché il dirigente si pronunci entro quindici giorni. Se anche questo termine scade senza esito, può essere attivato il potere sostitutivo della regione, che nomina un commissario ad acta incaricato di provvedere entro sessanta giorni. Il sistema, almeno in teoria, non tollera che l'inerzia amministrativa si traduca in una paralisi indefinita della posizione del privato. Un altro procedimento ampliativo di particolare rilievo è la valutazione di impatto ambientale, la cosiddetta VIA, disciplinata **dal d.lgs. 152 del 2006**. Qui l'effetto ampliativo consiste nella possibilità di realizzare progetti con significativo impatto sul territorio, ma solo all'esito di una verifica approfondita della loro compatibilità ambientale. Il procedimento si apre con la presentazione di un'istanza volta alla verifica preliminare, corredata da uno studio preliminare ambientale. Tale documentazione è pubblicata sul sito web dell'autorità competente, in modo che chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni. Della pubblicazione sono informate le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati. Questa fase di screening serve a stabilire se il progetto debba essere assoggettato alla VIA vera e propria. L'autorità conclude con un provvedimento motivato, anch'esso pubblicato. Se il progetto deve essere sottoposto a VIA, il proponente presenta una nuova istanza corredata della documentazione completa. Prima ancora, può attivare la fase di scoping, chiedendo un parere sulla completezza e sul livello di dettaglio dello studio di impatto ambientale, così da evitare lacune che rallenterebbero il procedimento. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, chiunque può presentare

osservazioni; nei trenta giorni successivi il proponente può replicare con proprie controdeduzioni. L'autorità può indire una consultazione pubblica sotto forma di inchiesta pubblica, rafforzando la dimensione partecipativa del procedimento. Valutati gli apporti partecipativi e la documentazione tecnica, l'autorità può chiedere integrazioni o modifiche progettuali. Nei procedimenti di competenza statale, entro sessanta giorni dalla conclusione della consultazione, l'autorità propone al Ministero dell'Ambiente l'adozione del provvedimento di VIA. Quest'ultimo deve essere analiticamente motivato e può prevedere prescrizioni, misure di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali. Non è un sì o un no astratto, ma un giudizio tecnico-giuridico condizionato. È prevista anche una variante procedimentale in cui il proponente può chiedere che la VIA sia rilasciata nell'ambito di un procedimento unico che ricomprenda tutte le autorizzazioni, intese e nullaosta necessari, con indizione di una conferenza di servizi decisoria. In questo modo si concentra in un'unica sede la valutazione complessiva del progetto, evitando la frammentazione degli assensi. In entrambi i casi, permesso di costruire e VIA, il tratto comune è chiaro: l'effetto ampliativo non è mai automatico, ma subordinato a una verifica di conformità agli interessi pubblici coinvolti. L'amministrazione attribuisce un vantaggio, ma solo dopo aver accertato che quell'espansione della sfera giuridica del privato non comprometta l'assetto normativo, urbanistico o ambientale. La libertà di iniziativa c'è, ma deve dialogare con il territorio, con le regole e con l'interesse collettivo. E il procedimento è il luogo in cui questo dialogo, almeno formalmente, avviene.

I procedimenti concorsuali

Le pubbliche amministrazioni non fanno solo divieti, sanzioni o autorizzazioni: molto spesso distribuiscono risorse. Denaro, beni, vantaggi, opportunità. Alloggi di edilizia economica e popolare, concessioni di beni demaniali, accesso agli impieghi pubblici. Il punto, ovviamente, è che queste utilità non sono infinite. E quando il bene è scarso e gli aspiranti sono molti, l'amministrazione deve scegliere. Non può tirare a sorte né affidarsi all'umore del giorno. Alcuni criteri fondamentali si ricavano direttamente dalla Costituzione. In particolare, gli **artt. 51, comma 1, e 97, comma 3**, stabiliscono, per l'accesso agli impieghi pubblici e più in generale agli uffici pubblici, il principio di eguaglianza e il principio del concorso pubblico. Questo significa che tutti devono poter concorrere in condizioni di parità e che la selezione deve avvenire attraverso una procedura comparativa aperta, non attraverso chiamate discrezionali o scelte opache. I procedimenti di tipo competitivo o concorsuale hanno quindi una funzione ben precisa: selezionare gli aspiranti a una risorsa limitata secondo regole predeterminate e controllabili. La loro struttura è orientata da alcuni principi generali. Il principio di pubblicità impone che la procedura sia resa conoscibile a tutti i potenziali interessati, così da garantire la più ampia partecipazione possibile. Non basta scegliere bene; bisogna consentire a chiunque abbia i requisiti di sapere che quella possibilità esiste. Il principio di parità di trattamento richiede che tutti gli aspiranti siano posti sullo stesso piano, senza favoritismi o discriminazioni. Le regole devono valere per tutti nello stesso modo, e ogni deviazione è fonte di illegittimità. Il principio di trasparenza consente il controllo, sia da parte dei partecipanti sia dall'esterno, sulla corretta applicazione dei criteri di selezione. La procedura deve essere verificabile, ricostruibile, motivata. Non basta dire chi ha vinto; occorre poter capire perché. Infine, il principio di oggettività dei criteri mira a ridurre gli spazi di discrezionalità, privilegiando parametri valutativi il più possibile predeterminati e misurabili. Questo non elimina del tutto la discrezionalità tecnica, ma la incanala entro confini verificabili. Un esempio emblematico è il concorso per l'accesso agli impieghi pubblici, disciplinato **dall'art. 35 del d.lgs. 165 del 2001**. Qui la procedura concorsuale rappresenta la regola ordinaria di reclutamento e costituisce lo strumento attraverso il quale si realizza l'equilibrio tra interesse pubblico al buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e interesse individuale all'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza. In sostanza, quando l'amministrazione distribuisce vantaggi limitati, il procedimento competitivo è il meccanismo che trasforma una scelta potenzialmente arbitraria in una decisione giuridicamente strutturata. È il modo con cui l'ordinamento prova a rendere la scarsità compatibile con

l'eguaglianza. Non sempre riesce in modo perfetto, ma almeno ha il buon senso di provarci attraverso regole e non attraverso preferenze personali.

L'accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il principio di trasparenza si traduce in una posizione giuridica soggettiva concreta. La disciplina si trova negli **artt. 22 e seguenti della legge 241 del 1990** e nel regolamento attuativo contenuto **nel d.p.r. 184 del 2006**. Non si tratta, però, di un potere illimitato di curiosità nei confronti dell'amministrazione: l'accesso riguarda documenti amministrativi già formati e specificamente individuati, e non può trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione. Inoltre, l'amministrazione non è tenuta a elaborare dati o a creare nuovi documenti per soddisfare la richiesta. La richiesta deve essere rivolta a una pubblica amministrazione e deve avere ad oggetto documenti determinati o almeno determinabili. Il regolamento distingue due modalità di esercizio del diritto: l'accesso informale e l'accesso formale. L'accesso informale è possibile quando non vi siano soggetti controinteressati, cioè titolari di interessi alla riservatezza che potrebbero essere lesi dall'ostensione del documento. In questi casi la richiesta può essere anche verbale, viene esaminata immediatamente e, se accolta, si realizza senza formalità particolari, mediante semplice esibizione del documento o rilascio di copia. È la forma più semplice e lineare, quando non emergono conflitti tra trasparenza e tutela di altri interessi. L'accesso formale diventa necessario quando esistono potenziali controinteressati, oppure quando vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, o ancora sull'accessibilità del documento in base alle norme che prevedono esclusioni o limitazioni. In tal caso la richiesta deve essere presentata per iscritto, indicare gli estremi del documento o gli elementi che consentano di individuarlo, ed essere motivata, proprio per dimostrare l'interesse qualificato che fonda la pretesa. L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale, cioè non meramente eventuale o esplorativo, e deve collegarsi a una situazione giuridica soggettiva individualizzata.

Nel procedimento di accesso formale è prevista una fase di contraddittorio con i controinteressati: l'amministrazione deve comunicare loro la richiesta, assegnando un termine di dieci giorni per presentare eventuale opposizione motivata. Qui si vede chiaramente come il diritto di accesso si collochi in equilibrio tra trasparenza e riservatezza. L'accesso è gratuito per quanto riguarda la mera visione dei documenti presso l'ufficio competente; il rilascio di copia comporta di regola il solo rimborso dei costi di riproduzione. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si forma il silenzio-diniego: la richiesta si intende respinta. Il provvedimento espresso che rifiuta, limita o differisce l'accesso deve essere motivato. Se invece l'accesso è accolto, l'atto indica l'ufficio e il periodo, non inferiore a quindici giorni, entro cui l'interessato può prendere visione o ottenere copia. Il procedimento può concludersi anche con un provvedimento di differimento dell'accesso. Il differimento è uno strumento meno drastico del diniego e deve essere preferito quando sia sufficiente a tutelare esigenze temporanee, come il buon andamento dell'azione amministrativa. L'idea è semplice: l'accesso non può essere negato se basta rinviarlo. Una volta concluso il procedimento principale cui il documento si riferisce, di regola non vi sono più ragioni per sottrarre la documentazione alla conoscenza degli interessati. Un caso tipico di differimento riguarda le procedure di affidamento di contratti pubblici: l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è vietato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per evitare interferenze con la regolarità della gara. Contro il diniego espresso o tacito, o contro il differimento, è possibile proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni. La giurisdizione è esclusiva e il rito è accelerato; il giudice può concludere con una sentenza di condanna che ordina l'esibizione dei documenti. In alternativa è previsto un ricorso amministrativo al difensore civico o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri. Tali organi devono pronunciarsi entro trenta giorni; se ritengono illegittimo il diniego o il differimento, lo comunicano all'amministrazione, che può confermare motivatamente il proprio provvedimento entro trenta giorni. In mancanza, si forma un silenzio-assenso e l'accesso è consentito. Accanto all'accesso documentale "classico", esiste poi l'accesso civico disciplinato dal **d.lgs. 33 del 2013**. Qui la logica cambia: non è richiesto un interesse diretto, concreto e attuale né la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata. L'accesso civico si fonda sull'idea che la trasparenza sia un valore in sé, funzionale al controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Anche in questo caso, però, la richiesta deve essere comunicata ai controinteressati, che possono opporsi. Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni. In caso di diniego, è possibile chiedere il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel complesso, il diritto di accesso mostra come la trasparenza amministrativa non sia un gesto di cortesia istituzionale, ma una posizione giuridica strutturata, con regole, termini e rimedi. È uno degli strumenti attraverso cui il cittadino può entrare nel procedimento non solo come destinatario, ma come soggetto capace di conoscere e, se necessario, contestare. E per un potere che tende naturalmente a chiudersi su sé stesso, non è un dettaglio secondario.

I CONTROLLI

La funzione di controllo consiste nel monitorare e verificare l'attività svolta dalle strutture operative. Non è una funzione primaria, nel senso che non realizza direttamente un interesse pubblico sostanziale come fare un'opera o rilasciare un'autorizzazione, ma è accessoria e strumentale: serve a garantire che le funzioni principali siano esercitate correttamente. In un sistema che si fonda sul principio di legalità, l'idea che il potere possa agire senza essere sottoposto a verifica sarebbe, francamente, inquietante. I modelli di controllo sono molteplici. Anche nel diritto privato troviamo esempi significativi: nella società per azioni, accanto all'assemblea e al consiglio di amministrazione, è previsto un organo di controllo interno, il collegio sindacale, che vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Questo schema mostra come la funzione di controllo sia connaturata a qualsiasi organizzazione complessa. A maggior ragione lo è **nelle pubbliche amministrazioni**, la cui attività è **funzionalizzata al perseguimento di interessi pubblici ed è sottoposta al principio di legalità**. Non solo le amministrazioni sono oggetto di controlli, ma esercitano a loro volta funzioni di vigilanza e controllo nei confronti di soggetti pubblici e privati, quando ciò sia necessario per tutelare interessi generali. In ambito giuridico, il controllo può essere definito come una verifica di regolarità di una funzione propria o altrui, oppure come un giudizio di conformità a regole, che comporta, in caso di difformità, l'adozione di misure repressive, preventive o rettificative. Non è quindi un'attività neutra: si fonda su un parametro di valutazione e può sfociare in conseguenze concrete. **Il primo elemento costitutivo del controllo è il soggetto titolare del relativo potere**. Esso deve trovarsi in una posizione di indipendenza e terzietà rispetto al destinatario del controllo, e spesso deve possedere una qualificazione tecnico-professionale adeguata allo standard richiesto. La Costituzione attribuisce alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, oltre alla partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. La Corte dei conti, organo ausiliario del Governo composto da magistrati reclutati prevalentemente per concorso, riferisce direttamente alle Camere. In altri casi il soggetto controllante può trovarsi in posizione di sovraordinazione rispetto al controllato, come accade nei rapporti gerarchici. **Il secondo elemento riguarda i destinatari del controllo**. Essi possono appartenere alla stessa organizzazione dell'organo controllante, e allora si parla di controllo interno, oppure a un soggetto distinto, e si parla di controllo esterno. Un esempio di controllo interno è quello esercitato dal collegio dei revisori in un ente pubblico; un esempio di controllo esterno è quello esercitato dalla Corte dei conti sulle amministrazioni statali o dalla CONSOB sulle società quotate. I controlli esterni possono riguardare sia soggetti pubblici sia soggetti privati che svolgano attività rilevanti per l'interesse pubblico. In questo ambito si parla spesso di funzione di vigilanza, che comprende poteri istruttori, come accessi e

ispezioni, e poteri decisorii, come ordini o sanzioni. **Il terzo elemento è l'oggetto del controllo.** Esso può riguardare singoli atti, e in tal caso si parla di controllo sugli atti, oppure il complesso dell'attività svolta e i risultati conseguiti, configurando un controllo sull'attività o sulla gestione. La differenza non è meramente terminologica: controllare un atto significa verificarne la regolarità formale e sostanziale; controllare la gestione implica valutare l'efficienza, l'efficacia e talvolta l'economicità dell'azione amministrativa. Il quarto elemento è il parametro o standard di valutazione. Esso può essere di natura tecnica, quando si verifica la conformità a regole scientifiche o professionali, oppure di natura giuridica. Nel diritto amministrativo la distinzione più rilevante è quella tra controllo di legittimità e controllo di merito. Il controllo di legittimità ha come riferimento norme e principi giuridici che disciplinano l'attività amministrativa; il controllo di merito, oggi tendenzialmente recessivo, implica una valutazione diretta dell'opportunità e del grado di soddisfazione dell'interesse pubblico. Proprio perché incide sull'autonomia decisionale degli apparati, il controllo di merito è visto con maggiore cautela. Infine, occorre considerare le misure adottabili all'esito del controllo. Esse possono consistere in ordini di adeguamento o di ripristino, nell'annullamento o nella riforma di atti, nell'irrogazione di sanzioni, nello scioglimento di organi o nell'esercizio del potere sostitutivo. Un esempio significativo di potere sostitutivo è quello attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, nel caso di violazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o di grave pregiudizio agli interessi nazionali. In tali ipotesi può essere assegnato un termine all'ente inadempiente e, decorso inutilmente, può essere nominato un commissario che adotti l'atto in sua vece.

I controlli sugli atti e sull'attività

Il controllo sugli atti si distingue anzitutto in preventivo e successivo, a seconda che intervenga prima o dopo che l'atto abbia prodotto i suoi effetti. Nel controllo preventivo l'atto non diventa efficace finché non supera la verifica; nel controllo successivo, invece, l'atto è già efficace e il controllo può eventualmente incidere su di esso in un momento successivo. Sotto un diverso profilo, il controllo può essere di legittimità o di merito. Il controllo di legittimità verifica la conformità dell'atto a norme e principi giuridici; il controllo di merito valuta invece l'opportunità, la convenienza o l'adeguatezza della scelta amministrativa rispetto all'interesse pubblico perseguito. Non è una distinzione puramente teorica: nel controllo di legittimità l'organo controllante si muove entro parametri giuridici vincolanti, mentre nel controllo di merito entra nel cuore della valutazione discrezionale. Le conseguenze dell'esito negativo variano a seconda del tipo di controllo. Se il controllo di legittimità è preventivo, l'atto non può produrre effetti; se è successivo, può condurre all'annullamento dell'atto con effetti ex tunc, cioè retroattivi. Quando il controllo si estende al merito, l'autorità controllante può arrivare a riformare direttamente l'atto oppure a sollecitare un riesame da parte dell'autorità che lo ha emanato. Un esempio significativo è il controllo sugli statuti delle università, che il Ministero competente può sottoporre a rilievi sia di legittimità sia di merito. Storicamente, il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali e locali ha avuto un ruolo centrale. Con l'affermarsi del modello dell'amministrazione di risultato, orientato ai valori di efficienza, efficacia ed economicità, questo modello è stato in parte ridimensionato. **La riforma del Titolo V della Costituzione ha segnato una forte riduzione dei controlli preventivi di legittimità**, sostituiti da forme di controllo maggiormente focalizzate sui profili finanziari e gestionali. A livello statale, il controllo preventivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti è oggi limitato a **un elenco tassativo di atti individuati dalla legge 20 del 1994**. Tra questi rientrano, ad esempio, **i provvedimenti adottati con delibera del Consiglio dei ministri, le piante organiche, il conferimento di incarichi dirigenziali e gli atti normativi a rilevanza esterna**. Il procedimento di controllo deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto, salvo sospensioni per richieste istruttorie. Se il controllo ha esito negativo, il ministro può chiedere al Consiglio dei ministri che l'atto sia comunque ammesso alla registrazione con riserva. In tal caso l'atto acquista efficacia nonostante il rilievo di illegittimità, ma la Corte dei conti ne dà comunicazione al Parlamento. È un equilibrio delicato tra legalità e responsabilità politica: l'atto passa, ma sotto gli occhi delle Camere.

Anche il controllo successivo su singoli atti è oggi molto ridimensionato. La Corte dei conti può tuttavia deliberare motivatamente che singoli atti di notevole rilievo finanziario siano sottoposti al suo esame per un periodo determinato. In questi casi può chiedere il riesame dell'atto entro quindici giorni, ma la richiesta non sospende l'esecutività. L'amministrazione, quindi, non resta paralizzata, ma è chiamata a rivalutare la propria decisione alla luce delle osservazioni ricevute. Diversa è la logica del controllo sull'attività o sulla gestione. Qui non si guarda al singolo atto, ma all'insieme dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alla regolarità contabile e finanziaria e ai risultati conseguiti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Si tratta necessariamente di un controllo successivo, perché implica una valutazione complessiva dei risultati. In attuazione **dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione**, la Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche. Essa verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni, accertando la conformità dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modalità e tempi dell'azione amministrativa. Inoltre controlla il funzionamento dei sistemi di controllo interno delle singole amministrazioni, creando un collegamento tra controlli interni ed esterni. Un momento centrale di questa funzione è l'esame del rendiconto generale dello Stato, che il **Governo presenta alla Corte dei conti entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario**. Il rendiconto viene confrontato con la legge di bilancio e, se risulta conforme, la Corte emette il giudizio di parificazione, trasmettendolo insieme a una relazione al Parlamento entro il 30 giugno. Non è un semplice atto formale: è il passaggio attraverso cui si certifica che le entrate e le spese dello Stato corrispondano a quanto autorizzato.

I controlli gestionali

I controlli gestionali rappresentano la forma principale di controllo interno nelle pubbliche amministrazioni. Non si tratta di verifiche esterne operate da organi terzi, ma di meccanismi interni all'apparato, pensati per monitorare il funzionamento complessivo dell'organizzazione e correggerne eventuali inefficienze. La disciplina generale è contenuta nel **d.lgs. 286 del 1999**, che individua quattro tipologie di controllo interno obbligatorie per tutte le amministrazioni, statali e non statali. Il primo è il controllo di regolarità amministrativa e contabile, diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Qui il parametro è prevalentemente giuridico e contabile: si verifica che gli atti siano conformi alla legge e che la gestione delle risorse rispetti le regole di contabilità pubblica. A seconda dell'amministrazione, il controllo è affidato agli uffici di ragioneria, agli organi di revisione o ai servizi ispettivi di finanza. I criteri di riferimento richiamano i principi della revisione aziendale, asseverati dagli ordini professionali, il che mostra come il controllo amministrativo assorba tecniche proprie dell'ambito economico-contabile. Il secondo è il controllo di gestione, che sposta l'attenzione dal rispetto formale delle regole ai risultati. Esso mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, con l'obiettivo di ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti. È uno strumento operativo a disposizione dei dirigenti, che possono utilizzarlo per correggere tempestivamente eventuali scostamenti e migliorare l'organizzazione del lavoro. Qui la domanda non è solo *"abbiamo rispettato la norma?"*, ma anche *"abbiamo speso bene le risorse per ottenere ciò che dovevamo ottenere?"*. Il terzo tipo riguarda la valutazione della dirigenza pubblica. Con periodicità annuale si procede alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti e delle loro competenze organizzative, anche sulla base dei risultati emersi dal controllo di gestione. Questo controllo non è neutro, perché incide direttamente sulla responsabilità dirigenziale, una forma di responsabilità specifica e distinta da quella disciplinare. Può tradursi, ad esempio, nel mancato rinnovo dell'incarico o in altre conseguenze sul piano professionale. In altre parole, la performance organizzativa diventa parametro di responsabilità personale. **Il quarto è il controllo strategico, volto a valutare l'adequatezza delle scelte compiute nell'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo politico**. Qui l'oggetto non è il singolo atto né la singola gestione, ma la coerenza complessiva tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti. Si analizza la congruenza tra le missioni affidate, le scelte operative adottate e le risorse assegnate, individuando eventuali

scostamenti, fattori ostativi, responsabilità e possibili rimedi. È un controllo che collega la dimensione politica dell'indirizzo alla dimensione amministrativa dell'attuazione. Nel loro insieme, questi controlli segnano il passaggio da un'amministrazione centrata solo sulla legalità formale a un'amministrazione orientata ai risultati. Non basta che l'azione sia conforme alla legge; deve anche essere efficace, efficiente, economicamente sostenibile e coerente con gli obiettivi strategici. Il sistema dei controlli interni diventa così una sorta di specchio permanente dell'apparato: se funziona, riflette criticità e margini di miglioramento; se è solo formale, diventa l'ennesimo adempimento burocratico che controlla tutto tranne ciò che davvero conta.

LA RESPONSABILITÀ

Da un punto di vista storico, la responsabilità dello Stato per i comportamenti o gli atti illeciti dei propri agenti non è affatto un dato originario. Al contrario, il punto di partenza è rappresentato dal principio dell'immunità del sovrano, sintetizzato nella celebre formula inglese "*The King can do no wrong*". In questa prospettiva, il sovrano era per definizione infallibile sul piano giuridico: se non può fare torto, non può nemmeno essere chiamato a risponderne. La responsabilità, semplicemente, non esisteva. Con l'affermarsi dello Stato di diritto, questo schema ha iniziato progressivamente a incrinarsi. Il potere pubblico ha cessato di essere concepito come espressione di una volontà insindacabile e ha cominciato a essere ricondotto entro limiti giuridici. L'idea che l'amministrazione fosse sottoposta alla legge e che i suoi atti potessero essere sindacati ha comportato, come conseguenza logica, anche la possibilità di affermarne la responsabilità in caso di violazione. In una prima fase, tuttavia, la responsabilità non era direttamente imputata allo Stato, ma ai singoli funzionari. Si riteneva che l'illecito fosse un fatto personale dell'agente, e che solo quest'ultimo dovesse risponderne. Era una soluzione formalmente coerente con l'idea di sovranità, ma poco soddisfacente sul piano sostanziale: il cittadino danneggiato si trovava spesso a dover agire contro un soggetto privo di adeguate risorse patrimoniali. L'evoluzione successiva ha portato al riconoscimento di una responsabilità diretta dell'amministrazione, fondata sull'idea che l'azione dell'agente sia imputabile all'ente di appartenenza. Nello Stato di diritto, infatti, il potere non è esercitato a titolo personale, ma in nome e per conto dell'amministrazione. Se l'azione è funzionalmente riferibile all'ente, anche la responsabilità deve esserlo. In questo percorso si consolida l'idea che la pubblica amministrazione non sia al di sopra dell'ordinamento, ma ne sia parte. La responsabilità diventa così il corollario del principio di legalità: se il potere è limitato dalla legge, la sua violazione genera conseguenze. L'immunità cede il passo alla sindacabilità, e il dogma dell'infallibilità sovrana viene sostituito dal principio, molto meno suggestivo ma decisamente più civile, secondo cui anche lo Stato può sbagliare. E, se sbaglia, deve risponderne.

L'art. 28 della Costituzione e gli sviluppi successivi

La responsabilità della pubblica amministrazione nel nostro ordinamento trova il suo fondamento nell'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti; e in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. È una disposizione che, letta con attenzione, segna il definitivo superamento dell'idea di immunità del potere pubblico. Il richiamo alle "leggi civili" rinvia alle regole codicistiche in tema di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale. Ciò significa che anche l'amministrazione, quando le ne ricorrono i presupposti, può essere chiamata a rispondere secondo gli schemi generali del diritto civile, senza la creazione di un regime speciale di irresponsabilità. A una prima lettura, la formulazione **dell'art. 28** potrebbe far pensare che la responsabilità personale del dipendente sia centrale e che quella dell'amministrazione sia solo accessoria. Si potrebbe cioè ritenere che la responsabilità dell'ente abbia carattere sussidiario, nel senso che il danneggiato dovrebbe agire anzitutto contro il dipendente autore dell'illecito e solo in un secondo momento, qualora questi non disponga di un patrimonio sufficiente, contro l'amministrazione. Inoltre, sembrerebbe trattarsi di una responsabilità parallela, nel senso che quella dell'ente presupporrebbe necessariamente l'accertamento della responsabilità

personale del funzionario. Questa lettura, però, non è quella accolta in via dominante. L'interpretazione prevalente considera la responsabilità del dipendente e quella dell'amministrazione come solidali, ai sensi dei principi generali in materia di obbligazioni solidali. Ciò comporta che il danneggiato può agire indifferentemente contro l'uno o contro l'altra, o contro entrambi, per ottenere l'integrale risarcimento del danno. Non vi è, quindi, un ordine obbligato di azione né un carattere meramente sussidiario della responsabilità dell'ente. Inoltre, la responsabilità dell'amministrazione non è necessariamente parallela a quella del dipendente in senso stretto. Essa può essere configurata anche sulla base dell'immedesimazione organica: l'azione del funzionario, quando è compiuta nell'esercizio delle sue funzioni, è imputabile direttamente all'ente. L'illecito non è solo "personale", ma diventa un illecito dell'amministrazione stessa. In questo modo si evita che il cittadino debba inseguire il singolo funzionario, spesso privo di adeguate garanzie patrimoniali, e si riconosce che il potere è esercitato in nome e per conto dell'ente. Naturalmente, nei rapporti interni tra amministrazione e dipendente può operare un'azione di rivalsa, qualora ricorrano i presupposti, ma questo riguarda il piano interno e non incide sul diritto del terzo danneggiato.

La responsabilità civile da comportamento illecito

Quando la responsabilità della pubblica amministrazione riguarda **meri comportamenti**, cioè condotte non riconducibili all'esercizio di un potere e non sfociate in un provvedimento, il modello va ricostruito distinguendo tre rapporti: quello tra il terzo danneggiato e il dipendente autore del fatto; quello tra il terzo e l'amministrazione; e infine il rapporto interno tra amministrazione e dipendente. Sul primo piano, la responsabilità del funzionario e quella dell'amministrazione sono **dirette e solidali**. Il danneggiato può scegliere se agire contro il dipendente, contro l'ente o contro entrambi. L'art. 22 del d.p.r. 3/1957 stabilisce infatti che l'impiegato che cagioni un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo, ma l'azione può essere esercitata congiuntamente a quella contro l'amministrazione. Non c'è quindi un obbligo di escutere prima il funzionario per poi, solo se incapiente, rivolgersi all'ente. La solidarietà rafforza la tutela del terzo.

Il secondo profilo è ancora più interessante: l'area della responsabilità dell'amministrazione è **più ampia** di quella del dipendente. Quest'ultimo risponde personalmente solo in caso di dolo o colpa grave per i danni arrecati nell'esercizio delle sue funzioni. Se vi è colpa lieve, l'azione può essere proposta solo contro l'amministrazione. In questo modo si rompe il parallelismo tra le due responsabilità. Lo stesso accade quando non sia possibile identificare il dipendente che ha materialmente posto in essere la condotta dannosa: purché sia accertato che il fatto sia riferibile a un dipendente di quella amministrazione, l'ente può essere chiamato a rispondere. L'apparato non può schermarsi dietro l'anonimato organizzativo. Il terzo rapporto è quello interno. Se l'amministrazione ha risarcito il danno al terzo, può esercitare azione di regresso contro il dipendente, secondo i principi della responsabilità amministrativa. Qui il problema non è più la tutela del danneggiato, ma l'equilibrio interno tra ente e agente. Occorre poi distinguere tra illecito derivante da meri comportamenti e illecito conseguente all'emanazione di provvedimenti illegittimi. Nel primo caso rientrano, ad esempio, i danni causati da un incidente con un mezzo militare o quelli subiti da uno studente per omessa vigilanza. **Si applica l'art. 2043 c.c.**: occorre una condotta dolosa o colposa, un danno ingiusto e il nesso di causalità. La condotta può consistere sia in un'azione sia in un'omissione o ritardo ingiustificato rispetto ad atti dovuti per legge o regolamento. In quest'ultima ipotesi, l'azione risarcitoria deve essere preceduta da una diffida formale. Se l'illecito deriva da un organo collegiale, i membri rispondono solidalmente, salvo che abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso. Perché sorga responsabilità, la condotta deve essere imputabile all'agente ai sensi **dell'art. 2046 c.c.**, quindi non deve ricorrere incapacità di intendere e di volere, e deve essere riferibile all'amministrazione in base al principio di **immedesimazione organica**. Il rapporto organico si spezza solo in caso di "frattura", quando il dipendente agisce per fini personali ed egoistici del tutto estranei alle sue funzioni. Il criterio è quello dell'"occasionalità necessaria": occorre verificare se il comportamento,

anche abusivo o penalmente rilevante, si inserisca comunque in un'attività funzionalmente collegata ai fini istituzionali dell'ente. Quanto alla colpa, la giurisprudenza ha chiarito che la discrezionalità amministrativa non è uno scudo assoluto. Anche nelle scelte discrezionali l'amministrazione deve rispettare le comuni regole di diligenza e prudenza, oltre al principio generale del **neminem laedere**. La discrezionalità non autorizza l'imprudenza. Il tema dell'ingiustizia del danno ha conosciuto un'evoluzione decisiva. Prima della **sentenza 500/1999 della Cassazione**, si riteneva che fosse risarcibile solo il danno derivante dalla lesione di un diritto soggettivo, non quello conseguente alla lesione di un interesse legittimo. Ciò comportava l'esclusione della responsabilità per danni da provvedimenti amministrativi illegittimi. Tuttavia, la giurisprudenza aveva già iniziato ad aggirare questa rigidità in alcune ipotesi, come l'occupazione di un terreno in base a un decreto di esproprio illegittimo: una volta annullato il provvedimento, il diritto soggettivo del proprietario si riespandeva retroattivamente, e l'occupazione diventava abusiva, **configurando un illecito ex art. 2043 c.c.** Diversamente, si negava il risarcimento nel caso di diniego illegittimo di un provvedimento favorevole, che incideva su un interesse legittimo pretensivo. Ed è proprio su questo punto che la **sentenza 500/1999** ha segnato la svolta, riconoscendo la risarcibilità anche del danno da lesione di interesse legittimo. In sostanza, il percorso è chiaro: da un sistema che proteggeva l'amministrazione quasi per definizione, si è arrivati a un modello in cui anche l'esercizio scorretto del potere può generare responsabilità risarcitoria. Non perché lo Stato sia diventato improvvisamente fragile, ma perché il principio di legalità, se preso sul serio, comporta una conseguenza inevitabile: se il potere viola la legge e danneggia, deve rispondere.

La risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi

Con la **sentenza n. 500 del 1999 la Corte di Cassazione** ha compiuto un passaggio che, per il **diritto amministrativo italiano**, è stato quasi sismico: ha superato la tradizionale irrisarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo. La svolta è avvenuta attraverso una **rilettura dell'art. 2043 c.c.** La norma non viene più intesa come disposizione "secondaria", che si limita a sanzionare la violazione di un divieto posto da altre norme primarie, ma come norma essa stessa primaria, che stabilisce un criterio generale di tutela risarcitoria per il danno ingiustamente subito. Non è più necessario individuare una norma che attribuisca un diritto soggettivo espressamente violato; ciò che conta è che sia stata lesa una posizione giuridicamente rilevante. Il baricentro si sposta così dalla qualificazione formale della situazione giuridica soggettiva alla verifica sostanziale della sua rilevanza nell'ordinamento. Non importa più se si tratti di diritto soggettivo o di interesse legittimo: ciò che rileva è la lesione di un interesse giuridicamente protetto. A questo punto diventa decisivo stabilire quando un interesse possa dirsi giuridicamente rilevante. La Corte propone un criterio di valutazione comparativa: occorre verificare, alla luce del diritto positivo, con quale intensità e consistenza l'ordinamento tutela l'interesse del danneggiato rispetto agli interessi contrapposti. Non tutti gli interessi legittimi sono automaticamente risarcibili. Il nodo centrale è il collegamento con il cosiddetto "bene della vita". Perché il danno sia risarcibile, occorre che il provvedimento illegittimo abbia inciso sull'interesse al bene della vita cui l'interesse legittimo si correla. Nel caso degli interessi legittimi oppositivi, il collegamento è immediato: il bene della vita consiste nella conservazione di una situazione di vantaggio che il provvedimento mira a comprimere o eliminare. Se l'atto è illegittimo, la lesione del bene della vita è evidente. Più complessa è la situazione degli interessi legittimi pretensivi, che si configurano quando il privato aspira all'emanazione di un provvedimento favorevole. Qui la lesione può derivare da un diniego illegittimo o da un ritardo ingiustificato. In questi casi non basta l'illegittimità dell'atto: occorre un giudizio prognostico, condotto alla luce della normativa di settore, per verificare se l'istanza fosse fondata. Bisogna accertare se il privato fosse titolare non di una mera aspettativa, ma di una posizione tale da generare un obiettivo affidamento circa l'esito favorevole del procedimento. In altre parole, occorre stabilire se, secondo un criterio di normalità, il provvedimento avrebbe dovuto essere positivo. Questo accade tipicamente nei casi di potere vincolato, dove la discrezionalità è assente o ridotta. Nei casi in cui non sia possibile accertare con certezza

l'acquisizione del bene della vita, ma solo in termini probabilistici, il risarcimento può riguardare la cosiddetta perdita di chance. Si pensi alle procedure di gara: se, annullata l'aggiudicazione illegittima, risulta che l'impresa seconda classificata avrebbe certamente ottenuto il contratto, il danno è pieno; se invece occorre una nuova valutazione discrezionale, la lesione riguarda la possibilità concreta di aggiudicarsi il contratto, non la certezza del risultato. **La sentenza 500/1999** chiarisce anche che l'illegittimità del provvedimento non implica automaticamente la colpa dell'amministrazione. Non vi è responsabilità "*in re ipsa*". Il giudice deve accertare se l'illegittimità derivi dalla violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità. Inoltre, la colpa va riferita all'apparato nel suo complesso, non al singolo funzionario.

Sul piano probatorio, la giurisprudenza amministrativa ha alleggerito l'onere del danneggiato facendo ricorso alle presunzioni semplici: l'illegittimità può costituire un indizio di colpa, soprattutto se accompagnata da elementi come la chiarezza della norma violata, il carattere vincolato del potere o la mancata considerazione dell'apporto partecipativo del privato. Spetta poi all'amministrazione dimostrare che l'errore fosse scusabile, ad esempio per incertezza normativa o contrasti giurisprudenziali. Dal punto di vista processuale, l'azione risarcitoria per lesione di interesse legittimo rientra oggi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Può essere proposta congiuntamente all'azione di annullamento o in via autonoma. Il termine per proporla è di 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento, un termine molto più breve rispetto alla prescrizione quinquennale ordinaria. Inoltre, il giudice può ridurre o escludere il risarcimento se il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno con l'ordinaria diligenza, anche utilizzando tempestivamente gli strumenti di tutela. Una figura specifica è il danno da ritardo, che si configura quando l'amministrazione non conclude il procedimento **nei termini previsti dall'art. 2 della legge 241 del 1990**. **L'art. 2-bis** prevede la risarcibilità del danno ingiusto derivante dall'inosservanza dolosa o colposa del termine. Qui emerge l'idea che il tempo dell'azione amministrativa sia esso stesso un bene giuridicamente rilevante, la cui violazione può generare responsabilità. Infine, la responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione trova applicazione quando l'ente agisce secondo moduli di diritto privato. **In tali casi si applicano gli artt. 1218 e seguenti del codice civile**. Analogamente, la responsabilità precontrattuale, fondata sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative, è ormai pienamente riconosciuta anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nel complesso, **la sentenza 500/1999** ha segnato il passaggio da un sistema che proteggeva l'amministrazione dalle conseguenze patrimoniali dell'esercizio illegittimo del potere a un modello in cui anche l'interesse legittimo può fungere da base per la tutela risarcitoria. Non è stato un gesto di generosità verso i privati, ma la presa d'atto che il principio di legalità, se serio, deve avere anche un prezzo quando viene violato.

La responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa trova il suo fondamento **nell'art. 18 del d.p.r. 3/1957**, secondo cui l'impiegato è tenuto a risarcire all'amministrazione i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Si parla, in questo caso, di **danno erariale diretto**, cioè del pregiudizio patrimoniale subito dall'ente a causa del comportamento illecito del proprio dipendente. Un'ipotesi particolare è quella del cosiddetto **danno erariale indiretto**, che si verifica quando l'amministrazione sia stata condannata a risarcire un terzo per un fatto del dipendente e agisca poi in regresso nei suoi confronti. Esempi tipici di danno erariale sono il danneggiamento di beni dell'amministrazione, spese inutili o consulenze superflue affidate senza necessità, oppure operazioni economicamente svantaggiose. Le condotte che possono dar luogo a responsabilità amministrativa sono in linea di principio atipiche, anche se il legislatore interviene sempre più spesso a individuare fattispecie specifiche. **Si pensi alla legge 190 del 2012**, che prevede la possibile responsabilità del dirigente preposto alla prevenzione della corruzione per danno erariale e danno all'immagine qualora non abbia vigilato sull'attuazione del piano anticorruzione. Questa forma di responsabilità attiene al rapporto interno tra dipendente e

amministrazione e costituisce una particolare declinazione della responsabilità del lavoratore subordinato verso il datore di lavoro per violazione dei doveri di diligenza. Tuttavia il regime non coincide con quello civilistico ordinario: si tratta di una disciplina ibrida, con finalità prevalentemente risarcitoria ma talvolta anche sanzionatoria. Le principali fonti sono il **r.d. 1214/1934**, che contiene il **Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti**, e la **legge 20 del 1994**. Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità amministrativa si applica a funzionari, impiegati, agenti pubblici e amministratori di amministrazioni statali e non statali, nonché di enti pubblici. La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la nozione di “agente pubblico”, includendovi anche soggetti esterni legati da un rapporto di servizio, come progettisti, direttori dei lavori o collaudatori in opere finanziate con fondi pubblici, pur se liberi professionisti. Più controversa è stata l'estensione agli amministratori di società a partecipazione pubblica. La Cassazione ha chiarito che, in linea di principio, le società pubbliche non coincidono con la pubblica amministrazione, salvo il caso delle società in-house o di enti che, per particolari deroghe legislative, risultino sostanzialmente assimilabili a p.a. In questi casi, il regime della responsabilità amministrativa si applica pienamente. La responsabilità ha natura personale: ciascuno risponde per la parte di danno a lui imputabile. Tuttavia, in presenza di dolo o di illecito arricchimento, la responsabilità diventa solidale. Nelle deliberazioni collegiali rispondono soltanto coloro che hanno espresso voto favorevole. Sotto il profilo oggettivo, la responsabilità sorge per fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave. È esclusa la responsabilità per colpa lieve. Inoltre, quando il danno deriva da un provvedimento amministrativo, resta ferma l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali: la Corte dei conti non può sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni di opportunità, proprio per non paralizzare l'autonomia gestionale. Il danno risarcibile non riguarda solo l'amministrazione di appartenenza, ma può estendersi ad altre amministrazioni o enti: si parla in tal caso di **danno obliquo**. Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal fatto o, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta del danno. Nella quantificazione si tiene conto del decremento patrimoniale o della mancata entrata subita dall'ente. In alcuni casi si aggiunge il danno all'immagine, come nelle ipotesi di corruzione. Devono però essere scomputati i vantaggi eventualmente conseguiti dall'amministrazione o dalla collettività. Una peculiarità significativa è il cosiddetto potere riduttivo della Corte dei conti, che può porre a carico del responsabile tutto o solo parte del danno accertato. Questo potere consente di modulare la condanna in rapporto alla gravità della condotta e alla concreta situazione del soggetto, evitando conseguenze sproporzionate rispetto al fatto. Sotto il profilo processuale, la responsabilità amministrativa è accertata in un giudizio davanti alla Corte dei conti. È un sistema che, pur muovendosi nell'ambito della responsabilità patrimoniale, mantiene una forte connotazione pubblicistica: non si tratta solo di riparare un danno, ma di garantire che la gestione delle risorse pubbliche avvenga nel rispetto dei doveri di servizio. Perché quando si maneggiano soldi pubblici, l'errore non è solo un errore: è un costo collettivo.

PROFILI ORGANIZZATIVI

Un'organizzazione è, in sostanza, un'unità di persone strutturata in modo stabile per perseguire scopi comuni che i singoli, da soli, non riuscirebbero a realizzare. Non basta mettere insieme individui: occorre una struttura gestionale che distribuisca funzioni, assegni ruoli, attribuisca compiti e responsabilità. Senza questa architettura interna, l'organizzazione si riduce a un gruppo disordinato. Nel caso delle pubbliche amministrazioni, l'organizzazione non è lasciata all'improvvisazione, ma è disciplinata da una pluralità di fonti normative, che si collocano su diversi livelli. Al vertice si trova la Costituzione. L'art. 97 pone i principi di imparzialità e buon andamento, che non riguardano solo l'attività amministrativa ma anche l'assetto organizzativo. Lo stesso articolo stabilisce che nell'ordinamento degli uffici siano determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari. L'art. 5 afferma il principio autonomistico; l'art. 114 chiarisce che la Repubblica è composta da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, tutti qualificati come enti autonomi. La Costituzione prevede inoltre l'organizzazione secondo ministeri, demandando alla legge statale la determinazione del loro numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione, e dedica

l'intero Titolo V all'assetto e ai poteri degli enti territoriali. A livello legislativo primario si collocano le norme che disciplinano l'organizzazione dei ministeri, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali e di numerosi enti pubblici. Le fonti sublegislative, come regolamenti governativi e regolamenti di organizzazione, definiscono in concreto le linee fondamentali degli uffici. Le regioni, attraverso statuti e leggi regionali, disciplinano la propria organizzazione e quella degli apparati regionali. Analogamente, gli enti locali adottano statuti e regolamenti per regolare l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Dal complesso di queste fonti emergono alcuni principi generali.

1. **Il principio del buon andamento incide sia sull'attività sia sull'organizzazione.** In quest'ultima dimensione si traduce, ad esempio, nel reclutamento del personale tramite concorso e nella programmazione delle piante organiche secondo esigenze effettive. L'organizzazione deve essere funzionale al risultato, non un fine in sé.
2. **Il principio di imparzialità si riflette anch'esso sull'assetto organizzativo.** Esso trova espressione nella distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa: ai vertici politici spettano indirizzo e controllo, ai dirigenti la gestione. È il tentativo di evitare che la politica invada l'amministrazione operativa. Lo stesso principio è alla base dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, che impone ai responsabili del procedimento e ai titolari di uffici di dichiarare situazioni di incompatibilità.
3. **Il principio di pubblicità e trasparenza** ha assunto una dimensione organizzativa con la normativa anticorruzione. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti dati relativi alla struttura organizzativa, alle competenze degli uffici e alle risorse disponibili. È prevista la figura del responsabile della trasparenza, di regola coincidente con il responsabile della prevenzione della corruzione, che vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e segnala eventuali inadempienze agli organi competenti. È inoltre previsto un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che pianifica le misure necessarie a garantire l'effettività degli obblighi informativi.
4. **Il principio autonomistico**, sancito dall'art. 5 e ribadito dall'art. 114, supera la concezione centralistica dello Stato come vertice sovraordinato a ogni altro apparato. Gli enti territoriali godono di autonomia statutaria, finanziaria e normativa; le funzioni amministrative sono distribuite secondo il principio di sussidiarietà verticale, per cui spettano al livello di governo più vicino ai cittadini, salvo esigenze di esercizio unitario. Questa autonomia trova però un bilanciamento nel principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, che impone consultazione, coordinamento e reciproca informazione.

Infine, dopo la riforma costituzionale del 2012, l'art. 97 impone alle pubbliche amministrazioni di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Anche questo è un principio organizzativo: non basta essere imparziali ed efficienti, occorre anche non compromettere la stabilità finanziaria.

Persone giuridiche, organi uffici

L'art. 11 del codice civile stabilisce che province, comuni ed enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. In altre parole, le persone giuridiche pubbliche hanno, in linea generale, la stessa capacità giuridica delle persone giuridiche private, salvo le deroghe previste da norme speciali. Non sono entità misteriose sospese sopra il diritto comune: sono soggetti di diritto, con una propria capacità, anche se inseriti in un regime pubblicistico. La teoria dell'organizzazione ruota attorno a tre concetti fondamentali: **persona giuridica**, **organo (e ufficio)** e **persona fisica titolare dell'organo**. La personalità giuridica è l'attitudine riconosciuta dall'ordinamento a essere titolari di diritti e doveri. È attribuita sia alle

persone fisiche sia alle persone giuridiche. La persona giuridica è dunque un'organizzazione formalmente considerata come soggetto distinto dalle persone fisiche che ne fanno parte. È un centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche. Tra le persone giuridiche private si distinguono strutture associative, in cui prevale l'elemento personale, e fondazioni, in cui prevale l'elemento patrimoniale. Anche tra le persone giuridiche pubbliche si ritrovano modelli simili: enti a base associativa, come ordini professionali o federazioni sportive, ed enti a prevalente carattere patrimoniale, come molti enti previdenziali. Le persone giuridiche private nascono su base negoziale: atto costitutivo, accordo associativo o atto unilaterale nel caso delle fondazioni. La personalità si acquista con il riconoscimento, che avviene mediante iscrizione nei registri previsti dalla legge; per le società per azioni, ad esempio, con l'iscrizione nel registro delle imprese. Gli enti pubblici, invece, sono istituiti per legge quando si tratta di enti a statuto singolare, oppure mediante atti amministrativi quando una legge generale prevede una categoria di enti. **L'art. 4 della l. 70/1975** sancisce un principio netto: nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge. La legge istitutiva ne definisce finalità, struttura organizzativa e poteri. Per operare nei rapporti esterni, la persona giuridica si avvale di organi. L'organo è un centro di competenza: attraverso la persona fisica che ne è titolare, la persona giuridica manifesta la propria volontà. Qui entra in gioco il rapporto di immedesimazione organica: l'atto posto in essere dalla persona fisica nell'esercizio delle sue funzioni è direttamente imputato alla persona giuridica. Non è una semplice trasmissione di effetti, ma una vera identificazione funzionale. La persona giuridica, che è un'entità astratta, "vuole" e "agisce" tramite il suo organo. Diverso è il modello della rappresentanza, tipico dei rapporti tra persone fisiche. Il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato; l'atto è riferibile al rappresentante, ma gli effetti si producono nella sfera giuridica del rappresentato, entro i limiti della procura. Se il rappresentante eccede i poteri, l'atto non vincola il rappresentato salvo ratifica. Questo schema presuppone una duplice volontà e si adatta meno al funzionamento delle persone giuridiche pubbliche, dove la volontà dell'ente coincide strutturalmente con quella dell'organo. Accanto agli organi vi sono gli uffici, che sono unità operative interne definite dall'organigramma. Gli uffici svolgono attività strumentali e interne; non impegnano l'ente verso l'esterno, salvo che si tratti di uffici-organo, cioè uffici il cui titolare ha anche poteri di rilevanza esterna. Negli enti privati l'organizzazione interna è tendenzialmente libera; nelle pubbliche amministrazioni, **invece, l'art. 97 Cost. prevede una riserva di legge relativa sull'ordinamento degli uffici**, che deve essere disciplinato da fonti legislative e da atti organizzativi come regolamenti e piante organiche. Organi e uffici operano tramite persone fisiche. Alcune assumono la titolarità dell'organo; altre svolgono funzioni di supporto. Nelle amministrazioni pubbliche l'assegnazione richiede un atto formale: l'investitura per il titolare, l'assegnazione per il personale. Con questo atto si instaura il rapporto di immedesimazione organica, che consente l'imputazione diretta dell'attività all'ente. Parallelamente esiste il rapporto di servizio, cioè il rapporto di impiego che lega la persona fisica all'amministrazione, disciplinato da contratto individuale e collettivo. Il rapporto di servizio è il presupposto del rapporto organico, ma non si confonde con esso. Gli organi e gli uffici possono essere classificati secondo vari criteri. Possono essere interni, quando svolgono attività preparatorie o istruttorie, oppure esterni, quando manifestano la volontà dell'ente nei confronti di altri soggetti. Possono essere necessari, se previsti come obbligatori dall'ordinamento dell'ente, oppure non necessari, se istituiti discrezionalmente. Possono essere monocratici, quando vi è un solo titolare, o collegiali, quando la volontà si forma mediante deliberazione di una pluralità di componenti. Nei collegi perfetti è richiesta la presenza di tutti i membri per deliberare; in via ordinaria è sufficiente la maggioranza dei componenti. I criteri di nomina variano: designazione da parte di altri enti, elezione, scelta per competenza tecnica. Infine, in base alle funzioni esercitate, gli organi possono essere attivi, quando emanano atti o svolgono attività materiali; consultivi, quando esprimono pareri; di controllo, quando verificano la regolarità o l'efficacia dell'azione amministrativa. In definitiva, l'organizzazione pubblica è un sistema di centri di competenza e di relazioni giuridiche che consente a un'entità astratta di operare nel mondo reale. Senza questa architettura, la persona giuridica resterebbe un nome su un atto. Con essa, diventa un soggetto capace di incidere concretamente sulla realtà. Ed è

proprio per questo che la legge la disciplina con tanta attenzione: quando l'organizzazione è pubblica, le sue decisioni non restano interne, ma toccano la vita dei cittadini.

Le amministrazioni pubbliche

Accanto allo Stato e agli enti territoriali, che rappresentano il modello più tradizionale di amministrazione, nel tempo sono stati istituiti una molteplicità di enti pubblici e, più di recente, anche soggetti formalmente privati ma sottoposti, almeno in parte, a regimi pubblicistici. Il panorama è tutt'altro che marginale: secondo i dati ISTAT, le amministrazioni pubbliche italiane sono circa 10.000, di cui circa 8.000 sono comuni. Un universo vasto, frammentato e tutt'altro che semplice da incasellare. Il punto è che nel nostro ordinamento manca una definizione legislativa unitaria di "pubblica amministrazione" alla quale si colleghi in modo sistematico un corpo omogeneo di regole. Non esiste una norma che dica, una volta per tutte, chi è p.a. e chi no. La nozione va quindi costruita in via interpretativa, ricavandola induttivamente dalle leggi settoriali che, di volta in volta, individuano i soggetti cui si applicano determinate discipline. **Un primo riferimento fondamentale è il d.lgs. 165/2001**, che detta la disciplina generale dell'organizzazione degli uffici pubblici e del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni. **L'art. 1, comma 2**, contiene un elenco ampio che include le amministrazioni e agenzie dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le università, gli enti del servizio sanitario nazionale, le camere di commercio e, più in generale, gli enti pubblici non economici. Questa definizione è spesso richiamata da altre leggi per delimitare il proprio ambito soggettivo di applicazione, diventando così una sorta di parametro di riferimento. Un secondo nucleo normativo è costituito dalla **l. 241/1990 sul procedimento amministrativo**. Il suo ambito soggettivo è delineato **dagli artt. 1 e 29**, che menzionano amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, regioni ed enti locali. Alcune disposizioni sono dichiarate inderogabili per tutte le amministrazioni pubbliche. Inoltre, la legge si applica anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. In materia di accesso ai documenti amministrativi, la nozione è ancora più ampia: comprende tutti i soggetti di diritto pubblico e anche quelli di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Qui si vede chiaramente come la qualifica formale non sia decisiva: conta la funzione svolta. Un terzo insieme di norme è rappresentato dal Codice dei contratti pubblici, che disciplina l'acquisto di beni, servizi e lavori. Anche in questo ambito la nozione di amministrazione si estende a soggetti che, pur non essendo in senso stretto enti pubblici tradizionali, sono qualificati come stazioni appaltanti o organismi di diritto pubblico in ragione della funzione svolta e delle modalità di finanziamento. Un quarto criterio rilevante emerge dal sistema europeo di contabilità nazionale e dal cosiddetto Patto di stabilità. Ai fini del controllo della spesa pubblica, le amministrazioni sono individuate dall'ISTAT sulla base di criteri stabiliti a livello europeo. In sostanza, devono trattarsi di enti che producono beni e servizi non destinati alla vendita sul mercato a prezzi economicamente significativi, che operano principalmente a favore della collettività e che sono finanziati in prevalenza tramite risorse pubbliche. L'elenco ISTAT viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l'eventuale contestazione dell'inclusione è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. Qui la nozione di p.a. è funzionale al controllo dei conti pubblici, più che all'applicazione di regole procedurali o organizzative. Da questo mosaico normativo si possono ricavare alcuni tratti comuni. In negativo, le pubbliche amministrazioni si collocano al di fuori del mercato: non operano per realizzare utili attraverso la vendita di beni e servizi a prezzi remunerativi. In positivo, producono beni pubblici materiali o immateriali che il mercato non garantisce in modo adeguato, come sicurezza, difesa, ordine pubblico, istruzione, sanità, previdenza. Spesso perseguono anche finalità redistributive. Il loro finanziamento grava prevalentemente sulla collettività attraverso il sistema fiscale. Le attività svolte possono assumere forme diverse: emanazione di provvedimenti amministrativi, attività materiali (come l'erogazione di prestazioni sanitarie o scolastiche), oppure trasferimenti di risorse finanziarie, come pensioni e contributi. Ciò che unifica queste realtà non è tanto la forma giuridica, quanto la funzione pubblica esercitata e il regime giuridico, almeno in parte, pubblicistico cui sono sottoposte.

Lo Stato

Dalla riforma di Cavour del 1853 in poi, l'ossatura amministrativa dello Stato italiano è stata costruita attorno ai ministeri. In origine il modello era semplice e verticale: al vertice il ministro, punto di raccordo tra politica e amministrazione, e sotto di lui una struttura unitaria organizzata secondo il principio gerarchico. Il ministro decideva, l'amministrazione eseguiva. Lineare, almeno sulla carta. Col tempo, però, il numero dei ministeri è aumentato, molte competenze sono state trasferite alle regioni e agli enti locali, e soprattutto il principio gerarchico è stato progressivamente sostituito dal principio di distinzione tra politica e amministrazione. Oggi i dirigenti sono titolari di competenze proprie, mentre ai ministri spettano funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. Non è più un rapporto di comando diretto, ma di definizione degli obiettivi e verifica dei risultati. **L'art. 95, comma 4**, della Costituzione affida alla legge il compito di determinare numero, attribuzioni e organizzazione dei ministeri. **La disciplina generale è contenuta nel d.lgs. 300/1999**, che elenca i ministeri, ne definisce l'organizzazione centrale e periferica, disciplina le agenzie e individua le principali aree funzionali. Ogni ministero è poi regolato in dettaglio da un regolamento governativo, che ne stabilisce la dotazione organica e individua gli uffici di livello dirigenziale generale. Accanto ai ministeri in senso proprio esistono i cosiddetti ministri senza portafoglio. Non sono a capo di un dicastero, ma sono preposti a singoli dipartimenti o uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e esercitano funzioni delegate dal Presidente del Consiglio. Hanno peso politico, ma non un ministero autonomo con bilancio proprio. L'organizzazione interna dei ministeri può seguire due modelli: dipartimentale o per direzioni generali. Il modello dipartimentale è previsto per ministeri con ambiti di intervento ampi e articolati, come quello dell'economia; i dipartimenti coordinano grandi aree di materie omogenee e sono guidati da un capo dipartimento, nominato con un procedimento che coinvolge il Presidente della Repubblica, il Consiglio dei ministri e il ministro competente. È un incarico a forte connotazione fiduciaria. Nei ministeri organizzati per direzioni generali può essere prevista la figura del segretario generale, che funge da raccordo tra il ministro e i dirigenti delle direzioni. In tutti i ministeri esistono uffici di diretta collaborazione con il ministro, come il gabinetto, la segreteria tecnica e l'ufficio legislativo. Alcune funzioni possono essere delegate ai sottosegretari di Stato. Accanto alle strutture centrali vi sono strutture periferiche, che realizzano il cosiddetto decentramento burocratico. La principale è la Prefettura – Ufficio territoriale del governo, che coordina a livello provinciale gli uffici periferici dello Stato e cura i rapporti con gli enti locali. A livello regionale il raccordo è assicurato dal commissario del governo, funzionalmente dipendente dalla Presidenza del Consiglio. In termini descrittivi, i ministeri possono essere distinti in base alle funzioni prevalenti: ministeri di ordine, come Interno, Difesa, Giustizia ed Esteri; ministeri economico-finanziari; ministeri con funzioni sociali e culturali; ministeri competenti per infrastrutture e servizi collettivi. È una classificazione utile per orientarsi, anche se la realtà è spesso meno ordinata delle etichette. Dal punto di vista giuridico, lo Stato è l'unico soggetto dotato di personalità giuridica; i ministeri sono organi dello Stato. Tuttavia, per consuetudine, essi godono di una certa legittimazione sostanziale e processuale autonoma, tanto da apparire quasi come enti a sé stanti. Hanno una propria pianta organica, gestiscono fondi specifici nel bilancio dello Stato e dispongono di beni mobili e immobili. All'interno dei ministeri operano anche le agenzie, strutture tecnico-operative con autonomia gestionale ma sottoposte all'indirizzo e alla vigilanza del ministro competente. Hanno organico e bilancio propri e sono disciplinate da uno statuto approvato con regolamento governativo. Una categoria particolare è quella delle agenzie fiscali, che a differenza delle altre hanno personalità giuridica di diritto pubblico autonoma e svolgono funzioni centrali come la riscossione dei tributi o la gestione del demanio. Storicamente, alcuni ministeri hanno anche istituito aziende interne con autonomia operativa per la gestione di servizi pubblici, come avvenne per le ferrovie dello Stato prima della loro trasformazione in società. Un ruolo a sé spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinata **dal d.lgs. 303/1999**. Non è un ministero in senso stretto, ma una struttura con maggiore flessibilità organizzativa. È composta da dipartimenti e uffici coordinati da un segretario generale e svolge funzioni di raccordo con il Parlamento, con gli organi costituzionali, con le istituzioni europee e

con il sistema delle autonomie, oltre a coordinare l'attività amministrativa del governo. Presso la Presidenza operano anche la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sedi di coordinamento e talvolta di adozione di atti vincolanti, come le intese previste da numerose leggi. Alla Presidenza afferisce inoltre l'Avvocatura dello Stato, organo ausiliario che svolge funzioni di consulenza legale e di rappresentanza in giudizio delle amministrazioni statali. È articolata in un'avvocatura generale a Roma e in avvocature distrettuali presso i capoluoghi di regione.

Gli enti territoriali: i comuni, le province, le regioni

Secondo l'**art. 114 Cost.**, la Repubblica è costituita non solo dallo Stato, ma anche da *comuni, province, città metropolitane e regioni*, tutti qualificati come enti autonomi, dotati di propri statuti, poteri e funzioni. La Costituzione, inoltre, individua espressamente gli organi fondamentali delle regioni — consiglio regionale, giunta e presidente — e ne definisce le **funzioni essenziali all'art. 121**. Il riparto delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo si fonda sui principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, enunciati **dall'art. 118 Cost.**: ciò significa che le funzioni devono essere attribuite, in via preferenziale, al livello di governo più vicino ai cittadini, salvo che per ragioni di adeguatezza o di esercizio unitario sia necessario collocarle a un livello superiore. A ciò si aggiunge l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, **garantita dall'art. 119 Cost.**, che comprende anche la possibilità di istituire ed applicare tributi propri. I rapporti tra Stato, regioni ed enti locali non seguono quindi un modello rigidamente gerarchico o "a cascata", ma un modello triangolare, perché anche i comuni intrattengono rapporti istituzionali diretti con lo Stato senza la necessaria intermediazione regionale. Dal punto di vista del diritto amministrativo, regioni ed enti locali costituiscono una categoria particolare di enti pubblici. Si tratta anzitutto di enti necessari, perché devono essere presenti obbligatoriamente su tutto il territorio nazionale. Sono poi enti ad appartenenza necessaria, poiché ogni cittadino, in base alla residenza, appartiene stabilmente a ciascuno di essi e in essi esercita diritti fondamentali, come per esempio il diritto di voto. Inoltre, sono enti a competenza generale, nel senso che possono curare gli interessi della collettività di riferimento con una certa libertà, sulla base dell'indirizzo politico espresso dagli elettori e dell'attività di indirizzo politico-amministrativo dell'organo consiliare. Infine, sono enti integralmente inseriti nell'ordinamento amministrativo, poiché tutti i loro atti, sia normativi sia non normativi, hanno natura formalmente amministrativa. L'unica eccezione è costituita dalle leggi regionali, che, nelle materie e nei limiti previsti **dall'art. 117 Cost.**, restano atti legislativi in senso proprio. Per quanto riguarda gli enti locali, la disciplina generale è **contenuta nel d.lgs. 267/2000**, cioè nel **Testo unico degli enti locali**.

Il comune, in particolare, è definito dal Testo unico come l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il suo carattere di ente a finalità generali deriva dal principio secondo cui spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, soprattutto nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Le funzioni comunali, così come quelle provinciali, vengono conferite di volta in volta da leggi statali o regionali. Tuttavia, i comuni esercitano anche alcune funzioni propriamente statali, come quelle in materia di anagrafe e stato civile; in relazione a tali funzioni, il sindaco agisce quale ufficiale di governo. Le funzioni fondamentali dei comuni, richiamate dall'**art. 117, comma 2, lett. p)**, Cost., sono oggi individuate dalla legislazione statale, **tra cui la l. 135/2012**. L'autonomia comunale si manifesta anzitutto attraverso la potestà statutaria. Lo statuto, approvato dal consiglio comunale a maggioranza qualificata, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e disciplina in particolare le attribuzioni degli organi, le forme di collaborazione tra enti, la partecipazione popolare e l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Una parte del contenuto dello statuto è necessaria, perché imposta dalla legge; accanto a questa, però, vi possono essere contenuti facoltativi o eventuali. Oltre alla potestà statutaria, i comuni dispongono anche di autonomia regolamentare nelle materie di

propria competenza, soprattutto con riferimento all'organizzazione e al funzionamento di organi e uffici e all'esercizio delle funzioni amministrative. Sotto il profilo organizzativo, gli organi di governo del comune sono il consiglio, la giunta e il sindaco. Il consiglio comunale è composto da un numero variabile di consiglieri, determinato in base alla popolazione, ed è l'organo rappresentativo e di indirizzo politico. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale: rappresenta l'ente, nomina e revoca gli assessori, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e nomina i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. La giunta è composta dal sindaco e dagli assessori, nominati anche al di fuori del consiglio comunale, e collabora con il sindaco; inoltre esercita una competenza generale residuale, cioè tutte le funzioni non riservate dalla legge al consiglio o al sindaco. Accanto agli organi di governo, in ogni comune è presente il segretario comunale, che svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa, verificando la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il direttore generale, invece, è figura prevista solo nei comuni più grandi ed esercita funzioni di raccordo tra gli organi politici e la dirigenza. I dirigenti degli enti locali, poi, sono responsabili della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica: dispongono di autonomi poteri di spesa, organizzano le risorse umane e strumentali e adottano gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, salvo quelli espressamente riservati ad altri organi. Qui si vede chiaramente il principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

Quanto ai controlli, prima della **legge costituzionale 3/2001** **gli atti dei comuni erano sottoposti a controllo preventivo di legittimità da parte dei comitati regionali di controllo**. Questo sistema è stato superato e sostituito da un modello che privilegia i controlli interni, come il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione e il controllo strategico. A essi si aggiunge il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio. Rimane però anche un controllo sugli organi: il consiglio comunale può essere sciolto, con decreto del Presidente della Repubblica, in casi tassativi come gravi violazioni di legge, atti contrari alla Costituzione, gravi motivi di ordine pubblico o impossibilità di funzionamento. In questi casi viene nominato un commissario straordinario fino al rinnovo dell'organo elettivo. Anche il sindaco può essere rimosso per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. Per favorire la cooperazione tra comuni, il Testo unico prevede vari strumenti: **le convenzioni, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi**; i consorzi, per l'esercizio associato di funzioni; le unioni di comuni, per l'esercizio in comune di più funzioni. Una forma particolare di unione è la comunità montana, istituita per valorizzare le zone montane e per esercitare funzioni delegate da comuni, province e regioni. La cooperazione può estendersi anche ad altri livelli di governo tramite gli accordi di programma, promossi dal sindaco per realizzare opere o interventi che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni. Le province sono enti intermedi tra comuni e regioni. Il Testo unico applica ad esse, in gran parte, la disciplina prevista per i comuni. Oggi hanno funzioni fondamentali limitate a determinati settori, soprattutto di programmazione e coordinamento, come la pianificazione territoriale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, la pianificazione dei trasporti in ambito provinciale, la regolazione della circolazione sulle strade provinciali e la programmazione della rete scolastica. Accanto a queste funzioni, ne esercitano altre di gestione, come la costruzione e manutenzione delle strade provinciali o la gestione dell'edilizia scolastica. I loro organi di governo sono l'assemblea dei sindaci, il consiglio provinciale e il presidente della provincia. Le città metropolitane, invece, hanno assorbito le funzioni provinciali nelle aree urbane più grandi e integrate sotto il profilo economico, sociale e territoriale. Si tratta di enti pensati per governare realtà urbane complesse, nelle quali più comuni risultano strettamente connessi. I loro organi sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, cui spetta anche l'approvazione dello statuto. Esse rappresentano quindi una forma di governo del territorio più adeguata alle grandi aree urbane. Per quanto riguarda le regioni, la loro organizzazione ricalca in parte quella degli enti locali: gli organi di governo sono il consiglio regionale, la giunta e il presidente della

regione, eletto direttamente dai cittadini. Le regioni possono disciplinare con legge regionale il sistema elettorale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, e possono definire nello statuto la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Con la **riforma costituzionale del 2001** è venuto meno il principio del parallelismo tra funzioni legislative e amministrative, cioè l'idea per cui chi aveva competenza legislativa avesse automaticamente anche quella amministrativa. Oggi il riparto delle funzioni amministrative si fonda, appunto, sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. **Sempre con la riforma del 2001 è stato soppresso il controllo governativo fondato sulla figura del commissario del governo presso la regione**, che prima poteva intervenire sia sugli atti legislativi sia su quelli amministrativi regionali. È rimasta invece una figura di raccordo, il rappresentante del governo presso le autonomie. Rimane inoltre un controllo sugli organi regionali: l'art. 126 Cost. prevede che il consiglio regionale possa essere sciolto e il presidente della giunta rimosso con decreto motivato del Presidente della Repubblica per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o motivi di sicurezza nazionale. Più in generale, **l'art. 120, comma 2, Cost.** attribuisce al governo un potere sostitutivo nei confronti di regioni ed enti locali nei casi di mancato rispetto di norme internazionali o dell'Unione europea, di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica o quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o economica dell'ordinamento. A ciò si aggiunge il potere governativo di annullamento straordinario d'ufficio degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni a tutela dell'unità dell'ordinamento. Infine, il sistema degli enti territoriali si regge anche su strumenti di raccordo istituzionale tra i diversi livelli di governo. In questo quadro assumono rilievo la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, che possono riunirsi in Conferenza unificata quando le materie coinvolgono insieme regioni ed enti locali. Questi organi, presieduti dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, svolgono funzioni consultive e di coordinamento e, in molti casi, esprimono pareri o intese che possono avere valore vincolante. Se l'intesa non viene raggiunta, essa può essere superata da una delibera motivata del Consiglio dei ministri.

Gli enti pubblici

Una prima distinzione riguarda gli enti pubblici disciplinati da leggi generali e gli enti pubblici a statuto singolare. I primi sono regolati da una disciplina generale che ne definisce i caratteri comuni e che poi si applica a una pluralità di enti appartenenti alla stessa categoria; è il caso, ad esempio, delle camere di commercio, delle aziende sanitarie locali o delle università. Gli enti a statuto singolare, invece, sono istituiti e disciplinati da una legge ad hoc, pensata specificamente per quel singolo ente: rientrano in questa categoria, ad esempio, l'ISTAT, il CONI o l'ENAC. La differenza, quindi, sta nel fatto che nei primi la legge costruisce un modello generale, mentre nei secondi la disciplina viene ritagliata direttamente su un ente determinato. Un'altra distinzione importante è quella tra enti pubblici nazionali ed enti pubblici regionali. Qui il criterio è il livello di governo dal quale l'ente dipende o dal quale viene istituito: gli enti nazionali fanno capo allo Stato, mentre quelli regionali sono istituiti e organizzati a livello regionale. Le aziende sanitarie locali, per esempio, rientrano tra gli enti regionali, proprio perché operano nell'ambito del servizio sanitario regionale e dipendono dall'organizzazione della regione.

Si distingue poi tra **enti di tipo associativo ed enti non associativi**. Gli enti associativi sono enti esponenziali di una categoria, di un gruppo o di una collettività determinata: rappresentano cioè interessi di soggetti appartenenti a una stessa realtà professionale o economica. È il caso, ad esempio, degli ordini professionali, dei collegi professionali o delle camere di commercio. In questi enti è frequente la presenza di organi rappresentativi, proprio perché la loro struttura è costruita attorno a una base collettiva. Gli enti non associativi, invece, non hanno questa matrice rappresentativa, ma una natura soprattutto patrimoniale e funzionale: sono generalmente amministrati da organi come il consiglio di amministrazione, i cui componenti vengono nominati dai ministeri o dagli enti pubblici di riferimento secondo quanto previsto dalla legge o dallo statuto. Una distinzione particolarmente

rilevante è poi quella tra enti pubblici non economici ed enti pubblici economici. Gli enti pubblici non economici sono istituiti per il perseguimento di uno scopo specifico, e proprio per questo si differenziano dagli enti territoriali, che invece hanno una competenza generale. Essi sono normalmente sottoposti a poteri di vigilanza e di indirizzo più o meno penetranti da parte dello Stato o delle regioni; quando questo legame è particolarmente intenso, si parla anche di enti strumentali, per evidenziare che l'ente opera come strumento dell'amministrazione di riferimento. Le loro risorse provengono in modo diretto o indiretto dalla finanza pubblica e, proprio per questo, essi non operano sul mercato come farebbe un normale soggetto imprenditoriale. Inoltre, svolgono la propria attività prevalentemente con moduli autoritativi, cioè mediante atti amministrativi. Gli enti pubblici economici, invece, presentano una struttura più ibrida. La loro organizzazione resta pubblicistica, perché continuano ad appartenere all'area pubblica, ma la loro attività si svolge prevalentemente secondo il diritto privato, cioè attraverso strumenti negoziali e non mediante atti autoritativi. Anche il rapporto di lavoro dei loro dipendenti non segue la disciplina generale del pubblico impiego. Tuttavia, pur operando con moduli privatistici, questi enti continuano a perseguire finalità pubbliche, e per questo rimangono sottoposti a poteri di indirizzo e controllo da parte di ministeri o di altri soggetti pubblici. Con i processi di liberalizzazione e privatizzazione, molti enti pubblici economici sono stati soppressi oppure trasformati in società per azioni; in altri casi, invece, anche enti pubblici non economici sono stati trasformati in soggetti privati senza scopo di lucro, come è avvenuto per la Croce Rossa Italiana.

Infine, occorre **considerare la distinzione tra enti pubblici ed enti privati**, che oggi è diventata meno netta di quanto possa sembrare. Più che una separazione rigida, si può immaginare una specie di linea continua: a un estremo stanno le pubbliche amministrazioni in senso pieno, cioè lo Stato e gli enti territoriali; in una posizione intermedia si collocano gli enti pubblici non economici e quelli economici; all'altro estremo stanno i soggetti di diritto privato. Avvicinandosi a quest'ultimo polo, gli elementi pubblicistici tendono progressivamente a diminuire. Questa distinzione tra pubblico e privato ha assunto nuova importanza per effetto di un orientamento giurisprudenziale che, in alcuni casi, tende a qualificare come enti pubblici anche società formalmente private, come le società per azioni a partecipazione pubblica. Il problema si pone soprattutto per stabilire quale sia il giudice competente e quale regime giuridico applicare agli atti emanati da tali soggetti. In alcuni casi, infatti, società formalmente private sono state considerate sostanzialmente pubbliche perché svolgono attività di rilevante interesse pubblico, sono istituite o fortemente disciplinate dalla legge e intrattengono rapporti molto stretti con i ministeri o con altri enti pubblici. In situazioni del genere, la veste privatistica non basta a escludere la natura pubblicistica sostanziale del soggetto. Per risolvere questi casi, la giurisprudenza ha elaborato alcuni indici di pubblicità, cioè criteri sintomatici utili a capire se un ente possa essere considerato pubblico: tra questi si ricordano l'istituzione per legge, il perseguimento di un fine pubblico, il rapporto di strumentalità rispetto allo Stato o a un ente territoriale, il finanziamento prevalente a carico dell'erario e il carattere necessario dell'ente.

Le autorità indipendenti

Le autorità amministrative indipendenti sono una figura relativamente recente nel panorama del diritto amministrativo e si affermano soprattutto dagli anni Novanta, nel contesto dello Stato regolatore. A differenza delle amministrazioni tradizionali, esse non si caratterizzano solo per l'elevato livello di tecnicità e specializzazione, **ma soprattutto per il fatto di essere strutturalmente indipendenti dal potere esecutivo**. Questa indipendenza si spiega, anzitutto, con la **teoria dei cosiddetti poteri neutri**: si tratta di soggetti che devono operare come **arbitri imparziali** in settori particolarmente delicati, senza essere condizionati dal circuito politico-rappresentativo. Il modello classico richiamato dalla dottrina è quello delle banche centrali. In secondo luogo, **l'indipendenza risponde all'esigenza di offrire una tutela rafforzata ad alcuni valori costituzionali** particolarmente sensibili, come la riservatezza dei dati personali o il diritto di sciopero. Infine, essa serve anche a **evitare conflitti di interesse tra lo Stato regolatore**, che deve agire in modo imparziale nei confronti degli operatori

economici, e lo **Stato imprenditore**, che potrebbe invece essere tentato di favorire imprese pubbliche partecipate. Questa indipendenza non resta sul piano teorico, ma viene garantita da una serie di strumenti istituzionali. Anzitutto, **le autorità indipendenti intrattengono un rapporto privilegiato con il Parlamento** più che con il Governo. Il Governo, infatti, non può impartire loro direttive né esercitare poteri di indirizzo politico-amministrativo. Anche il **sistema di nomina dei componenti riflette questa logica**: spesso la nomina è affidata ai Presidenti delle Camere oppure richiede un parere parlamentare vincolante adottato con maggioranze qualificate. Inoltre, **queste autorità svolgono un'attività di consulenza istituzionale verso Parlamento e Governo attraverso poteri di segnalazione e proposta**, la cosiddetta *advocacy*, con cui richiamano l'attenzione del legislatore su problemi o distorsioni emersi nei settori di competenza. A ciò si aggiunge **l'obbligo di presentare una relazione annuale al Parlamento**. Un secondo presidio di indipendenza riguarda la struttura degli organi. I componenti, di regola in numero ristretto, vengono scelti in base a requisiti molto rigorosi di competenza, professionalità e autonomia. La durata del mandato è generalmente più lunga di quella della legislatura, spesso di sette anni, proprio per evitare un allineamento con il ciclo politico-elettorale. Inoltre, **la regola della non rieleggibilità o non confermabilità** per un secondo mandato serve a rendere i componenti **meno esposti a pressioni esterne**. In alcuni casi sono previste anche incompatibilità successive, cioè divieti di assumere incarichi presso imprese vigilate nei periodi immediatamente successivi alla cessazione del mandato, così da prevenire fenomeni di condizionamento o di scambio.

Un ulteriore elemento essenziale è **l'ampia autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria**. Le leggi istitutive prevedono di solito che queste autorità operino in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Esse possono disciplinare la propria organizzazione interna con regolamenti propri, gestire autonomamente i concorsi per il personale e modellare la struttura amministrativa secondo le esigenze del settore regolato, pur nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. A ciò si aggiunge, in molti casi, **il loro inserimento in reti sovranazionali di regolazione**, specialmente a livello europeo: questo collocamento rafforza ulteriormente la loro autonomia **rispetto ai governi nazionali**, perché le autorità nazionali agiscono dentro sistemi integrati di vigilanza e regolazione. Sotto il profilo del **regime giuridico**, le autorità indipendenti presentano una particolarità importante: esse, entro certi limiti, **attenuano la rigida separazione dei poteri**. Infatti concentrano in sé funzioni che, nel modello classico, **sarebbero distribuite tra soggetti diversi**. Da un lato esercitano poteri di regolazione, cioè adottano regole generali nei settori di competenza; dall'altro esercitano poteri amministrativi in senso proprio, come poteri autorizzatori, prescrittivi, ispettivi e sanzionatori; in più, sempre più spesso, sono chiamate anche a risolvere controversie in via stragiudiziale tra utenti, consumatori e operatori economici, svolgendo una funzione paragiurisdizionale. In questi procedimenti il contraddittorio è normalmente rafforzato rispetto alla disciplina minima prevista dalla legge n. 241 del 1990, proprio perché le decisioni delle autorità possono incidere in modo molto rilevante sulle posizioni giuridiche dei destinatari. Le autorità indipendenti possono essere ricondotte, in linea generale, a tre grandi gruppi. Vi sono anzitutto le autorità generaliste, che operano trasversalmente nei confronti di una pluralità di soggetti pubblici e privati e non solo in uno specifico settore economico. A questa categoria appartengono soprattutto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali. Vi sono poi le autorità di settore che vigilano su mercati concorrenziali particolarmente delicati, come quelli finanziari e assicurativi; tra queste si collocano la **Banca d'Italia**, la **CONSOB** e l'**IVASS**. Infine, esistono le autorità di regolazione dei servizi pubblici, sviluppatasi soprattutto in seguito **ai processi di liberalizzazione**.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cioè l'Antitrust, ha il compito principale di **applicare la disciplina a tutela della concorrenza**. Essa interviene contro le intese restrittive della concorrenza, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni tra imprese che possano alterare il corretto funzionamento del mercato. A questo scopo esercita poteri di accertamento e repressione, che si traducono in provvedimenti inibitori, ordinatori e sanzionatori. I suoi poteri possono essere attivati

sia d'ufficio sia su segnalazione degli interessati. La sua attività è prevalentemente di regolazione ex post, perché interviene soprattutto su comportamenti già posti in essere, diversamente da molte autorità di settore che svolgono anche un'intensa regolazione preventiva. Importante è poi il suo potere di advocacy: può segnalare a Parlamento e Governo norme o atti amministrativi che producono distorsioni concorrenziali e proporre gli interventi necessari per rimuoverle. Inoltre, le è riconosciuto anche il potere di impugnare davanti al giudice amministrativo provvedimenti generali o individuali adottati in violazione delle regole della concorrenza. **Il Garante per la protezione dei dati personali è l'autorità preposta all'applicazione della disciplina in materia di privacy.** Opera sulla base del Codice in materia di protezione dei dati personali, coordinato con la normativa europea, e lavora in stretto collegamento con il Comitato europeo per la protezione dei dati e con le altre autorità nazionali. I suoi poteri sono molteplici. Da un lato ha poteri di carattere normativo o para-normativo, perché adotta linee guida, promuove codici di deontologia e verifica che essi siano conformi alla normativa vigente. Dall'altro esercita poteri amministrativi, come quelli di ordinare la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali. Inoltre svolge anche una funzione paragiurisdizionale, poiché gestisce reclami presentati da chi ritiene lesi i propri diritti in materia di trattamento dei dati. Questa tutela si pone come alternativa rispetto all'azione davanti al giudice ordinario, fermo restando che contro le decisioni del Garante è possibile rivolgersi proprio a quest'ultimo. In alcuni casi, inoltre, il Garante è anche legittimato ad agire in giudizio contro il titolare o il responsabile del trattamento. **La Banca d'Italia svolge funzioni diverse ma tra loro collegate.** Anzitutto esercita una funzione monetaria, in quanto fa parte del Sistema europeo delle banche centrali insieme alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali degli altri Stati membri. Accanto a ciò, essa svolge una fondamentale funzione di vigilanza sul sistema bancario e sugli intermediari creditizi, secondo la disciplina del Testo unico bancario. In questo ambito dispone di poteri normativi, ad esempio in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche, di poteri autorizzatori, ispettivi, prescrittivi e sanzionatori. I parametri che utilizza sono spesso tecnici ed elastici, come quello della sana e prudente gestione, che richiede valutazioni altamente specialistiche. **La CONSOB, istituita nel 1974, è l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.** Il suo compito è garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari, dei mercati e dei prodotti finanziari. Anch'essa dispone di poteri molto estesi: poteri normativi, autorizzatori, ispettivi, prescrittivi e sanzionatori. Opera in stretto coordinamento con le autorità finanziarie degli altri Paesi europei e partecipa ai processi di regolazione sovranazionale, anche sotto la supervisione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, cioè l'ESMA. In questo modo la vigilanza finanziaria non resta confinata sul piano interno, ma si inserisce in una rete europea integrata. **L'IVASS, cioè l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,** opera invece nel settore assicurativo. È stato istituito nel 2012 ed è strettamente collegato alla Banca d'Italia, tanto che ne è presieduto dal direttore generale. Anche il suo organo di indirizzo conferma questa integrazione, essendo costituito dal direttorio della Banca d'Italia integrato da due esperti in materia assicurativa e previdenziale. L'IVASS svolge attività di vigilanza sul mercato assicurativo e opera in raccordo con l'autorità europea competente in materia di assicurazioni e pensioni aziendali e professionali.

Le società a partecipazione pubblica

Le **società partecipate da una o più pubbliche amministrazioni** rappresentano un fenomeno che si è sviluppato per una pluralità di ragioni. Una prima causa è collegata all'affermazione dello **Stato imprenditore**, che raggiunse il suo apice tra gli anni Sessanta e Settanta. In quella fase storica, l'intervento pubblico nell'economia veniva giustificato soprattutto dall'esigenza di salvare imprese private in crisi, di tutelare i livelli occupazionali e di promuovere politiche di programmazione economica, specialmente a sostegno delle aree meno sviluppate del Paese. Questo sistema delle partecipazioni statali venne poi progressivamente smantellato verso la fine degli anni Ottanta, sia perché divenuto troppo oneroso per la finanza pubblica, sia perché ritenuto incompatibile con una più rigorosa applicazione delle regole europee in materia di aiuti di Stato. Molte imprese pubbliche furono

così liquidate o privatizzate, come avvenne, ad esempio, per Telecom o per Autostrade per l'Italia. Una seconda causa del fenomeno è rappresentata dai **processi di liberalizzazione dei mercati** avviati negli anni Novanta. In tale contesto, numerosi enti pubblici economici che gestivano servizi pubblici in regime di monopolio legale furono trasformati per legge in società per azioni, con attribuzione iniziale della titolarità delle azioni allo Stato. Questo fenomeno è stato definito **privatizzazione fredda**. In un momento successivo, in molti casi, tali partecipazioni furono cedute, in tutto o in parte, a soggetti privati, dando luogo alla cosiddetta **privatizzazione calda**. Una terza causa si collega ai processi di **razionalizzazione organizzativa** attuati da molte pubbliche amministrazioni. Per ragioni di efficienza e snellezza operativa, infatti, esse hanno spesso ritenuto preferibile non gestire internamente alcune attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative, ma esternalizzarle, affidandole a società appositamente costituite. Si tratta delle cosiddette **società strumentali**. Accanto a queste ragioni fisiologiche, se ne rinvencono anche di tipo **patologico**, come la moltiplicazione di cariche da distribuire secondo criteri politici oppure l'elusione delle regole pubblicistiche in materia di assunzione del personale o di affidamento dei contratti mediante procedure ad evidenza pubblica.

Un riordino organico della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica è stato realizzato con il **d.lgs. 175/2016**, adottato nell'ambito della riforma Madia. Va premesso che il diritto europeo mantiene, in linea generale, un atteggiamento di **neutralità** rispetto alla proprietà pubblica o privata delle imprese, purché siano rispettate condizioni di effettiva parità concorrenziale. La scelta di incentivare o limitare il ricorso alle società partecipate dipende dunque da opzioni interne del legislatore nazionale. Il Testo unico del 2016 si ispira chiaramente a una logica di **contenimento** del fenomeno, imponendo alle pubbliche amministrazioni un divieto generale di costituire società o di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società commerciali aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Anche quando tale vincolo finalistico risulta rispettato, il decreto individua in modo tassativo le attività per le quali è ammessa la partecipazione pubblica. Tra queste rientrano, ad esempio, i servizi di interesse generale, la progettazione o realizzazione di opere pubbliche, l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti partecipanti e i servizi di committenza. Da questa impostazione discendono conseguenze molto rilevanti. In primo luogo, le amministrazioni sono tenute ad approvare **piani annuali di riassetto** delle partecipazioni societarie, allo scopo di verificare il rispetto dei parametri indicati dalla legge, come il raggiungimento di un fatturato minimo, l'assenza di perdite strutturali o il fatto che il numero dei dipendenti non sia inferiore a quello degli amministratori. Qualora tali requisiti non siano rispettati, l'amministrazione deve procedere a liquidazioni, cessioni o accorpamenti. In secondo luogo, il decreto impone un rigoroso **obbligo di motivazione analitica** delle delibere con cui si decide di costituire una società o di acquisire una partecipazione. Più in generale, il Testo unico disciplina in chiave pubblicistica la posizione dello **Stato azionista**, cioè i principi e le modalità procedurali che le pubbliche amministrazioni devono osservare quando acquistano, mantengono o alienano partecipazioni. Per quanto riguarda invece la disciplina interna delle società partecipate, il decreto segue il principio, raccomandato anche dall'OCSE, secondo cui esse restano soggette in via principale al **diritto comune**, salvo specifiche deroghe espresse. Le società a partecipazione pubblica possono essere distinte in diverse tipologie. Vi sono anzitutto le **società quotate**, alle quali il d.lgs. 175/2016 si applica solo nei casi espressamente richiamati, così da non penalizzarle rispetto alle società private quotate. Vi sono poi le **società meramente partecipate**, nelle quali la pubblica amministrazione detiene soltanto una partecipazione di minoranza, anch'esse sottoposte in larga parte al diritto comune. Una categoria più rilevante è quella delle **società in controllo pubblico**, nelle quali le amministrazioni detengono direttamente o indirettamente la maggioranza delle azioni; a esse si applica gran parte dei vincoli pubblicistici previsti dal Testo unico. Una posizione ancora più particolare è occupata dalle **società in-house**, il cui regime è in larga misura assimilato a quello delle pubbliche amministrazioni, in quanto esse risultano così strettamente legate all'ente pubblico da poter essere considerate quasi una sua articolazione interna. Infine, vi sono le **società a partecipazione**

pubblica di diritto singolare, disciplinate da leggi speciali, come nel caso della RAI. Un elemento centrale della nuova disciplina è, come detto, l'**obbligo di motivazione analitica**. Quando una pubblica amministrazione intende costituire una società o acquisire una partecipazione, deve adottare una delibera che giustifichi puntualmente la necessità della scelta rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La motivazione deve esplicitare le ragioni della scelta, le finalità perseguite, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria. Inoltre, l'amministrazione deve valutare anche la possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate, la possibilità di gestione diretta o di esternalizzazione mediante strumenti diversi, nonché la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda gli enti locali, lo schema della delibera deve essere sottoposto a **consultazione pubblica**. Le delibere devono inoltre essere trasmesse alla **Corte dei conti** e all'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**, la quale può esercitare poteri di diffida e di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.

Anche l'**alienazione delle partecipazioni** deve avvenire secondo procedure rispettose dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Solo eccezionalmente, e a condizione che la delibera motivi in modo puntuale la convenienza economica della scelta, è ammessa la negoziazione diretta con un singolo acquirente. Il decreto ha inoltre istituito, presso il Ministero dell'Economia, una struttura con compiti di **monitoraggio, indirizzo e coordinamento**, dotata di poteri ispettivi, nonché del potere di emanare orientamenti applicativi e individuare le migliori pratiche. Le società a controllo pubblico sono poi tenute a dotarsi di regolamenti interni per il rispetto della disciplina della concorrenza, di un ufficio di controllo interno, di codici di condotta e di programmi di responsabilità sociale d'impresa. Particolarmente importante è la figura della **società in-house**. Perché una società possa essere qualificata come tale, devono sussistere due requisiti fondamentali. Il primo è il cosiddetto **controllo analogo**, che richiede un rapporto così intenso tra l'amministrazione e la società da rendere quest'ultima assimilabile a un ufficio interno dell'ente pubblico. Per realizzare questo requisito, la partecipazione deve essere sostanzialmente pubblica e lo statuto o i patti parasociali devono attribuire al socio pubblico poteri effettivi di influenza sulle strategie e sulle decisioni fondamentali della società. Il controllo analogo può assumere forma **congiunta**, quando più amministrazioni affidano a un'unica società la gestione di un servizio e mantengono insieme il potere di incidere sulle sue decisioni strategiche, oppure forma **indiretta**, quando una pubblica amministrazione controlla una società che, a sua volta, controlla un'altra società. Il secondo requisito consiste nello svolgimento dell'attività **prevalentemente a favore delle pubbliche amministrazioni** che controllano la società. Essa, infatti, non deve operare in misura significativa sul mercato, per evitare distorsioni della concorrenza. A questo fine il d.lgs. 175/2016 stabilisce che almeno l'80% dell'attività debba essere svolta in favore dell'amministrazione o delle amministrazioni controllanti. Le società in-house sono sottoposte a un regime pubblicistico più intenso rispetto alle altre società partecipate. In particolare, esse sono tenute ad applicare integralmente il **Codice dei contratti pubblici** e rientrano nel regime della **responsabilità amministrativa per danno erariale**, che invece non si applica alle altre tipologie di società partecipate. Per tutti gli aspetti non espressamente derogati dal d.lgs. 175/2016, continuano comunque a trovare applicazione le regole del diritto comune, comprese le ordinarie procedure fallimentari. Infine, merita un cenno la disciplina del **golden power**, introdotta dalla legge n. 56/2012. Essa prevede che, in presenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il Governo possa esercitare speciali poteri di intervento. Tali poteri non si collegano più soltanto alla titolarità di azioni, come avveniva nella precedente disciplina della golden share, ma possono incidere più in generale su operazioni societarie riguardanti attività di rilevanza strategica. Ad esempio, il Governo può imporre condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti o ai trasferimenti tecnologici nel caso di acquisto di partecipazioni in società che operano in settori strategici.

Le relazioni interorganiche e intersoggettive

Guardando al **profilo dinamico dell'organizzazione amministrativa**, occorre soffermarsi non più soltanto sulla struttura statica degli enti, degli organi e degli uffici, ma sulle **relazioni** che si instaurano all'interno delle amministrazioni e tra amministrazioni diverse. In questa prospettiva vengono in rilievo sia le **relazioni interorganiche**, che si sviluppano tra organi e uffici appartenenti al medesimo apparato, sia le **relazioni intersoggettive**, che intercorrono invece tra enti pubblici distinti. Le principali forme di relazione organizzativa sono quattro: **gerarchia, direzione, controllo e coordinamento**. Il **rapporto di gerarchia** costituisce la forma più intensa di relazione organizzativa e caratterizza, anzitutto, i rapporti tra persone inserite nella stessa struttura amministrativa, secondo gradi e qualifiche, ma anche i rapporti tra uffici e tra i titolari di essi. Esso presuppone che le competenze dell'organo o dell'ufficio subordinato siano integralmente comprese nell'ambito delle competenze dell'organo o dell'ufficio sovraordinato. Proprio per questo il superiore gerarchico non si limita a impartire ordini puntuali, ma dispone di una serie di poteri ulteriori. In particolare, può **avocare** a sé un singolo affare normalmente attribuito al subordinato; può **sostituirsi** a quest'ultimo in caso di inerzia; può **risolvere conflitti** tra uffici sottordinati; può **decidere sui ricorsi gerarchici** proposti da terzi contro atti emanati dall'organo subordinato; e può infine **annullare d'ufficio** o addirittura **revocare** gli atti di quest'ultimo. Il rapporto di gerarchia, tuttavia, riguarda esclusivamente relazioni interne a uno stesso apparato e **non può sussistere nei rapporti intersoggettivi tra enti pubblici distinti**, poiché ciascun ente è dotato di una propria autonomia.

Meno intenso del rapporto di gerarchia è il **rapporto di direzione**. In questo caso non vi è una totale inclusione delle competenze dell'organo subordinato in quelle del soggetto sovraordinato, né sussiste un potere così penetrante come quello gerarchico. Il rapporto di direzione si esprime piuttosto attraverso l'emanazione di **direttive**, che orientano l'azione dell'organo o dell'ente destinatario lasciando tuttavia a quest'ultimo uno spazio di autonomia nell'attuazione concreta. Si tratta quindi di una relazione meno rigida, nella quale il soggetto sottordinato conserva un margine di scelta sulle modalità con cui perseguire gli obiettivi indicati. Anche il rapporto di direzione può assumere tanto una dimensione **interorganica**, quanto una dimensione **intersoggettiva**. Un'altra relazione organizzativa fondamentale è quella di **controllo**. Anch'essa può avere natura **interorganica**, quando si realizza all'interno della stessa amministrazione mediante controlli interni, oppure natura **intersoggettiva**, quando si esercita tra soggetti distinti, come accade nei controlli esterni. Il controllo determina comunque una posizione di sovraordinazione del soggetto controllante rispetto al destinatario del controllo, pur senza necessariamente dar luogo a un rapporto gerarchico in senso proprio. Esso ha infatti la funzione di verificare la regolarità, la legittimità, l'efficienza o i risultati dell'attività amministrativa, secondo i diversi modelli di controllo previsti dall'ordinamento. Al di fuori dei rapporti di sovraordinazione e sottordinazione si collocano poi i **rapporti di equiparazione**, che riguardano organi, uffici ed enti che non dipendono l'uno dall'altro ma che sono chiamati a **cooperare** nello svolgimento delle rispettive funzioni. In un sistema amministrativo sempre più complesso, multilivello e caratterizzato da una forte specializzazione, il **coordinamento** diventa infatti un'esigenza essenziale. Esso può assumere due forme principali. Da un lato vi è il **coordinamento politico-amministrativo**, che riguarda soprattutto i rapporti interni al Governo e quelli tra lo Stato, le regioni e il sistema delle autonomie locali. In questo ambito un ruolo centrale è svolto, ad esempio, dal **Consiglio dei ministri** e dal sistema delle **Conferenze**, già esaminato, che costituiscono sedi stabili di raccordo tra i diversi livelli di governo. Dall'altro lato vi è il **coordinamento amministrativo in senso stretto**, che si realizza attraverso strumenti giuridici e procedurali diretti a consentire l'azione congiunta di più amministrazioni. Tra questi rientrano, ad esempio, le **intese**, i **pareri**, le **conferenze di servizi**, gli **accordi tra pubbliche amministrazioni** e gli **sportelli unici**. Si tratta di strumenti che servono a superare la frammentazione delle competenze e a rendere più ordinata ed efficace l'azione amministrativa. Un discorso a parte riguarda le **autorità amministrative indipendenti**. Con riferimento ad esse si è osservato che l'indipendenza può essere intesa quasi come una “**non**

relazione”, nel senso che ciascuna autorità, proprio in ragione della sua posizione di autonomia rispetto al potere esecutivo e agli altri apparati, è chiamata a esercitare i propri poteri senza dover dipendere da altri soggetti o sottostare a vincoli di direzione politica. L’indipendenza, dunque, non elimina ogni forma di raccordo istituzionale, ma esclude relazioni di subordinazione o ingerenza incompatibili con la funzione di garanzia loro affidata. Infine, nei casi previsti dalla legge, è ammessa anche la **delega di funzioni** da parte di un ente a favore di un altro. In questa ipotesi l’ente delegato esercita le funzioni **in nome proprio**, ma **per conto e nell’interesse dell’ente delegante**. La delega consente quindi una distribuzione più flessibile dell’esercizio delle funzioni amministrative, pur restando fermo il collegamento funzionale con l’ente titolare originario. Un esempio è rappresentato dall’attribuzione per legge ai comuni di funzioni amministrative relative a servizi di competenza statale.

Il disegno organizzativo degli enti pubblici e lo spazio regolatorio

Due nozioni particolarmente utili per lo studio dell’apparato amministrativo sono quelle di **disegno organizzativo degli enti pubblici** e di **spazio regolatorio**. Si tratta di due prospettive diverse ma complementari: la prima consente di descrivere la struttura del singolo apparato, la seconda permette invece di coglierne la posizione e il ruolo all’interno del sistema complessivo delle amministrazioni pubbliche. Il **disegno organizzativo** di un ente pubblico consiste in una sorta di schema di analisi, formato da principi e indicatori, che consente di esaminare e confrontare tra loro i diversi apparati pubblici. Esso offre quindi una chiave di lettura utile a ricostruire la fisionomia di ciascun ente. Tra gli indicatori principali rientrano anzitutto le **fonti** che ne disciplinano l’organizzazione, poiché ogni apparato trova la propria base normativa in un insieme di disposizioni costituzionali, legislative, regolamentari o statutarie che ne definiscono struttura e funzionamento. Un secondo elemento rilevante è dato dalla **tipologia degli organi** previsti per ciascun ente, dalle **modalità di nomina** dei loro titolari e dalla **ripartizione delle competenze** tra i diversi organi. Questo profilo consente di comprendere come si articola internamente il potere amministrativo, quali organi abbiano funzioni di indirizzo, quali di gestione, quali di controllo, e in che modo essi interagiscano tra loro. Rientrano poi nel disegno organizzativo anche le **funzioni e i poteri attribuiti all’ente**, cioè l’ambito materiale entro cui l’apparato è chiamato a operare e gli strumenti giuridici di cui dispone per perseguire le finalità pubbliche assegnategli. A ciò si aggiungono i **controlli** e le forme di **vigilanza** cui l’ente è sottoposto, elementi fondamentali per comprendere il grado di autonomia di cui esso gode rispetto ad altri apparati pubblici. Infine, occorre considerare le **risorse finanziarie** su cui l’ente può fare affidamento, poiché anche il profilo economico e patrimoniale incide in modo decisivo sulla concreta capacità dell’apparato di svolgere le proprie funzioni. In definitiva, il disegno organizzativo offre una rappresentazione per così dire **statica** dell’ente pubblico: esso consente di fotografarne la struttura interna, di individuarne gli elementi costitutivi e di descriverne l’assetto complessivo. Diversa, anche se complementare, è la nozione di **spazio regolatorio**. Essa non guarda tanto al singolo apparato in sé considerato, quanto piuttosto alla sua **collocazione dinamica** all’interno di un sistema più ampio e complesso di relazioni tra soggetti pubblici. In questa prospettiva, l’ente non viene osservato come una realtà isolata, ma come parte di una rete di rapporti con altri apparati, rapporti che possono mutare nel tempo e ridefinirsi in base all’evoluzione delle funzioni pubbliche, delle tecniche di regolazione e degli equilibri istituzionali. Lo spazio regolatorio, quindi, più che un concetto strettamente giuridico, è una nozione descrittiva che serve a rappresentare l’insieme degli apparati pubblici come un **universo interdipendente e in continua trasformazione**. Esso mette in evidenza come ogni ente, oltre ad avere una propria struttura interna, occupi una determinata posizione in un contesto nel quale si intrecciano competenze, poteri, forme di controllo, rapporti di collaborazione e dinamiche evolutive. Proprio per questo lo spazio regolatorio consente di cogliere l’aspetto più propriamente **dinamico** dell’organizzazione amministrativa.

SERVIZI PUBBLICI

Il modello originario di organizzazione dei servizi pubblici presentava due caratteristiche fondamentali. In primo luogo, l'attività era spesso sottoposta per legge a un **regime di riserva originaria** a favore dello Stato, con esclusione dei privati dallo svolgimento del servizio in regime di concorrenza. Si trattava dei cosiddetti **monopoli legali**, richiamati dall'art. 43 Cost., che hanno storicamente riguardato, ad esempio, la gestione delle linee ferroviarie e dei servizi telefonici, riservate allo Stato rispettivamente nel 1905 e nel 1907. In secondo luogo, la gestione del servizio avveniva ad opera dei pubblici poteri, in forma **diretta**, tramite aziende speciali interne allo Stato o al comune, oppure in forma **indiretta**, attraverso enti pubblici economici. In questo contesto, la dottrina elaborò inizialmente la cosiddetta **concezione soggettiva del servizio pubblico**, coerente con una visione del diritto pubblico fortemente centrata sul ruolo dello Stato. Secondo tale impostazione, il servizio pubblico era definito come un'attività diretta a soddisfare un bisogno di interesse generale della collettività, dunque caratterizzata anzitutto da un **elemento materiale**, cioè il fine sociale perseguito. A questo si aggiungeva un **elemento organico**, poiché il servizio doveva essere assunto come compito proprio da un soggetto pubblico e svolto prevalentemente da esso. Infine, rilevava anche un **elemento formale**, rappresentato dalla sottoposizione dell'attività a un regime giuridico speciale. Con il progressivo superamento dell'impostazione statalista, questa concezione ha lasciato spazio alla **concezione oggettiva del servizio pubblico**, oggi prevalente. Tale impostazione è più coerente con il principio di **sussidiarietà orizzontale**, che valorizza il possibile coinvolgimento dei privati nello svolgimento di attività di interesse generale. In questa prospettiva, ciò che conta non è tanto la natura pubblica o privata del soggetto che eroga il servizio, quanto piuttosto la **destinazione dell'attività al soddisfacimento dei bisogni della collettività**. Il baricentro si sposta quindi dall'elemento soggettivo a quello funzionale: il servizio pubblico è tale perché diretto al benessere collettivo, indipendentemente da chi lo svolga.

Questa evoluzione si è consolidata con il passaggio dallo **Stato gestore** allo **Stato regolatore** e con l'avvio dei processi di **liberalizzazione e privatizzazione**. In tale nuovo quadro, il compito dello Stato non è più quello di erogare direttamente i servizi, bensì quello di garantire, attraverso strumenti di regolazione, controllo e vigilanza, che essi siano comunque resi alla collettività secondo standard qualitativi e quantitativi adeguati. Di regola, infatti, l'erogazione viene affidata a gestori privati, mentre il soggetto pubblico mantiene un ruolo di indirizzo, regolazione e garanzia. Per comprendere meglio la materia, è utile richiamare due classificazioni generali dei servizi pubblici. Una prima distinzione è quella tra **servizi aventi rilevanza economica** e **servizi privi di rilevanza economica**. I primi sono servizi suscettibili di essere gestiti in forma imprenditoriale, anche da soggetti privati operanti in concorrenza, come accade ad esempio nei settori dei trasporti, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni. I secondi, invece, sono servizi che normalmente vengono assunti direttamente dalle pubbliche amministrazioni, con costi posti prevalentemente a carico della fiscalità generale, come avviene per la scuola, la sanità e l'assistenza sociale. In questi casi prevale la finalità sociale rispetto alla logica di mercato. Una seconda distinzione riguarda i **servizi a fruizione collettiva necessaria** e i **servizi a fruizione individuale**. I primi si riferiscono ai cosiddetti beni **non escludibili**, cioè a utilità di cui tutti possono beneficiare indistintamente e rispetto alle quali non è configurabile un rapporto diretto tra gestore e singolo utente. In tali ipotesi, la relazione giuridica si instaura essenzialmente tra la pubblica amministrazione e il gestore del servizio, come avviene, ad esempio, nel caso dell'illuminazione pubblica delle strade. I secondi, invece, sono caratterizzati dal fatto che il gestore intrattiene un rapporto giuridico anche con il singolo utente, il quale usufruisce personalmente del servizio e normalmente corrisponde un prezzo o una tariffa, come accade nel caso del trasporto pubblico mediante acquisto del biglietto.

I servizi di interesse generale nel diritto europeo

La disciplina europea in materia di servizi pubblici si fonda sui principi del TFUE e sulle numerose direttive di liberalizzazione adottate nei diversi settori. Essa si sviluppa lungo due direttrici fondamentali, che devono essere considerate in modo complementare. Da un lato, il diritto dell'Unione valorizza la funzione sociale dei servizi di interesse generale, riconoscendoli come strumenti essenziali per la coesione sociale e territoriale. Dall'altro lato, afferma che anche in questo ambito devono trovare applicazione, per quanto possibile, le regole della concorrenza e del mercato, ammettendo deroghe solo quando siano strettamente necessarie per il perseguimento dell'interesse pubblico. Secondo la prima direttrice, i servizi di interesse generale sono considerati elementi fondamentali per garantire la coesione sociale e territoriale e per salvaguardare la competitività dell'economia europea. Essi non sono quindi visti soltanto come attività economiche, ma anche come strumenti indispensabili per assicurare condizioni minime di benessere e uguaglianza sostanziale tra i cittadini. Questa impostazione emerge anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che richiama espressamente il diritto di accesso all'assistenza sociale, alla prevenzione sanitaria, alle cure mediche e ai servizi di interesse economico generale. Ne deriva che l'ordinamento europeo riconosce a tali servizi una rilevanza non solo economica, ma anche sociale e costituzionale. La seconda direttrice emerge invece dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dall'art. 106, comma 2, secondo cui la regola generale è l'applicabilità delle norme comuni in materia di concorrenza anche alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Le deroghe sono consentite soltanto entro i limiti in cui l'applicazione integrale delle regole del mercato impedirebbe, in fatto o in diritto, l'adempimento della specifica missione di interesse pubblico affidata al gestore. In altri termini, il diritto europeo adotta una logica di compatibilità tra servizio pubblico e concorrenza: la tutela dell'interesse generale non elimina automaticamente il mercato, ma può giustificare limitazioni solo se proporzionate e strettamente necessarie. Il diritto europeo distingue inoltre tra servizi di interesse economico generale e servizi non economici di interesse generale. I primi consistono in beni o servizi offerti in un determinato mercato, come ad esempio i trasporti o i servizi postali, e sono pertanto sottoposti, in linea di principio, alla disciplina della concorrenza. I secondi, invece, si collocano fuori dal mercato, come avviene tipicamente per l'istruzione, la sanità e altre prestazioni sociali essenziali; proprio per questa loro natura non economica, essi restano esclusi dall'applicazione delle norme europee in materia concorrenziale. La distinzione è quindi decisiva, perché consente di comprendere quando l'ordinamento europeo imponga l'apertura al mercato e quando, invece, lasci agli Stati membri maggiore libertà di organizzazione. In questo quadro si inseriscono le direttive di liberalizzazione, che hanno progressivamente trasformato il modello tradizionale dei servizi pubblici nazionali. Esse distinguono principalmente tra concorrenza nel mercato e concorrenza per il mercato. La concorrenza nel mercato si realizza nei settori in cui, per le caratteristiche del servizio, è possibile la presenza contemporanea di una pluralità di operatori economici che competono tra loro. In questi casi, l'accesso all'attività non richiede normalmente una concessione esclusiva, ma avviene attraverso un provvedimento autorizzatorio non discrezionale, che consente a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti di operare sul mercato. Il servizio viene dunque erogato in un contesto di concorrenza aperta, come accade, ad esempio, nel settore dei trasporti aerei o nei servizi di telefonia. Diversa è la logica della concorrenza per il mercato, che riguarda quei casi in cui il servizio, per ragioni tecniche o economiche, non può essere svolto efficientemente da una pluralità di operatori, ma richiede la presenza di un unico gestore. Ciò accade, ad esempio, nei casi di monopolio naturale, dove la duplicazione delle reti o delle infrastrutture sarebbe inefficiente o eccessivamente costosa. In tali ipotesi, il diritto europeo non esclude il mercato, ma lo sposta nella fase di scelta del soggetto affidatario: il gestore viene individuato tramite una procedura competitiva alla quale possono partecipare, su un piano di parità, tutti gli operatori interessati. In questo modo si realizza una forma di competizione "a monte", finalizzata all'affidamento della concessione, come accade tipicamente nella gestione delle reti ferroviarie, delle autostrade o di altre infrastrutture essenziali.

La regolazione e le forme di gestione dei servizi pubblici

La disciplina dei servizi pubblici ha ad oggetto **tre fasi fondamentali**: l'**assunzione** dell'attività come servizio pubblico, la **regolazione** del servizio e le **forme di gestione**.

La prima fase è quella dell'**assunzione di un'attività come servizio pubblico**. Essa deriva da una scelta politica con cui i pubblici poteri prendono atto che il mercato, da solo, non è in grado di offrire in modo adeguato determinati beni o servizi ritenuti essenziali per la collettività. In questi casi lo Stato o gli enti locali intervengono predisponendo strumenti di regolazione idonei a garantire livelli minimi quantitativi e qualitativi delle prestazioni e, se necessario, mettono a disposizione anche risorse pubbliche, come accade ad esempio nel caso dei contributi destinati al mantenimento di tratte ferroviarie secondarie. In questa fase riemerge una componente soggettiva della nozione di servizio pubblico, perché la decisione di "assumere" un'attività come servizio pubblico costituisce una responsabilità propria ed esclusiva dei pubblici poteri. A questo proposito, la nozione di servizio pubblico presenta due caratteri essenziali: la **storicità** e la **relatività**. La storicità significa che i beni e i servizi considerati essenziali mutano nel tempo, in relazione all'evoluzione dei bisogni sociali e del contesto economico. Ciò che in un determinato periodo storico è percepito come indispensabile può perdere in seguito tale connotazione o, viceversa, acquistarla. La relatività indica invece che l'area del servizio pubblico varia a seconda dei diversi contesti economici e sociali: un servizio può essere ritenuto essenziale in un determinato territorio o in una certa fase storica, ma non in altri contesti. La seconda fase è quella della **regolazione dei servizi pubblici**, che è finalizzata a garantire il corretto svolgimento del servizio e l'attuazione dei principi giuridici che lo governano. Questi principi si ricavano sia dalla giurisprudenza europea sia dalla **legge n. 481/1995**.

Il primo principio è quello della **doverosità**. I pubblici poteri hanno il compito di assicurare, direttamente o indirettamente, che il servizio venga effettivamente erogato secondo standard quantitativi e qualitativi predeterminati. Per questo motivo i gestori sono gravati da specifici **obblighi di servizio pubblico**, stabiliti negli atti di regolazione o negli atti di affidamento. Strettamente collegato alla doverosità è il principio della **continuità**, secondo cui l'erogazione del servizio non può essere interrotta arbitrariamente. Il servizio pubblico, proprio perché destinato a soddisfare bisogni essenziali della collettività, deve essere garantito in modo regolare e costante. A tutela di questa esigenza interviene anche il diritto penale, che prevede specifiche fattispecie di reato nei casi di interruzione o turbamento del servizio, e il diritto del lavoro, che limita l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali per assicurare comunque prestazioni minime indispensabili.

Un altro principio fondamentale è quello della **parità di trattamento**, in base al quale tutti gli utenti hanno eguale diritto ad accedere al servizio e a ricevere prestazioni di pari qualità. Il gestore del servizio pubblico, diversamente da un operatore economico che agisce in un mercato ordinario, non può scegliere liberamente la propria clientela né discriminare tra gli utenti. In questa logica si inserisce anche l'**obbligo a contrarre** previsto dal codice civile per le imprese che operano in condizioni di monopolio legale. A esso si affianca il principio della **universalità**, in forza del quale il servizio pubblico deve essere reso, di regola, accessibile a tutti, indipendentemente dalla collocazione geografica degli utenti, dal loro reddito o dalla loro condizione sociale. Il servizio non deve quindi essere organizzato soltanto secondo logiche di profitto, ma deve garantire una copertura generale della collettività. Ulteriore principio è quello della **abbordabilità**, ossia dell'accessibilità economica del servizio. Ciò significa che il servizio deve essere fornito a prezzi sostenibili per gli utenti e che la regolazione può prevedere tariffe agevolate o altre misure di favore per categorie meno abbienti o svantaggiate. Infine vi è il principio della **economicità**, secondo il quale il gestore deve poter svolgere il servizio in condizioni tali da assicurare un equilibrio economico dell'attività e un ragionevole margine di utile. Anche quando il servizio persegue finalità pubbliche, il gestore deve essere messo nelle condizioni di operare secondo criteri imprenditoriali, evitando squilibri strutturali che compromettano la qualità e la continuità della prestazione.

La terza fase riguarda le **forme di gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica**, che possono essere classificate in base al grado di collegamento del gestore con l'amministrazione pubblica titolare del servizio. La forma più tradizionale è la **gestione diretta**, che si ha quando il servizio viene svolto da strutture interne dell'ente pubblico titolare, come nel caso delle aziende speciali. In questo modello non vi è una vera separazione tra titolare del servizio e soggetto gestore. Un secondo modello è la **gestione indiretta**, nella quale il servizio è affidato a un **ente pubblico** appositamente incaricato del suo svolgimento. Si tratta di una formula storicamente molto diffusa, oggi però meno frequente, che in passato ha caratterizzato ad esempio la gestione delle poste o delle telecomunicazioni. Una terza forma è rappresentata dalla **società in-house**. Si tratta di una società formalmente distinta dall'amministrazione, ma ad essa così strettamente collegata sul piano organizzativo e funzionale da poter essere assimilata a un suo ufficio interno. Quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge, il servizio può essere affidato direttamente a tale società senza gara, mediante concessione o convenzione.

Una quarta forma è la **società mista**, cioè una società a partecipazione pubblica e privata che realizza una forma di esternalizzazione solo parziale del servizio. In base all'art. 17 del d.lgs. 175/2016, la scelta del socio privato deve avvenire mediante una procedura competitiva avente un doppio oggetto: da un lato, la selezione del socio in possesso delle migliori qualità tecniche ed economiche; dall'altro, l'affidamento del servizio alla società stessa. La partecipazione del socio privato può anche essere minoritaria, ma non inferiore al 30%. La società mista costituisce una forma di **partenariato pubblico-privato istituzionale**, perché la collaborazione tra soggetto pubblico e soggetto privato si realizza stabilmente all'interno di un'organizzazione comune. In sede europea si distingue, più in generale, tra **partenariato pubblico-privato istituzionale** e **partenariato pubblico-privato contrattuale**. Il primo ricorre appunto nella società mista, dove pubblico e privato partecipano insieme alla vita della società e interagiscono nei suoi organi. Il secondo si realizza invece quando l'amministrazione si limita ad affidare a un soggetto privato, tramite contratto, l'esecuzione del servizio, senza creare una struttura organizzativa comune. All'interno del partenariato di tipo contrattuale rientra la **concessione del servizio a soggetti terzi**, che rappresenta una quinta forma di gestione. Essa viene utilizzata nei casi in cui, per ragioni tecniche o economiche, il servizio possa essere efficacemente svolto da un solo gestore. L'affidamento avviene tramite procedura competitiva e realizza la cosiddetta **concorrenza per il mercato**. Anche qui il rapporto tra amministrazione concedente e concessionario è di lunga durata, spesso pluriennale o pluridecennale, per consentire l'ammortamento degli investimenti. Tuttavia, a differenza della società mista, nella concessione non vi è un coinvolgimento organizzativo diretto dell'amministrazione nella gestione del servizio. L'ultima forma è quella dell'**autorizzazione rilasciata a più gestori**, che consente a più operatori di erogare il servizio in concorrenza tra loro, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico fissati dal regolatore. In questo caso si realizza la **concorrenza nel mercato**, poiché il servizio è aperto a una pluralità di gestori. Infine, il **contratto di servizio** disciplina i rapporti tra l'amministrazione titolare del servizio e il gestore. Quando quest'ultimo è scelto mediante gara, lo schema del contratto viene normalmente allegato al bando e agli altri atti della procedura. I rapporti tra gestore e utenti sono invece regolati secondo modelli privatistici, attraverso **contratti di utenza**, spesso conformi a schemi tipo predisposti dal regolatore. Anche le **tariffe** applicate agli utenti trovano la loro disciplina nel contratto di servizio.

Le autorità di regolazione

Le **autorità di regolazione dei servizi pubblici** costituiscono una particolare sottospecie delle **autorità indipendenti di settore**. Esse sono state istituite soprattutto in concomitanza con i processi di **liberalizzazione** avviati negli anni '90, quando si è passati da un sistema fondato sul **monopolio legale** a un sistema aperto, almeno in parte, alla **concorrenza**. Proprio questo passaggio ha reso centrale il problema della regolazione, cioè della predisposizione di regole e strumenti di controllo capaci di disciplinare un mercato concorrenziale in settori che, per le loro caratteristiche tecniche ed

economiche, non possono essere lasciati al libero gioco del mercato. Il problema della regolazione si manifesta su **tre versanti principali**.

1. Il primo riguarda i **rapporti tra i gestori del servizio e l'autorità di regolazione**. In questi settori il regolatore deve costruire un quadro di regole che consenta, da un lato, lo sviluppo della concorrenza e, dall'altro, il perseguimento delle finalità proprie del servizio pubblico. Questa esigenza si avverte soprattutto nei mercati caratterizzati dalla presenza di **monopoli naturali**, cioè di reti e infrastrutture non facilmente duplicabili, come accade ad esempio nell'energia, nei trasporti o nelle telecomunicazioni. In simili situazioni la concorrenza non nasce spontaneamente, ma deve essere resa possibile attraverso una **regolazione ex ante**, che crea artificialmente le condizioni del mercato. A questa si affianca poi la tutela generale della concorrenza, affidata all'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**, che interviene ex post con sanzioni e altri strumenti repressivi quando vengano violate le regole concorrenziali.
2. Il secondo versante riguarda i **rapporti reciproci tra i gestori concorrenti**. Quando più operatori agiscono nello stesso settore, essi sono spesso gravati da obblighi reciproci finalizzati a garantire il corretto funzionamento del mercato e la tutela degli utenti. Un esempio classico è la **portabilità del numero telefonico**, che impone agli operatori di consentire all'utente il passaggio da un gestore all'altro senza perdere il proprio numero. Questi rapporti tra gestori sono in parte rimessi a strumenti negoziali, ma, qualora non sia possibile raggiungere un accordo, l'autorità di settore può intervenire con **provvedimenti unilaterali**, imponendo le soluzioni necessarie.
3. Il terzo versante concerne i **rapporti tra gestori e utenti**. Anche tali rapporti sono disciplinati da regole dettate dalle autorità di settore e dalle **carte dei servizi**, che fissano standard qualitativi, modalità di erogazione, diritti degli utenti e strumenti di tutela. In caso di violazione, l'utente può anzitutto presentare un **reclamo al gestore**, secondo le procedure da questo predisposte. Se il problema non viene risolto, può rivolgersi all'**autorità di settore**, la quale può definire la controversia in sede **stragiudiziale**.

Le principali autorità nazionali di regolazione settoriale sono **ARERA**, cioè l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, **AGCOM**, ossia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e **ART**, cioè l'Autorità di regolazione dei trasporti. Un nucleo essenziale di disciplina comune per queste autorità è contenuto nella **legge n. 481/1995**, alla quale si affiancano poi le norme speciali contenute nelle singole discipline di settore. Questa legge, anzitutto, individua le **finalità della regolazione**, chiarendo che l'intervento delle autorità deve essere orientato a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza, ma anche la qualità, l'accessibilità e la fruibilità dei servizi pubblici. Inoltre, essa detta alcune **regole organizzative** dirette a rafforzare l'indipendenza delle autorità, elemento essenziale perché esse possano svolgere il proprio ruolo senza interferenze da parte del potere esecutivo o degli operatori regolati. La legge delinea poi in termini generali le **funzioni e i poteri** delle autorità, che vengono successivamente specificati dalle discipline settoriali. Tra questi poteri rientra anzitutto la funzione di **advocacy**, consistente nel formulare osservazioni e proposte al governo e al parlamento per migliorare l'assetto normativo e regolatorio del settore. Le autorità possono inoltre **predisporre e aggiornare gli schemi di concessioni e autorizzazioni**, esercitando così un ruolo fondamentale nella configurazione dei rapporti tra pubblici poteri e gestori del servizio. Esse svolgono poi compiti di **vigilanza e controllo** sullo svolgimento dei servizi, avvalendosi di poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documenti. Infine, hanno anche funzioni di tutela degli utenti e dei consumatori, valutando **reclami, istanze e segnalazioni** e intervenendo, ove necessario, nella risoluzione delle controversie.

I servizi pubblici locali

La **disciplina dei servizi pubblici locali** è contenuta anzitutto nel **Testo unico degli enti locali**, in particolare negli artt. **112 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000**, oltre che nelle **leggi settoriali** relative ai singoli servizi, come ad esempio quelle in materia di distribuzione dell'energia elettrica, del gas o dei trasporti pubblici locali. Per i servizi gestiti tramite **società a partecipazione pubblica** rileva inoltre il **d.lgs. n. 175/2016**, cioè il Testo unico in materia di società partecipate. In termini generali, i servizi pubblici locali sono definiti in modo molto ampio dall'art. 112 TUEL, che ricomprende tutti i servizi aventi ad oggetto la produzione di beni e attività dirette a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Si tratta quindi di una nozione molto estesa, che valorizza non tanto la forma organizzativa del servizio quanto la sua funzione sociale e il suo collegamento con gli interessi della collettività locale. Proprio perché si tratta di un tema politicamente rilevante, le **decisioni fondamentali sull'organizzazione dei servizi pubblici locali** spettano al **consiglio comunale o provinciale**, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), TUEL. La scelta del modello di gestione non è dunque rimessa ai soli organi amministrativi, ma costituisce una decisione di indirizzo politico-amministrativo dell'ente. Per quanto riguarda i **servizi pubblici locali aventi rilevanza economica**, il TUEL, in particolare l'art. 113, prevedeva tre principali **forme di gestione**.

1. La prima è quella dell'affidamento a **società di capitali individuate tramite procedura a evidenza pubblica**. In questo caso il servizio viene esternalizzato a un soggetto scelto mediante gara, in ossequio ai principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
2. La seconda forma è quella delle **società miste pubblico-private**, nelle quali l'ente locale partecipa insieme a un socio privato. Anche qui, però, il socio privato non può essere scelto liberamente, ma deve essere individuato con una **procedura a evidenza pubblica**, così da garantire la selezione del partner economicamente e tecnicamente più idoneo.
3. La terza forma è quella dell'affidamento a **società in-house**, cioè società formalmente distinte dall'ente ma ad esso così strettamente collegate da poter essere assimilate, sotto certi profili, a una sua articolazione interna. Questo modello consente l'affidamento diretto del servizio, ma solo in presenza dei presupposti rigorosi elaborati dal diritto europeo e nazionale, come il **controllo analogo** e lo svolgimento prevalente dell'attività in favore dell'ente affidante.

Diversa era la disciplina dei **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica**, come ad esempio alcuni **servizi sociali**, oppure servizi culturali come **musei e biblioteche**. In passato essi erano regolati dall'art. **113-bis TUEL**, che consentiva la gestione mediante **affidamenti diretti ad aziende speciali, istituzioni o società in-house**. Tuttavia questa disposizione è stata dichiarata **incostituzionale** dalla **Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2004**, perché ritenuta lesiva delle competenze legislative regionali. Di conseguenza, per i servizi privi di rilevanza economica, spetta alle **regioni** individuare i modelli di gestione.

Il servizio sanitario nazionale, il servizio scolastico, i servizi sociali

Analizzando alcuni **servizi privi di rilevanza economica** disciplinati da leggi statali e regionali, vengono in rilievo soprattutto il **servizio sanitario nazionale**, il **servizio scolastico** e i **servizi sociali**. Si tratta di attività rivolte alla tutela di bisogni essenziali della persona e della collettività, il cui finanziamento grava in larga misura sulla fiscalità generale e la cui disciplina risponde prevalentemente a finalità sociali, più che di mercato. Il primo e più importante è il **servizio sanitario nazionale**, istituito in attuazione dell'art. 32 Cost., che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. La materia rientra nella **competenza legislativa concorrente** tra Stato e regioni ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. Le prestazioni offerte dal servizio sanitario nazionale comprendono sia attività di tipo **erogativo**, come l'assistenza medico-generica, specialistica e infermieristica, sia attività **amministrative** in settori quali l'igiene, la sicurezza sul

lavoro e la tutela ambientale. Il finanziamento del servizio grava principalmente sulla collettività e sulla fiscalità generale, anche se nel tempo sono state introdotte forme di **compartecipazione alla spesa** da parte degli utenti, come i ticket, nonché meccanismi di autofinanziamento regionale. Sotto il profilo organizzativo, il servizio sanitario dà luogo a una **amministrazione composita**, nella quale operano più livelli di governo. Lo **Stato**, e in particolare il Ministero della Salute, conserva soprattutto competenze di **programmazione generale**; le **regioni** hanno invece la responsabilità primaria dell'organizzazione del servizio e sono titolari di tutte le funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente riservati allo Stato; gli **enti locali** svolgono un ruolo più limitato. In particolare, allo Stato spetta la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni**, che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, così da assicurare un nucleo minimo di tutela eguale per tutti. La programmazione si concretizza nell'adozione del **piano sanitario nazionale**, elaborato con il coinvolgimento delle regioni, che costituisce la cornice di riferimento per i **piani sanitari regionali**. Allo Stato compete inoltre la predisposizione di uno schema generale per la redazione della **carta dei servizi sanitari**, adottata poi dalle singole strutture. Le **aziende sanitarie locali**, o **ASL**, sono definite dalla legge come **aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale**. I loro organi principali sono il **direttore generale** e il **collegio sindacale**. Il direttore generale è nominato dalla regione mediante una procedura selettiva tra candidati iscritti in un albo nazionale e in possesso di specifici requisiti di professionalità ed esperienza. Egli è responsabile della gestione complessiva dell'azienda e nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e i responsabili delle strutture operative. Le ASL assicurano i principali livelli di assistenza, cioè l'assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e quella ospedaliera. Nel sistema sanitario pubblico possono operare anche **strutture private**, che concorrono all'erogazione delle prestazioni attraverso il modello delle cosiddette **tre A: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali**. In primo luogo, è necessaria l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria e all'esercizio dell'attività, diretta a verificare il possesso dei requisiti tecnici minimi. In secondo luogo, per entrare stabilmente nel sistema pubblico, la struttura deve ottenere l'**accreditamento**, che la regione rilascia sulla base di valutazioni discrezionali collegate alla programmazione regionale e quindi al fabbisogno effettivo dei servizi. In terzo luogo, una volta accreditata, la struttura stipula con la regione **accordi contrattuali** che stabiliscono le attività da svolgere, la quantità massima di prestazioni e le relative modalità di remunerazione a carico del servizio sanitario. Una volta completata questa sequenza, la struttura privata entra a far parte del servizio sanitario regionale, acquisendo la qualità di **gestore del servizio pubblico** e restando soggetta alla vigilanza regionale. Un secondo settore fondamentale è il **servizio scolastico**, che può essere definito come un **servizio pubblico sociale a uso individuale e a erogazione gratuita**. Anch'esso si struttura come un sistema a rete, nel quale concorrono il livello statale, quello regionale e locale, oltre a soggetti privati che operano in base al principio di **sussidiarietà orizzontale**. I principi fondamentali del servizio scolastico trovano fondamento nella Costituzione, che tutela la **libertà di insegnamento** e garantisce il **diritto all'istruzione**; lo stesso diritto è richiamato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il servizio scolastico costituisce, da un lato, un compito costituzionalmente necessario dello **Stato**, il quale deve organizzarlo e gestirlo mediante proprie strutture, istituendo **scuole statali per tutti gli ordini e gradi**. Dall'altro lato, però, la Costituzione esclude la possibilità di un monopolio pubblico, poiché riconosce ai **privati** il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, purché senza oneri per lo Stato, e di ottenere il riconoscimento statale. Dopo la riforma del Titolo V del 2001, l'istruzione rientra nella **competenza legislativa concorrente** tra Stato e regioni, mentre la **formazione professionale** appartiene alla competenza legislativa esclusiva regionale. Le **istituzioni scolastiche pubbliche** hanno oggi **personalità giuridica** e godono di **autonomia organizzativa, didattica e finanziaria**. Ogni scuola elabora un **piano dell'offerta formativa**, che costituisce il documento fondamentale della sua identità culturale e progettuale. Gli organi principali della scuola pubblica sono il **dirigente scolastico**, responsabile della gestione manageriale; il **collegio dei docenti**, che sovrintende al funzionamento

didattico; e il **consiglio d'istituto**, al quale partecipano anche rappresentanti dei genitori e degli studenti. Anche le **scuole private** possono far parte del sistema dell'istruzione, ma solo attraverso un procedimento di **riconoscimento** fondato sull'accertamento di requisiti di qualità, efficacia e conformità agli ordinamenti generali dell'istruzione, oltre che sulla coerenza con la domanda formativa delle famiglie. Una volta riconosciute, esse restano sottoposte alla **vigilanza statale**, che verifica il mantenimento dei requisiti e il rispetto degli obblighi di servizio pubblico. Un terzo ambito particolarmente importante è quello dei **servizi sociali**, che comprendono tutte le attività dirette a predisporre ed erogare servizi, gratuiti o a pagamento, o prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e difficoltà della persona nel corso della vita. Dopo la riforma del Titolo V, i servizi sociali rientrano nella **competenza legislativa residuale esclusiva delle regioni**, mentre allo Stato spetta soltanto la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni**, in modo da garantire una tutela minima uniforme su tutto il territorio nazionale. Anche in questo settore opera il principio di **sussidiarietà verticale**. Le **regioni** svolgono funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, anche attraverso la predisposizione di piani e la definizione degli ambiti territoriali. Le **province** hanno soprattutto compiti di raccolta dei dati e analisi dell'offerta dei servizi. I **comuni** occupano invece una posizione centrale, poiché sono titolari delle funzioni amministrative in materia e provvedono concretamente all'erogazione dei servizi, sostenendone anche l'onere economico. Allo stesso tempo, nei servizi sociali trova ampia applicazione il principio di **sussidiarietà orizzontale**, che valorizza il ruolo dei soggetti privati e del privato sociale. In questo quadro si inserisce la disciplina del **Terzo settore**, oggetto di una riforma organica operata con il **d.lgs. 117/2017**, poi modificato dal **d.lgs. 105/2018**. Rientrano nel Terzo settore le **organizzazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale**, gli **enti filantropici**, le **imprese sociali**, comprese le cooperative, nonché **associazioni e fondazioni**. Questi enti possono svolgere un ampio insieme di **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale**. In tal modo, il legislatore riconosce formalmente il contributo essenziale di tali soggetti nell'ambito dei servizi sociali e, più in generale, nella realizzazione di interessi generali.

IL PERSONALE

Come tutte le organizzazioni, anche le **pubbliche amministrazioni** hanno bisogno di dotarsi di personale per svolgere i propri compiti. Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è oggi disciplinato da una normativa speciale, riordinata soprattutto nel **d.lgs. 165/2001**, ma il suo assetto attuale è il risultato di una lunga evoluzione storica tra due modelli opposti: uno **publicistico** e uno **privatistico**. In origine prevaleva una **concezione publicistica** del pubblico impiego. Si riteneva infatti che il dipendente pubblico fosse inserito in un rapporto di **supremazia speciale** nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, caratterizzato da particolari doveri, come la **fedeltà**, l'**obbedienza** e il **segreto d'ufficio**, nonché da limitazioni nell'esercizio di alcuni diritti, per esempio in tema di appartenenza politica o sindacale. In questa prospettiva, lo stipendio non era considerato come il corrispettivo di una prestazione lavorativa, ma come un **credito di diritto pubblico**, quasi assimilabile a una prestazione alimentare. Coerentemente con tale impostazione, si escludeva che il rapporto di impiego potesse essere regolato mediante strumenti contrattuali: esso doveva invece essere disciplinato da **atti normativi** e da **provvedimenti amministrativi unilaterali**. Anche le controversie relative al rapporto di impiego rientravano, di conseguenza, nella giurisdizione del **giudice amministrativo**. La **Costituzione**, pur non imponendo un modello interamente publicistico, riflette in parte questa impostazione. Essa stabilisce anzitutto che i pubblici impiegati sono **al servizio esclusivo della Nazione** (art. 98, comma 1), affermando così che essi non devono perseguire interessi di parte o essere asserviti alla politica, ma devono operare in posizione di neutralità. I dipendenti pubblici sono infatti considerati strumenti essenziali per garantire non solo il **buon andamento**, ma anche l'**imparzialità** dell'amministrazione (art. 97 Cost.). Proprio per assicurare tali valori, la Costituzione prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda, di regola, mediante **concorso pubblico** (art. 97, comma 3), e che l'accesso ai pubblici uffici sia garantito a tutti i cittadini

in condizioni di **eguaglianza** (art. 51 Cost.). Inoltre, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono adempierle con **disciplina e onore**, prestando anche giuramento nei casi stabiliti dalla legge (art. 54, comma 2). Da queste norme emerge una stretta connessione tra **status di cittadino** e **status di dipendente pubblico**: il secondo viene visto quasi come una particolare proiezione del primo. Nel complesso, però, la Costituzione non impone uno statuto interamente separato e pubblicistico del lavoro pubblico. Come ha chiarito la **Corte costituzionale**, essa consente piuttosto un equilibrio tra **fonti pubblicistiche unilaterali** e **fonti contrattuali**, lasciando quindi spazio a una progressiva evoluzione verso modelli più vicini al lavoro privato. Nel periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione, la concezione pubblicistica entra progressivamente in crisi per almeno due ragioni. Da un lato, anche nel settore pubblico si afferma la richiesta di un più pieno riconoscimento dei **diritti sindacali** e dell'introduzione di veri meccanismi di **contrattazione collettiva**. Dall'altro lato, si fa sempre più forte l'esigenza di rendere l'amministrazione più **efficiente**, più **flessibile** e più coerente con una visione **aziendalistica** dell'organizzazione pubblica. In questo quadro, già alla fine degli anni Sessanta la contrattazione collettiva viene ammessa per gli enti ospedalieri, mentre la **legge quadro sul pubblico impiego** del 1983 rappresenta il primo tentativo di introdurre un modello generale di contrattazione. Tuttavia, quel sistema era ancora un modello **ibrido**: l'accordo collettivo nasceva sì da una negoziazione tra le parti, ma produceva effetti solo attraverso la sua trasposizione in **atti normativi o amministrativi unilaterali**. Si trattava quindi di una contrattazione non ancora pienamente privatistica, perché il risultato finale restava inserito in uno schema autoritativo. La vera svolta si è avuta con il **d.lgs. 165/2001**, che ha riordinato la disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni secondo una logica chiaramente ispirata alla **privatizzazione del pubblico impiego**, poi ulteriormente sviluppata e corretta dal **d.lgs. 150/2009**. Con questa riforma il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, salvo alcune eccezioni, viene ricondotto prevalentemente al **diritto privato** e regolato, per molti aspetti, dalle norme del codice civile e dalla contrattazione collettiva. In questo modo si afferma l'idea che, pur restando il lavoro pubblico legato a finalità istituzionali e a principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, esso possa essere disciplinato con strumenti più vicini a quelli del lavoro subordinato privato.

Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro

Il **d.lgs. n. 165/2001** definisce, all'art. 1, l'ambito di applicazione generale del regime del **pubblico impiego privatizzato**, individuando un elenco molto ampio di pubbliche amministrazioni — tra cui Stato, enti territoriali, camere di commercio e altri enti pubblici — i cui dipendenti sono sottoposti, in linea di principio, al **regime privatistico** previsto dall'art. 2, comma 2. Non tutto il lavoro pubblico, però, è stato contrattualizzato. Alcune categorie di personale restano infatti assoggettate al **diritto pubblico**, come dispone l'art. 3 del decreto. Si tratta, ad esempio, del personale militare, delle forze di polizia, dei magistrati, degli avvocati dello Stato, dei vigili del fuoco, dei professori universitari e di altre categorie per le quali continuano a valere le regole speciali dettate dai rispettivi ordinamenti. Per tali categorie il regime pubblicistico si atteggia in modo diverso a seconda dei casi. In alcune ipotesi, come per i **magistrati**, la disciplina del rapporto di lavoro rimane integralmente pubblicistica. In altre, invece, pur restando fermo il carattere pubblicistico del rapporto, alcuni aspetti possono essere regolati attraverso **accordi collettivi** oppure mediante **procedure di concertazione** con le rappresentanze del personale, come accade ad esempio per il personale diplomatico e prefettizio o per il personale militare. Anche in questi casi, tuttavia, la disciplina finale non si perfeziona con un contratto, ma viene recepita tramite **provvedimenti unilaterali**, in particolare con decreti del Presidente della Repubblica. Coerentemente con questa impostazione, tutte le controversie relative a tali rapporti restano devolute alla **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo**. Per il personale rientrante nel regime privatistico, il d.lgs. 165/2001 non realizza una piena assimilazione al lavoro privato comune, ma costruisce piuttosto un **diritto privato speciale o differenziato**, caratterizzato da numerose deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del lavoro subordinato. Ne deriva che il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici continua a presentare diversi **profili di specialità**. Un esempio significativo è la

regola secondo cui lo svolgimento di fatto di **mansioni superiori** rispetto alla qualifica posseduta non comporta, come invece accade nel lavoro privato, il diritto automatico all'inquadramento nella qualifica superiore. Questa deroga è giustificata dall'esigenza di tutelare il **principio del concorso pubblico**, che impedisce avanzamenti di carriera non coerenti con procedure selettive imparziali. Un ruolo centrale nel sistema è attribuito alla **contrattazione collettiva**, alla quale spetta determinare "i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali" ai sensi dell'art. 40, comma 1. Tuttavia la contrattazione collettiva non opera in modo illimitato, ma entro uno spazio definito e circoscritto dalla legge. In primo luogo, sono escluse dalla contrattazione tutte le materie relative all'**organizzazione degli uffici**, che restano disciplinate da ciascuna amministrazione mediante atti pubblicistici, come regolamenti e provvedimenti amministrativi. Sono poi sottratte alla negoziazione anche le materie concernenti le **prerogative dei dirigenti e degli uffici** competenti all'organizzazione e alla gestione del personale, esercitate con i poteri del privato datore di lavoro. Restano inoltre escluse, tra l'altro, le questioni relative al **conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali**, alla definizione delle **dotazioni organiche**, ai **procedimenti di accesso al lavoro** e al regime delle **incompatibilità**. Nel complesso, la tendenza legislativa più recente è stata quella di **restringere progressivamente gli spazi della contrattazione collettiva**, rafforzando le aree riservate alla disciplina unilaterale dell'amministrazione. Quanto alle modalità di svolgimento della contrattazione, il sistema si articola su più livelli. Il decreto delinea infatti una struttura **flessibile e a cascata**, demandando alla stessa contrattazione collettiva il compito di definire la struttura del sistema contrattuale, i rapporti tra i vari livelli e la durata dei contratti. Il primo livello è quello che individua i **comparti di contrattazione**, che non possono essere più di quattro e che raggruppano categorie di personale appartenenti ad amministrazioni omogenee. All'interno dei comparti possono essere previste anche **sezioni contrattuali** riferite a specifiche professionalità. Il secondo livello è costituito dai **contratti collettivi nazionali**, stipulati per ciascun comparto. Essi regolano gli aspetti economici e giuridici fondamentali del rapporto di lavoro e definiscono altresì le materie, i vincoli, i limiti finanziari e le procedure della contrattazione decentrata. Al di sotto di essi si collocano i **contratti collettivi integrativi**, riferiti alla singola amministrazione. Questi ultimi sono finalizzati soprattutto a migliorare l'efficienza e la produttività degli uffici e a valorizzare, anche sul piano del trattamento economico accessorio, la **performance individuale** dei dipendenti. Va però sottolineato che, se non si raggiunge l'accordo per la stipula del contratto integrativo, l'amministrazione può intervenire **in via unilaterale e provvisoria** sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla conclusione del contratto stesso. In questo punto emerge chiaramente come, anche nel sistema privatizzato, permanga una **residua unilateralità** pubblicistica. Dal punto di vista soggettivo, la contrattazione collettiva pubblica presenta una struttura peculiare. Per la parte pubblica opera l'**ARAN** (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Essa rappresenta le pubbliche amministrazioni nella negoziazione dei contratti collettivi nazionali e può anche assistere le singole amministrazioni nella contrattazione integrativa. L'ARAN è dunque il soggetto che, in nome e per conto delle amministrazioni, svolge la funzione negoziale sul piano nazionale. La controparte dell'ARAN è costituita dalle **organizzazioni sindacali** dei dipendenti pubblici. Non tutte però possono partecipare alla negoziazione: il decreto richiede infatti un requisito minimo di **rappresentatività**, fissato al 5%, calcolato come media tra il dato associativo — cioè il numero delle deleghe sindacali conferite dai lavoratori per il versamento dei contributi — e il dato elettorale, cioè i risultati ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali. Inoltre, l'ARAN può procedere alla sottoscrizione del contratto collettivo solo se le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi di accordo rappresentano complessivamente almeno il **51%** come media tra dato associativo ed elettorale nel comparto, oppure almeno il **60% del dato elettorale**. Questo meccanismo serve a garantire che la contrattazione collettiva pubblica sia realmente espressione delle organizzazioni sindacali più rappresentative e non di soggetti minoritari.

La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro

I **procedimenti di selezione e di avviamento al lavoro nelle pubbliche amministrazioni**, che precedono la costituzione del rapporto di lavoro, sono disciplinati esclusivamente dalla **legge** o da altri atti normativi e amministrativi. In questo ambito domina il **principio del concorso pubblico**, che costituisce la regola generale di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le eccezioni sono limitate e riguardano soltanto alcune ipotesi specifiche: da un lato, il personale collocato nelle qualifiche più basse, per le quali è richiesto il solo titolo della scuola dell'obbligo, che può essere assunto tramite **avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento**; dall'altro, le **assunzioni obbligatorie degli invalidi**, che avvengono mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste. Anche per l'accesso alla **dirigenza**, sia di prima sia di seconda fascia, il concorso pubblico resta la regola generale. Per i dirigenti di seconda fascia, tuttavia, è prevista anche una modalità alternativa, rappresentata dal **corso-concorso** bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, della durata di dodici mesi. Il **procedimento concorsuale** si articola in una serie di fasi ben definite. La prima è quella dell'**avvio della procedura**, che ciascuna amministrazione promuove nell'ambito della propria programmazione triennale del fabbisogno di personale. L'avvio avviene mediante l'adozione del provvedimento che indice il concorso e la pubblicazione del **bando**, di regola nella Gazzetta Ufficiale e con ulteriori modalità idonee a garantirne la massima diffusione. Il bando assume un ruolo centrale, perché costituisce la **lex specialis** della procedura: esso vincola l'amministrazione nello svolgimento delle prove e nella valutazione dei candidati, e la sua violazione comporta l'illegittimità degli atti successivi. La seconda fase è quella della **presentazione delle domande di partecipazione**, che devono essere inviate o depositate entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando. Segue poi la fase **istruttoria e valutativa**, affidata a una **commissione esaminatrice** nominata dall'amministrazione. La composizione della commissione deve garantire imparzialità e competenza: essa è infatti formata da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed eventualmente soggetti esterni. Proprio per tutelare la neutralità della selezione, non possono far parte della commissione né gli organi di direzione politica dell'amministrazione né soggetti che ricoprano cariche politiche o sindacali. La fase successiva è quella **decisionale**, che torna in capo all'amministrazione che ha indetto il concorso. Essa consiste nella verifica della regolarità dell'intera procedura e nell'**approvazione della graduatoria di merito**, con l'indicazione dei candidati vincitori e degli eventuali idonei. Una volta concluso il procedimento, i vincitori vengono assunti mediante **contratto individuale di lavoro** oppure, per il personale ancora soggetto al regime pubblicistico, tramite **provvedimento di nomina**. Nel caso del personale contrattualizzato, il contratto individuale non lascia comunque spazio a una libera determinazione del contenuto del rapporto, poiché i diritti e gli obblighi del dipendente sono già in larga parte definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Quanto al **regime giuridico dei dipendenti pubblici**, esso presenta alcune caratteristiche peculiari. Un primo profilo è dato dall'**obbligo di esclusività**: il dipendente pubblico è tenuto a dedicare le proprie energie lavorative all'amministrazione di appartenenza e, in linea generale, non può esercitare il commercio, l'industria, una professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati. Questo obbligo si ricollega idealmente al dovere di fedeltà alla Nazione sancito dall'art. 98 Cost. e la sua violazione può comportare sanzioni disciplinari fino alla risoluzione del rapporto. Il regime delle **incompatibilità** è sottratto alla contrattazione collettiva ed è disciplinato in modo dettagliato dalla legge. Sono ammesse alcune deroghe, come il **part-time** per determinate categorie — ad esempio docenti universitari, insegnanti e medici del Servizio sanitario nazionale — e sono escluse dal divieto alcune attività retribuite particolari, come collaborazioni con giornali o la partecipazione a convegni. Un secondo aspetto tipico riguarda la **disciplina delle mansioni**. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto oppure a mansioni equivalenti. L'assegnazione a mansioni superiori è consentita solo in via eccezionale, ad esempio in caso di vacanza di posto in organico o di sostituzione di un altro dipendente assente, e in tal caso dà diritto soltanto al trattamento economico corrispondente, ma non all'automatico inquadramento nella qualifica superiore. Anche qui emerge la differenza rispetto al

lavoro privato e la persistente centralità del principio del concorso. Il **trattamento economico** è definito principalmente dalla contrattazione collettiva ed è articolato in due componenti: **trattamento fondamentale** e **trattamento accessorio**. Quest'ultimo non viene attribuito automaticamente, ma dipende da una valutazione che tiene conto della **performance individuale**, della **performance organizzativa** dell'amministrazione o della singola unità organizzativa e dell'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o nocive. Il d.lgs. 150/2009 ha rafforzato questa logica introducendo un sistema di **misurazione, valutazione e trasparenza della performance**, affidato in ciascuna amministrazione a un **organismo indipendente di valutazione**, nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. A livello nazionale, un ruolo di indirizzo e coordinamento è attribuito all'**Autorità nazionale anticorruzione**. Altro profilo importante è quello della **mobilità**, pensata come strumento per rendere più flessibile l'impiego delle risorse umane e favorire una migliore distribuzione del personale tra le amministrazioni. Per la **mobilità individuale** tra comparti diversi è prevista una tabella di equiparazione dei livelli di inquadramento. Inoltre, prima di indire nuovi concorsi per coprire posti vacanti, le amministrazioni devono attivare le procedure di mobilità. Quanto alla **mobilità collettiva**, essa rileva soprattutto nei casi di eccedenza di personale. In tali ipotesi è previsto un procedimento che comporta informazione preventiva alle rappresentanze del personale e alle organizzazioni sindacali e che favorisce, ove possibile, il reimpiego presso altre amministrazioni, il ricorso a forme flessibili di lavoro o ai contratti di solidarietà. Se non è possibile una diversa collocazione, il personale eccedentario viene posto in **disponibilità**, con sospensione del rapporto di lavoro e corresponsione di un'indennità pari all'80% della retribuzione per un massimo di due anni. Tale personale è inserito in appositi elenchi nazionali o regionali ai fini dell'eventuale ricollocazione. Molto rilevante è anche la materia delle **sanzioni disciplinari**. Il d.lgs. 150/2009 è intervenuto per ridurre ulteriormente gli spazi della contrattazione collettiva, lasciando a quest'ultima ancora la definizione delle tipologie di infrazioni e delle relative sanzioni, ma riservando alla legge la disciplina di molte fattispecie e del procedimento. Tra le sanzioni si annoverano il rimprovero verbale, la sospensione dal servizio e il licenziamento disciplinare. La legge tipizza direttamente alcune condotte particolarmente gravi, come la falsa attestazione della presenza in servizio o l'assenza giustificata da certificazione medica falsa, che possono condurre al licenziamento. Anche il **procedimento disciplinare** è regolato legislativamente. Per le sanzioni di minore gravità il procedimento è avviato dal dirigente competente mediante contestazione degli addebiti entro venti giorni, con successiva fase di contraddittorio orale o scritto e conclusione entro sessanta giorni dalla contestazione. Per le sanzioni più gravi, invece, il procedimento è gestito da un apposito **ufficio competente per i procedimenti disciplinari**, istituito presso ciascuna amministrazione, e si svolge secondo termini più lunghi. Alla responsabilità disciplinare si aggiungono, naturalmente, anche la **responsabilità civile**, la **responsabilità amministrativa per danno erariale** e la **responsabilità penale** per eventuali reati propri del pubblico dipendente.

La dirigenza pubblica

Con l'ampliarsi delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, il **modello gerarchico tradizionale** ha mostrato progressivamente i propri limiti. Non era più realistico concentrare in un unico organo tutto il potere decisionale formale. Per questo, a partire dagli anni Settanta, si afferma un modello diverso, fondato sulla **dirigenza pubblica** come categoria professionale autonoma. Nascono così tre qualifiche dirigenziali — dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente — e i dirigenti cessano di essere semplici preposti a uffici interni, diventando invece titolari di veri e propri organi, capaci di esprimere all'esterno la volontà dell'amministrazione. La riforma del pubblico impiego avviata negli anni Novanta, poi confluita nel **d.lgs. 165/2001**, ha rafforzato ulteriormente questo ruolo. La valorizzazione della dirigenza risponde a una duplice esigenza: da un lato, accrescere l'efficienza della pubblica amministrazione, introducendo figure assimilabili ai manager privati; dall'altro, garantire l'**imparzialità** dell'azione amministrativa, limitando le interferenze della politica nelle decisioni gestionali. È qui che si colloca il modello della **distinzione tra politica e amministrazione**, introdotto

dal decreto del 2001, che cerca di conciliare il principio democratico — secondo cui nessun potere pubblico può sottrarsi al circuito politico-rappresentativo — con il principio di imparzialità della PA sancito dall'art. 97 Cost. Il primo grande tema riguarda la **ripartizione delle competenze**. Agli organi politici sono attribuite esclusivamente funzioni di **indirizzo politico-amministrativo** e di **controllo ex post**. Spetta a essi definire gli obiettivi e i programmi da attuare, individuare priorità, piani, programmi e direttive generali, adottare atti normativi e di indirizzo interpretativo e applicativo, nonché assegnare agli uffici le risorse umane, finanziarie e materiali. Ai dirigenti, invece, è riservata la **gestione amministrativa**, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo. A loro compete anche l'adozione dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli discrezionali, e sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati. Questa ripartizione è molto netta: le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate solo da specifiche norme di legge che riservino espressamente taluni atti al vertice politico. Inoltre, il vertice politico **non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé** gli atti di competenza dirigenziale. Proprio per questo il rapporto tra organo politico e dirigente non può essere qualificato in termini di gerarchia. In caso di inerzia o ritardo, però, l'organo politico può fissare un termine entro cui il dirigente deve provvedere; se il dirigente resta inadempiente, oppure in caso di grave inosservanza delle direttive generali, il vertice politico può nominare un **commissario ad acta** che si sostituisce a lui. All'interno di ogni amministrazione statale è istituito il **ruolo dei dirigenti**, articolato in **prima e seconda fascia**. I dirigenti degli uffici dirigenziali generali svolgono funzioni di impulso generale, coordinano e controllano i dirigenti sottordinati, formulano proposte ed esprimono pareri al vertice politico, anche in relazione alle direttive generali annuali. In questo senso, il loro ruolo non è meramente esecutivo: partecipano in qualche misura anche alla definizione dell'indirizzo politico-amministrativo, perché quest'ultimo, per essere efficace, deve essere calibrato sulla concreta realtà amministrativa. Il rapporto tra politica e amministrazione assume così una forma quasi circolare. I dirigenti di livello inferiore, invece, curano l'attuazione concreta dei progetti e degli obiettivi loro assegnati, dirigono e coordinano gli uffici, gestiscono il personale e svolgono i compiti eventualmente delegati dai dirigenti generali. Anche loro possono formulare proposte e pareri verso il livello superiore. Quindi la dirigenza non è solo il terminale operativo della macchina amministrativa, ma anche un anello essenziale di raccordo tecnico tra indirizzo e attuazione. Il secondo grande tema è quello del **conferimento degli incarichi dirigenziali**. Prima delle riforme degli anni Novanta, gli incarichi avevano di fatto carattere stabile e i responsabili degli uffici dirigenziali erano quasi inamovibili. Oggi, invece, vige un sistema molto diverso. Gli incarichi vengono conferiti tenendo conto delle **attitudini**, delle **capacità professionali**, dei risultati ottenuti negli incarichi precedenti, delle competenze organizzative e delle esperienze maturate anche nel settore privato o all'estero. Inoltre, gli incarichi hanno una **durata limitata nel tempo**, anche se sono rinnovabili previa verifica positiva dei risultati raggiunti. L'atto di conferimento dell'incarico deve indicarne l'oggetto, gli obiettivi da conseguire e la durata. A esso si collega il **contratto individuale**, che definisce il trattamento economico sulla base dei contratti collettivi nazionali. Una parte importante della retribuzione è costituita dal trattamento accessorio collegato alle funzioni svolte e ai risultati conseguiti: esso deve rappresentare almeno il **30% della retribuzione complessiva**, proprio per rafforzare la logica manageriale e premiale del sistema. Le modalità di conferimento variano a seconda del livello dell'incarico. Gli incarichi più elevati, come quelli di **segretario generale del ministero** o di direzione di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, sono conferiti con **decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente. Gli incarichi di dirigente generale sono invece conferiti con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, sempre su proposta del ministro competente. Gli altri incarichi dirigenziali sono attribuiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale. Una quota limitata di incarichi può essere attribuita anche a **soggetti esterni all'amministrazione**, purché dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale. La legge consente questa possibilità entro limiti percentuali precisi: il 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e l'8% di quella di seconda fascia.

I soggetti esterni devono aver maturato esperienze significative in enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, oppure possedere una qualificazione scientifica o professionale elevata, spesso di tipo accademico. È un'apertura pensata per introdurre competenze specialistiche e capacità manageriali nuove, senza però svuotare il ruolo della dirigenza interna. I dirigenti pubblici sono poi sottoposti a una **verifica periodica dei risultati**, per accertare la corrispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti dagli organi politici. Se non raggiungono gli obiettivi assegnati, o se violano le direttive ricevute, o ancora se omettono di vigilare sul rispetto da parte del personale degli standard qualitativi e quantitativi fissati dall'amministrazione, può sorgere una forma specifica di responsabilità: la **responsabilità dirigenziale**. Essa si aggiunge alla normale responsabilità disciplinare e ha una funzione strettamente collegata alla logica della distinzione tra indirizzo politico e gestione. La responsabilità dirigenziale viene accertata nel rispetto del **contraddittorio**, previa contestazione degli addebiti e previo parere di un **comitato di garanti** nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le conseguenze possono essere diverse, in ordine crescente di gravità: mancato rinnovo dell'incarico, riduzione della retribuzione di risultato, revoca dell'incarico con collocazione in altro ruolo, fino al recesso dal rapporto di lavoro. È quindi uno strumento pensato per rendere effettiva la responsabilizzazione dei dirigenti rispetto ai risultati della loro attività. Infine, per gli incarichi più alti dell'amministrazione statale, opera un particolare meccanismo di **spoil system**. La cessazione degli incarichi apicali, come quelli di segretario generale dei ministeri e di direzione delle strutture articolate in uffici dirigenziali generali, si verifica automaticamente con l'insediamento di un nuovo governo, e più precisamente al novantesimo giorno dal voto di fiducia. Questo meccanismo mira a garantire al nuovo esecutivo la possibilità di avvalersi di figure apicali pienamente in sintonia con il proprio indirizzo politico, pur restando ferma la distinzione tra funzione di indirizzo e funzione di gestione.

I BENI

Tutte le organizzazioni, per poter operare, hanno bisogno non solo di personale, ma anche di **beni strumentali** necessari allo svolgimento della propria attività. Vale anche per le pubbliche amministrazioni: per realizzare i propri fini, esse devono disporre di beni mobili e immobili. In ambito privatistico, del resto, l'azienda è definita come il "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" (art. 2555 c.c.), e qualcosa di analogo vale anche per l'apparato pubblico. La **Costituzione** riconosce espressamente questa realtà. Da un lato afferma che "la proprietà è pubblica o privata" (art. 42, comma 1); dall'altro precisa che "i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati", legittimando così Stato ed enti pubblici a essere titolari di beni. Il **codice civile**, negli artt. 822 e seguenti, dedica una disciplina specifica ai beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici, distinguendo tra **beni demaniali** e **beni patrimoniali**. I primi sono soggetti a un regime fortemente pubblicistico; i secondi, invece, sono sottoposti alle regole particolari che li riguardano e, in via residuale, alle norme comuni del codice civile. Questa distinzione, però, non si fonda tanto sulle caratteristiche sostanziali del bene, quanto piuttosto su un criterio prevalentemente **formale**, basato sulla loro inclusione in categorie o elenchi normativi. Va aggiunto che non solo i beni pubblici, ma anche i **beni privati** possono essere toccati da regimi pubblicistici. La proprietà privata, infatti, pur essendo garantita, può essere conformata dal legislatore e dai pubblici poteri per assicurarne la **funzione sociale** e renderla accessibile a tutti, come stabilisce l'art. 42, comma 2, Cost. Per questo oggi la disciplina dei beni non ruota più soltanto attorno alla distinzione soggettiva tra proprietà pubblica e proprietà privata, ma guarda sempre di più alla **relazione oggettiva del bene con l'interesse pubblico**. In altri termini, ciò che conta è quanto intensamente un bene sia collegato a un'utilità collettiva. Da questo punto di vista si può costruire una classificazione dei beni secondo il grado di specialità del regime giuridico applicabile. Al livello più basso vi sono i **beni privati sottoposti essenzialmente al diritto comune**, che seguono la disciplina ordinaria civilistica. Un gradino oltre si trovano i **beni privati di interesse pubblico**, cioè beni che restano formalmente privati ma sono incisi, per particolari profili, da vincoli o limiti posti a tutela di interessi collettivi. Seguono

poi i **beni patrimoniali indisponibili**, che appartengono a enti pubblici e sono destinati a una funzione di pubblico interesse, con la conseguenza che non possono essere sottratti liberamente alla loro destinazione. All'estremo della specialità si collocano infine i **beni pubblici in senso stretto**, cioè i beni del **demanio pubblico**, assoggettati a un regime tipicamente pubblicistico. Per comprendere meglio questa classificazione, è utile richiamare anche la distinzione elaborata dalla **scienza economica**, che suddivide i beni in quattro categorie: beni privati, beni pubblici, beni di club e beni comuni. Questa classificazione si fonda su due criteri: **escludibilità** e **rivalità**. Un bene è escludibile quando è possibile impedire ad altri di usarlo o goderne; è non escludibile quando ciò non è realisticamente possibile. Un bene è rivale quando l'uso da parte di un soggetto riduce la possibilità di uso da parte di altri; è non rivale quando l'uso di uno non limita, almeno fino a un certo punto, l'uso altrui. I **beni privati** sono insieme escludibili e rivali: un esempio tipico sono gli alimenti. Possono essere appropriati da un singolo e, se uno li consuma, gli altri non possono più farlo. I **beni pubblici**, invece, non sono né escludibili né rivali: basti pensare all'illuminazione pubblica o alla difesa nazionale. In questi casi il mercato non è in grado di produrre spontaneamente il bene in misura adeguata, perché non è possibile far pagare in modo selettivo chi ne beneficia. Per questo si giustifica l'intervento pubblico, che può assumere varie forme: proprietà pubblica del bene, predisposizione di apparati amministrativi appositi, oppure regolazione amministrativa. Il loro finanziamento grava di regola sull'intera collettività, attraverso la fiscalità generale. I **beni di club** presentano una combinazione diversa: sono **non rivali**, ma **escludibili**. Ciò significa che più persone possono usufruirne contemporaneamente senza pregiudicarsi troppo a vicenda, ma è possibile escludere chi non paga o non appartiene al gruppo autorizzato. Rientrano in questa categoria, per esempio, la televisione via cavo o le autostrade a pedaggio. Sono beni che possono essere prodotti e gestiti anche dal mercato, oppure da enti associativi o no profit, proprio perché l'accesso può essere selezionato. Infine vi sono i **beni comuni**, che non sono escludibili ma sono rivali. Esempi tipici sono i pascoli, i fiumi o altre risorse naturali condivise. In questo caso il problema è il **sovraconsumo**: poiché nessuno può essere facilmente escluso dal godimento del bene, ma l'uso di uno riduce la disponibilità per gli altri, c'è il rischio che il bene venga sfruttato eccessivamente fino a deteriorarsi o addirittura esaurirsi. È la classica situazione che giustifica l'introduzione di regole pubblicistiche limitative dell'uso, proprio per salvaguardare il bene nel lungo periodo.

I beni di interesse privato e i beni di interesse pubblico

Si può porre una distinzione oggettiva tra beni di interesse privato e beni di interesse pubblico. I **beni di interesse privato** sono, in linea di principio, disciplinati dal **codice civile**. Il proprietario ha infatti il diritto di "godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo", entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento (art. 832 c.c.). Questo però non significa che tali beni siano sempre sottratti a interferenze pubblicistiche: anche beni di interesse privato possono essere assoggettati a regimi speciali che attribuiscono all'amministrazione poteri conformativi. È il caso, ad esempio, della disciplina urbanistica ed edilizia oppure dei vincoli posti a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Dentro questa categoria rientrano anche alcuni **beni pubblici in senso soggettivo**, cioè i **beni patrimoniali disponibili** appartenenti allo Stato e agli enti territoriali, regolati in via generale dal diritto comune (art. 826 c.c.). Si tratta di beni che non sono destinati né a un pubblico ufficio né a una fruizione collettiva diretta, come può accadere per immobili locati a privati. In questi casi la pubblica amministrazione li possiede non per destinarli immediatamente a un interesse pubblico specifico, ma per ricavarne un reddito. Tuttavia anche qui emergono profili pubblicistici, che non riguardano tanto il regime del bene in sé, quanto piuttosto le **modalità di acquisto e alienazione**, che devono rispettare procedure di evidenza pubblica. Diversa è la categoria dei **beni di interesse pubblico**, nei quali la rilevanza pubblicistica non è esterna o occasionale, ma **immanente al bene stesso**. Nei beni di interesse privato, l'interesse pubblico eventualmente interferisce dall'esterno con l'esercizio del diritto di proprietà; nei beni di interesse pubblico, invece, l'interesse collettivo è incorporato nella natura e nella funzione del bene. È il caso, per esempio, dei reperti archeologici, delle

statue di valore storico, dei beni culturali e dei beni paesaggistici. La categoria più importante è proprio quella dei **beni culturali** e dei **beni paesaggistici**. I beni culturali sono le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, nonché le altre cose individuate dalla legge come testimonianze aventi valore di civiltà. I beni paesaggistici, invece, sono gli immobili e le aree che esprimono valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. In entrambi i casi il bene non è protetto solo perché appartiene a qualcuno, ma perché rappresenta un valore per la collettività. Su questa materia, di grande rilievo anche sul piano internazionale ed europeo, interviene il **Codice dei beni culturali e del paesaggio**. Esso prevede due modalità di individuazione dei beni culturali: da un lato, tramite **elenchi tassativi** di beni qualificati come culturali direttamente dalla legge; dall'altro, tramite un **procedimento amministrativo**, svolto in contraddittorio con il proprietario, volto a verificare se determinati beni presentino il richiesto interesse culturale. Una volta individuati, questi beni vengono inseriti in un **catalogo nazionale** e sottoposti a un regime speciale di vigilanza e ispezione. Questo regime speciale si articola anzitutto nella **tutela**. Per eseguire interventi di rimozione, demolizione o lavori sui beni culturali è necessaria un'autorizzazione ministeriale. Inoltre, se il bene necessita di interventi conservativi, il Ministero può imporli al proprietario privato, con spese a suo carico, pur potendo in certi casi riconoscere contributi pubblici. Qui il sacrificio imposto al privato si giustifica proprio in ragione del valore pubblico intrinseco del bene. Un secondo profilo riguarda la **circolazione**. I beni culturali sono sottoposti a limiti particolarmente incisivi: alcuni sono assolutamente inalienabili; per altri è richiesta un'autorizzazione preventiva; quelli di proprietà privata possono essere alienati, ma lo Stato o altri enti pubblici possono esercitare il **diritto di prelazione**. Per questo gli atti di alienazione devono essere denunciati alla soprintendenza competente, così da consentire allo Stato o ad altro ente territoriale di subentrare nell'acquisto entro il termine previsto dalla legge. Inoltre, i beni culturali possono essere anche espropriati per pubblica utilità. Rileva poi il profilo della **fruizione**. Per i beni appartenenti a soggetti pubblici l'ordinamento tende a garantire il massimo grado possibile di godimento collettivo. Per i beni culturali appartenenti a privati, invece, la visita pubblica può essere imposta solo in casi particolari, ad esempio quando il bene sia stato dichiarato di interesse eccezionale con un atto del Ministero adottato in contraddittorio con il proprietario. Accanto alla tutela e alla fruizione, il Codice considera anche la **valorizzazione**, cioè l'insieme delle attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e diffusione. La valorizzazione può essere promossa tanto da soggetti pubblici quanto da soggetti privati, ed esprime bene l'idea moderna del bene culturale come bene non solo da conservare, ma anche da rendere vivo e conoscibile. Un'altra importante categoria di beni di interesse pubblico è costituita dalle **aree naturali protette**, disciplinate dalla **legge n. 394/1991**. Qui il regime speciale è diretto alla conservazione delle specie animali e vegetali, alla tutela degli equilibri ecologici, alla promozione di una corretta integrazione tra uomo e ambiente, e anche allo sviluppo di attività educative, scientifiche e ricreative. Le aree protette si distinguono in parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali. L'ente parco disciplina i beni compresi nell'area protetta attraverso due strumenti: il **regolamento** e il **piano del parco**. Il regolamento disciplina le attività consentite e vietate, come quelle costruttive, economiche, ricreative o di circolazione, in modo da evitare pregiudizi ai valori ambientali e paesaggistici. Il piano del parco, invece, organizza il territorio secondo un diverso grado di protezione: vi possono essere **riserve integrali**, dove l'ambiente è conservato nella sua totalità; **riserve generali orientate**, con forti limitazioni alle nuove costruzioni; **aree di protezione**, dove sono ammesse certe attività tradizionali; e **aree di promozione economica e sociale**, in cui è consentita una gamma più ampia di attività, purché compatibili con le finalità di tutela. Infine, una forma più recente di beni privati divenuti di interesse pubblico è rappresentata dalle **reti infrastrutturali**, cioè dalle infrastrutture fisiche necessarie per l'erogazione di alcuni servizi pubblici, come energia, trasporti o comunicazioni. Anche se il servizio può oggi essere erogato da più operatori in concorrenza, la rete mantiene spesso la natura di **monopolio naturale**, perché non è economicamente duplicabile. Per questa ragione essa richiede una regolazione pubblica intensa. La regolazione delle reti si sviluppa

soprattutto sotto due profili. Da un lato, occorre garantire l'**accesso alla rete** a una pluralità di operatori in condizioni di uguaglianza, così da evitare che il proprietario o gestore della rete escluda i concorrenti. Dall'altro, bisogna disciplinare le **tariffe di accesso e di utilizzo**, per impedire al monopolista di abusare della propria posizione dominante. Anche qui si vede bene come il bene, pur restando magari formalmente privato, venga attratto in una sfera di interesse pubblico a causa della sua funzione essenziale per la collettività.

I beni patrimoniali indisponibili e i beni demaniali

Il codice civile distingue i **beni pubblici** in due grandi categorie: **beni patrimoniali** e **beni demaniali**. I **beni patrimoniali indisponibili** sono disciplinati da regole speciali e, per ciò che queste non prevedono, dal codice civile, come dice l'art. 828 c.c. Il codice ne offre un elenco tassativo: vi rientrano, per esempio, foreste, miniere, caserme, cose di interesse storico e altri beni destinati a finalità pubbliche. La loro caratteristica essenziale è l'**indisponibilità**, cioè il fatto che non possono essere sottratti alla loro destinazione pubblica se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguarda. In pratica, finché resta il vincolo di destinazione, il bene non può essere liberamente venduto o utilizzato per fini diversi. Questo vincolo può essere rimosso, di regola, con un atto amministrativo, come nel caso di una caserma dismessa. Inoltre, essendo beni necessari all'adempimento di un pubblico servizio, non possono essere assoggettati a espropriazione secondo le regole ordinarie. I **beni demaniali**, invece, sono sottoposti a un regime pubblicistico ancora più intenso. Si distinguono in **demanio necessario** e **demanio eventuale**. Il **demanio necessario** comprende beni che possono appartenere soltanto allo Stato. L'art. 822, comma 1, ne dà un elenco tassativo: ad esempio il lido del mare, la spiaggia, i porti, i fiumi. Sono beni che per loro natura sono strettamente legati alla collettività e all'interesse pubblico generale. Il **demanio eventuale** comprende invece beni che fanno parte del demanio solo se appartengono allo Stato, alle regioni o ad altri enti territoriali, come stabilisce l'art. 824 c.c. L'elenco è contenuto nell'art. 822, comma 2, e comprende, per esempio, strade, autostrade, acquedotti e altri beni artificiali destinati a uso pubblico. Quindi qui il bene non è demaniale in sé, ma lo diventa in relazione al soggetto pubblico cui appartiene. Oltre ai beni indicati dal codice civile, anche **leggi speciali** possono qualificare certi beni come demaniali. Ad esempio, il Codice dell'ambiente considera beni del demanio necessario dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee. Questo mostra che la categoria del demanio non è chiusa solo nel codice civile, ma può essere integrata dalla legislazione speciale. La **condizione giuridica dei beni demaniali** è particolarmente rigorosa. Essi sono **inalienabili** e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, come afferma l'art. 823, comma 1, c.c. Questo significa che sono beni **incommerciabili**: non possono essere venduti liberamente, non possono essere usucapiti e non possono essere aggrediti dai creditori dell'ente pubblico con gli strumenti ordinari previsti dal diritto civile. Per la loro tutela, l'amministrazione dispone non solo dei mezzi ordinari a difesa della proprietà previsti dal codice civile, ma anche di poteri di **autotutela amministrativa**. L'art. 823, comma 2, consente infatti all'autorità amministrativa di reagire direttamente contro occupazioni abusive o usi illegittimi, senza dover necessariamente ricorrere prima al giudice. È una forma di protezione rafforzata, coerente con la funzione pubblica del bene. Quanto all'uso, i beni demaniali sono per lo più destinati alla **fruizione pubblica generale**, cioè all'uso da parte di tutti. Però possono anche essere attribuiti in **uso particolare** a singoli soggetti mediante **concessione amministrativa**. È il caso, ad esempio, di un tratto di spiaggia dato in concessione a un privato: il bene resta demaniale, ma il suo godimento particolare viene attribuito temporaneamente a un soggetto specifico. Il codice civile include nei beni demaniali sia **beni naturali** sia **beni artificiali**. La distinzione è importante soprattutto per capire come si acquista o si perde la demanialità. Nei beni naturali, la perdita della demanialità dipende spesso da mutamenti della situazione di fatto: per esempio, una spiaggia può scomparire per erosione. Nei beni artificiali, invece, la cessazione della demanialità dipende di regola da una decisione amministrativa. A questo proposito rileva il fenomeno della **sdemanializzazione**, cioè il passaggio del bene dal demanio al patrimonio dello Stato. L'art. 829

c.c. stabilisce che questo passaggio deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa con un atto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale. Una volta sdemanializzato, il bene perde il regime pubblicistico proprio del demanio ed entra nel patrimonio dell'ente, diventando quindi assoggettabile, in linea di principio, al diritto privato e anche alienabile. Negli ultimi anni si è sviluppato anche il cosiddetto **federalismo demaniale**, disciplinato dal d.lgs. 85/2010, che ha previsto il trasferimento di molti beni immobili dallo Stato a regioni, province e comuni. L'obiettivo era duplice: da un lato valorizzare il patrimonio pubblico a livello territoriale, dall'altro favorire anche operazioni di vendita e razionalizzazione del patrimonio nell'ottica del riequilibrio della finanza pubblica.

I beni comuni e le prospettive di riforma

I **beni comuni** sono, nella tradizione, le **res communes omnium**, cioè cose appartenenti idealmente a tutti e a nessuno: per esempio **aria, mare, astri**. Si tratta di entità che, riprendendo l'impostazione del codice civile, **non possono formare oggetto di diritti**, perché non sono suscettibili di appropriazione esclusiva da parte dei singoli. Proprio per questo, in senso tecnico, non sono "beni" giuridici nel significato pieno del termine. La loro caratteristica essenziale è quindi la **non appropriabilità**: nessuno può diventare proprietario dell'aria o del mare in quanto tali. Per questo motivo i beni comuni non hanno, nel codice civile, una disciplina organica autonoma. Il codice non li tratta come categoria separata, ma li ricomprende talvolta entro il **demanio** o entro il **patrimonio pubblico**, a seconda dei casi concreti e del tipo di utilità considerata. Oggi però i beni comuni assumono un rilievo crescente soprattutto sul piano della **tutela ambientale**. Infatti molti di essi, proprio perché travalicano i confini statali, sono disciplinati soprattutto da **convenzioni internazionali** e da **norme europee**. La protezione dell'ambiente, dell'atmosfera, del mare e delle altre risorse comuni ha infatti una dimensione inevitabilmente **transnazionale**: non può essere efficacemente garantita da un singolo Stato isolatamente. Un punto molto interessante è che, con il **progresso tecnologico**, alcuni beni un tempo considerati "comuni" hanno assunto una **rilevanza economica** e quindi una configurazione più vicina a quella del bene giuridico in senso proprio. L'esempio classico è l'**etere**, cioè lo **spettro delle frequenze radio**. In origine l'etere era visto come una realtà comune, non suscettibile di appropriazione. Ma con lo sviluppo della radio, della televisione, della telefonia mobile e delle comunicazioni wireless, esso è diventato una **risorsa scarsa e preziosa**, utilizzabile economicamente e tecnicamente solo attraverso una regolazione pubblica. Per questo oggi viene considerato un **bene patrimoniale indisponibile**: appartiene alla sfera pubblica ed è destinato a una funzione di interesse generale, ma può essere attribuito in **uso esclusivo** a determinati soggetti. Questa attribuzione avviene per consentire attività come:

- telefonia mobile,
- trasmissioni radiofoniche,
- trasmissioni televisive,
- altre comunicazioni elettroniche.

Di conseguenza si è resa necessaria una disciplina volta a regolare la **ripartizione** dello spettro radio e il suo **uso efficiente**, tenendo conto sia di finalità pubbliche sia di interessi economici privati. Tra le finalità pubbliche rientrano, ad esempio, la **difesa militare**, il **traffico aereo**, la sicurezza e le comunicazioni istituzionali; tra quelle private, invece, rientrano le attività imprenditoriali legate ai servizi di comunicazione.

CONTRATTI

Le pubbliche amministrazioni, oltre ad agire mediante provvedimenti amministrativi, **godono anche di una capacità generale di diritto privato**. Ciò significa che possono stipulare contratti per acquistare beni e servizi o per affidare lavori necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. I

contratti pubblici costituiscono una componente molto rilevante della spesa pubblica e rappresentano, per molte imprese, una fonte essenziale di fatturato. Tuttavia, a differenza dei soggetti privati, che sono liberi di scegliere il proprio contraente, le pubbliche amministrazioni, nella stipulazione dei contratti, **sono sottoposte a regole speciali di natura pubblicistica**, poste a tutela sia dell'interesse pubblico sia della parità di trattamento tra tutti i potenziali contraenti. In particolare, la formazione della volontà negoziale della PA e la scelta del contraente non avvengono liberamente, ma tramite un **procedimento amministrativo a evidenza pubblica**, di tipo competitivo, che integra lo schema civilistico della proposta e dell'accettazione. Si distinguono, in particolare, **due fasi**.

1. La **prima fase** è quella della **formazione del vincolo contrattuale**, ed è retta dal **diritto pubblico**. Il Codice dei contratti pubblici prevede infatti che alle procedure di affidamento si applichino, per quanto non espressamente disciplinato, anche le disposizioni della **l. 241/1990** sul procedimento amministrativo. Questa fase si sviluppa attraverso una sequenza procedimentale che culmina nell'adozione del **provvedimento di aggiudicazione**.
2. La **seconda fase** è quella della **stipulazione e dell'esecuzione del contratto**, retta invece prevalentemente dal **diritto privato**. Il Codice dei contratti pubblici stabilisce infatti che, per quanto non diversamente previsto, alla stipula e all'esecuzione si applicano le disposizioni del **codice civile**. Ne deriva che il contratto pubblico presenta una struttura mista: pubblicistica nella fase di scelta del contraente, privatistica nella fase del rapporto contrattuale vero e proprio.

L'influenza del diritto europeo

La disciplina dei contratti pubblici è uno dei settori del diritto amministrativo maggiormente influenzati dal **diritto dell'Unione europea**. Oggi essa pone l'accento soprattutto sull'esigenza di **aprire il mercato degli appalti pubblici alla concorrenza**, in attuazione del principio di libera circolazione delle merci e dei servizi nello spazio europeo. Per questa ragione, la normativa introduce regole che impongono:

- la **pubblicità dei bandi di gara**;
- la **trasparenza delle procedure**;
- la **par condicio** tra i concorrenti;
- la **non discriminazione** tra operatori economici.

Il testo richiama il **Codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. 50/2016**, che ha sostituito il precedente d.lgs. 163/2006. La disciplina generale dei contratti pubblici è adottata a livello statale in forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materie come la **tutela della concorrenza** e l'**ordinamento civile**. Le regioni possono intervenire solo in spazi limitati, perché una regolazione troppo differenziata del mercato dei contratti pubblici a livello territoriale potrebbe alterare la concorrenza.

I capitolati

Tra le fonti rilevanti in materia di contratti pubblici vi sono anche i **capitolati generali e speciali**, che possono contenere la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei contratti o di singoli contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni. I **capitolati generali** contengono regole applicabili a una pluralità di contratti; i **capitolati speciali** disciplinano invece uno specifico rapporto contrattuale. Quando essi sono richiamati nel bando o negli altri atti di gara, **diventano parte integrante del contratto**. A supporto delle amministrazioni, l'ANAC può predisporre **capitolati-tipo e contratti-tipo**, allo scopo di favorire uniformità e correttezza delle procedure.

Le fonti esterne al Codice dei contratti pubblici

La disciplina dei contratti pubblici non si esaurisce nel Codice, ma è integrata da numerose altre fonti.

Un primo rilievo assume la **legge anticorruzione (l. 190/2012)**, che individua proprio nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici uno dei settori più esposti al rischio di corruzione. Essa prevede, tra l'altro, i **patti di integrità** e i **protocolli di legalità**, sottoscritti dalla stazione appaltante e dalle imprese partecipanti, il cui mancato rispetto può comportare l'esclusione dalla gara. La legge prevede inoltre le **white lists**, cioè elenchi di imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa. Un secondo rilievo assume il **codice penale**, che contiene specifiche fattispecie di reato relative alle gare pubbliche, tra cui in particolare il reato di **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**. Un terzo gruppo di norme è costituito dalla **normativa antimafia**, che impone alle imprese partecipanti alle gare pubbliche obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** derivanti dalle commesse pubbliche. Infine, anche il **Codice del processo amministrativo** contiene disposizioni specifiche in materia di contratti pubblici. In particolare, esso prevede un **rito speciale accelerato** per le controversie relative alle gare, al fine di rendere più rapida ed effettiva la tutela delle imprese partecipanti.

L'ANAC e l'organizzazione del sistema

Sotto il profilo organizzativo, il mercato dei contratti pubblici è affidato alla vigilanza dell'ANAC, che ha sostituito la precedente Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Essa è preposta alla **vigilanza** e al **controllo** sui contratti pubblici e svolge anche attività di **regolazione**, attraverso l'emanazione di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile. Tra le sue funzioni principali rientra la gestione del **sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza**. Le amministrazioni che vogliono bandire gare devono dimostrare di possedere requisiti adeguati, come la capacità di progettazione, la capacità di gestire correttamente le procedure e la capacità di verificare l'esecuzione dei contratti. La qualificazione ha durata quinquennale. L'ANAC gestisce anche il **sistema di rating di impresa**, che rileva ai fini della qualificazione delle imprese partecipanti alle gare pubbliche. Un'ulteriore funzione riguarda l'**albo dei componenti delle commissioni giudicatrici**. Per i contratti aggiudicati secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, il Codice prevede infatti la nomina di una commissione giudicatrice. Per garantire maggiore imparzialità, i commissari devono essere selezionati, secondo il principio del sorteggio, tra gli iscritti all'albo gestito dall'ANAC.

I principi generali e il campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici

L'art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici deve garantire la **qualità delle prestazioni** e deve svolgersi nel rispetto dei principi di **economicità, efficacia, tempestività e correttezza**, nonché dei principi di **libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità**. A ciò si collega il divieto, posto dal comma 2, per le stazioni appaltanti di limitare artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente determinati operatori economici. Il nuovo Codice, tuttavia, non si limita a tutelare soltanto la concorrenza. Esso tiene conto anche di ulteriori interessi pubblici, imponendo il rispetto degli obblighi in materia **ambientale, sociale e del lavoro** previsti dalla normativa vigente. Inoltre, richiede che i criteri di partecipazione alle gare siano formulati in modo tale da non escludere irragionevolmente le **microimprese, le piccole imprese e le medie imprese**. In questa prospettiva si parla spesso di **uso strategico degli appalti pubblici**, cioè dell'impiego della contrattazione pubblica anche per il perseguimento di finalità ulteriori rispetto al semplice approvvigionamento di beni o servizi. Un esempio significativo è costituito dai **c.d. appalti sociali**, nei quali all'appaltatore viene richiesto di impiegare categorie svantaggiate di lavoratori. Per comprendere il funzionamento del Codice, occorre poi soffermarsi sul suo **ambito di applicazione**, che può essere analizzato distinguendo tra **ambito soggettivo** e **ambito oggettivo**.

L'ambito soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, il Codice si applica anzitutto alle **amministrazioni aggiudicatrici**, vale a dire alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e agli **organismi di diritto pubblico**. Per questi soggetti vale il regime più rigoroso e formalizzato previsto per le procedure di affidamento, proprio perché si presume che le loro decisioni di acquisto possano essere influenzate non solo da logiche economiche, ma anche da finalità pubblicistiche. Particolare rilievo assume la figura dell'**organismo di diritto pubblico**, che può essere anche formalmente privato, ma che viene attratto nell'orbita pubblicistica quando ricorrono contemporaneamente tre condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un soggetto dotato di **personalità giuridica**, pubblica o privata. In secondo luogo, esso deve essere stato istituito per soddisfare **specifiche esigenze di interesse generale**, aventi carattere **non industriale o commerciale**. Questo significa, in sostanza, che il soggetto non deve perseguire finalità tipicamente lucrative. In terzo luogo, il soggetto deve essere sottoposto a una **influenza dominante** da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico. Tale influenza può manifestarsi in tre modi alternativi: tramite il **finanziamento maggioritario** dell'attività; tramite il **controllo sulla gestione**; oppure tramite la **designazione della maggioranza dei componenti** dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza. Proprio sulla base di questi criteri, la giurisprudenza ha ricondotto alla nozione di organismo di diritto pubblico soggetti come la **RAI** o le **Ferrovie dello Stato**. Accanto alle amministrazioni aggiudicatrici, il Codice prende in considerazione anche le **imprese pubbliche**, cioè quelle sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante. Tuttavia, poiché si tratta di soggetti che operano con finalità economiche, ad essi si applica un regime meno rigido. Il Codice prende inoltre in considerazione le **imprese private titolari di diritti speciali o esclusivi**, cioè soggetti privati che operano in forza di diritti attribuiti per legge o per provvedimento amministrativo. Tali soggetti rientrano nella categoria più ampia degli **enti aggiudicatori**. Le imprese pubbliche e quelle titolari di diritti speciali o esclusivi ricadono però nell'ambito del Codice soltanto quando operano nei **settori speciali**, come l'energia elettrica e il gas, l'acqua, i servizi postali, i porti o gli aeroporti. Si tratta di settori che storicamente appartengono all'area dei servizi pubblici e nei quali la concorrenza non è ancora pienamente sviluppata. Proprio per questa ragione il Codice attenua, in tali ambiti, la rigidità delle procedure ordinarie, prevedendo come modalità tipica di scelta del contraente la **procedura negoziata previa pubblicazione di un bando**.

L'ambito oggettivo

Sotto il profilo oggettivo, il Codice prevede un **elenco tassativo di contratti esclusi**, in tutto o in parte, dalla disciplina generale. Tra questi rientrano, ad esempio, i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di beni immobili. Tuttavia, anche quando un contratto è escluso dall'applicazione piena del Codice, il suo affidamento non è mai del tutto libero. Infatti, l'art. 4 stabilisce che tali contratti devono comunque rispettare i principi generali di **economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica**. Dunque l'esclusione dal Codice non comporta un ritorno pieno alla libertà privatistica, ma lascia sopravvivere un nucleo minimo di garanzie pubblicistiche.

Gli ulteriori criteri di differenziazione della disciplina

Oltre all'ambito soggettivo e oggettivo, il Codice individua ulteriori criteri per stabilire quale disciplina trovi applicazione nei singoli casi. In particolare, rilevano soprattutto **l'importo del contratto** e **l'oggetto del contratto**. L'importo del contratto Seguendo l'impostazione del diritto europeo, il Codice distingue tra **contratti sopra soglia** e **contratti sotto soglia**. I **contratti sopra soglia**, detti anche di **rilevanza comunitaria**, sono quelli il cui valore supera le soglie fissate dalle direttive europee. Per essi si applicano integralmente le procedure dettagliate previste dal diritto

dell'Unione e recepite nel Codice. I **contratti sotto soglia**, invece, sono quelli che non superano gli importi minimi fissati a livello europeo per le diverse categorie contrattuali. Nel testo che hai riportato le soglie sono indicate, rispettivamente, in **135.000 euro per le forniture**, **209.000 euro per i servizi** e **5.225.000 euro per i lavori**. Per questi contratti la disciplina è meno rigida, ma restano comunque applicabili i principi generali del diritto europeo e nazionale.

L'oggetto del contratto

Il secondo criterio riguarda l'**oggetto del contratto**. I contratti pubblici possono infatti avere ad oggetto:

- la fornitura di beni;
- la prestazione di servizi;
- la realizzazione di lavori.

In particolare, per i **lavori pubblici** il Codice prevede regole speciali e modelli contrattuali specifici.

Appalto e concessione

Una prima distinzione importante riguarda quella tra **appalto** e **concessione**. Anche i lavori e i servizi possono infatti essere affidati non soltanto tramite appalto, ma anche tramite **concessione**, che rappresenta una figura contrattuale autonoma. La **concessione** ha per oggetto non solo la realizzazione dell'opera o l'organizzazione del servizio, ma anche la **successiva gestione**. Proprio dalla gestione derivano i ricavi che consentono al concessionario di recuperare i costi sostenuti e di conseguire un utile. In questo modo la concessione permette alla stazione appaltante di **ridurre o addirittura evitare esborsi finanziari diretti**, trasferendo sul concessionario il rischio economico dell'operazione.

La finanza di progetto e il partenariato pubblico-privato

Una tecnica particolare di realizzazione delle opere pubbliche, alternativa alla concessione tradizionale, è la **finanza di progetto**. In questo caso, un promotore privato propone alla pubblica amministrazione il progetto da realizzare, coinvolgendo anche soggetti finanziatori. All'esito della procedura di gara, l'aggiudicatario costituisce una **società di progetto**, incaricata di realizzare e, se previsto, gestire l'infrastruttura. La finanza di progetto è una delle principali forme di **partenariato pubblico-privato**, disciplinato dal Codice. In tali modelli, il privato non si limita a eseguire una prestazione per conto della pubblica amministrazione, ma partecipa più attivamente alla realizzazione e talvolta alla gestione dell'opera o del servizio, condividendone in parte i rischi e i benefici. Tra le altre forme di partenariato pubblico-privato, il testo richiama, ad esempio, la **locazione finanziaria di opere pubbliche**, il **contratto di disponibilità** e il coinvolgimento di privati o associazioni non profit nella gestione di spazi verdi urbani, piazze, strade o altri beni inutilizzati.

Il contraente generale

Per le infrastrutture di particolare rilievo, e cioè quelle di importo superiore a **100 milioni di euro** qualificate dal governo come **strategiche**, il Codice prevede la possibilità di affidamento al **contraente generale** (*general contractor*). Si tratta di un soggetto dotato di elevate capacità organizzative, tecniche e finanziarie, che assume su di sé il compito dell'**intera realizzazione dell'opera**. In tal modo la pubblica amministrazione si rapporta con un unico soggetto responsabile dell'esecuzione complessiva dell'intervento, semplificando il coordinamento delle attività.

Le procedure di affidamento

L'affidamento dei contratti pubblici avviene attraverso un procedimento amministrativo articolato in più fasi, disciplinato dall'art. 32 del Codice. Prima ancora dell'avvio della singola procedura, l'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni si inserisce entro una più ampia attività di programmazione, diretta a individuare le priorità dell'azione amministrativa anche in rapporto alle risorse finanziarie disponibili. Si pensi, ad esempio, al programma triennale dei lavori pubblici, che costituisce il presupposto pianificatorio per l'avvio delle procedure di affidamento. L'avvio del procedimento vero e proprio avviene mediante la delibera a contrarre, che consiste in un atto unilaterale della pubblica amministrazione con cui vengono individuati gli elementi essenziali del contratto e il sistema di scelta del contraente. A questa fase segue la predisposizione e la pubblicazione del bando di gara, che deve essere redatto in conformità ai bandi-tipo predisposti dall'ANAC; la stazione appaltante può discostarsene, ma solo fornendo un'adequata motivazione nella stessa delibera a contrarre. Al bando sono di regola allegati uno schema di contratto, un capitolato tecnico e, nel caso dei lavori pubblici, il progetto. Il bando costituisce la *lex specialis* della procedura, cioè la disciplina specifica della singola gara, e vincola sia l'amministrazione sia i partecipanti. Nella sua predisposizione la pubblica amministrazione gode di un ampio margine di discrezionalità, che però deve rispettare i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Di regola il bando non è un atto immediatamente lesivo, e perciò può essere impugnato solo insieme all'atto conclusivo della procedura, cioè all'aggiudicazione definitiva; fa eccezione il caso in cui esso contenga clausole immediatamente escludenti, dalle quali emerga in modo evidente una discriminazione o un ostacolo diretto alla partecipazione. Per consentire l'accesso alle gare anche a imprese di dimensioni ridotte o comunque prive, singolarmente considerate, di tutti i requisiti richiesti, l'ordinamento prevede alcuni strumenti di cooperazione e integrazione tra operatori economici. Tra questi vi sono i consorzi stabili, che devono essere composti da almeno tre imprese impegnate a operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici per almeno cinque anni. Vi sono poi i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti con riferimento a una singola gara e fondati su un accordo tra imprese, con attribuzione di un mandato all'impresa capofila che assume la rappresentanza delle altre. Essi possono essere verticali, quando le imprese si ripartiscono prestazioni qualitativamente diverse, oppure orizzontali, quando si suddividono lo stesso tipo di prestazione in quote predeterminate. Un ulteriore strumento è l'avvalimento, che consente a un'impresa partecipante di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando facendo affidamento su quelli di un'altra impresa, detta ausiliaria, che si obbliga contrattualmente a metterli a disposizione. Dopo questa fase si apre quella della selezione dei partecipanti. Il Codice prevede tre tipi principali di procedure. Nelle procedure aperte chiunque sia in possesso dei requisiti può presentare direttamente un'offerta. Nelle procedure ristrette ogni operatore economico può chiedere di partecipare, ma solo quelli successivamente invitati dalla stazione appaltante possono presentare l'offerta. Vi sono infine le procedure negoziate, ammesse solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, nelle quali la pubblica amministrazione consulta con modalità più flessibili gli operatori economici prescelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto. Le procedure negoziate possono svolgersi con o senza previa pubblicazione del bando, a seconda dei casi stabiliti dal Codice. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate, la fase di valutazione delle offerte è preceduta da una fase di prequalifica. In questa sede la stazione appaltante seleziona le imprese da invitare a presentare l'offerta sulla base di requisiti minimi predeterminati, che devono garantire la serietà e l'affidabilità dei concorrenti. I criteri di selezione devono essere oggettivi, non discriminatori e proporzionati, e il Codice impone anche un numero minimo di candidati da invitare, così da assicurare una concorrenza effettiva. Sempre nella prospettiva di favorire la massima partecipazione, l'art. 83, comma 8, stabilisce che i casi di esclusione dalla gara per irregolarità o mancanza di requisiti sono esclusivamente quelli espressamente previsti dalla legge. A ciò si aggiunge il meccanismo del soccorso istruttorio, che limita la possibilità di escludere le offerte per mere carenze formali della documentazione, imponendo alla stazione appaltante di distinguere tra irregolarità essenziali e irregolarità sanabili. Una volta individuati i partecipanti ammessi, si passa alla fase della

valutazione delle offerte, che serve a selezionare l'impresa con la quale la pubblica amministrazione stipulerà il contratto. Il Codice prevede due principali criteri di selezione. Il primo è quello del prezzo più basso, oggi ammesso solo in casi tassativi per i contratti sopra soglia, ma ancora criterio generale per i contratti sotto soglia. Il secondo è quello del miglior rapporto qualità/prezzo, che richiede una valutazione più complessa e discrezionale ed è attualmente privilegiato anche dal diritto europeo. In questo caso il bando deve indicare con precisione gli elementi qualitativi che verranno valutati, come per esempio il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali o il contenimento dei consumi energetici, nonché la ponderazione di ciascuno di essi mediante attribuzione di punteggi. La valutazione è affidata a una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante, secondo i criteri di imparzialità previsti dalla normativa. Terminata la valutazione delle offerte, si apre la fase dell'aggiudicazione. La commissione formula una graduatoria finale e viene così individuato il miglior offerente. Prima che si giunga all'aggiudicazione definitiva, vi è una fase di controllo sulla regolarità delle operazioni di gara, che si conclude con un atto di approvazione della stazione appaltante, di regola entro trenta giorni, decorso inutilmente il quale può formarsi il silenzio-assenso. Tuttavia l'aggiudicazione definitiva non equivale ancora, sotto il profilo civilistico, all'accettazione dell'offerta. L'offerta del concorrente ha infatti il valore di proposta contrattuale irrevocabile per un termine determinato, mentre il bando vale solo come invito a offrire. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata a un ulteriore controllo, avente ad oggetto il possesso effettivo, da parte dell'impresa selezionata, dei requisiti di partecipazione che essa aveva autodichiarato al momento della domanda. Solo una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva l'amministrazione può procedere alla stipula del contratto, che deve avvenire di regola entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'aggiudicatario può sciogliersi dal vincolo. Inoltre la stipula non può comunque avvenire prima che siano trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione alle altre imprese partecipanti, così da consentire a queste di proporre eventuali impugnazioni. Nel corso del procedimento può rendersi necessario un subprocedimento di verifica quando la stazione appaltante individua una o più offerte anormalmente basse. In tal caso si apre un contraddittorio con l'impresa interessata, invitata a fornire giustificazioni scritte sugli elementi dell'offerta ritenuti anomali o incongrui. Se tali giustificazioni non risultano convincenti, la stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione, convoca l'offerente in audizione, consentendogli di chiarire ulteriormente la propria posizione. L'eventuale provvedimento di esclusione deve essere congruamente motivato ed è immediatamente impugnabile. Accanto al modello ordinario, il Codice prevede anche alcune procedure innovative. Una di queste è il dialogo competitivo, utilizzato quando la stazione appaltante non dispone delle conoscenze necessarie per definire da sola le soluzioni tecniche, giuridiche o finanziarie del progetto e ha quindi bisogno di confrontarsi preliminarmente con gli operatori economici. In tal caso il bando indica soltanto i bisogni e gli obiettivi perseguiti, mentre il contenuto specifico della soluzione viene elaborato nel corso di un dialogo con le imprese ammesse, svolto separatamente con ciascuna di esse. Una volta individuate le soluzioni ritenute più adeguate, le imprese vengono invitate a presentare l'offerta finale sulla base di esse. Un'altra procedura innovativa è costituita dalle aste elettroniche, che trovano applicazione quando l'aggiudicazione dipende da elementi esprimibili in valori numerici precisi e quindi confrontabili automaticamente con strumenti informatici. In questo caso le imprese presentano in via telematica prezzi o valori progressivamente migliorativi e possono conoscere in tempo reale la propria posizione in graduatoria. L'asta si conclude nel momento stabilito e l'aggiudicazione avviene a favore del miglior offerente. Infine, una particolare rilevanza assumono gli accordi quadro, che sono contratti destinati a fissare, per un certo periodo di tempo, le condizioni generali dei futuri appalti da affidare. Essi vengono aggiudicati attraverso una procedura ordinaria e possono individuare una o più imprese. Se l'accordo quadro viene concluso con una sola impresa, la stazione appaltante può poi stipulare direttamente con essa i singoli contratti esecutivi; se invece le imprese sono più di una, i contratti successivi verranno conclusi secondo le modalità previste nell'accordo stesso. Gli accordi quadro sono spesso utilizzati dalle centrali di

committenza, come la Consip, con la funzione di rendere più efficiente e meno frammentata la politica degli acquisti delle pubbliche amministrazioni.

L'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto pubblico è retta, in linea generale, dai principi del diritto privato. Tuttavia, soprattutto in materia di lavori pubblici, il Codice prevede una disciplina speciale, giustificata dal fatto che nella fase realizzativa possono emergere problemi tecnici non sempre prevedibili al momento della progettazione. Proprio per questo, accanto alle regole civilistiche ordinarie, opera un sistema di garanzie e controlli pubblicistici volto ad assicurare il corretto adempimento del contratto e la tutela dell'interesse pubblico. L'esatto adempimento da parte dell'impresa aggiudicataria è garantito innanzitutto attraverso idonee garanzie fideiussorie e assicurative. Inoltre vige il principio della sostanziale invariabilità del contratto, poiché modifiche introdotte in fase esecutiva potrebbero alterare il significato complessivo della procedura di gara e compromettere la par condicio tra gli operatori economici. In questa prospettiva, il Codice ammette le varianti in corso d'opera solo in casi tassativi. Si tratta di modifiche delle prestazioni originariamente previste dal contratto, consentite, ad esempio, in presenza di mutamenti normativi sopravvenuti oppure di errori progettuali. In ogni caso tali variazioni non possono determinare un aumento del valore del contratto superiore a un quinto; oltre questo limite, l'amministrazione aggiudicatrice deve risolvere il contratto e procedere a una nuova gara. Una disciplina particolare riguarda anche l'adeguamento dei prezzi, che mira a contemperare due esigenze contrapposte: da un lato evitare un aumento incontrollato degli oneri gravanti sull'amministrazione, dall'altro non compromettere la remuneratività del contratto per l'impresa. Per questo le clausole di revisione dei prezzi devono essere previste fin dall'inizio nei documenti di gara in modo chiaro, preciso e inequivocabile, così da garantire trasparenza e prevedibilità. Un ulteriore limite posto dal Codice riguarda la cedibilità del contratto. Il contratto non può essere ceduto dall'impresa affidataria a terzi, a pena di nullità. È però ammesso, entro determinati limiti, il subappalto, cioè l'affidamento a un'altra impresa di una parte delle prestazioni dedotte nel contratto. Questo è consentito entro il limite del cinquanta per cento dell'importo complessivo delle prestazioni. Per garantire regolarità e trasparenza, la volontà di ricorrere al subappalto deve essere dichiarata già al momento della presentazione dell'offerta; inoltre il contratto di subappalto deve essere trasmesso all'amministrazione almeno venti giorni prima dell'inizio della relativa esecuzione, e l'impresa deve dimostrare che il subappaltatore possiede i requisiti necessari per lo svolgimento delle attività affidate. Alla fase esecutiva è preposto il direttore dei lavori, figura centrale nei rapporti tra impresa e pubblica amministrazione. Nei contratti di minore importo egli può coincidere con il responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori esercita funzioni di controllo tecnico, contabile e amministrativo sull'esecuzione del contratto; nei lavori più complessi può essere affiancato da direttori operativi e da ispettori di cantiere. L'andamento dei lavori viene documentato nel giornale dei lavori, mentre sul piano contabile è previsto un apposito registro nel quale possono essere iscritte le cosiddette riserve, vale a dire eccezioni e contestazioni dell'impresa relative, ad esempio, alle modalità di esecuzione richieste o ai maggiori oneri sostenuti. Una volta ultimata l'opera, il direttore dei lavori ne attesta l'esecuzione con il certificato di ultimazione dei lavori e predispose il conto finale. La verifica conclusiva della conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite avviene poi mediante il collaudo, affidato a un soggetto terzo che non abbia preso parte in alcun modo all'esecuzione dei lavori, così da garantirne l'imparzialità. Nel corso dell'esecuzione possono però verificarsi situazioni tali da determinare lo scioglimento del vincolo contrattuale. Una prima ipotesi è la risoluzione, che interviene nei casi di grave inadempimento, ritardo o irregolarità nell'esecuzione del contratto. In tale evenienza l'appaltatore inadempiente è tenuto a sopportare anche gli oneri derivanti dalla maggiore spesa che l'amministrazione debba sostenere per affidare i lavori a un'altra impresa. Una seconda ipotesi è il recesso, che consiste nel potere della stazione appaltante di sciogliersi unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, purché provveda al pagamento dei lavori già eseguiti, dei materiali esistenti in cantiere e di un indennizzo spettante all'appaltatore. Nel complesso, dunque, anche se la

fase di esecuzione del contratto pubblico resta in larga misura assoggettata alle regole del diritto privato, il legislatore ha introdotto una serie di correttivi pubblicistici diretti a salvaguardare la regolarità dell'esecuzione, la trasparenza del rapporto e la tutela dell'interesse pubblico che permea tutta la materia dei contratti della pubblica amministrazione.

I mezzi di tutela

Per garantire una tutela effettiva e soprattutto rapida nel settore dei contratti pubblici, l'ordinamento predispone una serie di strumenti speciali, giustificati dal fatto che le controversie in questa materia incidono su interessi particolarmente delicati: da un lato la concorrenza tra imprese, dall'altro la necessità che l'amministrazione concluda e realizzi tempestivamente opere, servizi e forniture di interesse pubblico. Proprio per questo la disciplina cerca di bilanciare l'esigenza di una tutela piena con quella di non bloccare eccessivamente l'azione amministrativa. Un primo strumento fondamentale è il cosiddetto **standstill period**. Il diritto europeo impone infatti alle stazioni appaltanti di non procedere immediatamente alla stipula del contratto dopo l'aggiudicazione, ma di attendere almeno trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento alle imprese partecipanti. Questo intervallo serve a consentire agli operatori economici eventualmente lesi di valutare se proporre ricorso. Inoltre, se un'impresa impugna l'aggiudicazione definitiva davanti al giudice amministrativo, il contratto non può essere stipulato per un ulteriore termine di venti giorni, oppure fino alla decisione cautelare del giudice, se questa interviene prima. In tal modo si evita che il contratto venga concluso troppo rapidamente, svuotando di utilità la tutela giurisdizionale. A questo si collega il secondo grande strumento, cioè il **rito speciale accelerato** previsto per le controversie in materia di contratti pubblici. Si tratta di un rito caratterizzato da termini processuali ridotti, a cominciare dal termine per proporre ricorso, che è di trenta giorni invece dei sessanta ordinari. La giurisdizione appartiene in via esclusiva al giudice amministrativo, il quale dispone di poteri particolarmente incisivi, perché non si limita ad annullare gli atti illegittimi della procedura, ma può intervenire anche sugli effetti del contratto già stipulato. In particolare, quando l'illegittimità dipende da vizi particolarmente gravi, come l'aggiudicazione senza previa pubblicazione del bando oppure la stipula del contratto in violazione dei termini dilatori previsti, il giudice, oltre ad annullare l'aggiudicazione, può dichiarare l'inefficacia del contratto. Questa inefficacia può operare retroattivamente oppure limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire. Tuttavia il giudice può anche decidere di lasciare fermo il contratto, nonostante l'illegittimità della procedura, qualora sussistano esigenze imperative connesse a un interesse generale. In questi casi la valutazione giudiziale diventa particolarmente delicata, perché occorre bilanciare la tutela della concorrenza con la necessità di non compromettere interessi pubblici rilevanti. Nello stesso ambito va ricordato che anche l'ANAC è titolare di una legittimazione straordinaria a impugnare davanti al giudice amministrativo provvedimenti adottati in violazione del Codice dei contratti pubblici. Accanto alla tutela giurisdizionale, il Codice prevede poi una serie di **strumenti alternativi di risoluzione delle controversie**, pensati per evitare, quando possibile, il ricorso al giudice e per favorire soluzioni più rapide. Uno di questi è la **transazione**, ammessa però soltanto per le controversie che riguardano diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. Restano quindi escluse le controversie che coinvolgono interessi legittimi, proprio perché questi, per loro natura, non sono disponibili. Un altro strumento è l'**accordo bonario**, che viene in rilievo soprattutto nei lavori pubblici quando l'impresa iscrive riserve nei documenti contabili e tali riserve siano idonee a determinare una variazione del prezzo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale. In questi casi si apre una procedura speciale, promossa dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, che porta alla costituzione di una commissione composta da tre membri, uno dei quali indicato dall'impresa che ha formulato le riserve. Si tratta di un meccanismo volto a comporre il conflitto in via preventiva, prima che esso sfoci in un vero e proprio contenzioso giudiziario. È previsto anche l'**arbitrato**, anch'esso limitato alle controversie concernenti diritti soggettivi. Perché si possa ricorrere a questo strumento, però, la stazione appaltante deve aver previsto già nel bando di gara che il contratto conterrà una clausola compromissoria. Presso l'ANAC è istituita una camera arbitrale

specificamente dedicata ai contratti pubblici, proprio per assicurare un certo grado di specializzazione nella trattazione delle controversie. Infine, durante lo svolgimento della gara, può assumere rilievo il **parere di precontenzioso dell'ANAC**. Esso rappresenta uno strumento particolarmente utile perché consente di affrontare e risolvere dubbi o conflitti interpretativi prima che degenerino in una lite giudiziaria. Il parere è vincolante per le parti che abbiano preventivamente dichiarato di volersi attenere a quanto in esso stabilito. In questo modo l'ANAC svolge anche una funzione deflattiva del contenzioso, oltre che di indirizzo e regolazione. Nel complesso, quindi, la tutela nel settore dei contratti pubblici si caratterizza per una forte specialità: da un lato si rafforza la tutela giurisdizionale con strumenti rapidi e incisivi; dall'altro si valorizzano meccanismi alternativi che consentono di risolvere le controversie in tempi più brevi e con minore impatto sull'esecuzione del contratto e sull'interesse pubblico sottostante.

LA FINANZA

Le attività della pubblica amministrazione, pur essendo anch'esse rivolte alla soddisfazione di bisogni collettivi, si distinguono profondamente da quelle delle imprese private sotto il profilo del finanziamento. Infatti, mentre l'impresa opera sul mercato producendo beni o servizi dietro il pagamento di un prezzo e mira a ricavare utili, la pubblica amministrazione svolge di regola attività finalizzate alla cura di interessi pubblici senza che il costo delle prestazioni gravi direttamente sui singoli destinatari. Tali attività sono sostenute prevalentemente attraverso la fiscalità generale. Le entrate delle pubbliche amministrazioni hanno dunque in larga misura natura tributaria, mentre solo in via complementare derivano da proventi patrimoniali, come ad esempio canoni di concessione, introiti derivanti dalla gestione di beni pubblici o biglietti di musei e altri servizi. In questo contesto assume un ruolo centrale il bilancio pubblico. Ogni anno spetta al Parlamento approvare il bilancio di previsione predisposto dal Governo, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi costituzionali, in particolare di quelli posti dall'articolo 81 della Costituzione. A differenza del bilancio d'impresa, che serve soprattutto ad accertare se l'attività economica si sia chiusa con un utile o con una perdita, il bilancio di previsione delle pubbliche amministrazioni ha una funzione diversa e più propriamente autorizzatoria e programmatica. Esso serve infatti, da un lato, a distribuire le risorse tra i diversi ministeri, enti pubblici e livelli territoriali di governo; dall'altro, a fissare i limiti massimi della spesa pubblica. In questo modo il bilancio diventa uno strumento essenziale di indirizzo politico e di controllo dell'uso delle risorse pubbliche, oltre che di garanzia dell'equilibrio tra entrate e uscite, secondo il principio del pareggio di bilancio. Accanto al bilancio di previsione vi è poi il rendiconto, o conto consuntivo, che ha funzione diversa. Mentre il primo guarda in avanti e autorizza la gestione finanziaria futura, il secondo verifica a posteriori se la gestione effettiva si sia svolta in conformità alle previsioni approvate. Il rendiconto serve quindi a controllare l'andamento concreto della gestione, a misurare gli scostamenti rispetto al programma iniziale e a consentire una valutazione complessiva dell'operato dell'amministrazione. L'approvazione del bilancio da parte del Parlamento non è soltanto un adempimento formale, ma una condizione essenziale per il funzionamento stesso dell'apparato pubblico. Senza l'autorizzazione parlamentare alla spesa, infatti, l'amministrazione non può legittimamente effettuare pagamenti, compresi quelli necessari per il funzionamento ordinario, come stipendi, pensioni e altre spese pubbliche. Proprio per evitare la paralisi dell'attività amministrativa, la Costituzione ammette il ricorso all'esercizio provvisorio, ma solo in via eccezionale e per un periodo limitato, non superiore a quattro mesi. La disciplina della finanza pubblica può essere considerata secondo due prospettive tra loro strettamente collegate. La prima è quella macrofinanziaria, che riguarda l'insieme delle entrate e delle uscite dello Stato e degli altri enti pubblici, considerate nell'ottica dell'equilibrio complessivo dell'economia pubblica. In questa dimensione rilevano i grandi obiettivi di finanza pubblica, come il contenimento del deficit, il rispetto dei vincoli europei e la sostenibilità del debito. La seconda è quella microfinanziaria, che riguarda invece la gestione concreta delle risorse da parte delle singole amministrazioni, cioè i procedimenti di entrata e di spesa, le modalità di utilizzo dei fondi e i controlli sull'impiego delle risorse pubbliche. Le due dimensioni non

sono separate, perché le scelte generali di finanza pubblica incidono direttamente sull'attività quotidiana delle amministrazioni, mentre il modo in cui le singole amministrazioni spendono e gestiscono le risorse influisce sull'equilibrio complessivo del sistema. In definitiva, la finanza pubblica rappresenta il presupposto materiale dell'azione amministrativa: senza risorse non vi può essere cura effettiva degli interessi pubblici. Proprio per questo il sistema dei bilanci, delle autorizzazioni parlamentari e dei controlli contabili costituisce una componente essenziale dell'organizzazione e del funzionamento della pubblica amministrazione.

I principi costituzionali

L'art. 81 della Costituzione è stato profondamente modificato dalla **legge costituzionale n. 1 del 2012**, che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio dell'equilibrio di bilancio, in attuazione dei vincoli europei rafforzati emersi dopo la crisi finanziaria. La riforma ha inciso sull'intera impostazione costituzionale della finanza pubblica, trasformando il bilancio da semplice strumento di autorizzazione della spesa a presidio costituzionale della sostenibilità finanziaria. Il nuovo primo comma stabilisce che lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del proprio bilancio, tenendo conto sia delle fasi favorevoli sia di quelle avverse del ciclo economico. Questo significa che il principio non va inteso in modo rigido e meccanico, ma secondo una logica dinamica, che consente di considerare l'andamento dell'economia: nelle fasi recessive possono rendersi necessari margini di flessibilità, mentre nelle fasi espansive è richiesto un maggiore contenimento della spesa e del disavanzo. Il secondo comma pone limiti più severi al ricorso all'indebitamento. Esso è ammesso soltanto per tener conto degli effetti del ciclo economico, quindi in funzione anticiclica, oppure in presenza di eventi eccezionali, come per esempio gravi crisi economiche o calamità naturali. In questi casi, però, l'indebitamento non può essere deciso liberamente dal Governo, ma richiede un'autorizzazione delle Camere approvata a maggioranza assoluta. Si rafforza così il controllo parlamentare sulle scelte che incidono in modo diretto sul debito pubblico. I commi successivi confermano poi il ruolo centrale del Parlamento nella decisione finanziaria. Il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo devono essere approvati dalle Camere, mentre l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso solo con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi. Resta quindi ferma l'idea che la gestione delle risorse pubbliche debba sempre poggiare su una base di legittimazione parlamentare. Particolarmente importante è anche il nuovo sesto comma, che rinvia a una legge rinforzata, approvata anch'essa a maggioranza assoluta, il compito di stabilire i criteri diretti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico dell'intero complesso delle pubbliche amministrazioni. In questo modo la Costituzione non si limita a enunciare un principio generale, ma prevede uno strumento legislativo specifico destinato a tradurlo in regole operative. Il rispetto di questi vincoli non riguarda soltanto lo Stato in senso stretto, ma tutte le pubbliche amministrazioni. Proprio per questo la **legge costituzionale n. 1 del 2012** ha inciso anche su altre disposizioni della Costituzione. **L'art. 119** è stato adeguato per chiarire che anche regioni ed enti locali concorrono all'equilibrio complessivo della finanza pubblica. Inoltre il **nuovo art. 117 attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato** la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, sottraendola alla precedente competenza concorrente, mentre resta concorrente la materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Si rafforza così l'esigenza di uniformità e coerenza dei conti pubblici su tutto il territorio nazionale. **La riforma costituzionale del 2012** si inserisce nel quadro dei vincoli di derivazione europea. Già i Trattati dell'Unione, e in particolare il Patto di stabilità e crescita, imponevano agli Stati membri dell'eurozona il perseguimento di obiettivi di equilibrio finanziario nel medio periodo. **Il regolamento n. 1466 del 1997**, che costituisce il cosiddetto braccio preventivo del Patto, prevede un sistema di sorveglianza fondato sulla presentazione, da parte degli Stati, di programmi di stabilità relativi all'anno in corso e ai tre successivi. In questi documenti devono essere indicati gli interventi programmati per mantenere o raggiungere un saldo di bilancio vicino al pareggio. Se la Commissione europea ritiene che uno Stato presenti un disavanzo eccessivo, avvia una procedura che coinvolge il Consiglio, il quale, tenuto conto

anche delle osservazioni dello Stato interessato, può rivolgere una raccomandazione per la correzione della situazione entro un termine determinato. Qualora lo Stato non si adegui, possono seguire misure sanzionatorie. Si tratta quindi di un sistema di sorveglianza multilivello che limita l'autonomia delle politiche di bilancio nazionali in nome della stabilità dell'intera area euro. Dopo la crisi economico-finanziaria questi vincoli sono stati ulteriormente irrigiditi con il Trattato sul Fiscal Compact. Esso ha previsto, tra l'altro, che quando il **rapporto tra debito pubblico e PIL supera il 60 per cento**, lo Stato debba ridurre l'eccedenza con un ritmo medio pari a un ventesimo all'anno. Sono stati inoltre introdotti ulteriori obblighi, come la comunicazione preventiva dei piani di emissione del debito pubblico e la previsione di organismi nazionali indipendenti incaricati di sorvegliare il rispetto delle regole di bilancio. Lo stesso Trattato, tuttavia, non ignora del tutto le esigenze di flessibilità. Esso consente margini di adattamento in presenza di circostanze eccezionali e prevede che, nel caso di disavanzo eccessivo, lo Stato debba predisporre un programma di partenariato economico e di bilancio contenente una descrizione dettagliata delle riforme da attuare. In caso di inadempimento possono intervenire anche meccanismi giurisdizionali davanti alla **Corte di giustizia dell'Unione europea**, con eventuali sanzioni finanziarie. In attuazione di questo quadro, l'Italia ha istituito con la **legge n. 243 del 2012 l'Ufficio parlamentare di bilancio**, organismo indipendente preposto all'analisi e alla verifica degli andamenti di finanza pubblica e alla valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. Si tratta di una struttura di garanzia tecnica, posta presso le Camere, che svolge un ruolo di supporto e controllo rispetto alle decisioni finanziarie, rafforzando la trasparenza e l'affidabilità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio. Nel complesso, la nuova formulazione **dell'art. 81 Cost.** riflette il passaggio da una concezione più flessibile della decisione finanziaria pubblica a un modello in cui il principio dell'equilibrio di bilancio diventa un vincolo costituzionale permanente. Questo vincolo, pur non eliminando ogni possibilità di ricorso al disavanzo, lo sottopone a condizioni rigorose, a controlli parlamentari rafforzati e a un più intenso coordinamento con l'ordinamento europeo.

Il Documento di economia e finanza, la legge di bilancio

La disciplina della **finanza pubblica** si fonda su alcuni **strumenti di programmazione** che servono a collegare, in modo ordinato, le **scelte economiche del Governo**, il **controllo parlamentare** e i **vincoli derivanti dall'ordinamento europeo**. I due atti principali di questo ciclo sono il *Documento di economia e finanza* e il *disegno di legge di bilancio dello Stato*. Il Documento di economia e finanza, cioè il **DEF**, viene presentato dal Governo alle Camere *entro il 10 aprile* di ogni anno ed è poi seguito, entro il 27 settembre, da una **nota di aggiornamento**. Si tratta **dell'atto con cui il Governo definisce il quadro complessivo della politica economica e finanziaria**, collocando le decisioni nazionali entro il sistema di coordinamento europeo. **Il DEF si articola in tre sezioni:**

1. La prima contiene lo **schema del Programma di stabilità**, cioè il documento richiesto dall'Unione europea in attuazione del Patto di stabilità e crescita, volto a illustrare gli obiettivi di finanza pubblica e il percorso per raggiungerli.
2. La seconda sezione contiene invece **l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente**, con l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati, e formula poi le previsioni tendenziali per almeno il successivo triennio.
3. La terza sezione è costituita dallo **schema del Programma nazionale di riforma**, anch'esso richiesto dalla disciplina europea, che espone gli interventi strutturali e le riforme che il Governo intende realizzare. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, una volta approvati, sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione dell'Unione europea entro il 30 aprile. Questo inserisce la programmazione economico-finanziaria italiana nel cosiddetto semestre europeo, cioè quella fase iniziale di ciascun anno nella quale si svolge un confronto preventivo tra Stati membri e istituzioni europee sulle politiche economiche, di bilancio e di riforma. In questo

modo, le principali scelte nazionali non si formano più in un contesto puramente interno, ma vengono sottoposte fin dall'inizio a un coordinamento sovranazionale.

Accanto al DEF vi è poi il **disegno di legge di bilancio dello Stato**, che il Governo presenta alle Camere *entro il 20 ottobre*. Esso costituisce il **principale atto normativo attraverso cui si realizza la manovra di finanza pubblica** e si **autorizza** la gestione finanziaria dello Stato **per il triennio di riferimento**. Il bilancio annuale di previsione è redatto sia in termini di competenza sia in termini di cassa: nel primo caso si considerano le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare; nel secondo, invece, si guarda ai flussi effettivi di incasso e pagamento. Il disegno di legge di bilancio si compone di due sezioni. La prima definisce ogni anno il quadro di riferimento finanziario complessivo e contiene, per ciascun anno del triennio, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in particolare quelli diretti alla riduzione del debito. La seconda sezione contiene invece lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ripartita per ministeri e il quadro generale riassuntivo con riferimento all'intero triennio. In questa struttura si riflette la duplice funzione del bilancio pubblico: da un lato, esso autorizza le entrate e le spese; dall'altro, distribuisce le risorse tra i diversi settori dell'azione pubblica. Il ciclo del bilancio non si esaurisce però nella sola approvazione della legge di bilancio. Entro il mese di giugno di ogni anno il Ministro dell'economia presenta un disegno di legge di assestamento, con cui aggiorna le previsioni iniziali sulla base dell'andamento della gestione e dei provvedimenti normativi intervenuti successivamente. Sempre entro giugno, il Ministro presenta alle Camere il rendiconto generale dell'esercizio dell'anno precedente, corredato da una nota integrativa. Il rendiconto ha la funzione di verificare ex post i risultati della gestione e di confrontarli con quanto autorizzato in sede previsionale. Prima di essere trasmesso al Parlamento, il rendiconto viene inviato alla Corte dei conti entro il 31 maggio. La Corte procede alla cosiddetta parificazione dei conti, cioè a un giudizio volto ad accertare la conformità o la difformità tra le previsioni di bilancio e i risultati della gestione effettiva. Una volta concluso questo controllo, il rendiconto viene restituito al Ministro dell'economia, che lo presenta alle Camere in forma di disegno di legge per l'approvazione prevista dall'art. 81 della Costituzione. Si può dunque dire che il ciclo del bilancio si apra e si chiuda in Parlamento: con l'approvazione del bilancio di previsione si autorizza la gestione; con l'approvazione del rendiconto la si verifica politicamente e giuridicamente. Un rilievo particolare assume poi la finanza delle regioni e degli enti locali, rispetto alla quale è stato avviato un processo di riforma ispirato al principio del federalismo fiscale. Il modello delineato dall'art. 119 della Costituzione tende a superare il sistema della finanza derivata, fondato prevalentemente sui trasferimenti statali, per sostituirlo con un sistema nel quale gli enti territoriali dispongano di entrate proprie e di compartecipazioni al gettito di tributi erariali, in misura tale da garantire la copertura integrale delle funzioni loro attribuite. A questo modello si accompagna però un meccanismo di perequazione, diretto a sostenere i territori con minore capacità fiscale, così da evitare squilibri eccessivi tra aree diverse del Paese. In questo quadro assumono un ruolo decisivo i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere assicurati uniformemente su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Essi rappresentano un limite all'autonomia finanziaria degli enti territoriali, perché impongono che determinate prestazioni fondamentali siano garantite ovunque, anche mediante il concorso finanziario dello Stato. Il criterio verso cui tende il sistema è inoltre quello dei costi standard, che si contrappone al tradizionale criterio della spesa storica. Non si guarda più, cioè, a quanto un ente ha speso in passato, ma a quanto dovrebbe ragionevolmente spendere per assicurare una certa funzione in modo efficiente. L'obiettivo è duplice: rendere confrontabili le amministrazioni e incentivare comportamenti virtuosi, poiché gli enti che sostengono costi superiori agli standard sono chiamati ad adottare misure organizzative e gestionali idonee a ridurli. Anche la finanza degli enti territoriali resta comunque strettamente condizionata dai vincoli europei di finanza pubblica, tradotti sul piano interno nel cosiddetto Patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono previste sanzioni che possono incidere in modo significativo sull'autonomia dell'ente: tra queste, il divieto di procedere a nuove assunzioni, il divieto di iscrivere in

bilancio spese per attività discrezionali e, nei casi più gravi, conseguenze che investono anche gli organi di governo e amministrativi dell'ente in situazione di dissesto. Su questo versante la Corte dei conti esercita poteri di controllo particolarmente incisivi. Quando accerta squilibri economico-finanziari, mancate coperture di spesa o violazioni dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno, gli organi di governo dell'ente locale sono tenuti ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti necessari per rimuovere le irregolarità e ristabilire gli equilibri di bilancio. Si conferma così che la disciplina della finanza pubblica, pur articolandosi tra diversi livelli territoriali, resta unitaria nella sua finalità essenziale: garantire sostenibilità, coordinamento e controllo nell'impiego delle risorse pubbliche.

La gestione delle risorse e il procedimento di spesa

In primo luogo, le **risorse economico-finanziarie attribuite a un determinato apparato amministrativo**, per esempio un ministero, non restano concentrate in modo indistinto, ma vengono distribuite all'interno della struttura secondo la catena organizzativa propria dell'amministrazione. L'organo di indirizzo politico-amministrativo **ripartisce infatti le risorse tra gli uffici di livello dirigenziale generale**; questi ultimi, a loro volta, le assegnano ai dirigenti competenti nei singoli ambiti di attività. Ne deriva che i **dirigenti**, sia di livello generale sia di livello inferiore, **esercitano in modo autonomo i poteri di spesa nell'ambito delle attribuzioni loro conferite**.

Questa autonomia si collega direttamente al **principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa**: la decisione politica **definisce obiettivi e assegna risorse**, mentre spetta ai dirigenti gestirle concretamente. Le obbligazioni che comportano spese a carico del bilancio pubblico possono nascere da fonti diverse. Talvolta **derivano direttamente dalla legge o da una sentenza**; altre volte scaturiscono da un provvedimento amministrativo oppure da un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione. In ogni caso, occorre distinguere il momento in cui viene assunta la decisione sostanziale di sostenere una spesa dal momento, distinto e successivo, in cui si procede materialmente all'erogazione delle somme dovute. La spesa pubblica, infatti, non viene eseguita in modo immediato e indifferenziato, ma attraverso un procedimento articolato in più fasi, ciascuna delle quali svolge una funzione specifica di controllo e di garanzia. La prima fase è quella dell'impegno. Con essa l'amministrazione individua la somma da destinare al soddisfacimento di un'obbligazione validamente assunta nei confronti di un creditore. L'impegno ha dunque la funzione di vincolare una parte delle risorse di bilancio a una determinata finalità di spesa, rendendo possibile l'adempimento dell'obbligazione. Non si tratta ancora del pagamento, ma del momento in cui la spesa viene formalmente assunta e collegata a un preciso titolo giuridico. Segue poi la fase della liquidazione della spesa. Si tratta di un atto interno all'amministrazione con cui si verifica l'effettiva esistenza del diritto del creditore e si determina in modo preciso l'importo da corrispondere. In questa fase vengono controllati i titoli e la documentazione giustificativa, come ad esempio le fatture, i documenti di consegna o gli altri atti che dimostrano che la prestazione dovuta all'amministrazione è stata effettivamente eseguita. La liquidazione serve quindi a trasformare la spesa impegnata in una somma certa, liquida ed esigibile. La terza fase è quella dell'ordinazione. Con questo atto l'amministrazione impartisce al tesoriere l'ordine di eseguire il pagamento della somma precedentemente liquidata. L'ordinazione avviene mediante il mandato o l'ordinativo di pagamento, cioè attraverso lo strumento formale con cui l'amministrazione dispone che il tesoriere provveda all'erogazione della somma al creditore. Anche qui non si ha ancora il pagamento materiale, ma il passaggio decisivo che mette in moto la fase finale del procedimento. L'ultima fase è appunto il pagamento. Esso consiste nell'erogazione materiale della somma dovuta da parte del tesoriere, che vi provvede dopo aver ricevuto il mandato di pagamento e averne verificato la regolarità formale. Solo in questo momento il procedimento di spesa si conclude realmente, perché il creditore ottiene quanto gli è dovuto. Nel complesso, questa scansione procedimentale mostra come la spesa pubblica sia assoggettata a una disciplina rigorosa e formalizzata. Ciò risponde all'esigenza di garantire legalità, controllo e corretta

gestione delle risorse pubbliche: ogni fase, infatti, serve a evitare che le somme siano erogate senza un titolo valido, senza adeguata verifica o senza copertura nell'ambito del bilancio.